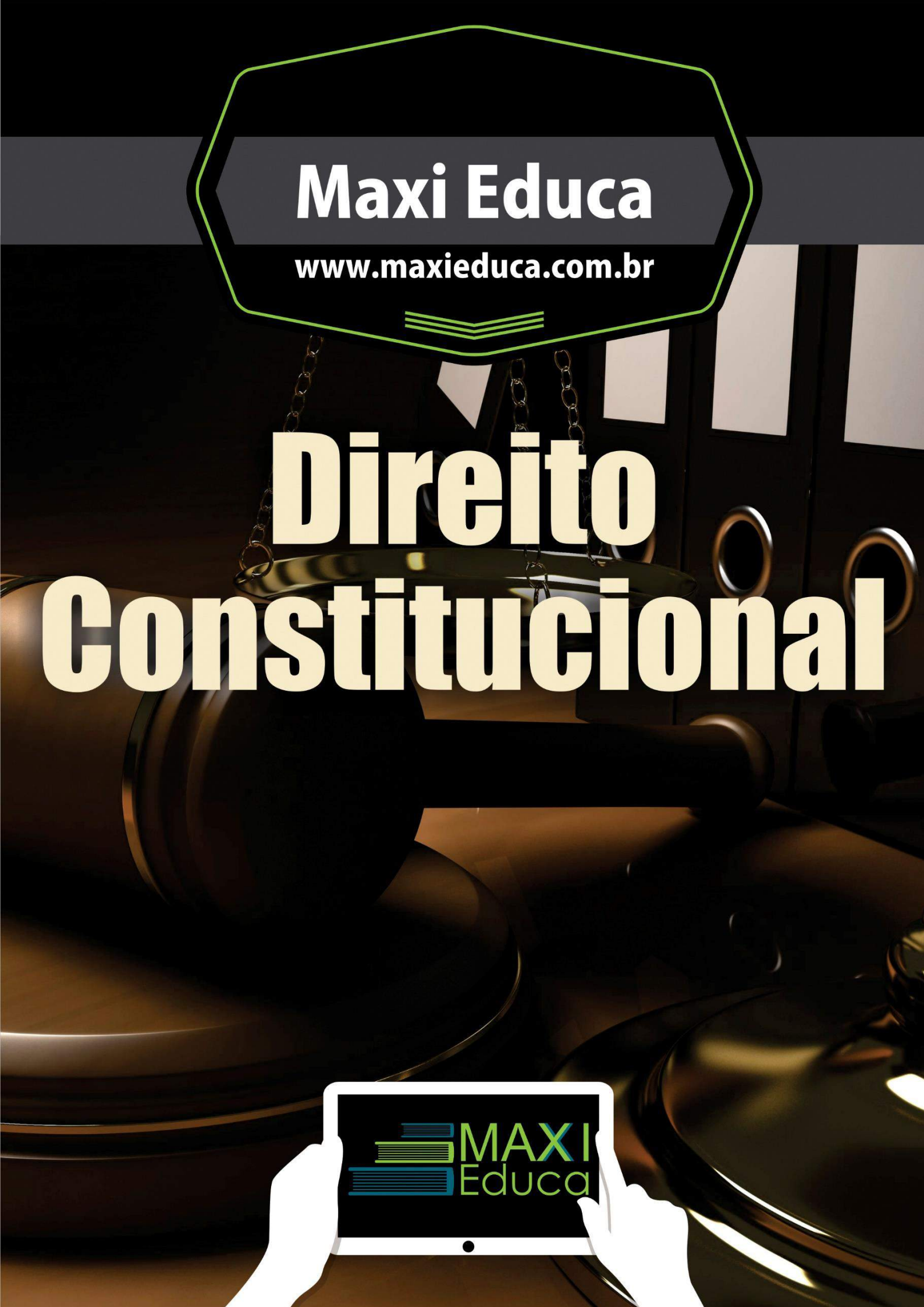




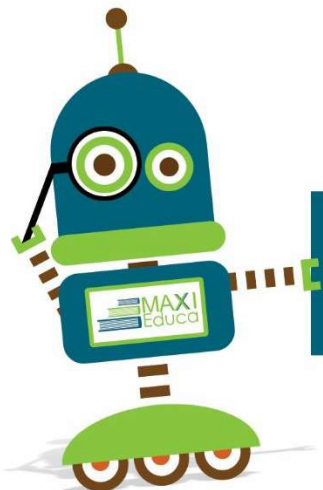
Maxi Educa

www.maxieduca.com.br

Direito Constitucional



MAXI
Educa



Sumário

1 História Constitucional do Brasil.....	1
2 Constituição: conceito e classificação.	5
3 Constitucionalismo. Espécies; Constitucionalismo Social. Constitucionalismo do Futuro. Constitucionalismo Transnacional. Transconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo.	11
4 Normas constitucionais: classificação.	14
5 Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais.	16
6 Disposições constitucionais transitórias.	18
7 Hermenêutica constitucional.	20
8 Princípios e regras jurídicas. Ponderação. Modelos e críticas.....	25
9 Poder constituinte.	27
10 Controle de constitucionalidade: direito comparado.	32
11 Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica.	37
12 O papel do Advogado-Geral da União no controle de constitucionalidade.	39
13 Inconstitucionalidade: normas constitucionais inconstitucionais.....	40
14 Inconstitucionalidade por omissão.	41
15 Ação direta de inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual.	43
16 Ação declaratória de constitucionalidade.	50
17 Arguição de descumprimento de preceito fundamental.....	53
18 Declaração de direitos: histórico; teoria jurídica e teoria política.	58
19 Direitos Políticos. Processo Eleitoral. Condições de elegibilidade e inelegibilidade. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Partidos Políticos.	62
20 Direitos e garantias individuais e coletivos. Processo eleitoral.	71
21 Princípio da legalidade.	102
22 Princípio da isonomia.	102
23 Regime constitucional da propriedade. Função social da propriedade.....	103
24 Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data.	104
25 Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no Direito Brasileiro e no direito comparado.	109
26 Direitos sociais e sua efetivação.	111
27 O Direito à saúde na ordem constitucional e legal.	117
28 Direito à saúde como direito humano.....	119
29 Sistema Único de Saúde. Atribuições da União, dos Estados e dos Municípios.	120
30 Princípios constitucionais do trabalho.	144
31 Estado federal: conceito e sistemas de repartição de competência; direito comparado.	148
32 Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. Intervenção Federal nos Estados membros. Lei n.º 12.562/2011.	149
33 Estado Democrático de Direito: fundamentos constitucionais e doutrinários.....	157
34 Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos.	158
35 Da União.....	161
36 Estado-membro; poder constituinte estadual: autonomia e limitações.	165

37 Estado-membro: competência e autonomia.	166
38 Administração Pública: princípios constitucionais.	170
39 Servidores públicos: princípios constitucionais.	176
40 Poder Legislativo: organização; atribuições; processo legislativo.	184
41 Poder Executivo: presidencialismo e parlamentarismo; ministro de Estado.	197
42 Presidente da República: poder regulamentar; medidas provisórias.	199
43 Crimes de responsabilidade do presidente da República e dos ministros de Estado.	204
44 Poder Judiciário: organização; estatuto constitucional da magistratura.	205
45 Ativismo judicial.	210
46 Supremo Tribunal Federal: organização e competência.	210
47 Superior Tribunal de Justiça: organização e competência. Justiça federal: organização e competência.	212
48 Justiça do trabalho: organização e competência.	215
49 Ministério Público: princípios constitucionais.	217
50 Advocacia-Geral da União: representação judicial e extrajudicial da União; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização e funcionamento. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.	222
51 Representação judicial e consultoria jurídica dos estados e do Distrito Federal.	224
52 Limitações constitucionais do poder de tributar.	225
53 Ordem econômica e ordem financeira: princípios gerais.	227
54 Princípios constitucionais da ordem econômica.	235
55 Intervenção do Estado no domínio econômico.	237
56 Meio ambiente.	239
57 Direitos e interesses das populações indígenas.	245
58 Interesses difusos e coletivos.	246
Questões	250

Candidatos ao Concurso Público,

O Instituto Maximize Educação disponibiliza o e-mail professores@maxieduca.com.br para dúvidas relacionadas ao conteúdo desta apostila como forma de auxiliá-los nos estudos para um bom desempenho na prova.

As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis pela matéria, portanto, ao entrar em contato, informe:

- Apostila (concurso e cargo);

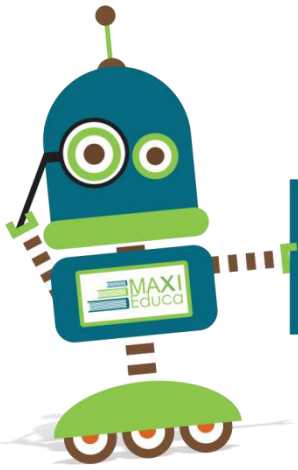
- Disciplina (matéria);

- Número da página onde se encontra a dúvida; e

- Qual a dúvida.

Caso existam dúvidas em disciplinas diferentes, por favor, encaminhá-las em e-mails separados. O professor terá até cinco dias úteis para respondê-la.

Bons estudos!



1 História Constitucional do Brasil

A evolução constitucional do Brasil se fez por fases e sempre refletindo o pensamento político da sociedade brasileira. Nesta evolução identificamos: a fase colonial, a fase monárquica, a fase republicana. A fase republicana, por sua vez, pode ser dividida em Primeira República e Segunda República.

- Fase colonial

A colonização do Brasil teve início com a organização das Capitanias Hereditárias, em que o território brasileiro pertencente a Portugal foi dividido em doze porções irregulares, todas confrontando com o oceano, única via de acesso com a metrópole.

As Capitanias Hereditárias caracterizavam-se por serem organizações independentes entre si e por serem doações a particulares, escolhidos entre os melhores cidadãos portugueses que estivessem dispostos a morar na colônia e fossem ricos o suficiente para colonizá-la e defendê-la. Os donatários, como eram denominados os seus titulares, dispunham de poderes e exerciam o governo com jurisdição civil e criminal. O poder político era exercido individualmente pelos donatários sem qualquer identificação de uns com os outros, sendo que a fonte comum desse poder era a metrópole. Em 1549, a metrópole instituiu o sistema de governadores-gerais, introduzindo um elemento referencial de poder unitário, que emanava de um documento intitulado Regimento do Governador geral.

Nas zonas de mineração surgem autoridades especiais em função da atividade econômica: junta de arrecadação da Fazenda Real, intendências de ouro ou dos diamantes, guardadores das minas, casas de fundição, capitães-mores das minas. Nas zonas agrícolas surgiu uma organização municipal composta de um poder local: o Senado da Câmara ou Câmara Municipal, composto de oficiais eleitos dentre os "homens bons da terra", ou seja, dentre os grandes proprietários rurais.

Esta organização política administrativa vai influenciar a formação e estruturação da organização política na fase imperial e nos primeiros momentos da fase republicana.

- Fase monárquica

Antes da declaração da independência do Brasil, o príncipe regente D. Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, através do ato de 03/06/1822. Todavia, essa Assembleia instalou-se após a independência, em 03 de maio de 1823. Os conflitos surgidos entre o imperador e a Assembleia constituinte inviabilizaram a elaboração da Constituição e, em consequência, o imperador criou em 12/11/1823 um conselho de estado com a função de elaborar um projeto de Constituição, após dissolver, no dia anterior, a assembleia constituinte.

Este projeto seria submetido à aprovação das Câmaras Municipais e, por solicitação destas, D. Pedro I outorgou, em 25/03/1824, a Constituição do Império. Esta Constituição reflete as ideias liberais da época, principalmente no que se refere aos direitos individuais e à adoção da separação dos Poderes, que, além dos três clássicos, acrescentou um quarto: o poder moderador.

De início declara que o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de União, ou Federação, que se oponha a sua independência (art. 1º). O território do Império é dividido em províncias, nas quais foram transformadas as capitanias então existentes (art. 2º).

O Império adota o governo monárquico hereditário, constitucional e representativo (art. 3º); a dinastia imperante é a de Dom Pedro I, então imperador, e defensor perpétuo do Brasil (art. 4º). A divisão e

harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece (art. 9º).

Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial (art. 10).

O Poder Legislativo é exercido pela assembleia geral, composta de duas câmaras: a dos deputados, eletiva e temporária, e a dos senadores, composta de membros vitalícios (arts. 13, 14, 35).

O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos (art. 98). A pessoa do imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeito a responsabilidade alguma (art. 99). Os seus títulos são "Imperador Constitucional, e Defensor Perpétuo do Brasil" e tem o tratamento de Majestade Imperial (art. 100). O imperador exerce o Poder Moderador (art. 101), é o chefe do Executivo, e o exercita pelos seus ministros de estado (art. 102). Cria um conselho de estado, composto de conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador e não superior a dez (art. 137, 138).

O Poder Judicial é independente, e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar, assim no cível, como no crime, nos casos, e pelo modo que os códigos determinarem (art. 151). O artigo 179 trata dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, cuja base é a liberdade, a segurança individual e a propriedade.

A Constituição do Império sofreu duas revisões: a primeira pelo ato adicional, de 12/08/1834, suprimiu o Conselho de Estado e substituiu a Regência Trina Permanente por uma Regência Una Provisória; a segunda pelo ato adicional, de 12/03/1840, restabeleceu o Conselho de Estado e reduziu a competência das Assembleias Legislativas das províncias. Com tais instituições funcionou longamente o Segundo Reinado, em um regime conservador, economicamente baseado na aristocracia dos plantadores de cana e de café cujo desmoronamento com o abolicionismo acelerou a precipitação do processo revolucionário, provocando a criação da República.

- Fase Republicana

A Primeira República

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil foi promulgada no dia 24.02.1891. Estabeleceu que: a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil (art. 1º); cada uma das antigas províncias formará um Estado, e o antigo Município do Rio de Janeiro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União (art. 2º); fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcado, para nele estabelecer-se a futura Capital federal (art. 3º); são órgãos da soberania nacional os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, harmônicos e independentes entre si (art. 15); o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art. 16); o Congresso Nacional compõe-se de dois ramos: a Câmara dos Deputados e o Senado (art. 16, § 1º); a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante o sufrágio direto, garantida a representação da maioria (art. 28); o Senado compõe-se de cidadãos elegíveis e maiores de 35 anos, em número de três Senadores por Estado e três pelo Distrito Federal (art. 30); exerce o Poder Executivo o Presidente da República, como chefe eletivo da nação (art. 41); o Presidente da República será submetido a processo e a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, e nos de responsabilidade, perante o Senado (art. 53); o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tantos juízes e tribunais federais, distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar (art. 55); os

Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em tudo que respeite ao seu peculiar interesse (art. 68); cria-se o Tribunal de Contas da União (art. 89). A Constituição de 1891 foi revisada em 1926 e destinou-se a corrigir certos abusos, que a ambiguidade do texto de 1891 favorecera, em detrimento da honesta realização do regime. Teve o mérito de indicar todos os princípios constitucionais, que tinham de ser amparados mediante a intervenção federal nos estados; de restringir a concessão de Habeas Corpus aos casos de liberdade individual; e dar ao governo da União competência para regular o comércio em ocasiões graves, que reclamassem uma atitude de defesa econômica ou de prevenção contra as anormalidades de circulação.

A Segunda República

Em 3 de outubro de 1930 eclodiu a revolução que restituiu o Presidente em 2/1/1930 e formou uma junta governista provisória composta pelos generais Augusto Tasso Fragoso e João de Deus Mena Barreto e pelo contra-almirante José Isaías de Noronha. Esta junta transmitiu o governo a Getúlio Vargas, em 3/11/1930. Em 11/11/1930, o Governo editou o Decreto nº 19.398 lixando a lei orgânica do governo provisório, com o objetivo de organizar a nova República.

Inicialmente foram instituídos dois Ministérios: o Ministério da Educação e da Saúde Pública (Dec. Nº 19.402, de 14/11/30) e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (Dec. N. 19.403, de 23/11/30). O governo provisório constituiu uma comissão com o objetivo de elaborar uma nova Constituição a ser submetida à aprovação da Assembleia Constituinte a ser eleita em 3/5/33.

Dessa Assembleia Constituinte surge a Constituição, que foi promulgada em 16/7/34, cujas bases principais são: quanto à forma de governo manteve-se o Regime Federativo (art. 1º); todos os poderes emanam do povo, e em nome dele são exercidos (art. 2º); são órgãos da Soberania Nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si (art. 3º); ampliou os poderes da União nos artigos 5º e 6º; enumerou alguns poderes dos Estados-membros conferindo-lhes os poderes remanescentes (arts. 7º e 8º) dispôs sobre os poderes entre a União e Estados-membros (art. 10); discriminou as rendas tributárias entre a União, Estados-membros e Municípios; aumentou os poderes do Executivo (art. 51 e segs); rompeu com o bicameralismo, ao atribuir o exercício do Poder Legislativo penas à Câmara dos Deputados e transformando o Senado Federal em seu órgão de colaboração (art. 22); criou a Justiça Eleitoral como órgão do Poder Judiciário (art. 63, d); admitiu o voto feminino (art. 108 e segs.); instituiu a representação corporativa de influência fascista ao lado da representação política tradicional: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei indicar (art. 23); manteve o Tribunal de Contas, que, diretamente ou por delegação, organizadas de acordo com a lei, acompanhará a execução orçamentária e julgará as contas dos responsáveis por dinheiro ou bens públicos (art. 99); ampliou os direitos e garantias individuais (art. 113); introduziu os títulos da Ordem Econômica e Social (Título IV), da família, da educação e da cultura (Título V); regulamentou os problemas da Segurança Nacional (arts. 159 e segs.); estatuiu princípios gerais sobre os funcionários públicos (arts. 159 e 173).

A Constituição de 1934 caracteriza-se como documento de compromisso liberal com uma certa “pitada” intervencionista. Todavia, alguns aspectos devem ser destacados: A sua grande força renovadora consistiu na solução social dada ao seu contexto. Surgiram capítulos novos, inspirados na Constituição alemã de Weimar, de 1919. Entre esses capítulos mais importantes figuram aquelas matérias alusivas à ordem econômica e social, à família, à educação e à cultura, normas concernentes ao funcionalismo público, às Forças Armadas etc. Surgiu uma potente Legislação de Trabalho e da Previdência Social.

Esta Constituição durou pouco. O Congresso Nacional editou três emendas à Constituição, em 18/12/35: a primeira dispõe que a Câmara dos Deputados, com a colaboração do Senado Federal, poderá autorizar o Presidente da República a declarar a Comoção Intestina Grave, com finalidades subversivas das instituições políticas e sociais, equiparada ao Estado de Guerra; a Emenda nº 2 dispõe que perderá patente e posto, por decreto do Poder Executivo, sem prejuízo de outras penalidades (...) o oficial da ativa, da reserva ou reformado, que praticar ato ou participar de movimento subversivo das instituições políticas e sociais; pela Emenda nº 3, o funcionário civil, ativo ou inativo, que praticar ato ou participar de movimento subversivo das instituições políticas e sociais, será demitido por decreto do Poder Executivo.

Estas emendas à Constituição mostram as intenções do governo em implantar uma ditadura da direita materializada com a instituição do Estado Novo cuja base de sustentação centrava-se na grande massa de trabalhadores.

A Constituição de 1937 (Polaca)

No dia 10 de novembro de 1937 o Presidente Getúlio Vargas outorga uma nova Constituição, instalando a ordem política do Estado Novo. Esta Constituição apresentou as seguintes alterações: suprimiu o nome de Deus; outorgou amplos poderes ao Presidente da República como a suprema autoridade do Estado; restringiu as prerrogativas do Congresso Nacional; aumentou a autonomia do Poder Judiciário; ampliou o prazo do mandato do Presidente da República; mudou o nome do Senado para Conselho Federal; criou o Conselho de Economia Nacional como Órgão Consultivo; restringiu a autonomia dos Estados-membros; instituiu o Estado de Emergência; dissolveu a Câmara Federal, o Senado Federal e as Assembleias Estaduais; instituiu a pena de morte. A Constituição outorgada por Getúlio Vargas foi inspirada no modelo fascista, sendo extremamente autoritária, conforme se verifica no

seu artigo 73: **Art. 73. O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional, e superintende a administração do país.**

Várias medidas foram tomadas com vistas à consolidação do Estado Novo, como por exemplo o Decreto-lei nº 8, de 20/12/37, que deu autonomia ao Tribunal de Segurança, e o Decreto-lei nº 431, de 18/05/38, que definiu os crimes contra a ordem social e contra a segurança nacional e regulou a pena de morte.

Algumas medidas foram tomadas em benefício dos trabalhadores, a exemplo da Consolidação das Leis do Trabalho (Dec.-lei nº 5.452, de 01/05/43).

A Constituição de 1946

Instalou-se, em 2/2/1946, uma nova Assembleia Constituinte, a quarta Assembleia Constituinte Brasileira, da qual resultou uma nova Constituição, promulgada em 18/9/1946. Esta Constituição, inspirada na democracia social Weimariana, regulou os problemas relativos à ordem econômica e social, à família, educação e cultura; ampliou as técnicas intervencionistas; combateu a força econômica dos trusts.

Durante a vigência dessa Constituição o Brasil foi governado sucessivamente por Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Este último foi eleito com uma esmagadora maioria de votos, entretanto a sua renúncia brusca provocou uma grande crise político-militar no País. Com a renúncia do Presidente Jânio Quadros, implantou-se o Parlamentarismo como solução para esta crise, tendo como Primeiro Ministro o Deputado Tancredo Neves.

O ato adicional que implantou o Parlamentarismo previa em seu texto a realização de consulta popular por meio de um plebiscito. Este plebiscito foi realizado em 6/01/1963 e o povo, por maioria, consagrou o regime Presidencialista, restaurando-se os tradicionais poderes ao Presidente João Goulart que assumira com a renúncia do Presidente Jânio Quadros.

A Constituição de 1967

Na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o Presidente João Goulart é deposto por um golpe militar, e é eleito pelo Congresso Nacional um novo Presidente militar: o Marechal Castello Branco. Com o objetivo de consolidar o novo regime, foram editados vários atos institucionais que fortaleciam o Poder Executivo e limitavam as ações consideradas de esquerda. Todavia, a grande quantidade de atos institucionais e complementares descaracterizaram a Constituição de 1946 levou o Presidente Castello Branco a elaborar, com a colaboração de vários juristas, um novo texto constitucional, o qual foi enviado ao Congresso Nacional em forma de projeto, e que foi aprovado em 24/01/1967 passando a vigorar como nova Constituição em 24 de março de 1967.

Esta Constituição estabeleceu o Federalismo como forma de Estado, dando-se maior expressão à União; privilegiou o Poder Executivo, cujo chefe passou a ser eleito indiretamente por um Colégio Eleitoral; alterou o processo legislativo, criando-se o regime da lei delegada e dos decretos-leis; ampliou a competência da justiça militar para repressão dos crimes contra a segurança nacional.

Durante a vigência dessa Constituição foram editados dezessete atos institucionais e setenta e um atos complementares, fazendo-se necessário unificá-los em um único texto. Nesse espírito, foi editada, em 17/10/1969, a Emenda Constitucional nº 1, dando nova redação à Constituição vigente.

A Constituição de 1967 foi emendada vinte e sete vezes até a promulgação da Constituição de 5/10/1988, que vigora hoje.

A Constituição de 1988

No dia 1º de fevereiro de 1987, sob a presidência do Ministro José Carlos Moreira Alves, Presidente do Supremo Tribunal Federal, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. No dia seguinte, o Deputado Ulisses Guimarães foi eleito Presidente da Constituinte, que elaborou e promulgou no dia 5 de outubro de 1988 a Nova Constituição Brasileira, a oitava de nossa história constitucional. Esta Constituição é composta por trezentos e quinze artigos, sendo 245 na parte permanente e mais 70 na parte transitória, o que lhe atribui o título de uma das maiores Constituições do mundo. Pela quantidade de artigos, a doutrina a considera como uma Constituição Analítica. Sua estrutura difere das Constituições anteriores compreendendo nove títulos, podendo ser considerada prolixa.



2 Constituição: conceito e classificação.

Como noção de Constituição podemos dizer que está é o documento que estabelece a disciplina e o conjunto de elementos essenciais ao Estado. Trata-se da lei fundamental do Estado, que contém normas referentes à estrutura, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos etc.

De acordo com **J.J. GOMES CANOTILHO**¹, todas as Constituições devem (conceito ideal de Constituição):

- a) Ter um sistema de consagração de garantias da liberdade;
- b) Conter o princípio da separação dos Poderes;
- c) Ser escritas.

Existem várias concepções sobre o conceito de constituição, das quais defluem os sentidos ou acepções tradicionais, mediante as quais a doutrina procurou compreender o que é uma constituição:

a) **Concepção sociológica**: visão formulada por **Ferdinand Lassalle**, enxerga as constituições como um fato social, como a soma dos fatores reais de poder de um país, resultado concreto do relacionamento entre as forças sociais. Para ele, existe uma Constituição real e uma escrita. Esta somente terá validade se coincidir com aquela. Tem como principais características:

- i. A Constituição é vista mais como *fato* do que como *norma*, prioriza-se a perspectiva do ser e não a do dever ser;
- ii. A Constituição não está sustentada numa normatividade superior transcendente, não se baseia num direito natural, e sim nas práticas desenvolvidas na sociedade.

b) **Concepção política**: formulada por **Carl Schmitt**, constituição seria uma decisão política fundamental, a qual **não se apoia na justiça de suas normas, mas sim no que nela foi politicamente incluído**. Para ele, existe a Constituição em si e normas ou leis constitucionais, as quais, apesar de integrarem o texto escrito, não seriam materialmente constitucionais. Para ele, faria parte da Constituição, efetivamente, a disciplina da forma de Estado, do sistema de governo, do regime de governo, da organização e divisão dos poderes e o rol de direitos individuais. As leis constitucionais são todas aquelas normas inscritas na Constituição que poderiam vir tratadas em legislação ordinária.

c) **Concepção jurídica**: formulada por **Hans Kelsen** (Teoria Pura do Direito), Constituição é o paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico de um Estado e instituidor de sua estrutura. Sua concepção é estritamente formal. Daqui resultou a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico. Para ele, constituição é norma pura, é um dever ser, não há fundamento sociológico ou político, apenas caráter normativo. Kelsen dá dois sentidos à palavra Constituição:

- i. **Jurídico-positivo**: direito positivo é norma escrita ou posta pelo homem (pirâmide das leis – princípio da compatibilidade vertical entre as normas superiores e inferiores). Logo, Constituição seria norma escrita;
- ii. **Lógico-jurídico**: a norma inferior encontra seu fundamento de validade na norma que lhe for superior. A Constituição encontra o seu fundamento de validade não no direito posto, mas no plano

¹ J. J. GOMES CANOTILHO - **Direito Constitucional**, p. 62-63.

pressuposto lógico, ou seja, em valores metajurídicos, já que seu fundamento não seria de cunho constitucional.

Modernamente, temos as principais concepções:

a) **Teoria da Força Normativa da Constituição:** formulada por **Konrad Hesse**, trata-se de uma resposta a Lassalle. A Constituição escrita não necessariamente será resultado da vontade da parte mais forte no embate, **pode ser que a Constituição escrita seja capaz de redesenhar a soma dos fatores reais de poder**. Logo, ela não seria somente um resultado sociológico da sociedade, mas também, e principalmente, **teria o poder de modificar o conjunto de forças, moldar a sociedade como ela é**. A interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da Constituição, com poder de moldar a realidade. Por isso que se diz que a concepção da força normativa é uma resposta à concepção sociológica: pois nesta, **a concepção apenas reflete a soma dos fatores reais de poder, enquanto naquela, a Constituição efetivamente tem o condão de moldar a realidade**.

b) **Constituição simbólica:** formulada por **Marcelo Neves**², a utilização da norma constitucional como símbolo advém da intenção do legislador. Este ou queria realmente concretizar o que escrevia ou tinha a intenção somente de entregar um símbolo à sociedade. Seria, para ele, o que acontece em constituições outorgadas em regimes ditatoriais.

c) **Constituição aberta:** formulada por **Paulo Bonavides**³, para ele o objeto da constituição é sempre dinâmico. **A constituição deve ser o documento dinâmico que não se enclausure em si mesmo, mas que acompanhe as modificações e necessidades da sociedade**, sob pena de ficar ultrapassada e condenada à morte. Por isso que é importante que ela seja redigida com conceitos jurídicos mais abertos, com normas de caráter mais abstrato, de forma a permitir, mediante a interpretação, sua adequação à realidade.

O **objeto** da Constituição foi evoluindo de acordo com as evoluções sociais, políticas e econômicas, de modo que atualmente, em princípio o objeto das Constituições estão estruturados da seguinte forma:

- **Estruturação do estado;**
- **Organização dos Poderes e seus órgãos;**
- **Disposição sobre o modo de aquisição de poder e a forma de seu exercício;**
- **Limitação da atuação do poder;**
- **Proteção aos direitos e garantias dos indivíduos;**
- **Fixação do regime político;**
- **Fixação e disciplina das finalidades sociais e econômicas do Estado;**
- **Determinação dos fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais do Estado.**

Não há consenso doutrinário sobre quais são os elementos; entretanto, a generalidade das leis fundamentais revela, em sua estrutura normativa, cinco categorias de elementos, conforme segue:

a) **Orgânicos:** são normas que dão estrutura ao Estado. Cuidam dos órgãos do Estado, suas funções, atribuições de poderes. Então, como exemplo, nós temos o artigo 44 da Constituição que trata das atribuições do Poder Legislativo;

² SOUZA JÚNIOR, Luiz Lopes. A Constituição e seus sentidos: sociológico, político e jurídico? Qual o sentido que melhor reflete o conceito de Constituição? Disponível em <http://www.lfg.com.br>. 09 de julho de 2009.

³ BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 37.

b) **Limitativos:** assim denominados porque limitam a ação dos poderes estatais e dão a tônica do Estado de Direito, consubstanciando o elenco dos direitos e garantias fundamentais: direitos individuais e suas garantias, direitos de nacionalidade e direitos políticos e democráticos;

c) **Sócio-ideológicos:** consubstanciados nas normas sócio-ideológicas, normas que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o Estado Social, intervencionista; que tratam da intervenção do Estado na ordem econômica e social. Ao contrário das normas limitativas, que limitam o poder do Estado, as normas sócio-ideológicas disciplinam a intervenção do Estado, o poder do Estado na vida privada, regulando a vida da sociedade e até mesmo desenvolvendo atividade econômica através de empresas públicas. Esse tipo de norma não costuma ser encontrada em constituições liberais;

d) **De estabilização constitucional:** destinam-se a dar perenidade às instituições, a dar segurança ao funcionamento das instituições; consagrados nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas, premunindo os meios e as técnicas contra sua alteração e infringência, a não ser nos termos nela próprios estabelecidos (ações concentradas de controle, intervenção, Estado de Sítio e de Defesa etc.);

e) **Formais de aplicabilidade:** são normas de aplicação da Constituição, vão tratar de vigência, eficácia de normas constitucionais. Vão tratar de quando a Constituição entra em vigor, o que ela revoga. Consubstanciadas nas normas que estatuem regras de aplicação das constituições, assim, o preâmbulo, o dispositivo que contém as cláusulas de promulgação e as disposições transitórias.

Classificação

a) Quanto ao conteúdo:

- **Materiais ou substanciais:** são as normas constitucionais escritas ou costumeiras, estejam ou não codificadas em um único documento, regulando a estrutura e organização do Estado e os direitos fundamentais. Elas têm conteúdo essencialmente constitucional. Todas as normas que cuidam da organização do Estado e dos Direitos Fundamentais, mesmo que não estejam na Constituição Formal, formarão a Constituição material do Brasil.

- **Formais:** documento escrito, estabelecido de modo solene pelo poder constituinte originário e somente modificável por processos e formalidades especiais nela próprios estabelecidos. A CF/88 é formal, todas as suas normas têm caráter constitucional independentemente de seu conteúdo.

b) Quanto à forma:

- **Escritas ou dogmáticas:** fruto de um trabalho racional ou sistemático. Pode ser codificada num único texto, ou não codificada, esparsa por textos diversos, como tem o ocorrido com nossa Constituição, que já não é mais codificada em decorrência da quantidade de normas constitucionais que se encontram apenas nas emendas.

- **Não escritas,** costumeiras, consuetudinárias ou históricas: é o exemplo da Constituição Inglesa, que se baseia nos costumes e na jurisprudência. Porém, pode ter textos escritos, os quais se incorporam à Constituição. Há uma ligação natural entre a Constituição histórica, que traduz a evolução do pensamento político, com a Constituição não escrita. A Constituição não escrita, na parte que é escrita, se apresenta em vários documentos, como ocorre no Reino Unido: uma parte ainda é da Carta do João Sem Terra de 1.215, que é considerado um documento constitucional; a Lei do Habeas Corpus que é de 1.689 é considerada uma Lei constitucional; a Lei que organiza o Parlamento é considerada também Lei constitucional.

c) Quanto à origem:

- **Democráticas,** populares ou promulgadas: são elaboradas por representantes do povo, ou seja, são fruto de uma assembleia constituinte que foi criada para isso. No Brasil, foram desse tipo as constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988.

- **Outorgadas ou impostas:** impostas verticalmente, sem participação popular, pelos detentores do poder. No Brasil, temos as constituições de 1824, 1937, 1967 e 1969.

- **Pactuadas:** quando o poder constituinte não está na mão de seu titular, o povo, mas há uma divisão de poderes entre ambos, sendo parte da constituição decidida pelos detentores do poder e outra parte pelo povo.

- **Cesaristas ou plebiscitárias:** na verdade, deveria classificar-se como referendada, já que a Constituição é submetida a um referendo após elaborada pelos constituintes.

d) Quanto à estabilidade:

- **Imutáveis:** não passíveis de modificações. Nesse tipo de constituição, há rápida ruptura entre a realidade social e a norma constitucional, perdendo esta a efetividade.

- **Rígidas:** exige quórum mais rígido do que as demais normas infraconstitucionais para ser modificada. Trata-se de um dos pilares do controle de constitucionalidade, já que para se fazer o controle há de se ter a supremacia da constituição, e para se ter a supremacia, essa deve ser rígida.

- **Semi-rígidas:** parte é rígida e parte flexível, como ocorreu com a constituição de 1824.

- **Flexíveis:** a lei ordinária tem a mesma natureza jurídica de emenda constitucional, não havendo divergência no processo legislativo de uma e de outra. Nas constituições flexíveis mostra-se inviável o controle de constitucionalidade.

e) Quanto à extensão:

- **Concisas, breves, curtas ou sintéticas:** preveem somente princípios e normas gerais, não se preocupam em definir todos os aspectos da sociedade, sendo típica dos estados liberais. Geralmente tem caráter eminentemente negativo. Exemplo: Constituição norteamericana.

- **Longas, analíticas ou prolixas:** típicas de estado de bem-estar social, visam a garantir uma série de direitos e deveres aos indivíduos e os limites da atuação estatal, de forma bem definida.

f) Quanto à finalidade:

- **Negativas, garantias, liberais ou de texto reduzido:** é aquela que na relação entre o Estado e o Indivíduo, se preocupa apenas em garantir o indivíduo contra o Estado. Ela recebe esse nome porque no tema de relacionamento do indivíduo, cidadão e o Estado, se preocupa apenas em garantir o indivíduo contra o Estado.

- **Dirigentes, plásticas ou programáticas:** estabelecem programas e definem os limites e a extensão de seus direitos; são sempre analíticas. Seu principal teórico foi Canotilho. É o modelo das Constituições Sociais. Dirigente porque quando o Estado intervém na ordem econômica e social, pretende nesse aspecto dirigir as atividades da sociedade. O Estado intervém através de um gerenciamento da vida privada. A Constituição brasileira aderiu ao modelo dirigente, mas um dirigismo que já foi bastante atenuado com várias emendas constitucionais que alteraram a previsão da intervenção na ordem econômica. Na época do primeiro Governo Fernando Henrique com as privatizações de empresas. Esse movimento que foi feito na primeira metade da década de 90 até 1995/1997 foi um movimento liberalizante que tornou a nossa Constituição menos dirigente, com um Estado menos interventor.

- **Constituições balanço:** é a denominação que se dá à Constituição que meramente descreve e sistematiza a organização política do Estado. Destina-se a espelhar certo período político, um dado estágio das relações de poder no Estado.

g) Quanto à ideologia ou objeto ideológico:

- **Liberais:** consolidam o pensamento liberal político e econômico. São, portanto, constituições que não pregam a intervenção do Estado na ordem econômico e social. É o Estado Mínimo, ou seja, que deve

ter uma participação mínima, cuidando apenas da coisa pública, não devendo reger a sociedade, pois essa usa das suas próprias forças, o mercado tem suas próprias forças. A sociedade progride com a busca pelo lucro e isso faz com que pessoas e empresas queiram produzir mais e melhor. É a Lei do mercado. Exemplo: Constituição norte-americana. Geralmente as Constituições liberais são negativas e concisas.

- **Sociais:** preveem a intervenção do Estado na ordem econômico-social ao regular o mercado, quer dizer, isso faz com que o mercado seja menos livre na regulação do mercado e na redução da desigualdade.

Uma característica das constituições sociais, portanto, é valorizar mecanismos de intervenção na ordem econômica, por exemplo, empresas públicas, regulação da ordem econômica também através do sistema tributário, por meio da criação de impostos com natureza extrafiscal, que são aqueles impostos que não são imaginados para arrecadar, até arrecadam, mas não é o objetivo deles, e sim, regular o mercado, como acontece no Brasil com os impostos de importação e exportação.

A possibilidade de criação de empresa pública, quer dizer, o Estado com um braço na iniciativa privada, para criar uma determinada concorrência num determinado setor.

E, na ordem social, tende a valorizar no âmbito dos Direitos Fundamentais também os Direitos Sociais, o que não é muito valorizado em constituições liberais, pois nessas, no âmbito dos Direitos Fundamentais, acabam valorizando o direito de liberdade (física, religiosa, de imprensa etc.).

Então, os Direitos Fundamentais numa Constituição Liberal basicamente se resumem aos Direitos Individuais. Já numa Constituição Social, passam a ser integrados também por Direitos Sociais (educação, saúde, previdência, assistência).

- **Socialistas:** mais do que intervir na ordem econômica e social, pretende planificar a sociedade. Então, ela acaba retirando da sociedade a sua liberdade de buscar o sucesso individual. O Estado não apenas planifica as suas ações no interesse público, mas se apropria dos meios de produção. Fica muito clara a diferença de abordagem dessas três diferenças de ideologia na Constituição, quando nós trabalhamos com um valor constitucional determinado, como o valor da igualdade.

A igualdade numa Constituição Liberal é uma igualdade formal. O Estado não pode discriminar as pessoas, têm que tratar a todos como iguais. Mas se as pessoas estão desiguales materialmente na vida, isso não é um problema do Estado, pois ele é um Estado Mínimo. Ele não pode desigualar, não pode discriminar, mas cada um com a sua vida. Nasceu pobre, problema seu; nasceu rico, que bom. Mas isso não é um problema do Estado, esse não pode discriminar as pessoas, que é a igualdade formal.

A visão da igualdade no Estado Social, além do Estado não poder discriminar, o Estado pode intervir na sociedade para reduzir a desigualdade. Então, quando o Estado se depara numa situação de miséria, ignorância, é legítimo que intervenha na sociedade, mas só nesses casos. Quando o desequilíbrio material entre as pessoas é suportável, o Estado não deve se meter, devendo intervir somente em situações extremas.

A igualdade num Estado Socialista é uma igualdade material, de resultado. Como o Estado pretende planificar a própria economia, a própria ação da sociedade, ele retira muito a liberdade das pessoas. O que ele pretende é que as pessoas basicamente tenham o mesmo padrão. A questão é que alguns países socialistas conseguem dar o mesmo padrão alto como a Finlândia e a Noruega. Outros conseguem igualar também, mas por baixo. Mas o objetivo é esse.

h) Quanto à dogmática:

- **Ortodoxa ou comprometida:** é aquela comprometida com uma determinada ideologia, que não pode ser alterada pelos governos que se alternarem no Poder.

- **Heterodoxa, eclética ou compromissória:** aquela que permite o convívio ideológico, sem promover exclusão prévia de formas de pensamento e de ideias sociais e políticas. A Constituição brasileira é uma Constituição Social, mas ela é compromissória, aberta. Isso fica claro, quando no artigo 3º, além daquela previsão da redução de desigualdades sociais e regionais, garante a autonomia privada, livre iniciativa, que é um valor do liberalismo.

i) Quanto à correspondência com a realidade ou classificação ontológica: trata-se de importante classificação, que despenca em concursos públicos, desenvolvida por Karl Lowenstein.

- **Normativas:** são aquelas constituições que conseguem regular a vida política de um Estado, por estarem em consonância com a realidade social.

- **Nominativas:** são aquelas constituições que não conseguem regular a vida política de um Estado, pelo descompasso com a realidade.

- **Semânticas:** é a constituição elaborada como mera formalização do Poder Político dominante. É exemplo a constituição nazista. Constitucionalmente, todas as medidas adotadas durante o Reich foram legítimas.

A Constituição de 1988 é **rígida, dogmática, programática, normativa, social, promulgada, escrita, heterodoxa e analítica.**

Conteúdo	MATERIAIS OU SUBSTANCIAIS	
	FORMAIS	
Forma	ESCRITAS OU DOGMÁTICAS	Codificadas
		Não codificadas
Origem	NÃO ESCRITAS, COSTUMEIRAS, CONSUETUDINÁRIAS OU HISTÓRICAS	
	PROMULGADAS, DEMOCRÁTICAS OU POPULARES	
	OUTORGADAS OU IMPOSTAS	
	CESARISTAS OU PLEBISCITÁRIAS	
Estabilidade	PACTUADAS	
	IMUTÁVEL	
	RÍGIDA	
	SEMI-RÍGIDA	
Extensão	FLEXÍVEL	
	CONCISAS OU BREVES	
Finalidade	EXTENSAS OU LONGAS	
	CONSTITUIÇÕES-GARANTIA, NEGATIVAS OU DE TEXTO REDUZIDO	
	DIRIGENTES	
Ideologia	CONSTITUIÇÕES-BALANÇO	
	LIBERAIS	
	SOCIAIS	
Quanto à dogmática	SOCIALISTAS	
	ORTODOXA	
Correspondência com a realidade ou ontológica	HETERODOXA	
	NORMATIVAS	
	NOMINATIVAS	
	SEMÂNTICAS	



3 Constitucionalismo. Espécies; Constitucionalismo Social. Constitucionalismo do Futuro. Constitucionalismo Transnacional. Transconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo.

Constitucionalismo é como se denomina o movimento social, político e jurídico a partir do qual emergem as constituições nacionais.

André Ramos Tavares⁴ identifica quatro sentidos para o termo constitucionalismo: “Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao **movimento político-social** com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. Numa segunda acepção, é identificado com a imposição de que haja **cartas constitucionais escritas**. Tem-se utilizado, numa terceira concepção possível, para indicar os **propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições** nas diversas sociedades. Numa vertente mais restrita, o constitucionalismo é reduzido à **evolução histórico-constitucional de um determinado Estado**.”

Seguindo a lição de **Uadi Lammêgo Bulos**⁵, o termo constitucionalismo tem dois significados diferentes: em **sentido amplo**, significa o fenômeno relacionado ao fato de todo Estado possuir uma Constituição em qualquer época da humanidade, independentemente do regime político adotado ou do perfil jurídico que se lhe pretenda atribuir; **em sentido estrito**, significa a técnica jurídica de tutela das liberdades, surgida nos fins do século XVIII, que possibilitou aos cidadãos o exercício, com base em Constituições escritas, dos seus direitos e garantias fundamentais, sem que o Estado lhes pudesse oprimir pelo uso da força e do arbítrio.

A doutrina costuma apontar as fases de evolução do constitucionalismo: **constitucionalismo primitivo, constitucionalismo antigo, constitucionalismo medieval, constitucionalismo moderno, constitucionalismo contemporâneo e constitucionalismo do futuro**.

A **primeira ideia de constitucionalismo** está associada às pioneiras limitações ao poder do Estado. As raízes desse “movimento constitucional”⁶ são encontradas entre os hebreus, para quem as leis dos homens estariam limitadas pelos comandos divinos. Os povos hebreus, juntamente com as cidades-estados gregas, formam o denominado **constitucionalismo antigo**.

A **segunda vertente do constitucionalismo** aparece na idade média, com o surgimento da Magna Carta do Rei João Sem-Terra, de 1215. Ainda que seja mais identificada como um Documento instituidor de privilégios, a Magna Carta de 1215 representou, sem dúvida, uma limitação do poder real, tendo importância histórica para a evolução do constitucionalismo.

O **marco do constitucionalismo moderno** está ligado a dois grandes acontecimentos do Séc. XVIII, símbolos da limitação do poder estatal, a saber: Constituição norte-americana, de 1787, e Revolução Francesa de 1789, e na consequente elaboração da Constituição francesa de 1791.

Este novo modelo de constitucionalismo caracteriza-se:

- a) pela publicidade, permitindo amplo conhecimento da estrutura do poder e garantia de direitos;
- b) pela clareza, por ser um documento unificado, que afasta incertezas e dúvidas sobre os direitos e os limites do poder;

⁴ Tavares, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. revista e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 17.

⁵ Op. Cit. p. 64.

⁶ J.J. Gomes Canotilho adverte que o mais correto seria referir-se a “movimentos constitucionais, ao invés do termo constitucionalismos. In: CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7 ed. Almedina. 2003. pag. 51.

c) pela segurança, justamente por proporcionar a clareza necessária à compreensão do poder.

Por sua vez, o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo surgiu após o fim da 2ª Guerra Mundial, quando o mundo ocidental sentiu a necessidade de reformular o conceito de Constituição, de maneira a não mais admitir como legítima a ação estatal que fragilizasse a dignidade da pessoa humana e outros valores como a justiça e a paz social, ainda que supostamente amparada na lei. A ordem é que nenhum ordenamento jurídico, por mais democrático que se intitule, possa violar os direitos fundamentais, possa desrespeitar o postulado da dignidade humana, considerado valor universal pela Declaração dos Direitos de 1948.

O **constitucionalismo do futuro** ou constitucionalismo do por vir, nada mais é do que numa nova perspectiva do movimento constitucionalista e representa o que se espera do futuro do direito constitucional.

Constitucionalismo social

O Constitucionalismo social é um sistema que defende o regime constitucional, ou seja, um governo regulado por uma Constituição que organize o Estado e limite o seu poder, bem como, a inclusão de normas e preceitos relativos à defesa dos Direitos Humanos Fundamentais em seu texto. Surgiu nas transições das monarquias absolutistas para o Estado Liberal de Direito e tem como objetivo a proteção dos Direitos Humanos Fundamentais, sem os quais a pessoa humana não consegue existir e fica à mercê do livre arbítrio dos governantes. Estabelecendo um Governo de Leis, o Homem passa a abraçar um Estado de Direito, ou seja, um país juridicamente organizado através da sistematização das normas em forma de lei, o que significa dizer que o Estado também está subordinado às leis, assim como, a sociedade.

Neoconstitucionalismo

O **neoconstitucionalismo**, enquanto fenômeno do Direito Constitucional contemporâneo, visa refundar o direito constitucional com base em novas premissas como a difusão e o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais e a força normativa da constituição, objetivando a transformação de um estado legal em estado constitucional.

O modelo normativo do neoconstitucionalismo é o axiológico, abandonando o documento político fundamental a concepção da limitação de poderes, pois, acima de tudo, importa tornar eficaz a Constituição, na busca incessante por concretizar os valores ínsitos aos direitos fundamentais nela consagrados.

Converte-se a Constituição no centro do sistema, adquirindo seu texto carga jurídica, imbuída, logo, de normatividade, imperatividade e superioridade; ingressa no cenário jurídico gozando agora não apenas sua formal supremacia, como também sua superioridade material e axiológica, visto sua preeminência normativa no sistema; passa, a partir da revolução paradigmática que o fenômeno do neoconstitucionalismo proporciona, a ter uma força normativa reconhecida, lastreada no caráter vinculativo e obrigatório de seus enunciados.⁷

Temos como características:

a) a supremacia do texto constitucional, sendo que todas as prescrições têm normatividade, ou seja, os direitos previstos na Carta Política, por regras ou princípios, serão efetivados ainda que não exista norma infraconstitucional dispondo sobre a matéria.

b) garantia, promoção e preservação dos direitos humanos: em todos os países que respeitam o princípio democrático tais direitos são assegurados; a CF/1988 abarcou todos eles, expressa ou implicitamente, seja na forma de regras ou na forma de princípios.

c) força normativa dos princípios constitucionais: é possível a resolução de determinada demanda com base em princípios, especialmente, quando o caso versar sobre direitos fundamentais. Em caso de colisão entre princípios, quando determinada situação fática pode ser regulada por dois princípios

⁷ COSTA, Lucas Sales da. Neoconstitucionalismo: definição, origem e marcos. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4063, 16 ago. 2014. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/29197>>.

oponentes entre si, aponta a doutrina como solução a ponderação de interesses, em que um princípio será aplicado em detrimento de outro sem que este se torne inválido.

d) constitucionalização do Direito: trata-se da aplicação do chamado efeito irradiante da Constituição, em razão do qual as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas à luz das disposições constitucionais.

e) ampliação da jurisdição constitucional: refere-se à interpretação e aplicação do Texto Constitucional em qualquer questão que demande um provimento judicial.

Constitucionalismo do Futuro.

O **constitucionalismo do futuro** consiste numa perspectiva de direito constitucional a ser implementada após o neoconstitucionalismo. Prega a consolidação dos direitos humanos de terceira dimensão, fazendo prevalecer a noção de fraternidade e solidariedade. Trata-se da “constituição do porvir”, calcada na esperança de dias melhores, um verdadeiro constitucionalismo altruístico.

Segundo José Roberto Dromi⁸, jurista argentino, que prevê um equilíbrio entre os atributos do constitucionalismo moderno e os excessos do constitucionalismo contemporâneo, as Constituições teriam sete valores fundamentais, quais sejam: **continuidade, verdade, consenso, solidariedade, integração, participação da sociedade na política e universalização dos direitos fundamentais para todos os povos do mundo.**

- **Continuidade** – As constituições do futuro não devem ficar sofrendo rupturas bruscas, séries de emendas;

- **Verdade** – As constituições não ficariam fazendo promessas impossíveis, pois de nada adiantaria uma carta dotada de excessivo protecionismo, mas destituída de qualquer exigibilidade;

- **Consenso** – Constituições seria fruto de um consenso democrático;

- **Solidariedade** – As constituições aproximam-se de uma nova idéia de igualdade, baseada na solidariedade dos povos, na dignidade da pessoa humana e na justiça social, com a eliminação das discriminações;

- **Integração** – As Constituições refletiriam a integração espiritual, moral, ética e institucional dos povos;

- **Participação da sociedade na política** – De forma ativa, integral no processo político eliminando, com isso, a indiferença social;

- **Universalização dos direitos fundamentais** – Os direitos fundamentais internacionais serão previstos nas constituições do futuro, com a prevalência universal da dignidade do homem, e serão eliminadas quaisquer formas de desumanização.

Constitucionalismo Transnacional.

Constitucionalismo Transnacional – possibilidade de se elaborar uma só constituição para vários países. Fala-se em uma desvinculação entre constitucionalismo moderno e o Estado nacional, a ideia de um constitucionalismo sem um Estado nacional

Transconstitucionalismo.

O transconstitucionalismo pode ser visto como sendo o "entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional".⁹ É a relação entre o direito interno e o direito internacional, para melhor tutela dos direitos fundamentais.

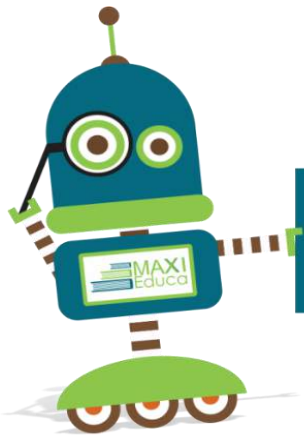
O chamado transconstitucionalismo, que se refere ao estudo combinado da jurisdição nacional com a jurisdição internacional. Esse estudo combinado do direito interno com o direito transnacional, sugere ser a evolução do neoconstitucionalismo, que fará surgir o que a doutrina já tem antecipado como transconstitucionalismo.

⁸ DROMI, José Roberto. La Reforma Constitucional: El Constitucionalismo del “por-venir”. In: ENTERRIA, Eduardo Garcia de; ARÉVALO, Manuel Clavero (coord). El Derecho Público de Finales de Siglo: Una Perspectiva Iberoamericana. Madri: Fundación BBV, 1997, p.107-116.

⁹ NEVES, Marcelo. **Transconstitucionalismo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

A sociedade global passou a ganhar instituições parecidas com as existentes no plano doméstico, a se observar pelos inúmeros tribunais internacionais, como a corte internacional de justiça, corte permanente de justiça internacional, corte interamericana de direitos humanos, corte europeia de direitos humanos, tribunais de integração econômica, além dos vários tribunais internacionais penais (TPI's).

Observa-se também a existência de relevantes organizações mundiais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esse fenômeno da globalização tem mudado o enfoque das relações internacionais. Se antes eram características marcantes da sociedade internacional ser paritária e descentralizada (sem hierarquia e poder central), hoje percebemos que tais características estão em franca mutação, cada vez mais surgindo organizações centralizando o poder e tribunais hierarquizando interpretações.



4 Normas constitucionais: classificação.

Como regra geral, todas as normas constitucionais apresentam eficácia, algumas jurídica e social e outras apenas jurídicas. **Eficácia social** verifica-se na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade para regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. **Eficácia jurídica**, por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência de relações concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam.

Normas de eficácia plena, contida e limitada.

Em relação à classificação e aplicabilidade das normas constitucionais, conforme bem leciona Antonio Henrique Lindemberg¹⁰, na esteira da teoria de José Afonso da Silva, temos normas:

- **De aplicabilidade imediata e eficácia plena:** São consideradas aquelas que não dependem de atuação legislativa posterior para a sua regulamentação, isto é, desde a entrada em vigor da Constituição estas normas já estão aptas a produzirem todos os seus efeitos. A título de exemplo podemos apontar as normas referentes às competências dos órgãos (CF, art. 48 e 49) e os remédios constitucionais.

- **De aplicabilidade imediata e eficácia contida ou restringível:** São normas constitucionais em que o legislador constituinte regulou suficientemente a matéria, mas possibilitou ao legislador ordinário restringir os efeitos da norma constitucional. Estas normas constitucionais têm aplicabilidade imediata, quer dizer, com a entrada em vigor da Constituição elas já são aplicáveis, no entanto, uma lei posterior poderá restringir, conter seus efeitos.

Como exemplo, pode ser citado o art. 5º, XIII da Carta Republicana de 1988, que diz ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Observando este artigo veremos que, se não houver uma lei regulamentando as profissões, qualquer pessoa poderá exercer qualquer tipo de atividade. No entanto, o legislador ordinário poderá, através de lei, estabelecer requisitos para o exercício de algumas profissões, como é o caso da profissão de advogado, onde a Lei 8.906/94 veio a estabelecer a necessidade de conclusão do curso de bacharelado em direito e ainda a aprovação no exame de ordem para aqueles que pretendam exercer a mencionada profissão, assim, é de se apontar que a lei veio restringir o alcance da norma constitucional, estabelecendo requisitos para o exercício profissional.

¹⁰ Adaptado de: https://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/AntonioLindemberg/lindemberg_toq11.pdf

- **De aplicabilidade mediata e eficácia limitada:** Classificam-se como normas de aplicabilidade mediata e eficácia limitada aquelas que precisam de atuação legislativa posterior para que possam gerar plenamente todos os direitos e obrigações e podem ser subdivididas em:

- Normas de eficácia limitada quanto aos princípios institutivos, que são as normas onde o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições dos órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante Lei.

A previsão de criação do Código de Defesa do Consumidor (CF, art. 5º, XXXII), a regulamentação do direito de greve do servidor público (CF, art. 37, VII), a organização administrativa e judiciária dos Territórios Federais (CF, art. 33), são exemplos de normas de eficácia limitada.

- Normas de eficácia limitada quanto aos princípios programáticos, que são *“aquelas normas constitucionais, através das quais o constituinte, em vez de regular direta e imediatamente determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado”*. São normas que dependem de ações metajurídicas para serem implementadas, temos como exemplo o direito ao salário mínimo digno (CF, art. 7º, IV), o direito à moradia, ao trabalho, a segurança (CF, art. 6º).

Pela própria natureza de direitos que exigem do Estado uma conduta prestativa, positiva, nem sempre é possível a sua pronta concretização, haja vista a carência e a limitação de recursos financeiros para a realização dos atos estatais.

De acordo com a lição de Gilmar Ferreira Mendes¹¹, estes direitos não dependem apenas de uma decisão jurídica, mas exigem atuações legislativas e administrativas para a sua real concretização, ou seja, são limitados pela conhecida teorização da Reserva do Financeiramente Possível.

Onde o Estado, não possuindo recursos suficientes para ofertar todas as prestações relacionadas como direitos fundamentais sociais, deve eleger aquelas que julga mais pertinentes de acordo com as condições do momento.

Assim, leciona o citado autor: “Observe-se que, embora tais decisões estejam vinculadas juridicamente, é certo que a sua efetivação está submetida, dentre outras condicionantes à reserva do financeiramente possível”.

A partir desse critério, poder-se-ia considerar irrazoável a condenação do Estado ao pagamento de medicamento extremamente caro, enquanto outros cidadãos carecem ainda dos medicamentos mais baratos (e por vezes tanto quanto ou mais essenciais), por falta de recursos públicos. Isso pode, a princípio, ofender a dignidade humana daquela pessoa, e até mesmo um alegado “mínimo para a existência” (se identificável). Porém, não pode o Judiciário fechar os olhos para o macro e aliviar sua consciência diária ao proteger o micro.

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.

Deve ser destacado também que os efeitos normalmente atribuídos a estas normas:

a) Acarretam a revogação dos atos normativos anteriores e contrários ao seu conteúdo e, por via de consequência, sua desaplicação, independentemente de um declaração de inconstitucionalidade, ressaltando-se que entre nós o Supremo Tribunal Federal consagrou a tese da revogação, em detrimento da assim chamada inconstitucionalidade superveniente.

b) Contêm imposições que vinculam permanentemente o legislador, no sentido de que não apenas está obrigado a concretizar os programas, tarefas, fins e ordens mais ou menos concretas previstas na norma, mas também que o legislador, ao cumprir seu desiderato, não se poderá afastar dos parâmetros prescritos nas normas de direitos fundamentais a prestações.

c) Implicam a declaração de inconstitucionalidade (por ação) de todos os atos normativos editados após a vigência da Constituição, caso colidentes com o conteúdo das normas de direitos fundamentais, isto é, caso contrários ao sentido dos princípios e regras contidos nas normas que os consagram.

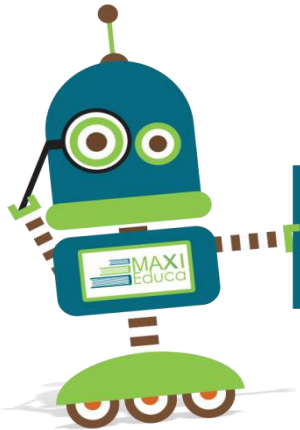
d) Geram um direito subjetivo de cunho negativo no sentido de que o particular poderá sempre exigir do Estado que se abstenha de atuar em sentido contrário ao disposto na norma de direito fundamental prestacional. Cuida-se, portanto, de uma dimensão negativa dos direitos positivos, já que as normas que

¹¹ MENDES, Gilmar. Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na Ordem constitucional. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, nº. 10, janeiro, 2002. Disponível na Internet: <http://www.direitopublico.com.br/>, acesso em 05/2015.

os consagram, além de vedarem a emissão de atos normativos contrários, proíbem a prática de comportamentos que tenham por objetivo impedir a produção dos atos destinados à execução das tarefas, fins ou imposições contidas na norma de natureza eminentemente programática.

e) Por fim, ainda verifica-se a possibilidade de ser exigido do Estado a concretização dos direitos prestacionais, através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º) ou através do mandado de injunção (CF, art. 5º, LXXI).

Concluindo, não há, numa Constituição, cláusulas a que se deve atribuir meramente o valor material de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos. Muitas, porém, não revestem dos meios de ação essenciais ao seu exercício os direitos, que outorgam, ou os encargos, que impõem: estabelecem competências, atribuições, poderes, cujo uso tem de aguardar que a legislatura, segundo o seu critério, os habilite a se exercerem.



5 Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais.

O STF já decidiu que o preâmbulo não possui relevância jurídica, não tem força normativa e não é de observância obrigatória pelos outros entes, não é limitação ao poder constituinte derivado e não é parâmetro para controle de constitucionalidade.

A doutrina pátria defende que ele tem a função de mera diretriz interpretativa do texto constitucional.

Conforme Peter Häberle, os preâmbulos são pontes no tempo, exteriorizando as origens, os sentimentos, os desejos e as esperanças que palmilharam o ato constituinte originário. Trata-se de uma forma de comunicação intergeracional entre o constituinte originário e as demais gerações.

Normas programáticas.

Normas ou **princípios programáticos**, que são aquelas normas constitucionais, através das quais o constituinte, em vez de regular direta e imediatamente determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado. As normas programáticas são as que estabelecem programas a serem desenvolvidos mediante a vontade do legislador infraconstitucional.¹² São normas que dependem de ações metajurídicas para serem implementadas, temos como exemplo o direito ao salário mínimo digno (CF, art. 7º, IV), o direito à moradia, ao trabalho, a segurança (CF, art. 6º).

Princípios constitucionais

Os princípios fundamentais ou constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica. Nos princípios constitucionais, condensam-se bens e valores considerados fundamentos de validade de todo o sistema jurídico.

Os princípios constituem ideias gerais e abstratas, que expressam, em menor ou maiores escala todas as normas que compõem a seara do direito. Poderíamos dizer que cada área do direito retrata a concretização de certo número de princípios, que constituem o seu núcleo central. Eles possuem uma força que permeia todo o campo sob seu alcance. Daí por que todas as normas que compõem o direito constitucional devem ser estudadas, interpretadas, compreendidas à luz desses princípios. Os princípios

¹² Tavares, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. revista e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 102.

consagrados constitucionalmente servem, a um só tempo, como objeto da interpretação constitucional e como diretriz para a atividade interpretativa, como guias a nortear a opção de interpretação.

Os princípios constituem a base, o alicerce de um sistema jurídico. São verdadeiras proposições lógicas que fundamentam e sustentam um sistema.

Sabe-se que os princípios, ao lado das regras, são normas jurídicas. Os princípios, porém, exercem dentro do sistema normativo um papel diferente das regras. As regras, por descreverem fatos hipotéticos, possuem a nítida função de regular, direta ou indiretamente, as relações jurídicas que se enquadrem nas molduras típicas por elas descritas. Não é assim com os princípios, que são normas generalíssimas dentro do sistema.

Serve o princípio como limite de atuação do jurista. No mesmo passo em que funciona como vetor de interpretação, o princípio tem como função limitar a vontade subjetiva do aplicador do direito, vale dizer, os princípios estabelecem balizamentos dentro dos quais o jurista exercitará sua criatividade, seu senso do razoável e sua capacidade de fazer a justiça do caso concreto.

Os princípios constitucionais estão contidos nos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal (CF).

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

O artigo define a forma de Estado (Federativa) e a forma de Governo (República) em duas palavras “República Federativa”, “formada pela União indissolúvel” (nenhum ente pode pretender se separar), numa Federação não existe a hipótese de separação, “constitui em Estado Democrático de Direito”. Essa expressão traz em si a ideia do Estado formado a partir da vontade do povo, voltado para o povo e ao interesse do povo (o povo tem uma participação ativa, sempre com o respeito aos Direitos e garantias fundamentais), e tem por fundamentos: 1) Cidadania; 2) Soberania; 3) Dignidade da pessoa humana; 4) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 5) Pluralismo político.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

a) O Poder Executivo é um dos poderes governamentais, segundo a teoria da separação dos poderes cuja responsabilidade é a de implementar, ou *executar*, as leis e a agenda diária do governo ou do Estado.). O poder executivo varia de país a país. Nos países presidencialistas, o poder executivo é representado pelo seu presidente, que acumula as funções de chefe de governo e chefe de estado.

b) O Poder Legislativo é o poder de legislar, criar leis. No sistema de três poderes proposto por Montesquieu, o poder legislativo é representado pelos legisladores, homens que devem elaborar as leis que regulam o Estado. O poder legislativo na maioria das repúblicas e monarquias é constituído por um congresso, parlamento, assembleias ou câmaras. O objetivo do poder legislativo é elaborar normas de direito de abrangência geral (ou, raramente, de abrangência individual) que são estabelecidas aos cidadãos ou às instituições públicas nas suas relações recíprocas.

c) O Poder judiciário é um dos três poderes do Estado moderno na divisão preconizada por Montesquieu em sua teoria da separação dos poderes. Ele possui a capacidade de julgar, de acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com as regras constitucionais em determinado país. Ministros, desembargadores e Juízes formam a classe dos magistrados (os que julgam).

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Traz os objetivos da República Federativa do Brasil. É uma norma programática. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- I - independência nacional;**
- II - prevalência dos direitos humanos;**
- III - autodeterminação dos povos;**
- IV - não-intervenção;**
- V - igualdade entre os Estados;**
- VI - defesa da paz;**
- VII - solução pacífica dos conflitos;**
- VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;**
- IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;**
- X - concessão de asilo político.**

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Traz os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Outros princípios fundamentais estão espalhados por todo o texto constitucional, de forma explícita ou implícita. Muitos de forma até repetitiva, para que não sejam desconsiderados. **As colisões de princípios são resolvidas pelo critério de peso**, preponderando o de maior valor no caso concreto, pois ambas as normas jurídicas são consideradas igualmente válidas. Por exemplo: o eterno dilema entre a liberdade de informação jornalística e a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (CF/88, art. 220, §1º). Há necessidade de compatibilizar ao máximo os princípios, podendo prevalecer, no caso concreto, a aplicação de um ou outro direito.



6 Disposições constitucionais transitórias.

O Ato das disposições constitucionais transitórias está inserido na CF/88, com a finalidade de estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, instituído pela manifestação do poder constituinte originário, providenciando a acomodação e a transição do antigo e do novo direito edificado.

As normas do ADCT são normas constitucionais e têm o mesmo status jurídico das demais normas do Texto principal e, como as demais normas constitucionais, as regras do ADCT são suscetíveis de serem reformadas e serem submetidas ao controle de constitucionalidade, no caso de ser emendadas.

O ADCT não só *pode* ser objeto de Emenda Constitucional, *como essa é uma praxe regularmente praticada*. Basta ver a EC nº 02/1992, ou a EC nº 42/2003, ou a EC nº 43/2004, ou a EC nº 53/2006, dentre outras.

Previsão da revisão constitucional no ADCT e norma de eficácia exaurida. A *norma de eficácia exaurida* é aquela que tem uma “razão para existir”, de forma que, após cumprido seu objetivo, ela perde sua força realizadora. Tal conceituação representa um prolongamento da classificação tradicional de José Afonso da Silva, entre normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, e normas de eficácia limitada.

No art. 3º, ADCT, se prevê que a revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Isto posto, em 1993, de fato começou a ser feita esta revisão constitucional, e, ao seu fim, em 1994, perdeu razão de existir o aludido dispositivo, pelo transcurso de lapso temporal aliado à realização do ato no art. 3º previsto.

Por sua vez, o poder reformador é o poder de alterar a Constituição via Emenda Constitucional. Com efeito, a revisão constitucional não pode ocorrer novamente à luz da Constituição Federal de 1988, pois o poder constituinte reformador não pode alterar a Lei Fundamental pátria neste aspecto. É dizer: norma de eficácia exaurida não pode ser objeto de Emenda Constitucional.

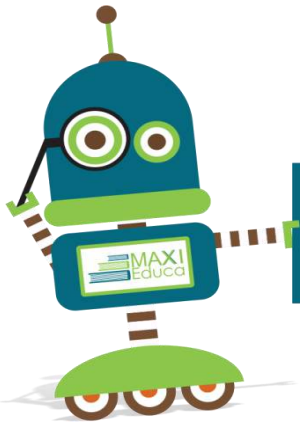
Natureza das normas previstas no ADCT e possibilidade de controle de constitucionalidade das normas do ADCT. Apesar do termo “Ato das Disposições Constitucionais *Transitórias*”, isso não retira a natureza de norma constitucional do que está previsto nesta parte da Constituição Federal de 1988. Não há diferença, pois, entre esta parte, dita “transitória”, e a parte restante da Constituição, dita “dogmática”.

Isto tanto é verdade, que tal como pode uma norma contida no ADCT ser objeto de Emenda Constitucional, também uma norma que contrarie algum dispositivo do ADCT pode ser objeto de controle de constitucionalidade, *p. ex.*

Ademais, esta ausência de desníveis/desigualdades entre o texto constitucional propriamente dito e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias decorre do princípio da unidade da Constituição, já explicado quando do estudo da Teoria da Constituição.

ADCT e o regime de transição entre o regime de 1967 (ou 1969, para quem assim entende) e o de 1988. Alguns dispositivos do ADCT englobam estipulações quanto às providências a serem adotadas no período de transição. É o caso do art. 4º, *caput*, do ADCT, *p. ex.*, que afirma que o mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março de 1990, ou do art. 5º, *caput*, que afirma não se aplicar para as eleições previstas em quinze de novembro de 1988 o disposto no art. 16 e as regras do art. 77, da Constituição.

ADCT e Princípio da Recepção. De fato, as disposições transitórias interligam-se com o princípio da recepção, pois tratam de normas que, como não seriam recepcionadas pela Constituição por absoluta ineficácia e inaplicabilidade futura, têm validade com força de norma constitucional, *mas por tempo determinado*.



7 Hermenêutica constitucional.

As leis são criadas com o objetivo de organizar a vida social, regulando a ação das pessoas, resolvendo-lhes os conflitos de interesses, bem como os dissídios que nascem na vida prática. Portanto, instituem-se leis visando à paz, à harmonia entre os cidadãos.

Muitas vezes, porém, as leis se mostram obscuras, ambíguas e lacunosas; impedindo-se assim a adequação do caso concreto a norma. Entretanto, a deficiência legal não pode servir de argumento para o magistrado furtar-se do julgamento das controvérsias que lhe sejam submetidas à autoridade, até porque a vida social se desenvolve protegida pelo Direito, e o juiz, por essa razão, não pode falhar em sua missão.

O Direito, para isso, não poderia furtar-se a fornecer os meios imprescindíveis para corrigir ou suprir deficiências que porventura existam nas leis, que resultem da ambiguidade, obscuridade ou omissão.

Deste modo, a **Hermenêutica** é o exame do saber sobre os pressupostos, a metodologia e a interpretação do direito. Está ligada à mitologia greco-latina. O Deus Hermes era um mensageiro dos deuses, era a divindade incumbida de levar a mensagem dos homens aos deuses e a mensagem dos deuses aos homens. A interpretação em geral, e a interpretação jurídica, é uma atividade de mediação comunicativa.

A hermenêutica constitucional será entendida como o saber que se propõe a estudar os princípios, os fatos, e compreender os institutos da Constituição para colocá-la diante da sociedade. O poder constituinte é o responsável pela criação da Constituição. O poder constituinte pode ser visualizado como um emissor de uma mensagem, ou conjunto de mensagens (Constituição) normativas, que organizam o Estado e definem os direitos fundamentais.

Noutro polo da relação comunicativa, podemos colocar a sociedade/comunidade jurídica que seria a receptora desse conjunto de mensagens normativas, estabelecendo aqui a relação comunicativa. A interpretação constitucional, feita pelos intérpretes da Constituição, vem mediar à relação comunicativa entre os dois polos ⇒ **Relação circular** ⇒ **circularidade hermenêutica**. Isso faz com a Constituição se concretize no âmbito da sociedade.

Métodos de interpretação constitucional.

A hermenêutica constitucional é guiada por métodos. Dentro da teoria do conhecimento o método é a forma de se alcançar o conhecimento. Uma polêmica desde já instaurada é aquela relativa à existência de métodos próprios (constitucionais) para essa análise, ou se esses métodos podem ser os mesmos utilizados pela hermenêutica jurídica.

A interpretação constitucional consiste num processo intelectual por meio do qual enunciados linguísticos que compõem a constituição transformam-se em normas (princípios e regras constitucionais), isto é, adquirem conteúdo normativo.

Segundo Amandino Teixeira Nunes Junior¹³, citando Paulo Bonavides¹⁴ destaca três métodos de interpretação constitucional: **a) método integrativo ou científico-espiritual; b) método tópico; c) método concretista.**

Método integrativo ou científico-espiritual: O *método integrativo ou científico-espiritual* foi desenvolvido por juristas alemães, capitaneado por Rudolf Smend. Na doutrina de Rudolf Smend, a base

¹³ Citado por NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. A moderna interpretação constitucional. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 7, n. 60, 1 nov. 2002. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/3497>>. Acesso em: 1 jun. 2015.

¹⁴ BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Malheiros, 1994, pág. 424

de valoração, vale dizer, os valores expressos e tutelados pela Constituição (econômicos, sociais, políticos e culturais) operam como valores de interpretação coletivos dos cidadãos e, destarte, devem ser compreendidos e aplicados.

A concepção de Smend é precursoramente sistêmica e espiritualista: vê na Constituição um conjunto de distintos fatores integrativos com distintos graus de legitimidade. Esses fatores são a parte fundamental do sistema, tanto quanto o território é a sua parte mais concreta. O intérprete constitucional deve prender-se sempre à realidade da vida, à "concretude" da existência, compreendida esta, sobretudo pelo que tem de espiritual, enquanto processo unitário e renovador da própria realidade, submetida à lei de sua integração.

Método tópico: Foi desenvolvido pelos juristas alemães Theodor Viehweg e Josef Esser. A primeira obra sobre o assunto, denominada "Tópica e Jurisprudência", de autoria de Viehweg, foi publicada em 1953.

O *método tópico* caracteriza-se como uma "arte de invenção" e, como tal, uma "técnica de pensar o problema", elegendo-se o critério ou os critérios recomendáveis para uma solução adequada.

Da tópica clássica, concebida como uma simples técnica de argumentação, a corrente restauradora, encabeçada por aquele jurista de Mogúncia, compôs um método fecundo de tratar e conhecer o problema por via do debate e da descoberta de argumentos ou formas de argumentação que possam, de maneira relevante e persuasiva, contribuir para solucioná-lo satisfatoriamente.

A principal crítica feita ao *método tópico* é a de que "além de poder conduzir a um casuísmo sem limites, a interpretação não deve partir do problema para a norma, mas desta para os problemas." Com a tópica, a norma e o sistema perdem o primado: são rebaixados à condição de meros pontos de vista, cedendo lugar à hegemonia do problema.

Método concretista: Foi desenvolvido por três juristas alemães Konrad Hesse, Friedrich Müller e Peter Häberle. Cada um deles ofereceu valiosos contributos para o desenvolvimento desse método.

O *método concretista* gravita em torno de três elementos essenciais: a *norma que vai concretizar*, a *compreensão prévia do intérprete* e o *problema concreto a solucionar*.

Como salienta Paulo Bonavides:

"Os intérpretes concretistas têm da Constituição normativa uma concepção diferente daquela esposada pelos adeptos de outros métodos, porquanto não consideram a Constituição um sistema hierárquico-axiológico, como os partidários da interpretação integrativa ou científico-espiritual, nem como um sistema lógico-sistemático, como os positivistas mais modernos. Ao contrário, rejeitam o emprego da ideia de sistema e unidade da Constituição normativa, aplicando um "procedimento tópico" de interpretação, que busca orientações, pontos de vista ou critérios-chaves, adotados consoante a norma e o problema a ser objeto de concretização. É uma espécie de metodologia positivista, de teor empírico e casuístico, que aplica as categorias constitucionais à solução direta dos problemas, sempre atenta a uma realidade concreta, impossível de conter-se em formalismos meramente abstratos ou explicar-se pela fundamentação lógica e clássica dos silogismos jurídicos"

Método concretista de Konrad Hesse: O *método concretista* de Konrad Hesse parte da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. Para Hesse, o teor da norma só se completa no ato interpretativo. A concretização da norma pelo intérprete pressupõe uma compreensão desta; essa compreensão pressupõe uma pré-compreensão.

Como lembra Lenio Luiz Streck¹⁵:

"Assim, partindo de Gadamer, Hesse mostra como o momento da pré-compreensão determina o processo de concretização: a concretização pressupõe a compreensão do conteúdo do texto jurídico a concretizar, a qual não cabe desvincular nem da pré-compreensão do intérprete nem do problema concreto a solucionar. O intérprete não pode captar o conteúdo da norma desde o ponto de vista quase arquimédico situado fora da existência histórica, senão unicamente desde a concreta situação histórica na qual se encontra, cuja elaboração (maturidade) conformou seus hábitos mentais, condicionando seus conhecimentos e seus pré-juízos."

¹⁵ STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica Jurídica (em) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito*. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, pág. 244.

Para Hesse, a concretização e a compreensão só são possíveis em face do *problema concreto*, de forma que a determinação do sentido da norma constitucional e a sua aplicação ao caso concreto constituem um processo unitário.

Método concretista de Friedrich Müller: O *método concretista* de Friedrich Müller tem sua base medular ou inspiração maior na tópica, a que ele faz alguns reparos, modificando-a em diversos pontos para poder chegar aos resultados da metodologia proposta.

Para Friedrich Müller, o texto de um preceito jurídico positivo é apenas a parte descoberta do iceberg normativo, que, depois de interpretado, transforma-se no *programa normativo*.

Além do texto, a norma constitucional compreende também um *domínio normativo*, isto é, pedaço da realidade concreta, que o programa normativo só parcialmente contempla.

Segundo Friedrich Müller, a norma constitucional não se confunde com o texto da norma. Ela é mais que isso: é formada pelo programa normativo e pelo domínio normativo. De sorte que a interpretação ou concretização de uma norma transcende a interpretação do texto, ao contrário, portanto do que acontece com os processos hermenêuticos tradicionais no campo jurídico.

Método concretista de Peter Häberle: A construção teórica de Häberle parece desdobrar-se através de três pontos principais: o primeiro, o alargamento do círculo de intérprete da Constituição; o segundo, o conceito de interpretação como um processo aberto e público; e, finalmente, o terceiro, ou seja, a referência desse conceito à Constituição mesma, como realidade constituída e "publicização". No processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com *numerus clausus* de intérpretes da Constituição.

Sendo a hermenêutica constitucional uma hermenêutica de princípios, é inegável que o ponto de partida do intérprete há de ser os princípios constitucionais, que "são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma resumida, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. No tópico seguinte vamos estudar os princípios constitucionais, indispensáveis para a interpretação.

Podemos destacar ainda como outros métodos de interpretação das normas constitucionais:

Método Jurídico (hermenêutico clássico): Para os que se valem desse método, a Constituição deve ser encarada como uma lei e, assim, todos os métodos tradicionais de hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa, valendo-se dos seguintes elementos de interpretação:

- elemento genético: busca investigar as origens dos conceitos utilizados pelo legislador;
- elemento gramatical ou filosófico: também chamado de literal ou semântico a análise se realiza de modo textual e literal;
- elemento lógico: procura a harmonia lógica das normas constitucionais;
- elemento semântico: busca a análise do todo;
- elemento histórico: analisa o projeto de lei, a sua justificativa, exposição de motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e psicológicas que resultaram na elaboração da norma;
- elemento teleológico ou sociológico: busca a finalidade da norma;
- elemento popular: a análise se implementa partindo da participação da massa, dos "corpos intermediários", dos partidos políticos, sindicatos, valendo-se de instrumentos como o plebiscito, referendo, *recall*, veto popular etc.;
- elemento doutrinário: parte da interpretação feita pela doutrina;
- elemento evolutivo: segue a linha da mutação constitucional.

Método normativo-estruturante: Neste método, defendido por Müller, a ideia é que o conceito de norma constitucional constitui-se muito mais amplo, por conseguinte abrangente, vislumbrando-se sobre dúbia perspectiva:

a) norma constitucional – enquanto texto normativo – mostra-se produto da interpretação, entendida como atividade mediadora e concretizadora de finalidades; e

b) norma constitucional inserida no âmbito normativo concebe a ideia de que o cidadão possui o lido direito de não asilar atos abusivos oriundos do poder público.

O desenvolvimento de novos métodos interpretativos das normas constitucionais, no entanto, justifica uma exegética singularizada, porquanto as normas constitucionais possuem ampla abertura

(coloquialidade), à qual permite dilatação semântica, o que compele o exegeta a buscar o sentido que melhor se adequa a situações específicas.

Método da comparação constitucional: A interpretação dos institutos se implementa mediante comparação nos vários ordenamentos. Estabelece-se, assim, uma comunicação entre as várias Constituições. Partindo dos 4 métodos ou elementos desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, histórico e sistemático), Peter Häberle sustenta a canonização da comparação constitucional como um quinto método de interpretação.

MÉTODO CONCRETISTA DE KONRAD HESSE	MÉTODO CONCRETISTA DE FRIEDRICH MÜLLER	MÉTODO CONCRETISTA DE PETER HÄBERLE
O teor da norma só se completa no ato interpretativo. A concretização da norma pelo intérprete pressupõe uma compreensão desta; essa compreensão pressupõe uma pré-compreensão. A concretização e a compreensão só são possíveis em face do <i>problema concreto</i>, de forma que a determinação do sentido da norma constitucional e a sua aplicação ao caso concreto constituem um processo unitário. A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinação da situação. Não existe interpretação constitucional desvinculada dos problemas concretos.	Tem sua base medular ou inspiração maior na tópica, a que ele faz alguns reparos, modificando-a em diversos pontos para poder chegar aos resultados da metodologia proposta. O texto de um preceito jurídico positivo é apenas a parte descoberta do iceberg normativo. Além do texto, a norma constitucional compreende também um <i>domínio normativo</i>, isto é, pedaço da realidade concreta, que o programa normativo só parcialmente contempla. A norma constitucional não se confunde com o texto da norma. Ela é mais que isso: é formada pelo programa normativo e pelo domínio normativo. A normatividade constitucional consiste no efeito global da norma com seus dois componentes (<i>programa normativo</i> e <i>domínio normativo</i>), no processo de concretização, que só se completa quando se chega à norma de decisão, isto é, à norma aplicável ao caso concreto	A construção teórica de Häberle parece desdobrar-se através de três pontos principais: a) o alargamento do círculo de intérprete da Constituição; b) o conceito de interpretação como um processo aberto e público; c) a referência desse conceito à Constituição mesma, como realidade constituída. Propõe-se: no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com <i>numerus clausus</i> de intérpretes da Constituição. Interpretação constitucional coisa de uma sociedade fechada. Dela tomam parte apenas os intérpretes jurídicos "vinculados às corporações" e aqueles participantes formais do processo constitucional. A interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade. Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade.

Princípios:

Além dos métodos de interpretação, a doutrina destaca alguns princípios específicos de interpretação:

Princípio da unidade da constituição: Na conformidade desse princípio, as normas constitucionais devem ser consideradas não como normas isoladas e dispersas, mas sim integradas num sistema interno unitário de princípios e regras.

Princípio da concordância prática ou da harmonização: Formulado por Konrad Hesse, esse princípio impõe ao intérprete que os bens constitucionalmente protegidos, em caso de conflito ou concorrência, devem ser tratados de maneira que a afirmação de um não implique o sacrifício do outro, o que só se alcança na aplicação ou na prática do texto.

Princípio da força normativa da constituição: Também formulado por Konrad Hesse, esse princípio estabelece que, na interpretação constitucional, deve-se dar primazia às soluções ou pontos de vista que, levando em conta os limites e pressupostos do texto constitucional, possibilitem a atualização de suas normas, garantindo-lhes eficácia e permanência.

Princípio do efeito integrador: De acordo com esse princípio, na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deve-se dar prioridade às interpretações ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e possibilitem o reforço da unidade política, porquanto essas são as finalidades precípua da Constituição. Assim, partindo de conflitos entre normas constitucionais, a interpretação deve levar a soluções pluralisticamente integradoras.

Princípio da máxima efetividade: Segundo esse princípio, na interpretação das normas constitucionais, deve-se atribuir-lhes o sentido que lhes empreste maior eficácia. Destarte, as normas constitucionais devem ser tomadas como normas atuais e não como preceitos de uma Constituição futura, destituída de eficácia imediata. O *princípio da máxima efetividade* significa o abandono da hermenêutica tradicional, ao reconhecer a normatividade dos princípios e valores constitucionais, principalmente em sede de direitos fundamentais. Exemplo: art. 37, CF – direito de greve dos funcionários públicos. Recentemente o STF decidiu sobre a matéria, reconhecendo que o direito não pode ser sonegado diante da omissão legislativa, prevendo a aplicação do direito de greve dos funcionários utilizando as regras do direito de greve no âmbito privado.

Princípio da supremacia constitucional: consiste em considerar a Constituição como o conjunto de normas fundamentais de um dado sistema jurídico. É a *lex fundamentalis*. Supremacia da CF também em sentido axiológico.

Princípio da presunção de constitucionalidade: presunção de legitimidade dos atos do poder público, tendo o intérprete que partir da premissa de que os atos do poder público são compatíveis com a CF. Evidentemente essa presunção não é absoluta, é relativa *iuris tantum*.

Princípio da interpretação conforme a constituição: A aplicação do *princípio da interpretação conforme a Constituição* só é possível quando, em face de normas infraconstitucionais polissêmicas ou plurissignificativas, existem diferentes alternativas de interpretação, ou seja, o texto permite extraírem-se interpretações diversas, umas em desconformidade e outras de acordo com a Constituição, sendo que estas devem ser preferidas àquelas. Entretanto, na hipótese de se chegar a uma interpretação manifestamente contrária à Constituição, impõe-se que a norma seja declarada inconstitucional.

Princípio da razoabilidade: Também chamado de postulado da razoabilidade, informa a busca de interpretações mais justas porque adequadas, necessárias e proporcionais, para servir na solução do conflito entre princípios, ajudando o intérprete na ponderação de bens e interesses. Esse princípio se divide em três dimensões: a) Adequação (utilidade – é a adequação entre meios e fins); b) Necessidade (vedação do excesso – dever de buscar restringir o mínimo possível os direitos fundamentais); c) Proporcionalidade (significa correlação entre custo e benefício).

Limites:

A Jurisdição constitucional refere-se à atividade dos juízes de interpretar e aplicar a Constituição. Não se trata apenas de questões que envolvam o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, mas, também, daquelas em que a Constituição seja aplicada diretamente para a solução de litígios.

A indicação do Estado Democrático de Direito como o paradigma do Novo Constitucionalismo implica uma tensão entre jurisdição e legislação, pois que **“as normas constitucionais não podem ser**

interpretadas sem o recurso a valorações políticas: tais valorações, porém, são sempre, até em determinado ponto, subjetivas¹⁶. Nesse cenário, decisões políticas importantes cada vez mais se deslocam do âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, caminhando para o âmbito do Poder Judiciário, o que para muitos significa o início de um “governo dos juízes”.

Toda essa onipotência judicial faz surgir a discussão a respeito da legitimidade democrática da jurisdição constitucional, na medida em que decisões de um Poder não eleito pelo povo se sobrepõem a decisões de órgãos representativos da vontade popular. De acordo com Alexandre de Moraes, **“a jurisdição constitucional retira sua legitimidade formalmente da própria Constituição e materialmente da necessidade de proteção ao Estado de Direito e aos Direitos Fundamentais”**¹⁷.

Diante do Novo Constitucionalismo, compete ao intérprete construir a norma adequada para a solução do caso concreto. Todavia, essa atividade não é totalmente livre. Nesse contexto, faz-se necessária a análise do processo hermenêutico, em especial no que tange aos limites da interpretação constitucional.

A interpretação constitucional parte de um texto, sendo ele um importante limite à atividade hermenêutica. O próprio texto constitucional funciona como uma barreira para os excessos de interpretação. Assim, quanto mais preciso for o enunciado, menor será o espaço de discricionariedade judicial, minimizando as possibilidades de interpretações válidas. Por outro lado, quanto menos preciso o texto, maiores serão as chances de múltiplas interpretações. Outro limite à interpretação constitucional é o espírito da Constituição, ou seja, a interpretação de um dispositivo, além de não poder ser contrária ao seu próprio texto, também deve observar os demais preceitos constitucionais. Isso decorre do princípio de unidade da Constituição.

Assim, de acordo com Lenio Streck¹⁸, **“o papel da jurisdição é o de levar adiante a tarefa de construir interpretativamente, com a participação da sociedade, o sentido normativo da Constituição e do projeto de sociedade democrática a ela subjacente”**. O autor destaca ainda que a jurisdição constitucional não pode ser entendida como uma substituição do poder constituinte pelo Poder Judiciário, ideia que violaria a própria noção de democracia. **“Um tribunal não pode paradoxalmente subverter a Constituição sob o argumento de a estar garantindo ou guardando”**.



8 Princípios e regras jurídicas. Ponderação. Modelos e críticas.

As normas jurídicas podem ser princípios ou regras. Tanto as regras como os princípios devem ser compreendidos como normas porque ambos dizem o que deve ser. Segundo Robert Alexy, entre regras e princípios existe não somente uma diferença de grau, mas uma diferença qualitativa.¹⁹

Diferenças entre princípios e regras:

a) Quanto ao conteúdo: os princípios são mandados de otimização e regras são mandados de definição. **Mandados de definição: as regras são descritivas; mandados de otimização: os princípios são parâmetros de aplicação das próprias regras.**

b) Quanto à estrutura linguística: princípios possuem um maior grau de abstração e generalidade. O princípio revela um valor ou um fim público.

¹⁶ Cfe. Bachof, Otto. Estado de Direito e Poder Político. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. LVI. Coimbra, Coimbra Editora, 1996, p. 10.

¹⁷ ALEXANDRE DE MORAES, Legitimidade da Justiça Constitucional. Disponível em: <http://www.sedep.com.br/?idcanal=24171>. Acesso em 16/06/2015.

¹⁸ STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. A nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da legitimidade da jurisdição constitucional.

¹⁹ Robert Alexy. La teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

c) Quanto ao compromisso histórico: os princípios são, para muitos, em maior ou menor medida, universais, absolutos, objetivos e permanentes, ao passo que as regras se caracterizam de forma bastante evidente pela contingência e relatividade de seus conteúdos, dependendo do tempo e lugar.

d) Quanto à aplicação: as regras têm aplicação “tudo ou nada”. Segundo Dworkin as regras têm aplicação “all or nothing”. Os princípios podem ser aplicados a um mesmo fato. Mais de um princípio pode incidir sobre o mesmo fato, ao contrário das regras.

e) Quanto ao efeito: as regras têm efeito delimitado pelo enunciado, os princípios têm uma relativa indeterminação de efeitos.

f) Quanto à função no ordenamento jurídico: a regra tem como função determinar situações fáticas e suas consequências jurídicas (mandado de definição). Já os princípios são multifuncionais, eles têm função nomogenética (os princípios orientam a elaboração das regras). O princípio tem função exegética. A função sistêmica do princípio significa que este é utilizado como fator de harmonização. A função integrativa do princípio é a função de colmatação de lacunas.

g) Quanto aos valores protegidos: os princípios buscam a proteção de um valor, que é a realização da justiça. Já as regras atentam para a segurança jurídica. A regra obedece ao binômio objetividade-previsibilidade. Previsibilidade: devem ser previamente elaboradas; objetividade: devem estar ao acesso de todos. Nem sempre, entretanto, as regras trazem algum valor, há regras simplesmente amorais.

Muitas vezes, com base nos princípios constitucionais, os tribunais invalidam leis e atos do poder executivo, gerando a crítica ao denominado contramajoritarismo. É também em respeito aos princípios constitucionais que todos os ramos do direito devem se conformar ao texto da constituição, surgindo a filtragem constitucional ou, como alguns autores a denominam, a constitucionalização do direito. Nesse novo modelo de ordenamento com a efetivação da Jurisdição Constitucional, toda norma infraconstitucional deverá ser interpretada e aplicada à luz da constituição, não podendo afrontar normas e princípios nela previstos.

É com base em princípios e cláusulas abertas como o da dignidade da pessoa humana, moralidade, dentre outros, que o **STF** tem sido provocado para se manifestar sobre a constitucionalidade de diversos temas avaliados como polêmicos pela opinião pública, como: pesquisas com células-tronco, aborto, dentre tantos outros.

Ponderação. Modelos e críticas.

O enquadramento da ponderação diante da abrangência atual acerca de novos parâmetros da interpretação jurídica. Quando duas regras estão em confronto, como elas não podem ser ponderadas, a solução seria a ponderação entre os princípios subjacentes às regras; esses princípios é que devem ser ponderados, mas as regras não podem ser ponderadas, porque elas não são dotadas de dimensão e peso.

Humberto Ávila admite a ponderação entre dois princípios; duas regras; ou, uma regra e um princípio. Uma vez que a regra, apesar de ser um comando mais duro, ainda assim, tem algum espaço de otimização, para ele. E a doutrina nacional hoje está dividida, pois a maioria afirma que as regras não podem ser ponderadas.

A Ponderação de Interesses para uns é um princípio instrumental da Hermenêutica Constitucional. A Ponderação de Interesses faz parte da classificação instrumental dos princípios constitucionais. Para outros, a Ponderação de Interesses é um postulado normativo.

São características da ponderação de interesses:

- a) É um método subsidiário aos métodos do positivismo jurídico;
- b) É utilizado para solução dos denominados casos difíceis (*hard cases*);
- c) É utilizado para a solução de casos concretos, e seu resultado pode ser alterado pela mudança fática;

d) Da Ponderação de Interesses resulta a aplicação de uma norma em conflito, com a aplicação da norma que se revelar mais forte do que outra diante do caso concreto.

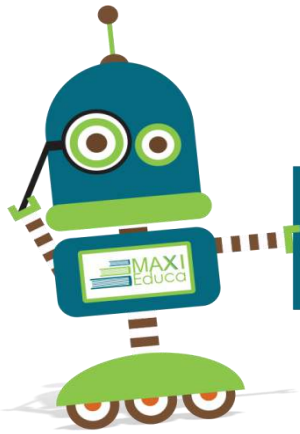
Hoje está bem consolidado que a Ponderação de Interesses deve ser aplicada a partir de fatos, há uma técnica de aplicação da Ponderação de Interesses. Então existem **três fases de aplicação** dessa técnica:

- a) Fase de identificação das normas em conflito;
- b) Fase de identificação dos fatos relevantes no caso;
- c) Fase da análise crítica dos fatos.

A técnica da ponderação dos interesses é alvo de muitas críticas, pois leva a um subjetivismo muito grande. **Uma das formas de se mitigar essa verdade do subjetivismo é o exercício de uma fundamentação mais profunda, demonstrando como o magistrado chegou a determinado**

raciocínio jurídico. Outra importante crítica recai sobre a banalização da ponderação de interesses. E isso de fato tem ocorrido. Como visto nas características do princípio instrumental, ele deve ser aplicado subsidiariamente. Entretanto, muitas vezes os tribunais já vão direto aos princípios como forma de resolver casos concretos, ignorando que existem regras de direito positivadas para aquele caso concreto.

O Juiz, antes de aplicar o método da Ponderação de Interesses, sabendo que é um método subsidiário, deve tentar aplicar os métodos positivistas. Primeiro, o método da hierarquia, depois, o método da especialidade, por fim, o método temporal.



9 Poder constituinte.

Poder Constituinte é o poder de elaborar uma nova Constituição, bem como de reformar a vigente. A palavra “poder” deve sempre ser entendida como a faculdade de impor, de fazer prevalecer a sua vontade em relação a outras pessoas. É poder constituinte, pois, estabelece uma nova ordem jurídica fundamental para o Estado. O poder constituinte pertence ao povo, que o exerce por meio dos seus representantes (Assembleia Nacional Constituinte). Observem o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal (CF):



Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Tendo em vista que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário são poderes constituídos, podemos concluir que existe um poder maior que os constitui; o Poder Constituinte. Assim, a Constituição Federal é fruto de um poder distinto daqueles que ela institui.

Características.

Quanto à natureza jurídica, duas são as principais correntes a respeito, são elas:

Juspositivista (Kelsen): o poder constituinte é um poder histórico, de fato, ele simplesmente existe, ou seja, não se funda numa ordem jurídica superior. Ele inaugura toda a normatização jurídica, não derivando de outro direito superior, sendo considerado um poder político.

Jusnaturalista (Tomás de Aquino, Sieyès): O poder constituinte é a fonte magnânima de todo o direito formal de um ordenamento jurídico.

O fundamento de validade do poder constituinte estaria no direito natural, que é superior hierarquicamente ao poder constituinte, ou seja, ele existe por força do sistema de direito natural; os adeptos reconhecem no Poder Constituinte a natureza extrajurídica, já que Direito não seria só norma. Foi a partir de Sieyès que a distinção formal entre poder constituinte e poderes constituídos se consolidou em termos definitivos.

Titularidade e Exercício do Poder Constituinte

A distinção sobre a titularidade do poder constituinte originário também é explicada por duas correntes doutrinárias:

1ª) Titular do poder constituinte é a nação: Emmanuel Sieyès defende que o poder constituinte é um poder nacional. O poder é da nação, definida como um conjunto de valores compartilhados em uma determinada sociedade. Para Sieyès, nação não é um conjunto de indivíduos, não é uma coletividade de pessoas, mas um conjunto de valores morais compartilhados. A Nação preexiste a qualquer forma constitucional, antes de tudo, é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, porque é a própria lei, só existindo acima dela o direito natural.

2ª) Titular do poder constituinte é o povo: é a ideia do Jean Jacques Rousseau. A origem popular do poder constituinte originário. O povo como um coletivo de pessoas cidadãos, comprometidas com aquela sociedade.

Hodiernamente considera-se o conceito de povo como titular do poder constituinte, por ser um conceito mais amplo, incluindo todos os nacionais que habitam em determinado território, independentemente de identidade de língua e de cultura.

A CF/88 expressamente declara: *“todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”* (art. 1º, p. único)²⁰ e seu exercício cabe à Assembleia Constituinte.

Poder constituinte originário.

Também é denominado de poder genuíno ou poder de 1º grau ou poder inaugural. É aquele capaz de estabelecer uma nova ordem constitucional, isto é, de dar conformação nova ao Estado, rompendo com a ordem constitucional anterior.

- **Histórico:** É aquele capaz de editar a primeira Constituição do Estado, isto é, de estruturar pela primeira vez o Estado.

- **Revolucionário:** São todos aqueles posteriores ao histórico, que rompem com a ordem constitucional anterior e instauram uma nova.

Trata-se de um poder de fato, de caráter absoluto, pois não está condicionado a qualquer limitação de ordem jurídica. É ele que estabelece a ordem fundamental do Estado. Em tese, pode dispor sobre qualquer assunto, da forma que melhor entender.

Não é possível alegar a violação de direito adquirido perante dispositivo emanado do poder constituinte originário, tendo em vista o seu caráter absoluto, que não encontra qualquer limitação de ordem jurídica, conforme bem evidencia o art.17 do Ato de Disposições Transitórias da Constituição.

Alguns autores defendem a distinção entre o poder constituinte material e o poder constituinte formal, sendo que o primeiro precederia o segundo.

Poder constituinte material é aquele poder de auto-organização do Estado, resultante das forças políticas dominantes em determinado momento histórico. O poder constituinte formal é o órgão que elabora o novo texto constitucional.

Com isso, podemos dizer que **o poder constituinte originário** é:

- a) inicial**, pois dá origem a uma nova ordem constitucional;
- b) ilimitado e autônomo**, já que não está submetido a nenhuma ordem jurídica, podendo dispor sobre qualquer assunto;
- c) incondicionado**, pois não tem fórmula preestabelecida para sua manifestação.

Cabe destacar ainda, que o Poder Constituinte Originário é caracterizado pela permanência, já que é o poder político que o povo possui para organizar o Estado e essa titularidade não se exaure no tempo.

²⁰ **Povo** é o conjunto de pessoas que têm a mesma nacionalidade, ou seja, ligação jurídica a um determinado Estado (povo é um conceito jurídico). Difere da ideia de *população* (conceito demográfico), que é a expressão numérica dos habitantes de um Estado (inclui os estrangeiros residentes) e difere da ideia de *nação* (conceito sociológico, cultural), que é o conjunto de pessoas que têm em comum fatores culturais, étnicos, históricos e/ou linguísticos. **OBS:** Povo, mas não nação: cidadãos da antiga Iugoslávia. Nação, mas não povo: os palestinos (já que a Palestina não é um Estado) e os curdos (pode-se falar em nação curda mas não em povo curdo, já que não há um Estado Curdo).

Poder constituinte derivado.

Também é denominado de poder instituído, constituído, secundário ou poder de 2º grau. É o poder de modificação da Constituição, bem como o poder do Estado-membro de uma Federação de elaborar sua própria Constituição. Abrange tanto o poder constituinte de reforma como o poder constituinte decorrente.

a) Reformador: É aquele criado pelo poder constituinte originário para reformular (modificar) as normas constitucionais. A reformulação se dá através das emendas constitucionais. O constituinte, ao elaborar uma nova ordem jurídica, desde logo constitui um poder constituinte derivado reformador, pois sabe que a Constituição não se perpetuará no tempo. Entretanto, este poder de reforma constitucional é limitado. Podendo ser as *limitações expressas* e *limitações implícitas* (assunto abordado logo).

b) Decorrente: Também foi criado pelo poder constituinte originário. É o poder de que foram investidos os Estados-membros para elaborar a sua própria constituição (capacidade de auto-organização). Os Estados são autônomos uma vez que possuem capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação, mas não são soberanos, pois devem observar a Constituição Federal. “*Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição*” (art. 25 da CF). Desta forma, o poder constituinte decorrente também encontra limitações. O exercício do poder constituinte decorrente foi conferido às Assembleias legislativas. “Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contando da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta” (art. 11 dos ADCT).

c) Revisor: Também chamado de poder anômalo de revisão ou revisão constitucional anômala ou competência de revisão. Foi estabelecida com o intuito de adequar a Constituição à realidade que a sociedade apontasse como necessária. O artigo 3º dos ADCT estabeleceu que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral (já foi realizada a revisão de nossa atual CF). O procedimento anômalo é mais flexível que o ordinário, pois neste segundo exige-se sessão bicameral e 3/5 dos votos.

O poder constituinte derivado é:

a) subordinado, pois se encontra abaixo do poder constituinte originário, limitado por este;

b) condicionado, uma vez que deve manifestar-se de acordo com o preestabelecido pelo poder constituinte originário.

Limites do Poder Constituinte Derivado

Os limites do poder constituinte derivado são estabelecidos pelo poder constituinte originário. Sempre que for feita referência a limites do poder constituinte, ela o será ao poder constituinte derivado. Podemos classificar esses limites dentro dos critérios expostos, como *limitações expressas* e *limitações implícitas*:

As primeiras estão previstas no texto constitucional, e se subdividem em três subespécies: *materiais*, *circunstanciais* e *procedimentais ou formais*. Por sua vez, os limites implícitos do poder de reforma são os que derivam dos limites expressos e se dividem em dois grupos: as normas sobre o titular do poder constituinte reformador e as disposições relativas à eventual supressão das limitações expressas.

Limitações expressas: Conforme o próprio nome aduz, são aquelas previstas textualmente pela Constituição Federal. Podem ser: **materiais, circunstanciais e procedimentais ou formais**.

- Pela **limitação material**, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.

Tais matérias formam o núcleo intangível da Constituição Federal, denominado tradicionalmente por “*cláusulas pétreas*” (art. 60, § 4º, da Constituição Federal). Importante ressaltar que o regime republicano não é tido como cláusula pétrea expressa (por não integrar o rol previsto no artigo citado). Contudo, há que se dar interpretação à Constituição no sentido de que a República é *cláusula pétrea* implícita após o

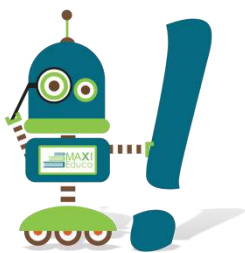
plebiscito realizado em 1993 (por força do art. 2º, do ADCT), quando ficou definido como forma de governo a republicana.

- No tocante aos **limites circunstanciais**, elas são limitações que pretendem evitar modificações na constituição em certas ocasiões anormais e excepcionais do país, a fim de evitar-se perturbação na liberdade e independência dos órgãos incumbidos da reforma, bem como a mudança precipitada em face de estados calamitosos ou de emergência. Essa limitação foi instituída a partir da Constituição de 1934, na qual não se procederia reforma da Constituição na vigência do Estado de Sítio. A Constituição de 1988 aumentou as hipóteses de que não se realizará emendas ao seu texto, ao dispor que, durante a vigência do Estado de Sítio, do Estado de Defesa ou de Intervenção Federal, não haverá possibilidade de alteração constitucional.

As limitações circunstanciais não se confundem com as chamadas *limitações temporais*, não consagradas por nossa Constituição Federal e que consiste na vedação, por determinado lapso temporal, de alterabilidade das normas constitucionais. Também não há previsão no nosso ordenamento de revisão do texto magno obrigatoriamente de tempos em tempos, como há na Constituição Portuguesa, na qual a cada cinco anos, ela passa por uma análise para emendas de seus dispositivos, caso seja necessário.

- Com relação à **limitação procedimental ou formal**, estas referem-se às disposições especiais, em relação ao processo legislativo ordinário, que o legislador constituinte estabeleceu para permitir a alteração da Constituição Federal. Trata-se de procedimento mais gravoso do que para as demais espécies normativas serem produzidas, até mesmo porque o objeto que se estará elaborando diz respeito à Constituição da República e não a uma simples lei ordinária ou complementar.

A iniciativa para apresentação de uma proposta de emenda constitucional é mais restrita do que a existente no processo legislativo ordinário. Isto porque, para a feitura de uma lei ordinária ou complementar, exige-se apenas que um membro ou uma comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ou que o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República, e os cidadãos deflagrem o processo legislativo, ao teor do art. 61, da Constituição Federal:



Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

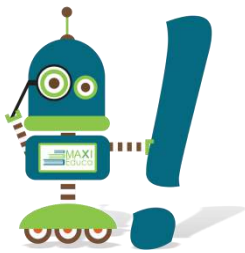
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Já para a elaboração de uma emenda faz-se necessário o início do processo pelo Presidente da República, ou por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou, ainda, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros (art. 60, incs. I, II e III, da Constituição Federal):



Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

A respeito da iniciativa disposta no inc. I, do art. 60, exige-se, da parte do parlamentar que a deseja propor, intenso trabalho de articulação, de transferência da própria convicção para seu par, a fim de que aqueles que estejam dispostos a apoiá-la venham a assinar a proposição. Isso difere da hipótese prevista no inc. II, na qual o Chefe do Executivo é o único com a faculdade de iniciativa que apenas depende de si próprio, tendo, sobre qualquer parlamentar o privilégio de não necessitar de composição ou poder de cooperação para apresentar a sua emenda. Por óbvio, claro está que, para a aprovação de sua proposta, necessário será uma precisa articulação no Congresso Nacional. Contudo, em tese, para a deflagração do processo o Presidente parte com vantagem em face dos Parlamentares.

Desta forma, demonstrado está a maior dificuldade para a deflagração do processamento de emendas constitucionais do que de leis ordinárias ou complementares.

A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60, § 2º, da Constituição Federal). Dessa forma, ressalte-se o quórum diferenciado para aprovação, bem como a necessidade de dupla votação em cada Casa Legislativa. Não existe participação do Presidente da República na fase constitutiva do processo legislativo de uma emenda constitucional, uma vez que o titular do poder constituinte derivado reformador é o Poder Legislativo. Assim, não haverá necessidade de sanção ou veto.

A emenda constitucional aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional seguirá, diretamente, à fase complementar, para promulgação e publicação (art. 60, § 3º, da Constituição Federal). A promulgação será realizada, conjuntamente, pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Limitações implícitas: Controvertido o tema de existir ou não limites implícitos no texto constitucional brasileiro ou, mesmo que não disposto no texto magno, implícito ao próprio sistema constitucional vigente defendido pelos doutrinadores.

Na lição ministrada por Alexandre de Moraes²¹: ***“Canotilho refere-se a certas garantias que pretendem assegurar a efetividade das cláusulas pétreas como limites tácitos para aduzir que, às vezes, as Constituições não contêm quaisquer preceitos limitativos do Poder de revisão, mas entende-se que há limites não articulados ou tácitos, vinculativos do poder de revisão. Esses limites podem ainda desdobrar-se em limites textuais implícitos, deduzidos do próprio texto constitucional, e limites tácitos imanentes numa ordem de valores pré-positiva, vinculativa da ordem constitucional concreta.***

A existência de limitação explícita e implícita que controla o Poder Constituinte derivado-reformador é, igualmente, reconhecida por Pontes de Miranda e Pinto Ferreira, que, entre outros doutrinadores, defendem a imutabilidade do dispositivo que garante o núcleo intangível da Constituição (art. 60, § 4º, da Constituição Federal), pois, se diferente fosse, a proibição expressa poderia desaparecer, para, só posteriormente, ser alterada as cláusulas pétreas. Além disto, observa-se a inalterabilidade do titular do Poder Constituinte derivado-reformador, sob pena de também afrontar a Separação dos Poderes da República.”

Outra limitação implícita defendida pela doutrina estaria na titularidade do Poder Constituinte Derivado Reformador, que, se não protegido, poderia ser transferido a outro poder, infringindo a Separação dos Poderes da República consagrada no art. 2º, da Constituição Federal.



10 Controle de constitucionalidade: direito comparado.

O controle de constitucionalidade somente é possível em países que adotam Constituição escrita e rígida. A rigidez é consequência do princípio da Supremacia Formal da Constituição, manifestando-se por meio de seu quórum especial de modificação e do processo legislativo mais prolongado. Da mesma forma, exige-se que todo o ordenamento jurídico esteja formal e materialmente de acordo com o texto constitucional.

Para tal, necessária é a previsão de órgãos de controle constitucional, assim como mecanismos aptos à sua efetivação.

O controle de constitucionalidade permite que todo o ordenamento jurídico infraconstitucional e, inclusive, as próprias emendas constitucionais, estejam de acordo com os preceitos constitucionais.

Sistemas gerais e sistema brasileiro.

Existem quatro grandes modelos no mundo Ocidental sobre o Controle de Constitucionalidade, sendo que em um deles não há Controle de Constitucionalidade formalmente estabelecido. São os modelos: **inglês, francês, austríaco-alemão, e o modelo norte-americano.**

a) Modelo Inglês:

O primeiro modelo é o modelo inglês. No Reino Unido, como não existe uma Constituição escrita e rígida, não se tem como estabelecer o Princípio da Supremacia Formal da Constituição. Faltando esse Princípio da Hermenêutica, não há pressuposto para o estabelecimento do controle. Só materialmente, há conceito de Constituição no Reino Unido, não há uma Constituição organizada formalmente. E como foi dito, **o Princípio da Supremacia da Constituição, é substituído pelo Princípio da Supremacia do Parlamento.**

²¹ MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 1977, página 417.

O Parlamento, no Reino Unido, deve ser bem compreendido, pelo fato de que os três órgãos de poder, tais como nós conhecemos, tem representação nesse Parlamento. Bem, para começar, o Parlamento congrega o Poder Legislativo em duas câmaras: a câmara baixa, que é a câmara dos comuns, e a câmara alta que é a câmara dos lordes. Então, o Poder Legislativo normalmente estabelecido no Parlamento Inglês. Como o Reino Unido adota o sistema de governo Parlamentarista, o gabinete, incluindo o Primeiro Ministro, é formado por parlamentares. Então, pode-se dizer, que o Poder Executivo tem representação na câmara dos comuns, uma vez que o Poder Executivo é integrado por parlamentares.

O órgão de cúpula do Judiciário Inglês é formado por lordes, e tem assento na câmara dos lordes. Então, considerando que os três órgãos de poder daquela formatação do Montesquieu, encontram assento no Parlamento Inglês, para o inglês isso é suficiente para garantir que as leis estejam adequadas com o costume e a jurisprudência dos Tribunais do Reino Unido.

No caso de a lei não estiver adequada, o instrumento é a **revogação**. Então deve ser editada uma nova lei, revogando aquela que contraria o senso comum da sociedade inglesa.

Vale registrar, no entanto, que desde 2008 os Tribunais Ingleses começaram a praticar o Controle de Validade, que não é propriamente um Controle de Constitucionalidade, porque o paradigma não é a Constituição. **O paradigma é a Carta de Direitos Humanos da Europa, é a Carta Europeia de Direitos Humanos.** Então, desde 2008, os Tribunais Ingleses têm competência para invalidar uma lei inglesa que disponha contra a Carta Europeia de Direitos Humanos. Essa prática tem sido feita na avaliação de casos concretos, e passou a inserir os Tribunais Ingleses em um tipo de jurisdição de Controle de Validade, não necessariamente de jurisdição constitucional. E algumas promulgadas pelo Parlamento Inglês já foram invalidadas a partir desse mecanismo.

Exemplo: havia uma lei inglesa, por exemplo, que possibilitava que um estrangeiro suspeito de ato terrorista e que não pudesse ser deportado por algum motivo, pudesse ficar preso sem culpa formada, sem condenação, pelo prazo que fosse necessário. É uma prisão que poderia ser uma prisão interna, sem condenação. Essa lei foi invalidada.

Outra lei invalidada desde 2008 foi uma que permitiu que os Tribunais Ingleses processassem, a partir de provas secretas que não fosse de conhecimento da defesa, pessoas suspeitas de terrorismo. Na advocacia isso é difícil, não adianta você defender alguém, sem saber as provas que estão sendo produzidas pela acusação. Bem, então **nesse modelo inglês, não há propriamente uma jurisdição constitucional.**

b) Modelo Francês:

O segundo modelo é o **modelo francês**. Por razões culturais e históricas, os franceses têm muita dificuldade de entender como pode o Juiz, que não é legitimado pelo voto, invalidar a vontade da maioria dos representantes do povo. Então, esse aspecto político é muito forte na concepção francesa contra a possibilidade do Judiciário invalidar, formalmente, uma lei já aprovada pelo Congresso Francês.

Uma das razões da dificuldade em superar esse entendimento é que historicamente, no absolutismo francês, os juízes eram meros delegatários da vontade do Imperador. Então, quem exercia o Poder Judiciário era o rei francês. Mas como ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele nomeava delegatários que eram os Juízes. Só que os Juízes Franceses, na época do absolutismo, não decidiam por vontade própria, decidiam de acordo com a vontade do rei. Essa imagem de um Juiz sem independência para julgar questões políticas é muito forte no imaginário francês.

Depois da Revolução Francesa, houve uma opção pelo sistema da Separação dos Poderes, radical, que **impede que o Judiciário analise questões de natureza política**. Essas questões, dizem os franceses, devem ser da atribuição do Poder Executivo e Poder Legislativo. **Então, o Judiciário não tem competência para invalidar leis que tenham sido aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo Presidente da República.** Para os franceses, isso seria uma invasão de atribuição e violaria o Princípio da Separação dos Poderes. Então, o que impede que a França faça um repressivo Controle de Constitucionalidade é uma alegada agressão ao Princípio da Separação dos Poderes.

A lei francesa não fica sem qualquer tipo de análise, porque os franceses estabeleceram na atual Constituição **a possibilidade de um projeto de lei, antes de ser sancionado pelo Presidente da República, ser analisado por um órgão político, que é o Conselho Constitucional.** Então, um projeto de lei antes de ser sancionado pelo Presidente da República, pode ser dirigido ao Conselho Constitucional, para que ele se pronuncie sobre a adequação daquele projeto de lei, em relação à Constituição Francesa.

É importante notar que o Conselho Constitucional não é um órgão Judiciário. O controle não é um controle judicial. O Conselho Constitucional é um órgão político, vinculado à presidência da República. Ele é integrado por nove membros, com mandato de nove anos, são três indicados pelo

Presidente da República, três pela Assembleia Nacional que faz as vezes de Câmara de Deputados no Brasil, e três pelo Senado. A cada três anos, um representante de cada indicado, indicado pelo Presidente, Assembleia, ou pelo Senado, toma posse. Então, a cada três anos é uma renovação de 1/3 dos membros do Conselho.

Além desses nove membros, os ex-Presidentes da República, têm assento vitalício no Conselho, apesar de que, na prática, nunca nenhum ex Presidente exerceu essa atribuição. Desde 1958, nunca nenhum ex-Presidente da República Francesa, ocupou o assento que poderia ter ocupado, no Conselho Constitucional.

O Conselho Constitucional faz esse tipo de atividade, analisa a validade do projeto de lei, ele também serve como Justiça Eleitoral na França. Na França não há um TSE, um TRE. Quem faz o controle da eleição é o Conselho Constitucional, quem pronuncia o vencedor da eleição é o Conselho Constitucional, quem dá posse ao Presidente da República é o Conselho Constitucional. Então ele tem um papel político muito importante.

Tecnicamente, essa verificação tem natureza de **Controle de Constitucionalidade Preventivo Político**. É um controle político, porque não é exercido pelo Poder Judiciário. É um controle preventivo, porque é realizado antes do aperfeiçoamento da lei, enquanto ela ainda é um projeto.

A provocação do Conselho Constitucional, não pode ser feita por qualquer um, pode ser feita pela Assembleia e pelo Senado, como substituição mínima do número de Deputados e Senadores. E pode ser também feita pelo Presidente da República. Se o Conselho Constitucional se pronunciar pela validade do projeto de lei, ele mesmo assim pode ser negado pelo Presidente da República, por motivo de falta de relevância do projeto. Mas, se o Conselho Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade do projeto, o Presidente da República não pode sancionar. Então, o pronunciamento do Conselho é parcialmente vinculante.

A partir da Reforma Constitucional 724/08, a França passou a contar com um sistema repressivo de controle de constitucionalidade. O conselho constitucional foi autorizado a declarar a inconstitucionalidade de normas que atentem contra direitos e liberdades garantidos pela Constituição francesa, mediante provocação do conselho de estado ou corte de cassação. Ademais, inclui-se um mecanismo análogo à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

c) Modelo Norte-Americano:

O terceiro modelo é o **modelo norte-americano**. A principal característica do constitucionalismo norte-americano, a principal contribuição que os Estados Unidos deram para a ciência política, foi a **Supremacia da Constituição**. Para os norte-americanos, a Constituição tem supremacia. Isso é algo muito claro na organização política norte-americana, a Constituição está acima dos demais atos do ordenamento jurídico.

O primeiro caso judicial em que uma Suprema Corte, no caso a Suprema Corte norte-americana, afirmou seu poder de exercer o controle de constitucionalidade foi em **Marbury v. Madison**²².

Em 1800, nas eleições presidenciais realizadas nos Estados Unidos, o então presidente federalista John Adams foi derrotado pela oposição republicana, perdendo representação tanto na esfera Legislativa quanto Executiva, sendo Thomas Jefferson o novo presidente. Com o intuito de manter sua influência política no Poder Judiciário, os federalistas, antes do término do mandato de John Adams, aprovaram uma lei de reorganização do Judiciário federal - *The Circuit Court Act*, visando reduzir o número de Ministros da Suprema Corte, impedindo que o presidente sucessor, Thomas Jefferson, nomeasse novos Ministros após a aposentadoria dos atuais.

Em seguida, nova lei - *the Organic Act of the District of Columbia* autorizou o presidente a nomear quarenta e dois juízes de paz, sendo todos confirmados pelo Senado na véspera da posse de Thomas Jefferson. Como ainda era presidente, em seu último dia efetivo, John Adams assinou os atos de investidura dos novos juízes de paz nomeados, cabendo ao seu Secretário de Estado, John Marshall, entregá-los. Em meio às pressões de final de mandato e sem tempo de entregar todas as nomeações, John Marshall não conseguiu concluir a sua tarefa e alguns juízes nomeados ficaram sem receber o ato de investidura, pois havia sido nomeado como presidente da Suprema Corte.

Ao tomar posse, Thomas Jefferson indicou como seu Secretário de Estado James Madison, a quem caberia continuar a entrega dos atos de investidura. No entanto, por designação do próprio presidente, o Secretário Madison recusou-se a entregar os atos faltantes. Dentre os juízes não empossados no cargo

²² Informações extraídas de Dimoulis, Dimitri. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais/Dimitri Dimoulis, Soraya Lunardi. --São Paulo: Atlas, 2011. pp. 33 - 46 e Barroso, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência / Luís Roberto Barroso - 3. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2008. pp. 3 -10.

estava William Marbury, que buscou ver seu direito judicialmente garantido, por meio de propositura de ação judicial - writ of mandamus. No meio tempo, os novos integrantes do Congresso, de maioria republicana, revogaram a lei de reorganização do Judiciário federal aprovada pelo presidente John Adams, extinguindo os cargos de juízes de paz criados e destituindo seus ocupantes. O pedido formulado por Marbury foi apreciado pela Suprema Corte, já em meio a um contexto politicamente conturbado, pois o presidente da Corte era o antigo Secretário de Estado, Marshall.

"O caso Marbury v. Madison foi a primeira decisão na qual a Suprema Corte afirmou seu poder de exercer o controle de constitucionalidade, negando aplicação a leis que, de acordo com sua interpretação, fossem inconstitucionais. Assinale-se, por relevante, que a Constituição não conferia a ela ou a qualquer outro órgão judicial, de modo explícito, competência dessa natureza."²³

Ao julgar o caso, a Suprema Corte buscou demonstrar que a inconstitucionalidade da lei não era a única cabível, visto que poderia ser reconhecida a incompetência da Corte ou o descabimento do writ of mandamus por outras razões, atribuição que decorreria logicamente do sistema. No voto elaborado por Marshall, a argumentação para indeferir o pedido de Marbury vinha da discussão da natureza das categorias de atos do Executivo, ou seja, que não eram passíveis de revisão judicial, sendo estes atos de natureza política e atos que a Constituição ou a lei houvessem atribuído a sua exclusiva discricionariedade. Deste modo, Marshall ainda enunciou três grandes fundamentos que justificam o controle de constitucionalidade, como segue: (i) a supremacia da Constituição, (ii) a nulidade da lei que contrarie a Constituição e (iii) é o Poder Judiciário o intérprete final da Constituição. De todo o modo, a decisão da Suprema Corte foi alvo de inúmeras críticas, como a influência das circunstâncias políticas no julgamento do Judiciário, vejamos o argumento de Barroso.²⁴

"Ao estabelecer a competência do Judiciário para rever os atos do Executivo e do Legislativo à luz da Constituição, era o seu próprio poder que estava demarcando, poder que, aliás, viria a exercer pelos trinta e quatro longos anos em que permaneceu na presidência da Corte. A decisão trazia, no entanto, um toque de inexcedível sagacidade política. É que as teses nela veiculadas, que em última análise davam poderes ao Judiciário sobre outros dois ramos de governo, jamais seriam aceitas passivamente por Jefferson e pelos republicanos do Congresso."

d) Modelo Austríaco-alemão:

O quarto modelo de jurisdição constitucional é o **modelo austríaco-alemão**, uma criação da genialidade do Hans Kelsen, que conseguiu convencer a Assembleia Constituinte da Áustria em adotar esse mecanismo de controle da Constituição Austríaca de 1929, e passou a figurar na Constituição Alemã logo depois da Segunda Guerra Mundial, na Lei Fundamental de Bonn em 1949.

Quando a Alemanha adota o mecanismo de Controle de Constitucionalidade idealizado por Kelsen, ele passa a ser replicado em outras Constituições, e hoje é adotado pela Constituição Espanhola, pela Constituição Portuguesa, pela Constituição Italiana, e também pela Constituição Brasileira, através de mecanismos de controle abstrato.

Kelsen imagina esse sistema de controle, já no século XX. O caso *Marbury v. Madison* é de 1801. Então, ele está observando mais de cem anos de funcionamento da jurisdição constitucional norte-americana e sabia o seguinte: a jurisdição norte-americana só dava certo porque havia estabilidade dos precedentes vinculantes. Na Áustria não se adotava o precedente vinculante, é um sistema romano-germânico de Direito, como é o brasileiro. Se uma decisão do Tribunal não necessariamente vincula um órgão inferior, haveria uma crise de constitucionalidade, se fosse dada a qualquer Juiz a possibilidade de fazer o Controle de Constitucionalidade.

Então Kelsen tem a perspicácia de verificar que a jurisdição constitucional norte-americana só dá certo por causa do sistema de precedentes vinculantes, que não seria adequado ao sistema jurídico romano-germânico. **Ele então imagina que o Controle de Constitucionalidade deve ser de atribuição exclusiva de uma Corte, a chamada Corte Constitucional** e não ser da competência difundida de qualquer Juiz ou Tribunal. Para ele, então, a competência para dirimir as questões que envolvam a jurisdição constitucional é uma competência concentrada em uma Corte que não deve ser integrada por Juízes, é uma Corte que tem natureza política, cujos integrantes devem exercer mandato. Mandato longo,

²³ Barroso, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência / Luís Roberto Barroso - 3. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2008. pp. 5.

²⁴ Op. cit. p. 9.

mas mandato. Realmente, na Europa, esse mandato varia de dez a doze anos, dependendo do país; os integrantes, então, não devem ser vitalícios.

Como o sistema jurídico é um sistema romano-germânico, as decisões devem ter efeito *erga omnes*, isto é, sua conclusão deve ser vinculante para todo o Judiciário, para todo o Legislativo, para todo o Executivo, para toda a sociedade. **Preocupado com a estabilidade das relações sociais, que podiam ter sido estabelecidas antes da declaração da inconstitucionalidade, Kelsen sustenta que a decisão pela inconstitucionalidade, deve ter efeito *ex nunc*, dali em diante. Ele se opõe, portanto, à teoria norte-americana de que o ato inconstitucional é nulo desde o início.** Para ele, a inconstitucionalidade surge com o pronunciamento da Corte.

Portanto, há uma diferença em como a escola norte-americana encara a natureza do ato inconstitucional. Para os norte-americanos, a inconstitucionalidade gera uma nulidade com efeito *ex tunc*, efeito para o passado. Para o Kelsen, a inconstitucionalidade gera efeito *ex nunc*, o efeito prospectivo, dali em diante. Para os norte-americanos, a decisão sobre inconstitucionalidade, como apenas ratifica algo que já existe, é uma decisão declaratória. O Judiciário declara a inconstitucionalidade. Para o Kelsen, como a própria decisão é fundamental para invalidar a lei, a decisão tem natureza constitutiva.

Modelo norte-americano	Ex tunc	Natureza declaratória
Modelo austríaco-alemão	Ex nunc	Natureza constitutiva

Kelsen afirma: **enquanto o Congresso cria a lei positivamente, cabe à Corte Constitucional, retirar a lei do mundo jurídico. Portanto, diz Kelsen, ela deve atuar como legislador negativo.** O legislador que não cria, mas que retira a lei do ordenamento. É o legislador ao contrário, mas cuja decisão produz efeito contra todos, abstrato, geral. Da mesma maneira que a lei produz efeito geral e abstrato, a decisão da Corte também deve produzir efeito geral e abstrato. Portanto ela é um legislador ao contrário, um legislador negativo.

Para o Kelsen, os Juízes não devem ter competência para dirimir a questão do controle. Se o Juiz se depara com a impossibilidade de decidir diante de um conflito entre normas, ele deve suspender o caso e provocar a Corte Constitucional.

O Brasil adota um sistema misto, híbrido, que mistura o modelo norte-americano e o modelo austríaco.

Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade.

Identificados os quatro grandes modelos de controle de constitucionalidade no constitucionalismo moderno, sendo eles o inglês, o americano, o austríaco e o francês, temos as principais matrizes de onde surgiram variações adaptadas a cada ordenamento jurídico, de acordo com as suas particularidades.

O modelo americano, como já demonstrado acima, pauta-se pelo controle difuso exercido por todos os juízes e tribunais, no desempenho ordinários de suas funções. O modelo austríaco, cujo marco foi a Constituição de 1920, cria um órgão próprio responsável por julgar apenas a constitucionalidade das leis, desta forma, se algum juiz de outras instâncias perceber que a matéria refere-se à inconstitucionalidade de leis, automaticamente, deverá remeter a questão à Corte Constitucional. Já, o que chama atenção no sistema francês é o seu caráter não jurisdicional e prévio, sendo exercido pelo Conselho Constitucional.

Influenciado pelos sistemas de controle de constitucionalidade americano e austríaco e diante de toda a evolução em termos de direito constitucional, o Brasil adotou um sistema de controle repressivo predominantemente judicial. Portanto, em regra, os órgãos judiciais são os competentes para averiguarem a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição Federal.

O controle jurisdicional de constitucionalidade, quanto a sua forma, é um controle misto, que abrange o controle abstrato (via de ação) e o difuso (incidental, via de exceção).



11 Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica.

Constituição do Império de 1824

Tratou-se da primeira Constituição brasileira pós independência, ocorrida aos 07 de setembro de 1822, consequência dos movimentos napoleônicos ocorridos na Europa que forçaram a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808.

O primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos da América, ferrenho defensor da liberdade de todas as colônias da América.

A Constituição de 1824 não seguiu a tradição do constitucionalismo norte-americano, mas sim do francês, no qual era muito forte a separação dos poderes. Influenciado por **Benjamin Constant**, havia aqui o **Poder Moderador**, exercido pelo monarca. Não havia controle judicial, salvo o poder absoluto do imperador de harmonizar os demais poderes.

De acordo com Pedro Lenza²⁵ “...a Constituição Imperial de 1824 não estabeleceu qualquer sistema de controle, consagrando o **dogma da soberania do Parlamento**, já que, sob a influência do direito Francês (a lei como ‘expressão da vontade geral’) e do inglês (supremacia do Parlamento), somente o Órgão Legislativo poderia saber o verdadeiro sentido da norma”.

O Poder Legislativo era delegado à Assembleia-Geral. Cabia a ela não somente fazer, suspender e revogar as leis, como também interpretá-las. O órgão judicial máximo era o **Supremo Tribunal de Justiça**, sem qualquer função expressa de controle de constitucionalidade. Tampouco formulou qualquer contribuição jurisprudencial nesse sentido.

Outro problema da Constituição de 1824 era o modelo semirrígido adotado, no qual nem todas as matérias previstas na Carta eram materialmente constitucionais. **O guardião da Constituição era o Senado**. Mas o Senado também nunca exerceu essa atribuição de guardião da Constituição, nunca criou nenhum mecanismo institucional para exercê-lo.

Constituição da República de 1891

Apesar de se propagar isso, não foi com essa Constituição que surgiu o controle difuso de constitucionalidade. Nasceu, pois, com a Constituição Provisória, Decreto nº 510 de 1890. Na Constituição provisória foi previsto o surgimento do atual **STF**, afirmando ser competência do congresso a guarda da constituição e das leis, mas não mais a competência de interpretar. Além disso, previu a organização da Justiça Federal, com o Decreto nº 848.

A CF/1891, porém, **consagrou definitivamente o controle difuso**. Previu que o Congresso teria a incumbência não privativa de velar pela guarda da Constituição e das leis. Também previu recurso para o **STF** das sentenças que julgassem válidas leis locais em face da Constituição. A Lei nº 221/1894 previu que os juízes e tribunais apreciariam a validade das leis e regulamentos e deixariam de aplicar aos casos correntes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição (consagração categórica e expressa do *Judicial Review* no Brasil).

Constituição da República de 1934

Previu o Mandado de Segurança para a defesa do direito certo e incontestável ameaçado por ato manifestamente ilegal ou inconstitucional das autoridades. Trouxe também o recurso extraordinário como

²⁵ Direito constitucional Esquematizado. 15ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 226

hoje o conhecemos. Previu também a necessidade da maioria absoluta de voto dos juízes para que os Tribunais pudessem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público.

Surgiu a participação do Senado para dar efeitos *erga omnes* das leis declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário no controle difuso. O motivo pelo qual se entabulou a intervenção senatorial foi o temor que representava, na época, o fantasma do chamado "governo dos juízes". Buscou-se, então, intensificar a fiscalização incidental, harmonizando as competências do Poder Judiciante, sem depreciar o Legislativo.

Foi também aqui que se previu a possibilidade dos Estados adotarem constituições próprias e leis próprias, respeitados os seguintes princípios sensíveis:

- a) Forma republicana representativa de governo;
- b) Independência e coordenação dos Poderes;
- c) Temporariedade das funções eletivas;
- d) Prestação de contas da Administração.

A Constituição de 1934 traz o primeiro mecanismo de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal, que é a ação de inconstitucionalidade interventiva, a representação de inconstitucionalidade interventiva. A primeira previsão foi na Constituição de 1934. Então a Constituição de 34 traz, pela primeira vez, uma ação de Controle de Constitucionalidade Concentrado, de competência concentrada. A Representação de Inconstitucionalidade Interventiva. Mas essa Representação de Inconstitucionalidade Interventiva, não é igual a que existe hoje no art. 36 da Constituição²⁶.

Constituição da República de 1937

Representou um retrocesso. Constituição polaca, face a inspiração polonesa e as casas de prostituição, que eram conhecidas como polacas. Suprimiu o mandado de segurança. Continuou prevendo a declaração judicial de inconstitucionalidade da lei ou do ato do Presidente. Entretanto, se declarada a inconstitucionalidade, poderia o Presidente submeter a lei novamente ao parlamento, o qual poderia confirmá-la por 2/3 dos votos, ficando **sem efeito** a decisão judicial. Assim, vemos que a lei inconstitucional continuaria vigente e produzindo plenos efeitos.

Constituição da República de 1946

Trouxe de volta o mandado de segurança, previu o controle difuso, a participação do Senado no controle difuso caso o Supremo declarasse a inconstitucionalidade das leis num caso *inter partes*.

Introduziu-se a ADIN genérica (controle abstrato concentrado) com a EC nº 16/1965. Porém, **a única autoridade que poderia originalmente propor a ADIN era o PGR**. Introduziu também a Representação de Inconstitucionalidade Interventiva com ela é hoje.

Constituições de 1967 e 1969

Não trouxeram inovações significativas em sede de controle de constitucionalidade.

Constituição da República de 1988

Principais características:

- Ampliou os legitimados para propor ADI.
- Criou a ADPO, o Mandado de Injunção, o Mandado de Segurança Coletivo.
- Previu a participação do PGR nas ações de inconstitucionalidade perante o **STF** e estabeleceu que o AGU deveria fazer a defesa, salvo na ADC.
- Criou a ADPF
- A EC nº 03/1993 criou a ADC para ato normativo federal, dando-lhe força vinculante, com legitimidade inicial menor do que a ADI.

²⁶ Art. 36 - A decretação da intervenção dependerá:

I - no caso do Art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do Art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.

- A EC nº 45/2004 estendeu expressamente o efeito vinculante da ADC para a ADIN e igualou a legitimidade de ambas.
- A EC nº 45/2004 introduziu a exigência da repercussão geral e a Súmula Vinculante.



12 O papel do Advogado-Geral da União no controle de constitucionalidade.

O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo e exerce a representação judicial da União perante o Supremo Tribunal Federal. Submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República, é nomeado dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

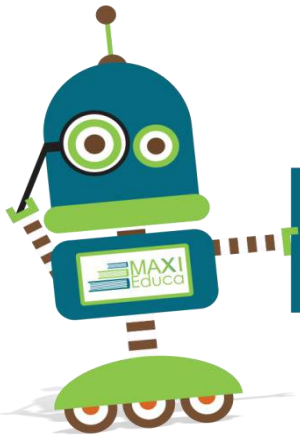
Além disso, é responsável pela direção da Advocacia-Geral da União, Instituição de Estado classificada pela Constituição como Função Essencial à Justiça, em que assume a posição de órgão de direção superior.

Suas atribuições são as descritas no art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. Delas se destaca:

- Dirigir a Advocacia-Geral da União;
- Representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal;
- Promover a defesa de leis e atos normativos impugnados em ações diretas de inconstitucionalidade;
- Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente;
- Assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
- Assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da Administração;
- Sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público;
- Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal;
- Unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Federal;
- Editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;
- Exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos de autarquias e fundações públicas;
- Homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União.

Dispõe o 3º do artigo 103 da CF/88: Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

O AGU será citado apenas na ação direta de inconstitucionalidade, não sendo necessária na ação declaratória de constitucionalidade ou em qualquer outra ação de controle concentrado. Na defesa do ato impugnado, o AGU desempenha uma função especial de *defensor legis*, atuando como verdadeiro curador das normas infraconstitucionais.



13 Inconstitucionalidade: normas constitucionais inconstitucionais

O ordenamento jurídico brasileiro, considerando a aplicação do princípio da supremacia da constituição, deve com ela ser compatível, sob pena de ser a norma considerada inconstitucional.

No caso de normas anteriores à nova Constituição, não há revogação pela simples inovação no ordenamento constitucional, ocorrendo o fenômeno denominado Recepção, que é o instituto pelo qual a nova Constituição, independentemente de qualquer previsão expressa, recebe norma infraconstitucional pertencente ao ordenamento anterior, com ela compatível, dando-lhe, a partir daquele instante, nova eficácia.

Ressaltando que o termo Recepção pode ser visualizado sob os enfoques macro e *stricto sensu*, vemos que, no primeiro, o fenômeno da Recepção é aquele em que, quando nasce uma Constituição, a ordem constitucional anterior é revogada, instante em que sobrevém ordem jurídica totalmente nova.

Neste instante, a nova Constituição não guarda qualquer vínculo com o ordenamento infraconstitucional anterior, mas abre-se a possibilidade de se aproveitar as normas infraconstitucionais que, porventura, não sejam contrárias à nova ordem. Assim, a partir de uma análise, apura-se quais normas são e quais não são compatíveis com o novo ordenamento. As compatíveis serão recepcionadas, já as incompatíveis serão revogadas, instante em que cessarão suas eficácias.

Dado o fato de a entrada em vigor de uma nova Constituição causar uma ruptura na ordem jurídica, paralisando momentaneamente a eficácia de toda a legislação ordinária existente naquele momento, uma vez que, tecnicamente, na verdade, a legislação infraconstitucional não permanece em vigor, ela perde momentaneamente seu suporte de validade e simultaneamente adquire um novo, se compatível com a nova Constituição, não havendo permanência de eficácia, mas aquisição de nova eficácia, nos termos da nova ordem constitucional.

O Supremo Tribunal Federal possui o poder de decidir sobre a constitucionalidade das normas jurídicas que foram aprovadas antes da entrada em vigor da Constituição de 1988. Note-se que no Brasil adota-se modelo misto de controle de constitucionalidade e, portanto, o tema deve ser analisado nos âmbitos do controle difuso e concentrado.

O controle de constitucionalidade de norma pré-constitucional frente à constituição atual é feito por meio do controle concentrado de constitucionalidade. A Constituição de 1988 (art. 102, §1º) previu o instrumento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) que, em acordo ao disposto na Lei Federal de n. 9.882/99 que a regulamenta, permite que o controle recaia sobre atos normativos editados anteriormente à atual Carta Magna.

É o que dispõe o art. 1º, parágrafo único, I da Lei de n. 9.882/99, segundo o qual a ADPF é cabível mesmo quando o ato ou lei federal, estadual ou municipal, que seja objeto de controvérsia constitucional, viole a constituição atual (1988):

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;

Ou seja, toda lei ou ato do poder público que viole a constituição poderá ser evitado ou reparado por meio de ADPF, mesmo que esta norma pré-constitucional seja anterior à constituição de 1988.

Assim, a conformidade à constituição vigente à época da norma pré-constitucional pode até ser eventualmente suscitada; em sede de controle concentrado, porém, o parâmetro de controle a ser adotado é a atual Constituição.



14 Inconstitucionalidade por omissão.

Introduzida pela Constituição Federal de 1988, trata-se de modalidade abstrata de controle de omissão de órgão incumbido de elaboração normativa, ou seja, é destinada a obter efetiva disposição acerca de norma constitucional que dependa de lei ou atos administrativos normativos indispensáveis à sua eficácia e aplicabilidade.

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, além da omissão legislativa, também alcança a omissão de órgãos administrativos que devem editar atos administrativos em geral, necessários à concretização das disposições constitucionais. Assim, diante da inércia ou omissão inconstitucional de órgão designado como competente para agir e efetivar disposições da Constituição, esta deve ser combatida com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Portanto, é uma ação direta que tem por objetivo a reparação de uma omissão inconstitucional. Os legitimados à sua proposição estão arrolados no artigo 103, incisos I a IX, da Constituição Federal, contudo, salienta-se que o legitimado por esse dispositivo não poderá propor a ação se ele é a autoridade competente para iniciar o processo legislativo questionado na ADIN por omissão.

De acordo com o § 2º, do Artigo 103 da Constituição, uma vez declarada a inconstitucionalidade por omissão para tornar efetiva norma constitucional, será dado conhecimento ao Poder Público competente, para que o mesmo providencie o que necessário for, em 30 (trinta) dias. Ainda com relação à omissão, poderá ser esta absoluta (total) ou relativa (parcial). A Doutrina denomina o combate à omissão de "*Síndrome de Inefetividade*".

Não são quaisquer omissões do Poder Público ensejadoras do ajuizamento da ADIN por Omissão.

Diz Alexandre de Moraes que o ajuizamento da ADIN por Omissão ocorre em relação as normas constitucionais de eficácia limitadora do **Princípio Institutivo e de caráter impositivo**, em que a Constituição investe o legislador na obrigação de expedir comandos normativos. Além disso, as normas programáticas vinculadas ao Princípio da Legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade, são suscetíveis de ADIN por Omissão.

De acordo com o Artigo 103, incisos I a IX, são ativamente legitimados para propor a ADIN por Omissão:

- Presidente da República;
- Mesa do Senado Federal;
- Mesa da Câmara dos Deputados;
- Mesa da Assembleia Legislativa;
- Mesa da Câmara Legislativa;
- Governadores dos Estados;
- Governadores do Distrito Federal;
- Procurador- Geral da República;
- Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional;
- Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil- Conselho Federal da OAB;
- Confederações Sindicais;
- Entidades de classe de âmbito nacional.

Procedimento

O procedimento para a propositura da ADIN por Omissão é semelhante ao da propositura da ADIN Genérica.

De acordo com a Lei 9.868/99, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez proposta a ADIN, não será admitida a sua desistência.

A petição inicial deverá indicar o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, bem como, o pedido, com suas especificações.

Deverá ser acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado. Será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Declarada a inépcia da inicial, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, tendo como remédio a interposição de agravo.

Na ADIN serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado Geral da União, cuja incumbência é a defesa da constitucionalidade de lei ou ato normativo impugnado e o Procurador Geral da República, o qual deve atuar em todos os processos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

No caso da ADIN por Omissão, inexistente prazo para a propositura da presente ação, entretanto, existe a necessidade de se aferir à existência do transcurso de tempo razoável, que permita a edição da norma omissa, em cada caso concreto. Não é obrigatória a oitiva do Advogado Geral da União, na ADIN por Omissão, tendo em vista a inexistência de ato impugnado a ser defendido e o Ministério Público obrigatoriamente deverá se manifestar antes da análise do Plenário sobre a ação proposta.

A concessão de medida liminar é incompatível com o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, pois um provimento Judicial não é capaz de afastar a omissão legislativa.

Destarte, o STF, ao declarar a inconstitucionalidade por omissão, relativamente à medida para tornar uma norma constitucional efetiva dará ciência ao Poder competente para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Em se tratando do Poder Legislativo, não estará o órgão obrigado a legislar, já que não disposição expressa na Constituição, mas sim, a obediência ao Princípio da Separação dos Poderes (independentes e harmônicos).

Contudo, se o STF informa diretamente ao órgão administrativo sobre a declaração de inconstitucionalidade por omissão, e sendo de sua competência a prática do ato até então considerado omissivo, deverá o mesmo suprir a omissão normativa em 30 (trinta) dias.

Diferenças entre a decisão proferida na adi por omissão e no mandado de injunção

Os efeitos da decisão no mandado de injunção têm bases controvertidas tanto na doutrina como na jurisprudência. De modo geral, é possível afirmar que há 4 (quatro) posições acerca do assunto, a saber: **1) posição concretista geral; 2) posição concretista individual; 3) posição concretista intermediária; e 4) posição não concretista.**

A posição concretista geral ocorre quando o STF vem a legislar no caso concreto, cuja decisão produz efeitos “erga omnes” até o momento em que o Legislativo cumpra com o seu desiderato.

A posição concretista individual é aquela que implementa o direito no caso concreto, cuja decisão tem eficácia para o autor do mandado de injunção, diretamente.

A posição concretista intermediária, por sua vez, é aquela em que só há o implemento do direito ao caso concreto, quando o Legislativo resolve não cumprir com o prazo estipulado pelo Judiciário para elaborar a norma regulamentadora.

Já a posição não concretista ocorre quando o Judiciário apenas decreta a inércia do Poder omissivo, não reconhecendo o direito no caso concreto. Nesse caso, há o simples reconhecimento formal da mora, sem intromissão na esfera de outro Poder. Esta foi durante muitos anos a posição dominante do STF.

Não obstante, em recentes julgados, vislumbra-se a alteração de orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido da aplicação da posição concretista geral. É o que se pode constatar com as decisões proferidas nos MI's 670, 708 e 712, em que o STF, ante a falta de norma regulamentadora, por unanimidade, determinou a aplicação da legislação do direito de greve da iniciativa privada para todos os servidores públicos, apesar do fato da impetração ter sido efetuada por sindicatos, individualmente.

Sob este aspecto, considerando a atuação do Supremo como legislador positivo, trava-se, através da jurisprudência do Supremo, uma nova contenda jurisprudencial, em nítido caráter de mutação constitucional, principalmente quando se põe em confronto com o princípio da tripartição dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição. Tal atuação trata-se, na verdade, de um reflexo do que se hoje passou a denominar de ativismo judicial, consequência de um Poder Legislativo fraco e inoperante.

Com relação a ADI por omissão, o art. 103, § 2º, da Constituição Federal, estabelece os seguintes efeitos:

- a) com relação ao Poder competente, em respeito a independência dos Poderes, será dada simples ciência da decisão, sem estipulação de prazo para o suprimento da omissão inconstitucional;
- b) com relação ao órgão administrativo, este deverá suprir a omissão inconstitucional em 30 dias, sob pena de responsabilidade.



15 Ação direta de inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual.

Trata-se do exercício de atividade política, pois implica em atividade legislativa negativa. É o exercício de um poder contramajoritário não se podendo compreender ela à luz do processo civil comum.

Ela deve ser utilizada quando se busca a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato federal, estadual ou distrital de caráter estadual, sem que esteja sendo analisado um caso concreto. Sua função máxima e última é a defesa da ordem constitucional e manutenção da higidez do ordenamento jurídico.

Quanto a origem e a evolução, remetemos o leitor aos tópicos 10 e 11, que tratam do tema com profundidade.

Legitimidade Ativa

Tecnicamente, na ADIN não há partes e nem interesse de agir. A ação é proposta não por autores, mas por legitimados ativos, que atuam em nome próprio no interesse de toda a sociedade (substituição processual). O **STF**, na ADI-MC 1.096, dividiu os legitimados em dois grandes grupos:

a) **Legitimados universais**: não precisam comprovar a pertinência temática para propor ADIN. Podem versar sobre qualquer assunto. São eles:

- Presidente;
- Procurador-Geral da República;
- Mesas da Câmara e do Senado (Mesa do Congresso Nacional não);
- Conselho Federal da OAB;
- Partidos políticos com representação nacional;

b) **Legitimados especiais**: necessitam comprovar a pertinência temática. São eles:

- Governadores;
- Mesas das Assembleias Legislativas;
- Confederação sindical;
- Entidade de classe de âmbito nacional.

A **pertinência temática** é um nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ADIN e o conteúdo material da norma por ela impugnada nessa sede processual. Trata-se de um “interesse de agir disfarçado”. Para o **STF**, a **pertinência temática** é uma **condição objetiva da ADIN**, quando o legitimado for o especial.

Partidos políticos: somente a direção nacional do partido pode propor ADIN, seus diretórios regionais não. Poderão propor apenas ADIN estadual, se previsto na Constituição do Estado (quem tem o poder de decidir sobre a propositura é o seu Presidente, o qual precisará, **caso previsto no Estatuto**, obter aprovação interna para efetivar tal intento). A perda superveniente da representação no Congresso Nacional não faz o partido perder a legitimidade para continuar a ADIN. É o entendimento que passou a prevalecer desde 2003 (ADI-QO 2.054). **Isso porque a aferição da legitimidade é feita ao tempo da propositura da ação.**

Seccionais da OAB: somente poderão propor ADIN estadual, se previsto na CE.

Confederação sindical: não confundir confederação sindical com centrais sindicais. O número mínimo de sindicatos para se formar uma confederação sindical é de 15. Isso porque, para se formar uma confederação sindical, são necessárias, pelo menos, três federações sindicais, as quais, por sua vez, somente serão constituídas com o número mínimo de 05 sindicatos (arts. 534 e 535, CLT).

Entidades de classe de âmbito nacional: o STF entende que “associações de associações” podem propor ADIN. Não é necessário que a confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional esteja em funcionamento há pelo menos um ano, pois este é um requisito apenas do MS Coletivo.

De acordo com o art. 482, § 2º, CPC, todos os legitimados ativos para propor ADIN podem se manifestar por escrito, nos incidentes de inconstitucionalidade **em curso nos tribunais** inferiores, sobre a questão constitucional objeto de apreciação **pelo órgão especial ou pelo Pleno do Tribunal**, no prazo fixado em regimento, sendo-lhes assegurado apresentar memoriais ou pedir a juntada de documentos.

Legitimidade Ativa e Capacidade Postulatória

Quando forem postulantes o Presidente e os Governadores, estes podem assinar a petição inicial da ADIN independentemente de terem capacidade postulatória, sem precisarem de advogado, já que a legitimidade adveio diretamente da Constituição. Podem, ademais, praticar quaisquer outros atos em regra privativos de advogados, como apresentar recursos, entre outros; porém, nada impede, evidentemente, que promovam a ADIN por intermédio de seus chefes de representação judicial.

Legitimidade Passiva

Não existe réu na ADIN; o que existe são legitimados passivos, que serão quaisquer autoridades de que emanem atos normativos ou administrativos.

Litisconsórcio Ativo e Passivo

É possível o litisconsórcio ativo facultativo. Nada impede que alguns órgãos ou um órgão ou PJ privada legitimada se litisconsorciem em petição de ADI.

O litisconsórcio passivo será necessário quando mais de um órgão tiver participado da edição da norma objeto da ADI. Exemplo: uma lei que tenha sido aprovado pelo CN e sancionado pelo presidente da república, terá como polo passivo, como requeridos, o CN e o PR.

Objeto

A ADIN poderá ser proposta em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Assim, a princípio, todas as espécies normativas listadas pelo art. 59 da CF/88 podem ser objeto de ADIN. O que é ato normativo? Segundo a ADI-MC 2.195, é ato normativo aquilo que apresenta os seguintes elementos:

- a) Ser genérico e abstrato;
- b) Ter autonomia jurídica, capaz de gerar, por si próprio, deveres e direitos;
- c) Impessoais;
- d) Obrigatórios (eficácia vinculante das prescrições nele constantes).

Caberá ADIN em face de:

a) Emendas constitucionais, comuns ou de revisão, podendo ser examinado qualquer vício, formal ou material, não se limitando às cláusulas pétreas;

- b) Leis complementares e ordinárias;
- c) Leis de efeitos concretos, como a LDO e a LOA. Com a ADIN-MC 4.048, o **STF** passou a permitir-se o controle abstrato em tema ou controvérsia constitucional, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato, de seu objeto. A ausência de densidade normativa da lei não é óbice ao controle abstrato. **Somente se exigirá densidade normativa para o ato de natureza infralegal.**
Assim, hoje, para o **STF** cabe ADIN somente pelo fato de ser lei. Se for ato normativo infralegal, aí sim caberá a discussão sobre efeitos concretos ou abstratos, somente cabendo a ADIN se os efeitos forem abstratos.
- d) lei que cria municípios (ADI-MC 2.381);
- e) lei promulgada e publicada, mas em período de *vacatio legis*;
- f) contra leis e atos normativos do Distrito Federal, quando exercendo competência legislativa de caráter estadual;
- g) contra lei delegada já pronta, assim como contra a resolução do Congresso Nacional que realiza a delegação (se, por exemplo, seu objeto for indelegável);
- h) contra Medida Provisória, tanto no que concerne aos seus requisitos constitucionais quanto ao seu conteúdo. **Os requisitos de relevância e urgência somente poderão ser examinados se puderem ser objetivamente identificados.** Algumas medidas provisórias requerem requisitos específicos, como a que versa sobre créditos extraordinários (é caso excepcional de MP versando sobre matéria orçamentária. Os requisitos específicos são a urgência e a imprevisibilidade (art. 167, § 3º c/c art. 62, § 1º, I, “d”).
A conversão da MP em lei não sana seus vícios originários. Porém, se o vício for nos requisitos da relevância e urgência, com sua conversão em lei, os vícios restarão superados. Caso a MP seja convertida em lei antes do julgamento da ADIN, deverá ser dada oportunidade ao legitimado ativo para aditar a petição inicial, **caso tenha havido modificação substancial do conteúdo da MP quando convertida em lei.** Caso não tenha ocorrido tal alteração substancial, desnecessário o aditamento. Cabe ADIN contra **decretos legislativos e resoluções, quando veicularem normas gerais e abstratas** (ADI-MC 769).
- i) em face de tratados internacionais, já que eles, após incorporados, são positivados e tem caráter de lei federal. A ADIN não é proposta contra o tratado em si, e sim contra o Decreto Legislativo que o aprovou ou contra o Decreto Presidencial que o promulgou.
- j) contra decreto ou regulamento autônomo, desde que ofendam diretamente à Constituição, ou desde que atentem contra a reserva legal (ADI-MC 1.969).
- k) contra Regimento Interno de tribunal desde que haja ofensa direta à CF, sem um vício de ilegalidade. (Essa ofensa deve ser com o ato já pronto, não cabe controle preventivo de constitucionalidade enquanto o regimento está sendo discutido, mesmo porque a norma ainda nem existe. Somente caberia eventualmente MS se o parlamentar fosse alijado da discussão)
- l) contra os antigos pareceres da Consultoria Geral da República (eram os pareceres que, quando aprovados pelo Presidente da República, tinham força normativa).
- m) contra Resolução do CNJ, já que possui força de lei.
- n) em face de súmula vinculante.

Não Caberá ADIN em face de

- a) Normas constitucionais originárias.
- b) Normas de Estado estrangeiro.
- c) Atos normativos privados, tais como regulamento de empresa, convenção de condomínio etc.
- d) Convenções coletivas de trabalho.
- e) Leis e atos normativos municipais e distritais de caráter municipal.
- f) Decretos meramente regulamentares.
- g) Leis e atos normativos pré-constitucionais. Isso porque aqui há de se falar em recepção ou não recepção.
- h) Leis e atos normativos temporários, quando sua eficácia já se exauriu. Se a eficácia se exaurir no curso do processo, a ação perderá objeto.
- i) Sentenças normativas da Justiça do Trabalho.
- j) Súmulas orientativas dos tribunais. Isso porque súmula não é ato normativo, apenas consolida o pensamento dominante. A doutrina entende ser cabível ADIN contra súmula vinculante, assim como vários ministros do **STF** (ADPF 80).
- k) Atos regulamentares internos dos órgãos da Administração.
- l) Resoluções do TSE que respondem a consultas.

Em todos os casos que não cabe ADIN, é possível o controle difuso de constitucionalidade e legalidade. Além disso, poderá caber ADPF, diante do seu caráter subsidiário.

Aspectos Processuais (Lei nº 9.868/99)

A petição inicial indicará:

- a) O dispositivo de lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;
- b) O pedido, com suas especificações;
- c) Outros.

Na ADIN, aplica-se o **princípio da adstrição ao pedido** (mas não se aplica a adstrição à causa de pedir), devendo o **STF** se ater ao pedido feito pelo legitimado ativo. Porém, ainda que o legitimado alegue a inconstitucionalidade somente em face de determinado dispositivo da CF, poderá o **STF** declarar a inconstitucionalidade em face de outro. Ele não está vinculado aos fundamentos jurídicos da inicial, somente ao pedido em si. Assim, se o legitimado pede a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 13, 17 e 25 da lei X, em face dos arts. 18 e 170 da CF/88 deverá o **STF** analisar a inconstitucionalidade em face de todos os dispositivos da Constituição, mas não poderá analisar a constitucionalidade, por exemplo, do art. 14 da Lei X.

No entanto, se houver dependência, poderá haver inconstitucionalidade por arrastamento, sendo essa uma exceção ao princípio da adstrição.

Quando a inicial for subscrita por advogados, deve vir acompanhada de procuração **com poderes específicos para atacar a norma impugnada**, em duas vias, com cópia da CEI ou ato impugnado. Porém perfeitamente possível que a inicial seja assinada pelo legitimado ativo previsto na Constituição, ainda que não seja advogado.

O STF entendeu que a inicial da ADI é manifestamente improcedente quando a norma impugnada já foi declarada constitucional em recurso extraordinário; trata-se da objetivação do controle difuso de **constitucionalidade**.

Modificação da Inicial, Desistência e Informações

O **STF** entende plenamente possível o aditamento ou emenda da petição inicial, embora não haja previsão legal ou regimental para tanto. Entretanto, o Tribunal tem limitado essa prática até o momento da prestação das informações pelo órgão do qual emanou o ato ou medida impugnada (ADIN 437).

Não se admitirá desistência após a proposição da ADIN, já que o processo é objetivo (**princípio da indisponibilidade de instância**). O mesmo vale para a cautelar.

O relator pedirá informações aos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 30 dias contados do recebimento do pedido.

Porém, se houver pedido de concessão de cautelar, os responsáveis pela edição do ato ou norma deverão se manifestar em 05 dias. Após o julgamento da cautelar, deve então o relator pedir informações sobre o mérito da causa. Em qualquer hipótese, serão ouvidos o AGU e o PGR, sucessivamente, no prazo de 15 dias cada.

Intervenção de Terceiros e Amicus Curiae

Não se admitirá intervenção de terceiros. Isso não significa que não possa haver mais de um legitimado ativo ou passivo na mesma ação. Admite-se o *amicus curiae*, por despacho teoricamente irrecorrível do relator, e desde que pedida a habilitação no processo no prazo de 30 dias das informações (art. 7º, § 2º).

Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade.

Porém, segundo a jurisprudência do **STF**, o *amicus curiae* tem sido admitido após o prazo de informações, inclusive após iniciado o julgamento. Recentemente, o Plenário do **STF** decidiu que a possibilidade do ingresso está limitada à data da remessa dos autos à mesa para julgamento: **O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta**. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4071 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2009)

O *amicus curiae* não pode recorrer, salvo se para interpor embargos de declaração contra o “despacho” que não permitiu sua participação no processo.

Após o prazo das informações, deverão ser ouvidos o AGU e o PGR, no prazo sucessivo de 15 dias cada (art. 8º).

Para que o *amicus curiae* seja aceito, é necessária a análise da:

- **Relevância da matéria:** por meio dela, o Supremo verifica se realmente é importante ouvir terceiros na ação, ou se seria medida despicienda, simplesmente tornando ela mais complexa, sem necessidade;
- **Representatividade:** o *amicus curiae* deve ser pessoa ou entidade com efetiva capacidade de esclarecer o tema objeto de análise, devendo existir adequação entre seu conhecimento/atividade e o que será discutido. Além disso, ele deve ter idoneidade suficiente para falar pela sociedade na condição de conselheiro da Corte. A isso se chama de representatividade adequada, a participação de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais.

Medida Cautelar

A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é da competência exclusiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão liminar nessas ações diretas está submetida à reserva de plenário, regra esta que decorre do art. 97 da Constituição e do art. 10 da Lei 9.868/99 ("a medida cautelar na ação direta será concedida pela maioria absoluta dos membros do Tribunal") e também está expressamente prevista no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 5º, X).

A submissão à reserva de plenário tanto da decisão de mérito quanto da decisão cautelar baseia-se no fato de que ambas produzem efeitos diretos sobre a **vigência** das normas.

A medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade tem o escopo de obstar que normas inconstitucionais gerem efeitos no mundo jurídico e no mundo dos fatos, efeitos esses muitas vezes irreversíveis.

Quanto uma norma inconstitucional entra em vigor, começa a produzir efeitos que não poderiam ser aceitos no ordenamento, fato este que **Konrad Hesse** denomina de **realidade inconstitucional**. Por tal motivo, o doutrinador assevera que o importante é primeiro:

- Evitar que norma inconstitucional entre em vigor;
- Caso entre em vigor, evitar que os efeitos da norma inconstitucional se perpetuem.

A medida cautelar apresenta como requisitos para concessão o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Em relação ao *periculum in mora*, sabe-se que não há prescrição em sede de ADIN. Os requisitos do perigo da demora, em determinadas situações, podem ser convertidos ou substituídos por outro requisito: **a conveniência**. Assim, em alguns casos, os requisitos para a concessão da cautelar será o *fumus boni iuris* e a conveniência.

A cautelar **será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal**, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato impugnado em **05 dias** (essa audiência poderá ser dispensada, se houver urgência). O relator tem a faculdade de ouvir o AGU e o PGR no prazo de **03 dias**.

No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato. O *amicus curiae* poderá também fazer a sustentação oral. Se concedida a cautelar, deverá ser publicada a **parte dispositiva** da decisão, no prazo de 10 dias.

A cautelar terá eficácia *erga omnes* e *ex nunc*. Além desses efeitos, se concedida a cautelar, **volta a ser aplicável a legislação anterior acaso existente**, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

Assim, são efeitos:

- a) *Erga omnes*: afasta-se a eficácia da norma impugnada para todos, até o julgamento de mérito da ação.
- b) *Ex nunc*: somente será *ex tunc* se expressamente previsto no acórdão concessivo, **não necessitando do quórum qualificado para se modular os efeitos temporais como ocorre na decisão final de mérito**. De qualquer forma, ainda que tenha apenas efeitos *ex nunc*, a cautelar será dotada de retroatividade mínima, já que atinge os efeitos futuros de atos praticados no passado.
- c) Vinculantes: vinculam os órgãos da Administração e os Tribunais, os quais não poderão aplicar a norma cuja vigência está suspensa. Porém, se indeferida a cautelar, nenhum efeito gerará;
- d) Repristinação: salvo se o Tribunal se manifestar expressamente em sentido contrário.

Mesmo antes da Lei nº 9.868/99, o **STF** admitia a concessão de cautelar com efeitos retroativos. Porém, para que a cautelar retroaja, deverá haver manifestação expressa do **STF** nesse sentido. No silêncio, não retroage.

O efeito vinculante na cautelar não está previsto na CF, nem mesmo na Lei nº 9.868/99. Parte da doutrina entende ser inconstitucional esse efeito, já que haveria cerceamento da atividade dos magistrados por decisão não definitiva. O **STF** afirmou a constitucionalidade desse efeito, realizando uma verdadeira mutação constitucional. Inclusive, a inobservância de medida cautelar em sede de ADI pelos tribunais inferiores e pela Administração dá azo até mesmo à reclamação constitucional.

Porém, somente a decisão concessiva da cautelar possui efeito vinculante, a denegatória não. Ou seja, os juízes poderão continuar declarando a norma inconstitucional em sede de controle difuso, não deverão, ante a negativa da cautelar em ADI, considerar que o tribunal declarou a norma constitucional. Isso porque a decisão da cautelar não possui caráter *dúplice*.

O início da eficácia da decisão concessiva de cautelar tem como marco a publicação do dispositivo ou da ata de julgamento da decisão concessiva.

Acolhido o requerimento cautelar, **o STF suspende a eficácia da norma até o final do julgamento**. A natureza da decisão cautelar é de decisão de suspensão de eficácia da norma. Veja que é diferente da decisão de mérito final. No mérito, o **STF** declara. A decisão de mérito é uma decisão sobre invalidade. A decisão cautelar é sobre eficácia.

Decisão Final de Mérito

O julgamento da ADIN somente pode ter início com o quórum de 08 ministros. Assim, se não presente esse mínimo, a sessão nem mesmo pode ser instaurada (art. 22). Para a declaração da inconstitucionalidade, deve haver pronunciamento nesse sentido de, no mínimo, 06 ministros (**maioria absoluta**).

Se não for alcançada a maioria necessária para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, deve o julgamento ser suspenso até que compareçam os demais Ministros e votem (art. 23, p. único).

Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ADIN ou procedente eventual ADC. Proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ADIN ou improcedente eventual ADC. Isso se trata da **natureza *dúplice* ou ambivalente**.

A decisão de mérito da ADI é uma decisão de natureza definitiva, tem efeito *erga omnes*. Então, seu dispositivo deve ser observado por todos, particulares, poder público, **STF**, todo mundo.

A sua razão de decidir, a sua fundamentação tem natureza vinculante para a administração pública e para o Poder Judiciário. Há um efeito vinculante, no que se refere à *ratio decidendi*, para a administração pública de todos os entes federativos e para os demais órgãos do judiciário. Mas o **STF** não está vinculado a sua razão de decidir; tem que cumprir a própria decisão por causa do efeito *erga omnes*.

Após julgada, será comunicada a decisão à autoridade. Somente cabem embargos de declaração; não cabe ação rescisória.

O Estado-membro não possui legitimidade para opor embargos de declaração da decisão de ADI ajuizada pelo respectivo governador. Isso porque o Estado não é legitimado para a ADIN. O mesmo raciocínio se faça em relação às mesas das Assembleias Legislativas.

Não aplica-se a prerrogativa da contagem em dobro para a Fazenda Pública em sede de ADC ou ADIN. O prazo em dobro é para processo subjetivo.

Modulação dos Efeitos (art. 27)

Poderá haver a modulação com a votação de 2/3 dos membros do Tribunal. A modulação pode ser temporal ou em relação aos efeitos da declaração. A modulação temporal pode ser para trás ou para algum período posterior.

O Brasil adotou o sistema norte-americano de controle de constitucionalidade, já que a lei inconstitucional é nula, não devendo gerar efeitos. Entretanto, pode-se ver claramente a mitigação dessa ideia de nulidade com a modulação de efeitos de algo que é inconstitucional. Até mesmo nos EUA houve decisão nesse sentido, com o caso **Linkletter Vs Walker**.

A modulação deve ser pedida na inicial pelo legitimado ativo. Entretanto, de acordo com o **STF**, pode ocorrer modulação até mesmo com pedido feito em sede de embargos de declaração.

A modulação dos efeitos atinge a eficácia da norma, e não a sua validade, enquanto a declaração pura e simples de inconstitucionalidade atinge a sua validade).

Eficácia e Efeitos da Decisão Definitiva da ADIN

O marco da eficácia da ADIN é diferente do que ocorre na medida cautelar. Isso porque na ADIN cabem Embargos de Declaração, o que postergaria em muito o trânsito em julgado e os acórdãos substitutivos. **A eficácia se opera na data da publicação do dispositivo do primeiro acórdão, e não do trânsito em julgado.**

A decisão do **STF** já fulmina a norma, não havendo que se falar em comunicação ao Senado para suspensão de lei, que é o que ocorre no processo subjetivo em sede de recurso extraordinário.

Efeitos da decisão da ADIN:

- a) *Erga omnes*;
- b) *Ex tunc*;
- c) Vinculantes;
- d) Repristinação.

Poderá não haver efeitos *erga omnes* e *ex tunc* se houver a modulação pelo voto de 2/3 dos Ministros.

O efeito vinculante foi estendido à ADIN pela Lei nº 9.868/99 e pela jurisprudência do **STF**. Somente houve a constitucionalização dos efeitos vinculantes para a ADIN após a EC 45/04. O desrespeito à eficácia vinculante da decisão do **STF** enseja **reclamação** constitucional à própria Corte. Todos os legitimados ativos para propor ADIN podem também intentar reclamação constitucional.

Além disso, todos aqueles que foram atingidos por decisões contrárias às do **STF** podem propor reclamação, a partir da data do julgamento, independentemente da publicação e da juntada do acórdão.

A coisa julgada material se opera em sua feição clássica, mesmo porque o **STF** não pode ressuscitar lei revogada. Porém, no caso de declaração de constitucionalidade, o **STF** poderá analisar de novo futuramente sua constitucionalidade, já que a lei poderá se tornar inconstitucional por alteração da realidade fática ou de mutação constitucional.

ADIN e Coisa Julgada

O **STJ** entendia que não caberia ação rescisória contra decisão judicial transitada em julgado baseada em lei declarada inconstitucional. Tal entendimento foi modificado, uma vez que, se a coisa julgada estiver baseada em lei inconstitucional, poderá ser proposta ação rescisória, **desde que exista ainda prazo para interpor a rescisória, o qual não é renovado com a declaração. O fundamento a ser adotado é a contrariedade a literal dispositivo de lei.**

Deve ser observado que, em sendo a matéria relativa a Direito Penal, na revisão criminal, não há o prazo de 02 anos.

Efeitos Repristinatórios

Quando uma norma é declarada inconstitucional, o princípio da supremacia da constituição impõe que todos os seus efeitos pretéritos sejam apagados, inclusive no que concerne à revogação de outras normas anteriores. Isso porque, por ter ofendido a Carta, ela não deveria nunca ter gerado efeitos.

Logo, a lei revogada será repristinada, salvo se o Tribunal disser expressamente o contrário.

Disso surge o problema do chamado **efeito repristinatório indesejado**. E se a lei revogada pela norma cuja inconstitucionalidade se pretende ver reconhecida também se revestir de vício de inconstitucionalidade? Nesse caso, cabe ao autor da ação direta de inconstitucionalidade formular pedido sucessivo dirigido à declaração da desvalia constitucional também do ato normativo revogado que padeceria da mesma mácula de inconstitucionalidade. Do contrário, será o caso de extinguir a ação sem análise do mérito, haja vista esse óbice de natureza processual.

Recursos

O único recurso cabível é o embargo de declaração, que deve ser interposto pelo legitimado ativo ou passivo. O *amicus curiae* somente pode interpor ED em face da decisão que o inadmite no processo.



16 Ação declaratória de constitucionalidade.

A ADC é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade de lei ou atos normativos federais em que se procura em tese ratificar a previsão relativa de validade destes atos. **Através dela a presunção relativa transforma-se em absoluta (*juris et jure*)** mediante provocação por ação direta e manifestação do STF na via principal. Está prevista no art. 103, § 4º, da CF/88, tendo sido regulada pela Lei nº 9.868/99.

Aspectos Comuns entre a ADIN e a ADC

- a) Mesmos legitimados ativos;
- b) Ambas são dúplices ou ambivalentes;
- c) São imprescritíveis;
- d) Uma vez propostas, não pode haver desistência;
- e) Admite-se litisconsórcio ativo (passivo não, já que não há legitimado passivo na ação);
- f) Não se admite intervenção de terceiros;
- g) Admite-se o *amicus curiae*, no prazo de 30 dias das informações, conforme a lei, ou até a remessa dos autos à mesa para julgamento, de acordo com o **STF**;
- h) Poderá ser designada audiência pública e poderão ser esclarecidas circunstâncias fáticas;
- i) A causa de pedir é aberta;
- j) Cabível cautelar;
- k) Decisão final com eficácia *erga omnes*, efeitos *ex tunc* e força vinculante;
- l) Aplicável a técnica da modulação dos efeitos temporais, pelo quórum de 2/3 dos Ministros;
- m) Participação do PGR como *custos legis*, mesmo nas ações por ele propostas;
- n) Decisão final irrecorrível, salvo para interposição de embargos de declaração;
- o) Cabível reclamação pelo seu descumprimento.

Legitimidade

A legitimidade para a propositura da ADC foi equiparada à da ADI pela EC nº 45/04; antes ela era mais restrita. Entretanto, a legitimidade aqui deverá ser auferida também por outro ângulo: há de ser cogitada também a legitimação para agir *in concreto*, a qual se relaciona com **a existência de um** estado de incerteza gerado por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade do ato normativo ou lei federal (exigência prevista no art. 14, III, da Lei nº 9.868/99).

Art. 14. A petição inicial indicará:

(...)

III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.

A questão da controvérsia afeta a aplicação do princípio de separação dos Poderes em sua acepção mais ampla. A generalização de medidas judiciais contra uma dada lei nulifica completamente a presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado e coloca em xeque a eficácia da decisão legislativa. A ação declaratória seria o instrumento adequado para a solução desse impasse jurídico-político, permitindo que os órgãos legitimados provoquem o **STF** com base em dados concretos, e não em simples disputa teórica.

Há de se configurar, portanto, situação hábil a afetar a presunção de constitucionalidade da lei. Assim, **não se admite a propositura de ADC se não houver controvérsia ou dúvida relevante quanto à legitimidade da norma, caso contrário o instrumento se subverteria como mera consulta ao Supremo.**

Essa controvérsia pode se dar, por exemplo, quando as instâncias ordinárias decidem frequentemente pela inconstitucionalidade da lei ou quando houver vários pronunciamentos contraditórios acerca dela entre órgãos jurisdicionais diferentes.

Não bastará, entretanto, a simples controvérsia doutrinária. Ela deve ser **JUDICIAL**, devendo ser demonstrada na inicial. Tem que trazer a demonstração de que a presunção da constitucionalidade daquela norma está abalada pelas divergentes decisões judiciais no controle difuso.

Decisões em processos que produzem efeitos *inter partes*, processo de julgamento em primeira instância não vem sendo considerada uma jurisprudência relevante para este fim.

Legitimado Passivo

Não há requerido; esta é uma ação proposta em face de ninguém, não há quem ocupe o polo passivo na ADC. A necessidade de o autor trazer a demonstração de que a presunção de constitucionalidade estaria abalada supre para o **STF** o debate, o contraditório. Então, foi por isso que o **STF** concluiu que não haveria inconstitucionalidade na EC 3 por ter criado uma ação constitucional sem requerido, pois o debate teria sido trazido para a ação através de uma via indireta, que é a demonstração da jurisprudência relevante.

Objeto

Somente pode ser objeto de ADC leis (quaisquer leis) ou atos normativos (de efeitos gerais e abstratos) **federais**. Também é cabível ADC em face de normas constitucionais secundárias ou derivadas, ou seja, aquelas inseridas na Constituição pelo Poder Constituinte Derivado.

É cabível ADC em face de medida provisória, decreto legislativo, **decreto executivo que promulga tratados e convenções**, regimentos dos Tribunais Superiores, decretos legislativos que sustentam atos advindos dos poderes delegados do Poder Executivo, pareceres da consultoria-geral da república aprovados pelo Presidente, tratados internacionais já incorporados etc.

Participação do AGU

O AGU não participa diretamente da ADC, já que o que se busca é a declaração de constitucionalidade, e não de inconstitucionalidade. Entretanto, por evidente é que o Ministro Relator poderá requisitar a ele informações, nos termos do art. 20, § 1º da Lei nº 9.868/99.

Parâmetro de Controle

O parâmetro é todo o bloco de constitucionalidade, as normas constitucionais, ADCT, textos constantes somente nas emendas, tratados internacionais incorporados como norma constitucional etc.

Em caso de ADC proposta com objetivo de aferir a constitucionalidade de uma lei em face de parâmetros constitucionais já revogados, reconhecia o **STF** a inadmissibilidade da ação; em caso de revogação de parâmetro de controle, julga-se prejudicada a ação.

O Supremo, no entanto, tem tendido a alterar esse entendimento: ele pende, agora, a reconhecer que a constitucionalidade de uma norma infralegal deve ser aferida de acordo com o bloco de constitucionalidade vigente à época em que foi editada. Isso porque, modificada a Constituição, e continuando a norma vigente, estar-se-ia admitindo a convalidação da norma inconstitucional, o que seria um atentado à Constituição.

Procedimento

A petição inicial indicará:

- a) O dispositivo de lei ou do ato normativo que se quer seja declarado constitucional e os fundamentos jurídicos (art. 14, I);
- b) O pedido, com suas especificações (art. 14, II); esse requisito consagra o princípio do pedido ou da congruência, o qual é essencial para a jurisdição constitucional, uma vez que dele depende, em determinada medida, a qualificação do órgão decisório pelo tribunal. A forma judicial constitui

característica peculiar que permite distinguir a atuação da jurisdição constitucional de outras atividades, de cunho meramente político.

c) Indicação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ADC (art. 14, III);

d) Cópias da lei ou ato normativo;

e) Procuração com poderes específicos, caso subscrita por advogado.

O relator poderá indeferir *in limine* as iniciais ineptas, não fundamentadas ou manifestamente improcedentes, decisão contra a qual cabe agravo no prazo de 05 dias.

O PGR deverá se manifestar em 15 dias após intimado. Porém, havendo pedido de cautelar, poderá haver o julgamento antes de sua manifestação. O Relator poderá **pedir informações a todos os Tribunais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de suas competências jurisdicionais**.

Medida Cautelar

Perfeitamente admissível, mas com efeitos diferentes daqueles observados na ADIN. Nela, será determinada, por maioria absoluta, que os juízes e tribunais **suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação** até seu julgamento definitivo, o qual deverá se dar no prazo de 180 dias (art. 21). O **STF** tem admitido a renovação do prazo da cautelar, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

O objeto da cautelar é a suspensão de decisões que declarem a inconstitucionalidade da lei no controle difuso **desde que não transitada em julgado no que se refere à entrega do bem da vida e suspensão de processo**.

A cautelar possui:

a) Eficácia *erga omnes*;

b) Efeito vinculante;

c) Eficácia *ex nunc*; podendo ser *ex tunc*, por expressa decisão.

Decisão Final

Acerca da decisão final, valem as mesmas regras versadas sobre a ADIN. A decisão tem natureza declaratória positiva. Então, julgado procedente o pedido, o **STF** tem que declarar a constitucionalidade. Julgado improcedente o pedido o **STF** tem que declarar a inconstitucionalidade, dizer qual é a sua natureza, abrangência, efeito no tempo e tudo mais.

Julgado procedente o pedido, a norma que era constitucional continuará sendo, só há uma alteração da natureza desta presunção, a norma sempre foi considerada constitucional pelo princípio da hermenêutica e da presunção de validade. Só que **esta presunção que era relativa transforma-se em presunção absoluta**. Pode-se dizer que a declaração de constitucionalidade tem efeito *ex tunc*, mas há uma alteração da natureza da presunção.



17 Arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Prevista no art. 102, § 1º, da CF/88, e regulamentada pela Lei nº 9.882/99, trata-se de instrumento de controle concentrado de constitucionalidade que visa à defesa dos preceitos fundamentais, não amparáveis por outras vias.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação direta da competência exclusiva do **STF**, em que se busca evitar ou reparar eventual lesão a um preceito fundamental causada por ato do Poder Público. Também pode ser proposta quando houver relevante fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à CF/88.

Como típico instrumento do modelo concentrado de controle de constitucionalidade, a ADPF tanto pode dar ensejo à impugnação ou questionamento direto de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, como **pode acarretar uma provocação a partir de situações concretas**, que levem à impugnação de lei ou ato normativo.

No primeiro caso, tem-se um tipo de controle de normas em caráter principal, opera-se de forma direta e imediata em relação à lei ou ao ato normativo, sendo a ADPF proposta diretamente no **STF**.

No segundo, questiona-se a legitimidade da lei tendo em vista a sua aplicação em uma dada situação concreta (caráter incidental). Aqui a instauração do controle de legitimidade da norma na ADPF repercutirá diretamente sobre os casos submetidos à jurisdição ordinária, uma vez que a questão prejudicial a ser dirimida nesses processos será elevada à apreciação do Supremo Tribunal. No que concerne à prática, esse controle assemelha-se à cisão funcional que se realiza, entre nós, no controle de constitucionalidade incidental (art. 97), com o destaque da questão prejudicial surgida perante o órgão fracionário para ser apreciada pelo Plenário do Tribunal.

Diferentemente do que se verifica no controle incidental, em que se realiza uma cisão funcional no plano horizontal (do órgão fracionário para o Plenário ou para o órgão especial do mesmo Tribunal), tem-se, na ADPF, uma **cisão funcional no plano vertical** (de órgãos das instâncias ordinárias para o **STF**). Daí por que haverá de se cogitar, normalmente, nesses casos, de suspensão cautelar dos processos ou de julgamento dos feitos até a deliberação definitiva do Supremo Tribunal Federal (Lei n. 9.882/99, art. 5º, § 3).

Assim, vemos que existe:

ADPF DIRETA	Já se inicia como controle concentrado
ADPF INDIRETA	Inicia-se como controle difuso

Legitimidade Ativa

Trata-se de processo objetivo. Assim, possuem legitimidade todos aqueles que podem propor ADC e ADI. No projeto original da lei regulamentar, estava prevista a legitimidade do cidadão, que foi vetada. Assim, não podem eles propor tal ação, apesar de poderem representar ao PGR para que venha a propor se assim entender.

Legitimidade Passiva

Ocupa o polo passivo como requerido o órgão que participou da edição da norma ou ato que viola ou tende a violar o preceito fundamental.

Cabimento

Como visto, é cabível para a proteção de preceito fundamental, e não de qualquer dispositivo da CF. **Preceito fundamental difere de princípio, sendo o preceito mais amplo que o princípio, já que envolve, além deste, direitos e garantias fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana.**

São três as hipóteses de cabimento:

- ADPF autônoma preventiva - Para **evitar lesão** a PF, resultante de ato do poder público; a ADPF preventiva não é preventiva quanto à natureza do objeto, ela é preventiva quanto à lesão e não se o objeto está aperfeiçoado ou não. **A ADPF preventiva não tem o mesmo conceito de controle de constitucionalidade preventivo.** O controle de constitucionalidade preventivo é feito antes do aperfeiçoamento do ato normativo. A ADPF preventiva é aquela que evita a lesão advinda de uma lei ou ato perfeito, mas cuja lesão não ocorreu. Logo, **enquanto nas demais ações de controle concreto a prevenção se dirige à higidez do ordenamento jurídico, na ADPF a prevenção se dirige a um fato lesivo.**

- ADPF autônoma repressiva/reparatória - Para **reparar lesão** a PF, resultante de ato do poder público;

- ADPF incidental - Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à CF (diferente da ADI e ADC, incabíveis para atos anteriores à CF e para atos municipais) – inconstitucional para Alexandre Moraes por extrapolar a competência constitucional do 102, § 1º, da CF, pela via de lei ordinária.

Entretanto, **o STF já admitiu o ajuizamento de ADPF em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, ou estadual, ou municipal, incluídos os anteriores à CF, ainda que, excepcionalmente, revogados.**

Há que se ressaltar que, em ambas as hipóteses (autônoma e incidental), tratam-se de processos **objetivos** de controle de constitucionalidade, uma vez que, **até na ação incidental, o STF não julgará a lide deduzida nas instâncias inferiores, como em uma advocatória, mas decidirá apenas a controvérsia constitucional**, em similitude com o recurso constitucional alemão e o recurso de amparo espanhol.

Em função justamente do princípio da subsidiariedade, a ADPF tem certas diferenças em relação à ADI e à ADC:

- Cabível para atos de municípios (ADC não cabe nem para atos estaduais);
- Cabível para atos concretos – com isso é possível que uma mera decisão liminar de um juiz de 1º grau vá para o **STF** via ADPF;
- Cabível para atos anteriores à CF;
- Cabível para atos revogados;
- Cabível para a declaração de constitucionalidade de lei estadual ou municipal, caso o questionamento de sua legitimidade gere lesão a preceito fundamental (Gilmar Mendes);
- Cabível para interpretações judiciais de preceitos fundamentais.

A ADPF não é cabível em face de:

- Decreto regulamentar que exorbita dos poderes regulamentares (se trata de ilegalidade, mera ofensa reflexa à Constituição);
- Orientação do **STF** com vias a esclarecer a posição da Corte;
- Súmulas de orientação jurisprudencial;
- Cancelamento, revisão ou interpretação de súmula vinculante.

O Princípio da Subsidiariedade

Quando for cabível outra ação **eficaz** para sanar a lesividade (art. 4º, § 1º, Lei nº 9.882/99), incabível será a ADPF; é preciso, em primeiro lugar, esgotar todas as vias possíveis.

Nesse sentido, se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), **meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata**. Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não será admissível a arguição de descumprimento. Em sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade— isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata — há de se entender possível a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental²⁷.

Também é possível que se apresente arguição de descumprimento com **pretensão de ver declarada a constitucionalidade de lei estadual ou municipal que tenha sua legitimidade questionada nas instâncias inferiores**. Tendo em vista o objeto restrito da ação declaratória de constitucionalidade, não se vislumbra aqui meio eficaz para solver, de forma ampla, geral e imediata, eventual controvérsia instaurada. Afigura-se igualmente legítimo cogitar de utilização da arguição de descumprimento nas controvérsias relacionadas com o princípio da legalidade (lei e regulamento), uma vez que, assim como assente na jurisprudência, tal hipótese não pode ser veiculada em sede de controle direto de constitucionalidade.

Há uma controvérsia no **STF** sobre se a ADPF será cabível quando a inexistência do meio eficaz se referir a outra ação de controle abstrato de constitucionalidade, ou se será cabível quando inexistir qualquer outro meio, ainda que difuso.

O Min. Gilmar Mendes defende que só cabe se não for caso de ADI, ADC ou ADO; já o Min. Celso de Melo lidera a posição majoritária, que defende que o preceito se refere a qualquer ação, desde que eficaz.

Importante, entretanto, ter em mente uma coisa: a existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, *a priori*, a utilização da ADPF. Isso porque a análise dos demais instrumentos para sanar a lesão aos preceitos fundamentais deve proceder a exclusão da ADPF, já que poderão eles não se demonstrarem efetivos.

Assim, a análise do cabimento da ADPF leva à seguinte pergunta: os meios existentes para sanar a lesão ao preceito fundamental são suficientes, de forma ampla, geral e imediata? Caso positivo, ela não será cabível. Caso negativo, será cabível.

Parâmetro de Controle

O paradigma na ADPF é a proteção do preceito fundamental, não havendo, portanto, proteção de normas constitucionais que não sejam consideradas preceitos fundamentais.

Sobre a noção de preceito fundamental não há definição na CF e nem legal. Não há até hoje no **STF** um debate teórico do que seria preceito fundamental. O **STF** vem afirmando circunstancialmente se uma determinada proposta é ou não é preceito fundamental; essa afirmação tem sido feita de forma circunstancial.

O que se tem de consenso na doutrina é que o preceito fundamental envolve somente normas **formalmente constitucionais** que tratem de dois objetos essencial e materialmente constitucionais: **A organização do Estado e a proteção dos direitos fundamentais**.

Existem controvérsias: a primeira se refere à inclusão dos direitos sociais no rol dos direitos fundamentais para fins de consideração de preceito fundamental. Autores mais ligados a direito de pensamento ideológico, como o Min. Gilmar Mendes, tendem a excluir os direitos sociais do rol dos preceitos fundamentais. Mas a maioria dos autores de direito constitucional tem viés de esquerda, e, além disso, me parece que tem fundamental jurídico mais consistente de interpretar uma constituição social. A constituição brasileira é social, ela não é somente liberal. Autores do calibre de Paulo Bonavides, José Afonso e Barroso, tendem a incluir os direitos sociais no rol dos preceitos fundamentais.

Assim, **repita-se: não há parâmetro exato de controle para a ADPF; mesmo porque ninguém sabe ao certo o que seria preceito fundamental; variará de acordo com o entendimento de cada Ministro do STF**. Entretanto, algumas casuísticas já firmaram o que certamente se encaixaria na noção do instituto:

²⁷ ADPF 76, rel. min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 13-2-2006, DJ de 20-2-2006.

- a) Direitos e garantias individuais;
- b) Princípios protegidos por cláusulas pétreas (art. 60, § 4º);
- c) Princípios sensíveis (art. 34, VII);
- d) Princípio da legalidade.

Assim, vê-se que a ADPF apresenta duas características que a fazem se diferenciar e muito dos demais instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade.

Se por um lado o paradigma da ADPF é menor do que da ADI (por não envolver toda a Constituição, emendas constitucionais e tratados de direitos humanos²⁸ recepcionados como emenda), por outro, o objeto da ADPF é muito mais amplo do que da ADI, por envolver também lei ou ato normativo federal, estadual, municipal e direito pré-constitucional.

Ademais, a lei fala em “ato do Poder Público”, no que certamente se envolve também a omissão quando não for caso de ADO ou outra ação eficaz.

A Questão do Direito Pré-Constitucional

Quando o STF, em ADPF, analisa uma lei anterior à CF, ele não declara a sua inconstitucionalidade. Ele continua dando um caráter do fenômeno da lei no tempo, só que a análise é concentrada da recepção. O STF não declara a inconstitucionalidade da norma anterior à CF/88 só porque está sendo analisado em ADPF. Em controle difuso quando o juiz se depara com análise de norma anterior à CF/88, a incompatibilidade desta norma anterior à CF ele declara a invalidade, ou diz que a norma continua em vigor ou considera revogada? **Ele diz que a norma continua em vigor ou considera-se revogada.** É exatamente esta conclusão quando o STF chega numa ADPF quando ele analisa norma anterior à CF. Essa foi a conclusão da ADPF nº 130, que declarou não ter sido recepcionada toda a lei de imprensa

Procedimento

Petição inicial contendo:

- a) A indicação do preceito fundamental que se considera violado;
- b) A indicação do ato questionado;
- c) A prova da violação do preceito fundamental,
- d) O pedido com suas especificações;
- e) Se for o caso, a demonstração da controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental questionado.

Ao autor da arguição de descumprimento de preceito fundamental cabe apresentar, juntamente com a petição inicial em duas vias, cópias do ato questionado e documentos necessários à comprovação do alegado. Aludida disposição prevê, também, a necessidade de serem as petições acompanhadas, quando subscritas por advogado, de instrumento de procuração.

A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, em caso de manifesta inadequação da ação, na hipótese de não atendimento de qualquer dos requisitos legais ou, ainda, em caso de inépcia da inicial (art. 4º, caput). Da decisão de indeferimento caberá agravo no prazo de cinco dias (art. 4º, § 2º).

Apesar de não haver previsão expressa na lei, não cabe desistência na ADPF, já que se trata de processo objetivo.

Perfeitamente admissível o *amicus curiae*.

A Lei nº 9.882/99 prevê a possibilidade de o relator autorizar a audiência das partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos e determinar a realização de audiências públicas com *experts* (art. 6º, § 1).

AGU e PGR

O AGU é citado quando há discussão de controvérsia de constitucionalidade de uma norma. Então, ele não é citado sempre; não é citado, por exemplo, se o objeto for o reconhecimento da não recepção.

²⁸ A primeira foi A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, foi incorporada ao Direito brasileiro com status de norma constitucional nos termos do art. 5º, § 3º, da CF, haja vista sua aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

O PGR é intimado na qualidade de *custos legis*. Há um detalhe que na prática não é aplicado pelo STF. A Lei nº 9.882/99 prevê a intimação do PGR nas ADPF que não tenham sido provocadas por ele. Só que o STF abre vistas sempre para o PGR e não apenas nas ações que ele não tenha provocado. Para efeito de concurso, **se vier alusão à Lei nº 9.882/99, realmente a lei prevê a intimação do PGR nas ADPFs que ele não tiver proposto.**

Em provas de concurso, caso haja alusão “na forma da lei”, a melhor resposta seria que a Lei nº 9.882/99 não prevê a intimação sempre, mas o regimento interno e a prática do STF prevê intimação.

Lei	Prevê intimação do PGR somente quando ele não tiver proposto a ADPF
STF	Sempre intima o PGR, mesmo quando foi ele quem propôs.

Medida Cautelar

Perfeitamente cabível, mediante decisão de maioria absoluta, com quórum de instalação da sessão de julgamento de 2/3 dos Ministros, e de concessão da maioria absoluta.

Além da possibilidade de decretar a suspensão direta do ato impugnado, admite-se na cautelar prevista para a arguição de descumprimento **a determinação de que os juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que guarde relação com a matéria discutida na ação** (art. 5º, § 3º). Confere-se, assim, ao Tribunal um poder cautelar expressivo, impeditivo da consolidação de situações contra a possível decisão definitiva que venha a tomar.

Decisões e Efeitos

Tendo por objeto o direito pré-constitucional, deverá o Tribunal limitar-se a reconhecer a legitimidade (recepção) ou não da lei, em face da norma constitucional superveniente. Incidindo, porém, sobre ato de efeito concreto (ato administrativo singular, sentença), o tribunal afirmará sua ilegitimidade.

Pode ser que o ato singular questionado (v. g., uma decisão judicial) afirme a inconstitucionalidade de uma lei ou de uma dada aplicação ou interpretação do próprio texto constitucional. Nessa hipótese, reconhecida a procedência da ação de descumprimento de preceito fundamental, ter-se-á a declaração de ilegitimidade do ato questionado, com a afirmação da constitucionalidade da lei ou da aplicação constitucional discutida.

A ADPF pode servir para realizar controle de constitucionalidade? Pode. A ADPF até pode ser utilizada para fins de controle de constitucionalidade, mas ela não é somente uma ação de controle. **A ADPF tem por pretensão a proteção de preceito fundamental. Esta proteção pode levar a uma decisão multifacetada. A decisão pode ser de interpretar um paradigma, pode ser uma decisão de interpretação do objeto.** Não se pode dizer abstratamente qual é a natureza da decisão da ADPF. Repito: dependerá do objeto.

Perfeitamente possível a modulação dos efeitos temporais mediante decisão fundamentada de 2/3 dos Ministros, para que ela seja *ex nunc* ou a partir de um momento fixado.

Efeitos do julgamento da ADPF:

- a) Eficácia *erga omnes*;
- b) Efeito vinculante;
- c) Repristinação;
- d) Natureza dúplice.

Fungibilidade entre ADI e ADPF

O Supremo já entendeu que a ADI pode ser recebida como se ADPF fosse, caso presentes os requisitos desta e ausentes o daquela.



18 Declaração de direitos: histórico; teoria jurídica e teoria política.

A evolução dos Direitos Humanos está intrinsecamente ligada a questões sociais, econômicas e culturais, moldando-se de acordo com a mobilização social para garantir que suas demandas possam ser atendidas.

Difícil traçar um marco cronológico para a evolução dos direitos humanos, haja vista a complexidade dos fatos e a identificação de pontos aleatórios para traçar tal análise²⁹. Contudo, através do estudo do Direito Natural é possível identificar que os direitos humanos existem desde os primórdios dos tempos.

O Direito Natural é o conjunto dos direitos à vida, à segurança pessoal, à liberdade e à igualdade, pois são inerentes ao indivíduo desde o **seu nascimento**, sendo, portanto, justo por natureza.

“No início da História, o direito teve raízes fincadas na dinâmica da natureza, porque o homem era movido pelas leis naturais da sobrevivência.

Tales de Mileto, nascido por volta do ano 600 a.C., é considerado o mais antigo filósofo ocidental. Fundou a Escola de Mileto, cujos principais pensadores foram Anaximandro e Anaxímenes.

A Escola de Mileto postulava que os elementos da natureza (physis), especificamente água, ar, fogo e terra, eram os condicionantes da vida humana. Como nada escreveram, essa teoria chegou até nós por meio dos filósofos que vieram depois de Sócrates. Segundo ela, o destino dos homens era regido por fenômenos naturais, principalmente aqueles ocasionados pela água, que seria o princípio de todas as coisas e estava em todas as coisas. Por isso, Tales de Mileto e seus seguidores eram chamados de filósofos naturalistas. Esse pensamento, baseado no bom senso e na equidade (segundo definição dada por Aurélio Buarque de Holanda), inspirou o Direito Natural. As primeiras noções do Direito Natural surgem principalmente com os estudos do filósofo Aristóteles, que definiu duas concepções complementares: o justo legal (dikaion nomikón) e o justo natural (dikaion physikón).

O Direito Natural também é chamado Jusnaturalismo.

Antonio Fernández-Galiano, no artigo “El jusnaturalismo”, inserido no livro Lecciones de teoría del derecho y derecho natural, de Benito de Castro Cid (1999 – p. 419-420), diz o seguinte:

... o jusnaturalismo afirma a existência de uma ordem preceptiva de caráter objetivo, imutável e derivada da natureza, que não pode contrariar os mandamentos dos homens e na qual encontra esse direito humano sua fonte e fundamento.

Mas o entendimento da noção do que seja o jusnaturalismo modificou-se ao longo dos tempos.”³⁰

O primeiro conceito de jusnaturalismo, foi o **Jusnaturalismo clássico**, que trazia em sua essência a ideia de que o fundamento do direito é a natureza das coisas, ou seja, a ordem natural da natureza, que deve ser seguida, pois, segundo Aristóteles, por exemplo, o que é natural é bom e justo. Esta primeira ideia de jusnaturalismo acredita-se que adveio com a Antígona, de Sófocles, onde há a invocação de leis divinas para justificar a desobediência às ordens dadas pelos reis.

Com o passar do tempo o direito passou a ser considerado uma herança divina, momento no qual surgiu o **Jusnaturalismo Teológico**, tendo como fundamento as leis concedidas por Deus. Referida posição imperou até a Idade Média, até onde prevaleceu as convicções religiosas. Um dos primeiros pensadores desse tipo de naturalismo foi Heráclito, que defendia a ideia de que o Universo era governado por uma lei divina.

²⁹ AGRA. Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição. Ed. Forense. 2010

³⁰ Sinopses Jurídicas. Direitos Humanos. Ricardo Castilho. Editora Saraiva. 2011

Posteriormente, surgiu o **jusnaturalismo escolástico (ou tomista)**, onde acreditavam que o direito tinha como base os mandamentos divinos, advindos da “lei eterna”. Para estes pensadores cristãos, como Santo Tomás de Aquino, dentro desses mandamentos haviam as leis naturais e as leis humanas e que a lei natural estabelece hierarquia entre as criaturas, mas que só é justa se baseada na lei eterna, na qual Deus é o fundamento de todas as coisas.

Um dos primeiros pensadores do **jusnaturalismo racional** foi o holandês Hugo Grotius. Ele o definiu desta maneira: *“Ditame da justa razão, destinado a mostrar que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário segundo seja ou não conforme a própria natureza racional do homem, e a mostrar que tal ato é, em consequência disto, vetado ou comandado por Deus, enquanto autor da natureza”*. Este trecho está no livro de Norberto Bobbio, *O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito*.³¹ Para este pensador, o fundamento do direito é o homem, que analisa as leis da natureza e as aplica. A base desse pensamento foi elaborada por Zenon e os estoicos, mas a essência já estava em Protágoras, cuja célebre fórmula determinava que o homem é a medida de todas as coisas. O jusnaturalismo racional foi, mais tarde, adotado pelos romanos, mas profundamente modificado nos séculos XVII e XVIII, quando se passou a atribuir à razão, por meio das ciências, o descobrimento da verdade, e não mais à entidade divina. Surgia, então, uma nova conceituação para o Direito Natural.³²

Nos séculos XIX e XX surgiu o **jusnaturalismo contemporâneo**, considerando que o direito precisa de um fundamento ético justo, ou seja, o direito precisa ser analisado de acordo com o plano histórico e social, considerando a variação da justiça no tempo e no espaço. Um dos pensadores desse jusnaturalismo foi Joaquín Herrera Flores.

Importante ressaltar o contraponto do Direito Natural, qual seja, o Direito Positivo.

O direito positivo, também chamado de juspositivismo que direito é somente o conjunto de leis postas pelo Estado, que define o que é justo por convenção ou justo por lei.

“O pensador Thomas Hobbes, no livro *Leviatã* (publicado em 1651) analisou cuidadosamente as leis da natureza e chegou à conclusão de que elas somente funcionariam se fossem respeitadas por todos. Mas considerou impossível essa obediência, porque achava que os homens são egoístas e somente poderiam viver em harmonia se estivessem subordinados a uma autoridade que fiscalizasse o cumprimento das leis naturais. Numa análise que considerava realista, definiu que havia grande perigo na falta de uma autoridade central, porque os homens em situação de igualdade tinham o mesmo direito a todas as coisas; o que ocorreria quando duas pessoas desejassem a mesma coisa e se considerassem donas dessa coisa?”

Cada uma tentaria tomar posse do objeto à força e acabariam deflagrando guerras generalizadas. Nessas guerras, nem sempre valeria a lei do mais forte, porque mesmo o fraco poderia lançar mão de recursos e desenvolver armas para vencer o oponente teoricamente mais poderoso. Por isso, Hobbes desenvolveu a teoria em que defendia o absolutismo, ou seja, o poder absoluto ao rei, ao governante que representava o Estado. Haveria entre os cidadãos e a autoridade um “pacto social”, pelo qual os homens abriam mão de parte de sua liberdade, para permitir que o rei (o Estado) cuidasse de todos, garantindo direitos e cobrando obrigações. Essa era a teoria, mas na prática sabemos que o absolutismo levou os reis a pensarem que eram donos dos destinos dos súditos. Houve até a publicação de obras de filosofia que demonstravam que os reis tinham poder originado dos deuses. Uma dessas obras foi *A Política* tirada da Sagrada Escritura, de Jacques Bossuet, publicada em 1701, da qual o rei Luís XIV, da França, lançou mão para justificar suas decisões totalitárias. É famosa uma frase de Luís XIV: “L’Etat c’est moi” (“O Estado sou eu”).

“Curiosamente, nessa época, a Inglaterra já havia abandonado os princípios da doutrina do direito divino dos reis, desde a Revolução Gloriosa de 1688, que expulsou os católicos do poder.”³³

Augusto Comte é considerado o pai do positivismo sociológico, porque sistematizou a doutrina, em obras que publicou a partir de 1816. Mas o conceito já existia em Roma, quando o imperador Justiniano criou um código legislativo para regular os povos conquistados e que firmou a base do Direito Romano. O conceito juspositivista também estava incluído em obras de autores como Descartes, Humes e Kant, que publicaram livros por volta de 1750. E é preciso considerar também o Código Napoleônico (também conhecido como Código Civil Francês), já em 1804, na Idade Moderna, fortemente influenciado pelo Direito Romano. Sua aceitação foi ampla em razão de a França ter sido berço da revolução que brandiu os conceitos básicos dos direitos humanos modernos: liberdade, igualdade e fraternidade. O avanço principal do Código Napoleônico foi a noção da separação dos poderes. No livro *Memorial de Santa Helena*, escrito em 1817 por Emmanuel Les Cases, Napoleão Bonaparte incluiu a seguinte reflexão:

³¹ *Idem*

³² *Idem*

³³ *Ibidem*

Minha verdadeira glória não foi ter vencido quarenta batalhas; Waterloo apagará a lembrança de tantas vitórias; o que ninguém conseguirá apagar, aquilo que viverá eternamente, é o meu Código Civil”.

O Código de Napoleão deu origem a chamada **Escola Exegética**, que determinava que o juiz deve julgar estritamente de acordo com a lei criada pelo poder legislativo. Referido Código reconhece o direito natural, mas privilegia o direito positivo como forma de atuação do Estado, aplicando-se o Direito Natural apenas nos casos em que haja conformidade. Referido código foi fundamental para o desenvolvimento do direito no mundo ocidental contemporâneo, já que foi a primeira codificação do direito e fundamental para o direito atual.

Em suma, o Direito Positivo é norteado estritamente nas leis impostas pelo homem, havendo punição real e concreta pelo seu descumprimento. Já o Direito Natural, se baseia no que é justo por natureza, tempo como fonte a ordem natural das coisas, a moral, a justiça, não havendo, portanto, punição no plano concreto, mas apenas no plano moral.

Apesar de tais diferenças, e do fato do Direito contemporâneo ser baseado no Direito Positivo, não é possível excluir o direito natural na interpretação das leis, do contrário, haveria o risco de grandes injustiças, apoiado em leis frias, não interpretadas de acordo com a moral e a ética, aplicadas no caso concreto. Além disso, o risco do legislador tornar-se totalitário seria enorme.

O Direito Positivo, orientado também pelo Direito Natural, auxilia na correta distribuição da Justiça e ordem social.

Ademais, para preservar os direitos humanos é preciso levar em conta que o direito muda ao longo do tempo, tendo em vista que os valores mudam, os costumes mudam, e por isso a interpretação das leis também é modificada com o tempo.

A Magna Carta de 1215, é o primeiro documento escrito que consagra os direitos humanos, assinado obrigatoriamente pelo rei da Inglaterra, João Sem-Terra. Neste documento, pela primeira vez na história foram listados os direitos das pessoas em relação ao poder da autoridade e é a base das Constituições Modernas.

“A história começa quando o rei Ricardo da Inglaterra, conhecido como Coração de Leão, seguiu para o Oriente, para combater nas cruzadas. Seu irmão, o príncipe João, assume o trono e estabelece para si mesmo prerrogativas que desagradaram profundamente os seus aliados, principalmente os barões. Entre essas prerrogativas estava o Direito de Nomeação, segundo o qual o soberano podia nomear bispos, abades e funcionários eclesiásticos, e o Direito de Veto, segundo o qual o soberano podia excluir pessoas de determinadas funções ou impedir que tomassem posse. Quando foi escolhido para a função de arcebispo o religioso Stephen Langton, o rei João não o aceitou e usou contra ele o Direito de Veto. O arcebispo Langton tinha sido escolhido pelo próprio papa Inocêncio III, e a posição do rei iniciou uma grande revolta da Igreja. Aproveitando-se da situação, os barões que formavam a corte real apoiaram o pontífice, exigindo que o rei renunciasse a direitos que consideravam exagerados. O movimento revoltoso ganhou força, e foram levadas ao rei duas exigências: que promettesse respeitar a lei e que admitisse que a vontade do rei não era mais forte do que a lei. Os barões queriam um documento escrito, com essas promessas, e para consegui-lo ameaçaram liderar os aldeões medievais, no seu legítimo direito de rebelar-se, previsto no *pactum subjectionis*.

No início do século XVIII, os cidadãos não aceitavam mais a tese do absolutismo dos reis nem o pretexto de que o poder dos soberanos provinha dos deuses. A própria palavra de São Paulo (*omnis potestas a Deo* = todo poder vem de Deus) começava a ser questionada.

Entrava em cena a ideologia revolucionária chamada liberalismo, que defendia a liberdade individual. A partir desse pensamento, a sociedade política da época fez um acordo de convivência com a autoridade real, o *pactum subjectionis* (pacto de sujeição), que funcionava assim: os aldeões, religiosos e nobres concordavam em subordinar-se a um senhor que, em troca, cuidaria de manter o país protegido pelo exército, organizar a produção agrícola e pecuária, cuidar do comércio e guardar as fronteiras. Nesse pacto estava previsto que, se os cidadãos não concordassem com as decisões do rei, tinham o direito de rebelar-se. No entanto, era um acordo tácito. Não havia documento escrito que o legitimasse. Por isso mesmo os barões da Inglaterra queriam que João Sem-Terra assinasse um documento que tornasse oficial a sua promessa de respeitar as liberdades individuais.”³⁴

A partir da Magna Carta foi implementada a monarquia constitucional inglesa, imitada mais tarde pelo mundo ocidental, apesar de em 1215 ter sido criada apenas para controlar o comportamento tirano do rei João Sem-Terra.

A cláusula mais conhecida da Magna Carta é a 39, que contém em seu texto o seguinte:

³⁴ Sinopses Jurídicas. Direitos Humanos. Ricardo Castilho. Editora Saraiva. 2011

Nenhum homem livre será preso, encarcerado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra.

Em síntese, a Magna Carta foi o primeiro documento escrito a resguardar direitos humanos, criada para limitar o comportamento tirano do rei João Sem-Terra da Inglaterra, que foi forçado a assinar o documento, sob ameaça dos barões de liderarem uma revolta dos aldeões. Além disso, referido documento foi a base para as constituições modernas, notadamente com observância ao artigo 40:

“A ninguém venderemos, nem a ninguém recusaremos ou atrasaremos o direito ou a justiça”.

Com o *Bill of Rights* da Virgínia há um maior desenvolvimento dos direitos fundamentais, ocorrendo a positivação dos direitos imprescindíveis ao desenvolvimento humano. Ele foi importante pela afirmação de que os homens possuem direitos que são inerentes a sua própria natureza, de acordo com os ideais jusnaturalistas; e por asseverar que todos são livres e iguais, sem distinção de qualquer natureza, no que contribuiu para sepultar a ideia de superioridade da realeza e da nobreza advindas da idade média.³⁵

Em 1789, a Assembleia Nacional da França votou a Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão, importante documento para mudança das relações entre Direitos humanos e Estado, positivando as prerrogativas do homem e obrigando os entes estatais a respeitá-los e garanti-los. Referida Declaração tinha o escopo de levar a ideia de liberdade a todos os povos e a todos os tempos, tendo, portanto, caráter universal.

Outro documento importante para evolução dos Direitos Humanos foi a Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, a primeira a defender a doção de direitos sociais, garantindo prestações mínimas que deveriam ser providas pelos entes estatais. Tal declaração surgiu em decorrência da Revolução Bolchevique de 1917 e conferiu direitos as mulheres, restringiu a propriedade privada, expandiu as liberdades associativas e colocou, em nível teórico, os trabalhadores como classe dominante da sociedade.

Um marco muito importante para a evolução do conceito de Direitos que conhecemos atualmente foi a Segunda Guerra Mundial, na qual ocorreram incontáveis atrocidades, como, por exemplo, a morte de milhões de judeus. Com o fim dessa Guerra, em 1945 foi assinada a Carta de Organização das Nações Unidas, que tem por fundamento o princípio da igualdade soberana de todos os Estados que buscam a paz e, em 10 de dezembro de 1948 a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Alexandre de Moraes³⁶ lembra que a Declaração dos Direitos Humanos foi a mais importante conquista no âmbito dos direitos humanos fundamentais em nível internacional, muito embora o instrumento adotado tenha sido uma resolução, não constituindo seus dispositivos obrigações jurídicas dos Estados que a compõem. O fato é que desse documento se originam muitos outros, nos âmbitos nacional e internacional, sendo que dois deles praticamente repetem e pormenorizam o seu conteúdo, quais sejam: o Pacto Internacional dos Direitos Cívicos e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966.

Posteriormente, surgiram muitos outros pactos importantes para o desenvolvimento dos direitos humanos, como: Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção contra a Tortura, etc.

Além do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, surgiram os sistemas regionais, que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano regional, em especial na Europa, na América e na África³⁷. Desse Sistema Regional surgiu em 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Em âmbito nacional, destaca-se a Constituição Federal, que positivou direitos humanos e conforme explica Lafer³⁸, a afirmação do jusnaturalismo moderno de um direito racional, universalmente válido, gerou implicações relevantes na teoria constitucional e influenciou o processo de codificação a partir de então. Embora muitos direitos humanos também se encontrem nos textos constitucionais, aqueles não positivados na Carta Magna também possuem proteção porque o fato de este direito não estar assegurado constitucionalmente é uma ofensa à ordem pública internacional, ferindo o princípio da dignidade humana.

³⁵ AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição. Ed. Forense. 2010

³⁶ MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. Ed. Atlas. São Paulo. 1997.

³⁷ PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9 ed. São Paulo. Saraiva. 2008.

³⁸ LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: Cia. Das letras. São Paulo. 2009



19 Direitos Políticos. Processo Eleitoral. Condições de elegibilidade e inelegibilidade. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Partidos Políticos.

Direitos políticos são os direitos do cidadão que permitem sua participação e influência nas atividades de governo.³⁹ Para **Pimenta Bueno**, citado por **José Afonso da Silva**⁴⁰, os direitos políticos são **“as prerrogativas, atributos, faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos.”**

Para **Gomes**⁴¹, direitos políticos são **“as prerrogativas e os deveres inerentes à cidadania. Englobam o direito de participar direta ou indiretamente do governo, da organização e do funcionamento do Estado.”**

A Constituição Federal de 1988 dedica o capítulo IV do título II, referente aos direitos e garantias fundamentais, aos direitos políticos.⁴² O tema direitos políticos compreende os institutos do direito de sufrágio, sistemas eleitorais, privação dos direitos políticos e inelegibilidades.

Sufrágio e Voto

O direito de sufrágio é exercido praticando-se o voto. Na Constituição Federal, está previsto o voto secreto, obrigatório, direto e igual para todos os brasileiros. O voto é secreto porque seu conteúdo não pode ser revelado pela Justiça Eleitoral, que deve garantir ao eleitor que seu voto será resguardado e mantido em sigilo. É direto e igual porque o eleitor brasileiro escolhe seus governantes sem intermediários, e cada pessoa tem direito a único voto de igual valor.

Por fim, o voto é obrigatório, porque, além de um direito, é também um dever jurídico, social e político. A Constituição declara que, no Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.

Tipos de sufrágio

Do latim *“sufragium”*, apoio. Representa o direito de votar e ser votado e é considerado universal quando se outorga o direito de votar a todos que preencham requisitos básicos previstos na Constituição, sem restrições derivadas de condição de raça, de fortuna, de instrução, de sexo ou de convicção religiosa. O sufrágio restrito (qualificativo) é aquele só conferido a pessoas que preencham determinadas condições de nascimento, de fortuna etc. Pode ser restrito censitário (quando impõe restrições vinculadas à capacidade econômica do eleitor – por exemplo: As Constituições de 1891 e 1934 vedavam o voto dos mendigos) ou restrito capacitário (pela Constituição Federal de 67 e até a Emenda Constitucional 25/85, o analfabeto não podia votar). O sufrágio identifica um sistema no qual o voto é um dos instrumentos de deliberação.

O sufrágio é universal porque todos os cidadãos do país podem votar, não sendo admitidas restrições fundadas em condições de nascimento, de capacidade intelectual, econômicas ou por motivos étnicos.

³⁹ <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/direitos-politicos-e-sufragio-roiteiros-eje>. Acesso em 17/06/2015.

⁴⁰ SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 345.

⁴¹ GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 4.

⁴² Artigos 14 a 16 da CF 88.

Sistemas eleitorais

O sistema eleitoral é o procedimento que vai orientar o processo de escolha dos candidatos.

Para **José Afonso da Silva**⁴³, sistema eleitoral é **“o conjunto de técnicas e procedimentos que se empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo no território nacional”**. **José Jairo Gomes**⁴⁴ igualmente conceitua o sistema eleitoral como **“o complexo de procedimentos empregados na realização das eleições”**. São conhecidos três tipos de sistemas eleitorais:

- a) Majoritário
- b) Proporcional
- c) Misto

O sistema majoritário é aquele em que são eleitos os candidatos que tiveram o maior número de votos para o cargo disputado. Por esse sistema são disputadas, no Brasil, as eleições para os cargos de presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. Deve-se observar, ainda, que, para os cargos de presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de duzentos mil eleitores, é necessária a obtenção da maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, no primeiro turno, sob pena de se realizar o segundo turno com os dois candidatos mais votados.

O sistema proporcional, por sua vez, é utilizado para os cargos que têm várias vagas, como vereadores e deputados, e por ele são eleitos os candidatos mais votados de cada partido ou coligação.

Tal sistema objetiva distribuir proporcionalmente as vagas entre os partidos políticos que participam da disputa e, com isso, viabilizar a representação de todos os setores da sociedade no parlamento.

A ideia do sistema proporcional é de que a votação seja transformada em mandato, na ordem da sua proporção, isto é, o partido que obtiver, por exemplo, 10% dos votos deve conseguirmos transformá-los em torno de 10% das vagas disputadas. Por fim, o sistema misto é aquele que procura combinar o sistema proporcional com o sistema majoritário. Muito se tem debatido sobre sua implantação no Brasil e há propostas para que esse sistema seja chamado de distrital misto, já que, por ele, parte dos deputados é eleita pelo voto proporcional e parte pelo majoritário.

O alistamento eleitoral (capacidade eleitoral ativa)

Cabe privativamente à União legislar sobre matéria eleitoral. Tanto o Presidente da República quanto o Tribunal Superior Eleitoral podem expedir as instruções que julgarem convenientes à boa execução das leis eleitorais; poder regulamentar que excepcionalmente pode ser exercido também pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas suas respectivas circunscrições.

O alistamento eleitoral (integrado pela qualificação e pela inscrição) e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos. São facultativos, contudo, para o analfabeto, para os maiores de dezesseis anos (até a data do pleito, conforme prevê o art. 12 da Resolução n. 20.132/98) e menores de dezoito, bem como para os maiores de setenta anos.

O art. 7.º do Código Eleitoral especifica as sanções para quem não observa a obrigatoriedade de se alistar e votar. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou se justificou devidamente, o eleitor não poderá obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso público, receber remuneração dos entes estatais ou paraestatais, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino etc.

Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, o conscrito (aquele que, regularmente convocado, presta o serviço militar obrigatório ou serviço alternativo, incluindo-se no conceito os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam o serviço militar obrigatório após o encerramento da faculdade). O conscrito que se alistou e adquiriu o direito de voto antes da conscrição tem sua inscrição mantida, mas não pode exercer o direito de voto até que o serviço militar ou alternativo esteja cumprido.

As condições de elegibilidade (capacidade eleitoral passiva)

São condições de elegibilidade, na forma da lei:

- A nacionalidade brasileira (observada a questão da reciprocidade, antes destacada quanto aos portugueses, e que apenas alguns cargos são privativos de brasileiros natos);
- O pleno exercício dos direitos políticos;

⁴³ Op. Cit. p. 368.

⁴⁴ Op. Cit. p. 109.

- O alistamento eleitoral (só pode ser votado quem pode votar, embora nem todos que votam possam ser votados – como o analfabeto e o menor de 18 e maior de 16 anos);
- O domicílio eleitoral na;
- A filiação partidária (pelo menos um ano antes das eleições, nos termos do art. 18 da Lei Federal n. 9.096/95);
- A idade mínima de 35 anos para Presidente da República, Vice-Presidente da República e Senador; a idade mínima de 30 anos para Governador e Vice-Governador; a idade mínima de 21 anos para Deputado (Federal, Distrital ou Estadual), Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz (mandato de 4 anos – art. 98, II, da CF) e a idade mínima de 18 anos para Vereador.

A aquisição da elegibilidade, portanto, ocorre gradativamente. De acordo com o § 2.º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, a idade mínima deve estar preenchida até a data da posse. Há, contudo, entendimento jurisprudencial no sentido de que o requisito da idade mínima deve estar satisfeito na data do pleito. Não há idade máxima limitando o acesso aos cargos eletivos.

Direitos políticos negativos

São as circunstâncias que acarretam a perda ou suspensão dos direitos políticos, ou que caracterizam a inelegibilidade, restringindo ou mesmo impedindo que uma pessoa participe dos negócios jurídicos de uma nação.

As inelegibilidades (que podem ser previstas pela CF ou por lei complementar): **São absolutamente inelegíveis**, ou seja, inelegíveis para qualquer cargo eletivo em todo o território nacional, os inalistáveis (incluídos os conscritos e os estrangeiros) e os analfabetos. O exercício do mandato não afasta a inelegibilidade, conforme estabelece a Súmula nº 15 do TSE.

São relativamente inelegíveis (só atinge a eleição para determinados cargos ou em determinadas regiões) os menores de 35 anos de idade (que não podem ser candidatos a Senador, Presidente da República ou Vice-Presidente da República) e, no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins (afins são os parentes do cônjuge), até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador, de Prefeito ou de quem os haja substituído nos seis meses anteriores ao pleito, salvo se o candidato já for titular de mandato eletivo e concorrer à reeleição (continuidade do mesmo cargo). Os parentes e o cônjuge, porém, são elegíveis para quaisquer cargos fora da jurisdição do respectivo titular do mandato e mesmo para cargo de jurisdição mais ampla.

Exemplo: O filho de um Prefeito Municipal pode ser candidato a Deputado, a Senador, a Governador ou a Presidente da República, ainda que não haja desincompatibilização de seu pai.

É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda (privação definitiva) ou suspensão (privação temporária) acontecerá em casos previstos no art. 15 da CF/88. A perda diferencia-se da suspensão porque nesta a requalificação dos direitos políticos é automática, e naquela, depende de requerimento. Os casos previstos são:

a) **Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado**: Somente os nacionais (natos ou naturalizados) e os portugueses com residência permanente no Brasil (preenchido o requisito da reciprocidade) podem alistar-se como eleitores e candidatos. O cancelamento da naturalização é hipótese de perda dos direitos políticos, e a Lei nº 818/49 prevê sua incidência em caso de atividades nocivas ao interesse nacional.

b) **Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa**: A recusa de cumprir obrigações a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VII, da CF, implica a perda dos direitos políticos, pois não há hipótese de restabelecimento automático. A Lei nº 8.239/91 incluiu a hipótese como sendo de suspensão dos direitos políticos, pois a qualquer tempo o interessado pode cumprir as obrigações devidas e regularizar a sua situação.

c) **Incapacidade civil absoluta**: São as hipóteses previstas na lei civil, em especial no art. 5º do Código Civil, e supervenientes à aquisição dos direitos políticos. Desde a Constituição Federal de 1946, a incapacidade civil absoluta está incluída como causa de suspensão dos direitos políticos.

d) **Condenação criminal transitada em julgado**: A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é causa de suspensão dos direitos políticos.

e) **Improbidade administrativa** (art. 15, V, da CF): A improbidade administrativa, prevista no art. 37, §4º, da CF, é uma imoralidade caracterizada pelo uso indevido da Administração Pública em benefício do autor da improbidade ou de terceiros, não dependendo da produção de danos ao patrimônio público material. Seu reconhecimento gera a suspensão dos direitos políticos do improbo.

f) **Condenação por crime de responsabilidade**: A condenação por crime de responsabilidade pode resultar na inelegibilidade do condenado por até oito anos, mas não afeta o direito de votar.

Ficha Limpa – A Lei Complementar nº 135/2010

A Lei Complementar nº 135/2010 modificou a lei das inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/90), acrescentando uma série de novas hipóteses de inelegibilidades relativas ao ordenamento jurídico.

Segundo seu artigo 1º, são inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

- a) os inalistáveis e os analfabetos;
- b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura;
- c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;
- d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
- e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
 - 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
 - 2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
 - 3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
 - 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
 - 5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
 - 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
 - 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
 - 8. de redução à condição análoga à de escravo;
 - 9. contra a vida e a dignidade sexual; e
 - 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
- f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos;
- g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
- h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
- i) os que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;
- j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura;

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;

n) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a fraude;

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22;

q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:

1 – os Ministros de Estado;

2 – os Chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República;

3 – o Chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;

4 – o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;

5 – o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;

6 – os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;

7 – os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;

8 – os Magistrados;

9 – os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, e fundações públicas e as mantidas pelo Poder Público;

10 – os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;

11 – os Interventores Federais;

12 – os Secretários de Estado;

13 – os Prefeitos Municipais;

14 – os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;

15 – o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;

16 – os Secretários-Gerais, os Secretários Executivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos Poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;

c) (Vetado.)

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;

e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os arts. 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de

setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5º da Lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas;

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes;

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão de Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses anteriores ao pleito;

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

III – para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;

b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:

1 – os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal;

2 – os Comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;

3 – os Diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;

4 – os Secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;

IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;

b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;

c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;

V – para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

VI – para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

VII – para a Câmara Municipal:

- a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;
- b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.

O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.

A renúncia para atender à desincompatibilização com vistas a candidatura a cargo eletivo ou para assunção de mandato não gerará a inelegibilidade prevista na alínea K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesta Lei Complementar.

Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais

A Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para a realização das eleições, proíbe aos agentes públicos de um modo geral, a realização de algumas condutas durante um certo período anterior à data das eleições e também, em alguns casos, durante um período posterior a elas.

De acordo com o § 1º do art. 73 da Lei n. 9.504/97, "**reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional**".

O objetivo visado com essas proibições, que estão basicamente elencadas no art. 73 da lei mencionada, é o de preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Além disso, essas proibições também possuem o propósito de coibir abusos do poder de administração, por parte dos agentes públicos, em período de campanhas eleitorais, em benefício de determinados candidatos ou partidos, ou em prejuízo de outros. A lei procura manter a igualdade entre os diferentes candidatos e partidos, evitando que qualquer agente público possa abusar de suas funções, com o propósito de trazer com isso algum benefício para o candidato ou para o partido de sua preferência.

As condutas vedadas pela lei aos agentes públicos em campanhas eleitorais estão relacionadas basicamente no seu art. 73:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três

meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

- a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
 - b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
 - c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
 - d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
 - e) a transferência ou remoção *ex officio* de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
- VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição.

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

Partidos Políticos

Os Partidos Políticos são associações constituídas para a participação da vida política de um país, para a formação da vontade nacional, com objetivos de propagação de ideias e de conquista, total ou parcial do poder político. São peças fundamentais de um sistema político democrático, destinadas “a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”. Dentro desse contexto, compete aos partidos de situação, além de propagar e implantar as ideias constantes do estatuto do partido, dar sustentação política ao governo no Parlamento, aprovando seus projetos. Aos partidos de oposição, além da propaganda de ideias e da luta pela conquista do poder político, compete à fiscalização dos atos do governo, bem como a formulação de políticas alternativas.

Deve existir uma identidade política do candidato com o partido pelo qual concorre às eleições populares. Pelo princípio da fidelidade partidária, o parlamentar eleito deve observar o programa ideológico do partido em que se inscreveu e as diretrizes dos órgãos de direção partidária.

O artigo 17 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 determina que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Assegurou também ao partido político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como manteve a exigência do caráter nacional do partido político, instituída pelo Código Eleitoral, Decreto nº 7.586/1945.

A partir de 1988, foi necessário produzir uma norma que disciplinasse o art. 17 da Constituição, uma vez que a Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP (Lei nº 5.682/1971), em vigor na época, já não mais cumpria o seu papel dentro da visão inovadora da nova Constituição. Assim, foi sancionada a Lei nº 9.096/95 e editada a Res.-TSE nº 19.406/95, revogada pela Res.-TSE nº 23.282/2010, que disciplinam a fundação, a organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos de acordo com as ideias dos legisladores de 1988.

Dentre outras coisas, a legislação permite que o próprio partido estabeleça regras para a realização de suas convenções, determine prazos superiores àqueles previstos na lei para que o filiado possa concorrer a eleições e ainda permite criar uma estrutura diferente da existente em outros partidos.

Até a entrada em vigor da nova lei, os partidos não tinham essa autonomia, pois seus atos internos eram submetidos à norma geral dirigida a todos os partidos – a LOPP –, bem como aos cuidados da Justiça Eleitoral.

Atualmente, as questões internas são resolvidas dentro do próprio partido, nos termos do estatuto, e, se questionadas judicialmente, após percorridas todas as instâncias dentro do próprio partido, compete à Justiça Comum processar e julgar tais casos. Entretanto, há exceções. Dentre elas, aquelas que envolvam filiados impossibilitados de disputar eleições e não haja mais tempo suficiente para se filiar a outra legenda, bem como os casos de infidelidade partidária, que são apreciados pela Justiça Eleitoral.

Ressalte-se que, enquanto a LOPP vigorou, o processo de registro de partidos políticos começava no TSE. Era necessário que o interessado apresentasse cópia do manifesto, do programa, do estatuto e da ata de sua fundação, a qual comprovasse a formação de, pelo menos, nove comissões regionais provisórias, com prova de publicação desses atos no Diário Oficial da União (DOU). A partir de então, era concedido um prazo de doze meses para que o partido se organizasse e obtivesse seu registro definitivo.

Os partidos com registro provisório concedido funcionavam como agremiações de fato e de direito, podendo, inclusive, participar de eleições, até que obtivessem seus registros definitivos deferidos pela Justiça Eleitoral. A lei que estabelecia normas para a realização das eleições municipais de 1988 (Lei nº 7.664/88) trazia expressamente essa permissão.

A partir da edição da Lei nº 9.096/95, o registro provisório passou a não mais ser permitido. Para registrar um partido político, o interessado tem que cumprir todos os requisitos estabelecidos na Lei dos Partidos Políticos e na Res.-TSE nº 23.282/2010. Assim, devem reunir-se os fundadores (pelo menos 101 eleitores), com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados, para elaborar o programa e o estatuto do partido, que deverá ser publicado no DOU. Nessa mesma reunião, serão eleitos, em caráter provisório, os dirigentes nacionais, que vão organizar o partido.

Após a publicação no DOU, promove-se o registro do partido no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal.

Obtido o registro no cartório, momento em que o partido em formação adquire personalidade jurídica, deve-se comunicar aos tribunais regionais o nome dos representantes que serão responsáveis pela entrega das listas do apoio mínimo de eleitores nos cartórios eleitorais.

O apoio mínimo consiste no colhimento das assinaturas correspondentes, no mínimo, a meio por cento (0,5%) dos votos válidos, dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os brancos e nulos, que deverão estar distribuídas em pelo menos nove estados. Além dessa exigência, em cada estado, deve-se atender ao mínimo de um décimo por cento (0,1%) do eleitorado.

É importante ressaltar que, com esse apoio mínimo, materializa-se o caráter nacional do novo partido.

Em seguida, o partido deverá constituir, definitivamente, na forma de seu estatuto, os órgãos diretivos municipais e regionais, registrando-os nos tribunais regionais eleitorais de, no mínimo, nove unidades da federação.

Registrados os órgãos partidários municipais e regionais nos tribunais regionais, deverá ser solicitado o registro do programa, do estatuto e do órgão de direção nacional no TSE, última fase do processo de registro.

A partir desse deferimento, o partido terá assegurada a exclusividade da denominação e da sigla, do número de legenda e dos símbolos, bem como estará apto a receber recursos do fundo partidário, a ter acesso gratuito ao rádio e à televisão e a participar do processo eleitoral.

Nota-se que a legislação brasileira evoluiu no sentido de afastar a possibilidade da influência ideológica do Estado sobre os partidos políticos, garantindo independência e autonomia nos procedimentos ligados a sua estrutura e a seu funcionamento. Dessa forma, essa liberdade partidária se apresenta como uma homenagem à natureza republicana e democrática da Constituição de 1988 e como elemento que fortalece o Estado democrático de direito.

CAPÍTULO V DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

§2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.



20 Direitos e garantias individuais e coletivos. Processo eleitoral.

Os primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento ligado à necessidade de se imporem limites e controles aos atos praticados pelo Estado e suas autoridades constituídas. Nasceram, pois, como uma proteção à liberdade do indivíduo frente à ingerência abusiva do Estado. Por esse motivo – por exigirem uma abstenção, um não-fazer do Estado em respeito à liberdade individual – são denominados direitos negativos, liberdades negativas, ou **direitos de defesa**.

Para os tradicionalistas⁴⁵, onde a maioria dos doutrinadores se firma, o primeiro documento limitativo foi a Magna Charta Libertatum, assinada pelo rei João Sem-Terra, na Inglaterra, em 1215, sendo uma Carta imposta ao rei pelos barões feudais ingleses. Para o doutrinador Carl Schmitt, negando tal afirmação acima exposta, uma vez que referido documento não era direcionado para todos, mas apenas para a elite formada por barões feudais, a primeira Constituição propriamente dita seria a Bill of Rights, promulgada em 1688 na Inglaterra, sendo que a mesma previa direitos para todos os cidadãos, e não apenas para uma classe.

A positivação dos direitos fundamentais deu-se a partir da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem (em 1789), e das declarações de direitos formuladas pelos Estados Americanos, ao firmarem sua independência em relação à Inglaterra (Virgínia Bill of Rights, em 1776). Originam-se, assim, as Constituições liberais dos Estados ocidentais dos séculos XVIII e XIX.

Os direitos fundamentais assumem hoje, também um duplo caráter, ou dupla função na ordem Constitucional. Num plano subjetivo, operando como garantidores da liberdade individual de toda coletividade. No plano objetivo, caracterizam-se pelo fato de sua normatividade transcender à aplicação subjetivo individual, pois que estes também orientam a atuação do Estado. Nesse plano, o conteúdo dos direitos fundamentais constitui um comando dirigido ao Estado no sentido de proteger os direitos, o que implica, além de medidas concretas visando a efetivá-los, a atividade legislativa destinada a desenvolvê-los.

Deve ser realçado que os direitos fundamentais se relacionam diretamente com a garantia de não-ingerência do Estado no individual e a consagração da dignidade humana, tendo um universal

⁴⁵ DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Aparentamentos Gerais dos Direitos Fundamentais. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 19 jun. 2012. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.37586&seo=1>>. Acesso em: 16 jun. 2015.

reconhecimento por parte da maioria dos Estados, seja em nível constitucional, infraconstitucional, seja em nível de direito consuetudinário ou mesmo por tratados e convenções internacionais.

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu título II os direitos e garantias fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos.

Evolução dos Direitos Fundamentais

Os direitos fundamentais foram sendo reconhecidos pelos textos constitucionais e pelo ordenamento jurídico dos países de forma gradativa e histórica, aos poucos, os autores começaram a reconhecer as gerações destes, podendo ser sintetizadas da seguinte forma:

1) Direitos de primeira geração: Surgidos no século XVII, eles cuidam da proteção das liberdades públicas, ou seja, os direitos individuais, compreendidos como aqueles inerentes ao homem e que devem ser respeitados por todos os Estados, como o direito à liberdade, à vida, à propriedade, à manifestação, à expressão, ao voto, entre outros. São limites impostos à atuação do Estado.

2) Direitos de segunda geração: Correspondem aos direitos de igualdade, significa um fazer do Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem social e econômica. Passou-se a exigir do Estado sua intervenção para que a liberdade do homem fosse protegida totalmente (o direito à saúde, ao trabalho, à educação, o direito de greve, entre outros). Veio atrelado ao Estado Social da primeira metade do século passado. A natureza do comportamento perante o Estado serviu de critério distintivo entre as gerações, eis que os de primeira geração exigiam do Estado abstenções (prestações negativas), enquanto os de segunda exigem uma prestação positiva.

3) Direitos de terceira geração: Os chamados de solidariedade ou fraternidade, voltados para a proteção da coletividade. As Constituições passam a tratar da preocupação com o meio ambiente, da conservação do patrimônio histórico e cultural, etc. A partir destas, vários outros autores passam a identificar outras gerações, ainda que não reconhecidas pela unanimidade de todos os doutrinadores.

4) Direitos de quarta geração: Segundo orientação de Norberto Bobbio, a quarta geração de direitos humanos está ligada à questão do biodireito. Referida geração de direitos decorreria dos avanços no campo da engenharia genética, ao colocarem em risco a própria existência humana, por meio da manipulação genética.

Por outro lado, o Professor Paulo Bonavides, afirma que em razão do processo de globalização econômica, com consequente afrouxamento da soberania do Estado Nacional, existe uma tendência de **globalização dos direitos fundamentais**, de forma a universalizá-los institucionalmente, sendo a única que realmente interessaria aos povos da periferia, citando como exemplos: o direito à democracia, à informação e ao pluralismo.

5) Direitos da quinta geração: Em que pese doutrinadores enquadrarem os direitos humanos de quinta geração como sendo os que envolvam a cibernética e a informática. Paulo Bonavides, vê na quinta geração o espaço para o **direito à paz**, chegando a afirmar que a paz é axioma da democracia participativa, ou ainda, supremo direito da humanidade.

Vale observar que ainda que se fale em gerações, não existe qualquer relação de hierarquia entre estes direitos, mesmo porque todos interagem entre si, de nada servindo um sem a existência dos outros. Esta nomenclatura adveio apenas em decorrência do tempo de surgimento, na eterna e constante busca do homem por mais proteção e mais garantias, com o objetivo de alcançar uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.

Características gerais dos direitos fundamentais.

Segundo o Professor José Afonso da Silva; direitos e garantias fundamentais são aquelas prerrogativas e instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas, são considerados indispensáveis. Vejamos as seguintes características:

- **Historicidade:** são produtos da evolução histórica.

- **Inalienabilidade:** Não é possível a transferência de direitos fundamentais, a qualquer título ou forma (ainda que gratuita);

- **Irrenunciabilidade:** Não está sequer à disposição do seu titular, abrir mão de sua existência. Pode até não usá-los adequadamente, mas não pode renunciar à possibilidade de exercê-los.

- **Imprescritibilidade:** Não se perdem com o decurso do tempo;

- **Relatividade ou Limitabilidade:** Não há nenhuma hipótese de direito humano absoluto, eis que todos podem ser ponderados com os demais. Como esclarece à perfeição André Ramos Tavares, ao afirmar: “não existe nenhum direito humano consagrado pelas constituições que se possa considerar absoluto, no sentido de sempre valer como máxima a ser aplicada nos casos concretos, independentemente da consideração de outras circunstâncias ou valores constitucionais”. Nesse sentido, é correto afirmar que os direitos fundamentais não são absolutos.⁴⁶

- **Universalidade:** São reconhecidos em todo o mundo. Todos os seres humanos têm direitos fundamentais que devem ser devidamente respeitados.

Efetividade dos direitos fundamentais.

Considerando que possuem os direitos fundamentais como objeto uma conduta positiva, os direitos sociais reclamam uma posição ativa do Estado nas esferas econômica e social. Diferentemente do que ocorre com os direitos de defesa, que são diretamente aplicáveis e capazes de desencadear todos os seus efeitos jurídicos extraídos do texto constitucional. Por isso, a questão da aplicabilidade e efetividade dos direitos sociais suscita grandes dúvidas em todo o ordenamento jurídico pátrio.

Embora reconhecidamente dotados de aplicabilidade diversa dos direitos de defesa, os direitos sociais de prestação acabam por integrar o raciocínio de que não existe norma constitucional desprovida de eficácia e aplicabilidade, pois a constituição, por ser a ordenação suprema do Estado e possuir a sua própria força normativa, deve encontrar em si mesma a tutela e a garantia de seus comandos, de forma a alcançar a sua máxima efetividade.

Partindo dessa premissa, o artigo 5º, parágrafo 1º da CF/88, reconhecendo a preponderância dos direitos fundamentais sobre todo o ordenamento jurídico pátrio, revela que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Assim, por esse raciocínio, a interpretação constitucional deve ser no sentido de que, de forma extensiva, deve ser alcançado todo o sistema dos direitos fundamentais, impedindo que algumas categorias, tais como os direitos sociais de prestação, que dependem de uma atuação positiva do Estado, se tornem letra morta do texto constitucional.

Perspectiva dos direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais surgiram com o objetivo inicial de assegurar as liberdades individuais das pessoas, exigindo uma ação negativa do Estado, surgindo, portanto, como um direito subjetivo. Há também o entendimento doutrinário de que, com o surgimento das novas gerações de direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais e coletivos, os direitos fundamentais possuem também uma dimensão objetiva.

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais está relacionada ao Estado Democrático de Direito cujas as constituições democráticas assumem um sistema de valores que os direitos fundamentais revelam e positivam, conforme adiante será estudado.

Direitos a prestações negativas.

Os direitos a prestações negativas, cujos efeitos subjetivos se traduzem em deveres de não-afetações, não-impedimentos ou não eliminações, são aqueles, como os denominados dentre os direitos sociais que o legislador constituinte alinhou como direito tipicamente de defesa, tais como no artigo 7º o direito à irredutibilidade do salário (VI), a garantia de salário não inferior ao mínimo (VII), a proibição de diferenciações de salários, de funções e de critérios de admissão em razão de sexo, idade, cor ou estado

⁴⁶ Tavares, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. revista e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.

civil (XXX), a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual (XXXII) e a igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo permanente e vínculo avulso (XXXIV).

Direitos a não-impedimentos.

Os direitos de defesa, no que diz com sua perspectiva subjetiva, produzem efeitos que genericamente se podem identificar como direitos a não-impedimentos de ações.

Como exemplo, temos o caso da liberdade religiosa de que trata o artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, no qual, ao mesmo tempo em que confere ao titular do direito fundamental um direito a algo, estabelece um direito ao não-impedimento do exercício do quanto ali estatuído. No mesmo enunciado se contém, pois, o direito à crença religiosa e o direito a não sofrer atos que configurem formas de impedimento ao exercício de tal direito.

Nesse caso, é incluído no âmbito da proteção da norma em seu aspecto negativo qualquer hipótese fática que consubstancie ato de impedimento ao exercício do direito à liberdade religiosa. Nesta perspectiva, quando o próprio Estado é responsável pela prática de qualquer ato de perturbação do direito fundamental, a proteção constitucional ocorrerá em termos de um direito de defesa, sob a modalidade de criar para o perturbador um dever de não impedir o comportamento protegido.

Por outro lado, quando um indivíduo for o responsável pela perturbação que impede o exercício da liberdade protegida titularizada por outro indivíduo, surge para o Estado, em função do dever de proteção, o dever de prestar positivamente algo ao titular do direito perturbado.

Direitos a não-afetação de propriedades e situações.

Ainda no estudo dos direitos tidos como de defesa, devem ser lembrados aqueles cujas normas estabelecem para o Estado obrigações de não afetar propriedades ou situações do titular do direito. Os exemplos apresentados pela doutrina são o direito à vida (CF/88, caput do artigo 5º), direito à saúde (art 6º, caput), direito à inviolabilidade do domicílio (art.5º, XI); direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X), o direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas (art. 5º, XII), o direito ao respeito à integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX).

Direitos a não eliminação de posições jurídicas.

Em relação aos direitos fundamentais, se observa que existem aqueles que, além de estabelecerem em favor do titular uma específica forma de proteção a um direito a algo, estatuem, do mesmo tempo, para o Estado, um dever de não eliminar aquelas determinadas posições, condições ou situações de vantagem jurídica ou, ainda, de prover imediatamente a cessação de uma lesão ou ameaça a direito especificamente incluído em seu âmbito de proteção.

As garantias institucionais oriundas dos direitos de defesa que se efetivam como direitos à não-eliminação de posições, situações ou condições de vantagem jurídica, tanto podem referir-se ao direito objetivo, em defesa do interesse coletivo, como podem referir-se a um direito subjetivo, como proteção a interesse individual, assim como podem dizer respeito a instituições de direito público, também em se referir aos institutos de direito privado, guindados à categoria constitucional.

Na primeira das hipóteses (garantia institucional ao direito objetivo), têm-se como exemplos as garantias da rigidez constitucional (art. 60, incisos I, II, III), da separação dos Poderes (art. 2º), do controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, I, parágrafos 1º e 2º), a inalterabilidade da forma federativa (art. 6º, parágrafo 4º, 1). Da segunda possibilidade (garantia institucional a direito subjetivo), são exemplos as garantias institucionais da propriedade (art. 5º, XXII), do direito de herança (art. 5º, XXXI, dos direitos autorais) (art. 5º, XXVII).

Direitos a prestações positivas.

Os direitos a prestações positivas são vinculados à ideia de que é incumbência do Estado disponibilizar os meios materiais e os implementos das condições fáticas aptas a possibilitarem o exercício das liberdades. Para alguns doutrinadores, têm esses direitos como principal objetivo assegurar tanto aos indivíduos, quanto aos grupos em que se inserem, a participação na vida política, econômica, social e cultural.

Como característica, temos que, objetivamente se constituem em um conjunto de normas através das quais o Estado se desincumbe de sua tarefa de equilibrar as desigualdades sociais; e, do ponto de vista

subjetivo, de serem faculdades atribuídas a indivíduos e grupos de participarem dos benefícios da vida em comunidade, que corresponde a direitos a prestações diretas e indiretas pelo poder público.

Os direitos a prestações podem ser definidos como sendo todos os direitos fundamentais a um ato positivo, uma ação do Estado, identificando-os como contrapartida exata ao conceito de direitos de defesa.

Dentre tais direitos se alinham o direito à saúde, à educação (art.6, CF/88), à aposentadoria (art. 7º, XXIV), à participação dos partidos políticos nos recursos do fundo partidário (art. 17, parágrafo 3º), ao acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). De notar-se, por relevante, que assim como dentre os denominados direitos individuais e coletivos alinhados nos incisos do art. 5º da Constituição Federal se encontram não somente direitos a prestações negativas como também direitos a prestações positivas - tais como o já mencionado direito à assistência judiciária gratuita (LXXIV), o direito a informações de interesse particular, coletivo ou geral (XXXIII), o direito à obtenção de certidões (XXXIV, 'b'), o direito das presidiárias à amamentação de seus filhos (L), o direito do preso à identificação dos responsáveis por sua prisão (LXIV), o direito à indenização, pelo Estado, por erro judiciário e por prisão por tempo superior ao previsto na sentença (LXXV), o direito ao registro civil de nascimento e à certidão de óbito gratuito aos reconhecidamente pobres (LXXVI), o direito à gratuidade da prestação jurisdicional quanto às ações de habeas corpus e habeas data (LXXVII), e, por fim, o direito à duração razoável do processo administrativo ou judicial, assegurada a celeridade de sua tramitação (LXXVIII).

Perspectiva objetiva dos direitos fundamentais.

A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais assenta-se na constatação de que eles não se limitam à única função de direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas que também irradiam valores e fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos. Na visão de Konrad Hesse, os direitos fundamentais como direitos objetivos constituem as “bases da ordem jurídica da coletividade”.⁴⁷

Em razão das origens históricas dos direitos fundamentais, que exigia a não intervenção do Estado nas liberdades individuais, predominou durante muito tempo o entendimento de que o direito fundamental era apenas um direito subjetivo. Entretanto, com o surgimento das novas gerações de direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais e coletivos, percebeu-se que os direitos fundamentais possuem também uma dimensão objetiva.

Os direitos fundamentais, em sua perspectiva objetiva, não condicionam apenas a atuação Estatal, mas também a sociedade, que se constitui, em tese, por uma ordem jurídica, política e valorativa representativa da vontade de seus membros. Em suma, o Estado e sociedade devem reconhecer a carga axiológica emanante dos direitos fundamentais.

Catálogo dos direitos fundamentais.

A constituição Federal de 1988 traz em seus artigos um rol exemplificativo dos direitos fundamentais, na medida em que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (art. 5º, § 2º).

Os direitos fundamentais catalogados são aqueles enumerados no catálogo próprio dos direitos fundamentais, no Título II da Constituição Federal (arts. 5º ao 17) e os direitos fundamentais fora do catálogo são todos os previstos fora do catálogo dos direitos fundamentais, em outros artigos da Constituição. O direito ao meio ambiente, por exemplo, é um direito fundamental de terceira geração, previsto no art. 225 do Texto Maior (não catalogado, portanto).

Sujeitos dos direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais vinculam dois ou mais sujeitos de direito, figurando, de um lado, o sujeito ativo, detentor ou titular do direito e, de outro, o sujeito passivo designado como destinatário da obrigação de respeitar o direito. Os direitos fundamentais vinculam o Estado, incluindo o legislador, os órgãos administrativos e o Poder Judiciário, bem assim os particulares.

⁴⁷ HESSE, Konrad. **Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha**. P. 239.

Tratando-se de pessoas físicas, pode-se afirmar que os direitos fundamentais se aplicam aos brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes no Brasil, estrangeiros em trânsito pelo território nacional ou qualquer pessoa que seja alcançada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

As pessoas jurídicas podem ser equiparadas às físicas, desde que o gozo do direito seja compatível com suas finalidades e natureza, tal ocorre na maioria dos direitos de resistência, como o de propriedade ou do sigilo de correspondência.

A Constituição chega, em alguns casos, a expressar tal titularidade, ao permitir às associações representarem seus filiados (CF, art. 5º, XXI) ou aos sindicatos defenderem a sua categoria (art. 8º, III). O próprio STF já aceitou direito à indenização por danos morais, direito à imagem, direito de propriedade às pessoas jurídicas; portanto, não há impedimento para o exercício de certos direitos fundamentais às pessoas jurídicas.

Funcionalidade dos direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais possuem quatro funções que são: **Função de Defesa ou Liberdade, Função de Prestação Social, Função de Proteção Perante Terceiros e Função de Não Discriminação.**

A **função de defesa ou de liberdade** impõe ao Estado um dever de abstenção. Essa abstenção significa dever de não-interferência ou de não-intromissão, respeitando-se o espaço reservado à sua autodeterminação; impõe-se ao Estado a abstenção de prejudicar, ou seja, o dever de respeitar os atributos que compõem a dignidade da pessoa.

A função de defesa ou de liberdade está relacionada com os direitos fundamentais de primeira dimensão.

A **função de prestação social** atribui à pessoa o direito social de obter um benefício do Estado, impondo-se a este o dever de agir, para satisfazê-lo diretamente, ou criar as condições de satisfação de tais direitos. Em regra, está relacionada aos direitos fundamentais à saúde, à educação, à moradia, ao transporte coletivo, dentre outros.

A função de prestação social dos direitos fundamentais tem grande relevância em sociedades, como é o caso do Brasil, onde o Estado do bem-estar social tem dificuldades para ser efetivado e tem relação com a fruição do mínimo existencial.

A **Função de Proteção Perante Terceiros**, significa que os direitos fundamentais das pessoas precisam ser protegidos contra toda sorte de agressões, impondo um dever ao Estado (poderes públicos) no sentido de que deve rotoger perante terceiros os titulares de direitos fundamentais. Trata-se de um vínculo que se estabelece entre indivíduos, em virtude do qual estes se relacionam uns com os outros. Verifica-se, então, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O Estado, atendendo à função, desempenhada pelos direitos fundamentais, de prestação perante terceiros, atua para proteger tais direitos.

Conforme Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, *"o efeito horizontal tem caráter mediato/indireto e, excepcionalmente, caráter imediato/direto. O efeito horizontal indireto refere-se precipuamente à obrigação do juiz de observar o papel (efeito, irradiação) dos direitos fundamentais, sob pena de intervir de forma inconstitucional na área de proteção do direito fundamental, prolatando uma sentença inconstitucional (...). O efeito horizontal imediato refere-se ao vínculo direto das pessoas aos direitos fundamentais ou de sua imediata aplicabilidade para a solução de conflitos interindividuais"*.⁴⁸

A **função de não discriminação** diz respeito a todos os direitos fundamentais. Refere-se, por exemplo, aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e culturais. Nenhuma pessoa poderá ser privada de um direito fundamental em razão de discriminação. Está-se, portanto, diante do princípio da igualdade.

Limites e restrições aos direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais não são absolutos; sofrem limitações justamente para que haja harmonia entre a coexistência das pessoas, atendendo à ideia de liberdade.

Deve ser considerado que certos direitos possuem o caráter incondicional, tais como o direito a não ser torturado e o de não ser submetido a tratamento desumano ou degradante. Tais direitos são os que mais se aproximam da dignidade da pessoa humana, demonstrando, portanto, sua prevalência.

⁴⁸ Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 113.

Na Constituição de 1988, é possível vislumbrar esse tipo de limitação nos casos a seguir percorridos. Tradicionalmente, exemplifica-se com o art. 5º, XVI, que dispõe sobre o direito de reunião, a qual deve ser pacífica, sem armas e não pode frustrar outra reunião previamente convocada para o mesmo local. Há ainda outros preceitos, todos do artigo 5º da Constituição de 1988, que contêm limitações expressas, tais como o inciso IV que limita a liberdade de expressão caso haja anonimato; o inciso XIV que limita o acesso à informação nos casos em que seja necessário para o exercício profissional resguardar o sigilo da fonte; o inciso XV que limita a liberdade de ir e vir caso não esteja em tempos de paz; o inciso XVII que limita a liberdade de associação caso haja caráter paramilitar; o inciso XLVII, alínea a que limita a não existência de pena de morte caso haja guerra declarada e outros.

Limites dos limites.

Conforme visto, no sistema constitucional brasileiro, verificou-se a dinâmica de limites e restrições aos direitos fundamentais. No entanto, a atividade limitadora e restritiva do Estado deve ser, igualmente, uma atividade limitada, de modo que a ação limitadora e restritiva se dê na medida estritamente necessária e indispensável à própria concretização e preservação de tais direitos e demais bens constitucionalmente protegidos.

Assim, existem os chamados “limites dos limites”, que demarcam o campo de atuação da atividade do legislador, quando estes limitam e restringem os direitos fundamentais.

No Brasil não há normatização expressa referente ao regime jurídico aplicável às limitações e restrições aos direitos fundamentais, sendo que a proteção aos direitos fundamentais decorre do caráter supremo e vinculante das disposições de direitos fundamentais e do princípio do Estado Democrático de Direito, previsto no caput do artigo 1º da Constituição Federal, em que se reflete a “necessidade constante de conciliação entre os direitos dos particulares e a soberania do ente estatal”.

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, expressamente anunciado pelo artigo 1º, inciso III da CF/88, firma-se como o princípio reitor da dinâmica em que os direitos fundamentais encontram-se, podendo ser concluído que qualquer limitação ou restrição a direitos fundamentais nunca poderá afetar desvantajosamente a dignidade da pessoa humana.

A proibição de retrocesso social.

O princípio da proibição do retrocesso social caracteriza-se como um limite às restrições impostas aos direitos fundamentais, de maneira a prevenir que “um direito fundamental prestacional legislativamente regulamentado e, como tal, dotado de preciosos contornos e nítido conteúdo, venha a sofrer alterações futuras que reduzam o significado que lhe foi atribuído pela norma ordinária anterior.

O Princípio de proibição de retrocesso social, ou *efeito cliquet*, tem na nomenclatura como origem francesa, onde a jurisprudência do Conselho Constitucional reconhece que o princípio da vedação do retrocesso (chamando “efeito cliquet”) se aplica inclusive em relação aos direitos de liberdade, no sentido de que não é possível a revogação total de uma lei que protege as liberdades fundamentais sem a substituir por outra que ofereça garantias com eficácia equivalente.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da legitimação do princípio do não retrocesso social, no sentido de que o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v. g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados.

Direitos e deveres individuais e coletivos

A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer direitos não só de indivíduos, mas também de grupos sociais, os denominados direitos coletivos. As pessoas passaram a ser coletivamente consideradas. Por outro lado, pela primeira vez, junto com direitos foram estabelecidos expressamente

deveres fundamentais. Tanto os agentes públicos como os indivíduos têm obrigações específicas, inclusive a de respeitar os direitos das demais pessoas que vivem na ordem social.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pode ser caracterizado como um dos mais importantes constantes do arcabouço jurídico brasileiro. Tal fato se justifica em razão de que este apresenta, em seu bojo, a proteção dos bens jurídicos mais importantes para os cidadãos, quais sejam: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

Tais bens jurídicos, taxados de invioláveis, não são passíveis de transação, possuem o caráter de indisponibilidade (não se pode abrir mão destes) e impenhorabilidade. Todavia, eles não são absolutos, pois possuem caráter de relatividade.

Isso decorre não somente pelo fato de que tais bens jurídicos são indispensáveis ao cidadão, mas também das características dos direitos humanos. É importante salientar que além de serem caracterizados como direitos fundamentais, tais bens jurídicos possuem a característica de serem considerados como direitos humanos.

Um exemplo acerca da relatividade da aplicação desses bens jurídicos está disposto no próprio bem jurídico vida. Como é possível perceber a existência de alguns institutos jurídicos que permitem atos atentatórios contra a vida, que, em tese, não são punidos. Podem-se citar, como exemplo, as excludentes da antijuridicidade, dispostas no Código Penal. São excludentes da antijuridicidade: a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal.

Ademais, outro exemplo estabelecido pela própria Constituição da República Federativa do Brasil está disposto no artigo 84, XIX, onde demonstra ser possível a aplicabilidade da pena de morte. Assim, uma grande característica desses bens jurídicos, taxados como direitos fundamentais e humanos, é a relatividade destes. Outrossim, o referido artigo apresenta outros bens jurídicos, como a liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

É importante salientar que o caput do artigo 5º da CF 88 garante tanto aos brasileiros como aos estrangeiros a inviolabilidade dos direitos a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

Desta maneira, tantos os brasileiros natos ou naturalizados, como os estrangeiros residentes no Brasil, possuem os bens jurídicos supracitados abarcados pela Constituição Federal. Entretanto, existe uma corrente na doutrina brasileira que admite a inviolabilidade dos bens jurídicos citados aos estrangeiros que estejam provisoriamente ou de passagem pelo nosso país. Assim, de acordo com essa corrente, seria perfeitamente possível a um estrangeiro que estivesse de passagem por nosso país e viesse a sofrer coação em seu direito de locomoção, impetrar o remédio constitucional denominado de habeas corpus.

A relação extensa de direitos individuais estabelecida no art. 5º da Constituição tem caráter meramente enunciativo, não se trata de rol taxativo. Existem outros direitos individuais resguardados em outras normas previstas na própria Constituição (por exemplo, art. 150, contendo garantias de ordem tributária).

I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

O inciso supracitado traz, em seu bojo, um dos princípios mais importantes existentes no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da isonomia ou da igualdade. Tal princípio igualou os direitos e obrigações dos homens e mulheres, porém, permitindo as diferenciações realizadas nos termos da Constituição.

II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

O inciso supracitado contém em seu conteúdo o princípio da legalidade. Ele garante a segurança jurídica e impede que o Estado aja de forma arbitrária. Tal princípio tem por escopo explicitar que nenhum cidadão será obrigado a realizar ou deixar de realizar condutas que não estejam definidas em lei. Ou seja,

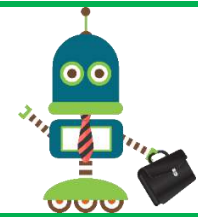
para o particular, apenas a lei pode criar uma obrigação. Além disso, se não existe uma lei que proíba uma determinada conduta, significa que ela é permitida.

Para nós, particulares, vigora a **legalidade ampla**. Para a maioria dos doutrinadores, a lei a que se refere este inciso deve ser entendida como uma das espécies legislativas do art. 59 da CF/88 (emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções).

Já a Administração Pública, segue uma regra diferente, a **legalidade estrita ou restrita**, prevista no art. 37, caput, da CF/88. O Poder Público só pode fazer o que a lei permite.

Outro ponto importante a ser ressaltado é que legalidade não se confunde com reserva legal. A legalidade é mais ampla, significa que deve haver lei, elaborada segundo as regras do processo legislativo, para criar uma obrigação. Já a reserva legal é de menor abrangência e significa que, determinadas matérias, especificadas pela Constituição, só podem ser tratadas por lei proveniente do Poder Legislativo (ex.: art. 5.º, inciso XXXIX: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal", este é o famoso princípio da reserva legal).

O princípio deve ser lido de maneira diferente para o particular e para a Administração, sendo que nas relações particulares, pode-se fazer tudo que a lei não proíbe, vigorando o princípio da autonomia de vontade. Já em relação à Administração, só pode fazer o que a lei permite.



III- ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

O inciso em questão garante que nenhum cidadão será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tal assertiva se alicerça ao fato de que o sujeito que cometer tortura estará cometendo crime tipificado na Lei nº 9.455/97. Cabe ressaltar, ainda, que a prática de tortura caracteriza-se como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não obstante as características anteriormente citadas, o crime de tortura ainda é considerado hediondo, conforme explicita a Lei nº 8.072/90. Crimes hediondos são aqueles considerados como repugnantes, de extrema gravidade, os quais a sociedade não compactua com a sua realização. São exemplos de crimes hediondos: tortura, homicídio qualificado, estupro, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, dentre outros.

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Este inciso garante a liberdade de manifestação de pensamento, até como uma resposta à limitação desses direitos no período da ditadura militar. Não somente por este inciso, mas por todo o conteúdo, que a Constituição da República Federativa de 1988 consagrou-se como a "Constituição Cidadã". Um ponto importante a ser citado neste inciso é a proibição do anonimato. Cabe ressaltar que a adoção de eventuais pseudônimos não afetam o conteúdo deste inciso, mas tão somente o anonimato na manifestação do pensamento.

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

O referido inciso traz, em seu bojo, uma norma assecuratória de direitos fundamentais, onde se encontra assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização correspondente ao dano causado. Um exemplo corriqueiro da aplicação deste inciso encontra-se nas propagandas partidárias, quando um eventual candidato realiza ofensas ao outro. Desta maneira, o candidato ofendido possui o direito de resposta proporcional à ofensa, ou seja, a resposta deverá ser realizada nos mesmos parâmetros que a ofensa. Assim, se a resposta deverá possuir o mesmo tempo que durou a ofensa, deverá ocorrer no mesmo veículo de comunicação em que foi realizada a conduta ofensiva. Não obstante, o horário obedecido para a resposta deverá ser o mesmo que o da ofensa.

Em que pese haja a existência do direito de resposta proporcional ao agravo, ainda há possibilidade de ajuizamento de ação de indenização por danos materiais, morais ou à imagem. Assim, estando presente a conduta lesiva, que tenha causando um resultado danoso e seja provado o nexo de causalidade com o eventual elemento subjetivo constatado, ou seja, a culpa, demonstra-se medida de rigor, o arbitramento de indenização ao indivíduo lesado.

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Este inciso demonstra a liberdade de escolha da religião pelas pessoas. Não obstante, a segunda parte deste resguarda a liberdade de culto, garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgias. Existem doutrinadores que entendem que a liberdade expressa neste inciso é absoluta, inexistindo qualquer tipo de restrição a tal direito. Contudo, entendemos não ser correto tal posicionamento. Tal fato se justifica com a adoção de um simples exemplo. Imaginemos que uma determinada religião utiliza em seu culto, alta sonorização, que causa transtornos aos vizinhos do recinto. Aqui estamos diante de dois direitos constitucionalmente tutelados. O primeiro que diz respeito à liberdade de culto e o segundo, referente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, explicitado pelo artigo 225 da CF/88. Como é possível perceber com a alta sonorização empregada, estamos diante de um caso de poluição sonora, ou seja, uma conduta lesiva ao meio ambiente. Curiosamente, estamos diante de um conflito entre a liberdade de culto e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos direitos constitucionalmente expressos. Como solucionar tal conflito? Essa antinomia deverá ser solucionada através da adoção do princípio da cedência recíproca, ou seja, cada direito deverá ceder em seu campo de aplicabilidade, para que ambos possam conviver harmonicamente no ordenamento jurídico brasileiro.

Desta maneira, como foi possível perceber a liberdade de culto não é absoluta, possuindo, portanto, caráter relativo, haja vista a existência de eventuais restrições ao exercício de tal direito consagrado.

O Brasil é um país LAICO ou LEIGO, ou seja, não tem uma religião oficial.

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

Neste inciso encontra-se assegurado o direito de prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Quando o inciso se refere às entidades civis e militares de internação coletiva está abarcando os sanatórios, hospitais, quartéis, dentre outros.

Cabe ressaltar que a assistência religiosa não abrange somente uma religião, mas todas. Logo, por exemplo, os protestantes não serão obrigados a assistirem os cultos religiosos das demais religiões, e vice versa.

VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Este inciso expressa a possibilidade de perda dos direitos pelo cidadão que, para não cumprir obrigação legal imposta a todos e para recusar o cumprimento de prestação alternativa, alega como motivo crença religiosa ou convicção filosófica ou política.

Um exemplo de obrigação estipulada por lei a todos os cidadãos do sexo masculino é a prestação de serviço militar obrigatório. Nesse passo, se um cidadão deixar de prestar o serviço militar obrigatório alegando como motivo a crença em determinada religião que o proíba poderá sofrer privação nos seus direitos.

IX – é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Este inciso tem por escopo a proteção da liberdade de expressão, sendo expressamente vedada a censura e a licença. Como é possível perceber, mais uma vez nossa Constituição visa proteger o cidadão de alguns direitos fundamentais que foram abolidos durante o período da ditadura militar. Para melhor compreensão do inciso supracitado, a censura consiste na verificação do pensamento a ser divulgado e as normas existentes no ordenamento. Desta maneira, a Constituição veda o emprego de tal mecanismo, visando garantir ampla liberdade ao cidadão, taxado como um bem jurídico inviolável do cidadão, expressamente disposto no *caput* do artigo 5º.

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação;

Os direitos da personalidade decorrem da dignidade humana. O direito à privacidade decorre da autonomia da vontade e do livre-arbítrio, permitindo à pessoa conduzir sua vida da forma que julgar mais conveniente, sem intromissões alheias, desde que não viole outros valores constitucionais e direitos de terceiro.

A CF/88 protege a privacidade, que abrange: intimidade, vida privada, honra e imagem.



Atenção! A vida pública não está protegida constitucionalmente. Assim, os atos que praticamos em público, com o objetivo de torná-los públicos, não estão resguardados pela privacidade.

A honra pode ser subjetiva (estima que a pessoa possui de si mesma) ou objetiva (reputação do indivíduo perante o meio social em que vive). As pessoas jurídicas só possuem honra objetiva.

O direito à imagem, que envolve aspectos físicos, inclusive a voz, impede sua captação e difusão sem o consentimento da pessoa, ainda que não haja ofensa à honra. Neste sentido, a súmula 403 do STJ:



Súmula 403 do STJ: “Independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.

Este direito, como qualquer outro direito fundamental, pode ser relativizado quando em choque com outros direitos. Por exemplo, pessoas públicas, tendem a ter uma restrição do direito à imagem frente ao direito de informação da sociedade. Também a divulgação em contexto jornalístico de interesse público, a captação por radares de trânsito, câmeras de segurança ou eventos de interesse público, científico, histórico, didático ou cultural são limitações legítimas ao direito à imagem.

Por outro lado, o inciso em questão traz a possibilidade de ajuizamento de ação que vise à indenização por danos materiais ou morais decorrentes da violação dos direitos expressamente tutelados. Entende-se como *dano material*, o prejuízo sofrido na esfera patrimonial, enquanto o *dano moral*, aquele não referente ao patrimônio do indivíduo, mas sim que causa ofensa à honra do indivíduo lesado.

Não obstante a responsabilização na esfera civil, ainda é possível constatar que a agressão a tais direitos também encontra guarida no âmbito penal. Tal fato se abaliza na existência dos crimes de calúnia, injúria e difamação, expressamente tipificados no Código Penal Brasileiro.

XI- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

O conceito de casa é amplo, alcançando os locais habitados de maneira exclusiva. Exemplo: escritórios, oficinas, consultórios e locais de habitação coletiva (hotéis, motéis etc.) que não sejam abertos ao público, recebendo todos estes locais esta proteção constitucional.

O referido inciso traz a inviolabilidade do domicílio do indivíduo. Todavia, tal inviolabilidade não possui cunho absoluto, sendo que o mesmo artigo explicita os casos em que há possibilidade de penetração no domicílio sem o consentimento do morador. Os casos em que é possível a penetração do domicílio são:

- Durante a noite: há possibilidade de ingresso no domicílio somente com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.
- Durante o dia: será possível ingressar no domicílio do indivíduo com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro e, ainda, por determinação judicial.

Note-se que o ingresso em domicílio por **determinação judicial** somente é passível de realização durante o dia. Tal ingresso deverá ser realizado com ordem judicial expedida por autoridade judicial competente, sob pena de considerar-se o ingresso desprovido desta como abuso de autoridade, além da tipificação do crime de Violação de Domicílio, que se encontra disposto no artigo 150 do Código Penal.

Todavia, o que podemos considerar como dia e noite? Existem entendimentos que consideram o dia como o período em que paira o sol, enquanto a noite onde há a existência do crepúsculo. No entanto, entendemos não ser eficiente tal classificação, haja vista a existência no nosso país do horário de verão adotado por alguns Estados e não por outros, o que pode gerar confusão na interpretação desse inciso.

Assim, para fins didáticos e de maior segurança quanto à interpretação, entendemos que o dia pode ser compreendido entre as 6 horas e às 18 horas, enquanto o período noturno das 18 horas às 6 horas (critério cronológico).

XII- é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Este inciso tem por escopo demonstrar a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. No entanto, o próprio inciso traz a possibilidade de quebra do sigilo telefônico, por ordem judicial, desde que respeite a lei, para que seja possível a investigação criminal e instrução processual penal.

Para que fique mais claro o conteúdo do inciso em questão, vejamos:

- **Sigilo de Correspondência:** Possui como regra a inviolabilidade trazida no Texto Constitucional. Todavia, em caso de decretação de estado de defesa ou estado de sítio poderá haver limitação a tal inviolabilidade. Outra possibilidade de quebra de sigilo de correspondência entendida pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito às correspondências dos presidiários. Visando a segurança pública e a preservação da ordem jurídica o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível à quebra do sigilo de correspondência dos presidiários. Um dos motivos desse entendimento da Suprema Corte é que o direito constitucional de inviolabilidade de sigilo de correspondência não pode servir de guarida aos criminosos para a prática de condutas ilícitas.

- **Sigilo de Comunicações Telegráficas:** A regra empregada é da inviolabilidade do sigilo, sendo, porém, possível à quebra deste em caso de estado de defesa e estado de sítio.

- **Sigilo das Comunicações Telefônicas:** A regra é a inviolabilidade de tal direito. Outrossim, a própria Constituição traz no inciso supracitado a exceção. Assim, será possível a quebra do sigilo telefônico, desde que esteja amparado por decisão judicial de autoridade competente para que seja possível a instrução processual penal e a investigação criminal. O inciso em questão ainda exige para a quebra do sigilo a obediência de lei. Essa lei entrou em vigor em 1996, sob o nº 9.296. A lei em questão, traz em seu bojo, alguns requisitos que devem ser observados para que seja possível realizar a quebra do sigilo telefônico.

Isso demonstra que não será possível a quebra dos sigilos supracitados por motivos banais, haja vista estarmos diante de um direito constitucionalmente tutelado.

A quebra desse tipo de sigilo pode ocorrer por determinação judicial ou por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

O sigilo de dados engloba dados fiscais, bancários e telefônicos (referente aos dados da conta e não ao conteúdo das ligações).

Quanto às comunicações telefônicas (conteúdo das ligações), existe uma reserva jurisdicional. A interceptação só pode ocorrer com ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, sob pena de constituir prova ilícita.

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Aqui estamos diante de uma norma de aplicabilidade contida. A norma de aplicabilidade contida possui total eficácia, dependendo, no entanto, de uma lei posterior que reduza a aplicabilidade da primeira. Como é possível perceber o inciso em questão demonstra a liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, devendo, no entanto, serem obedecidas às qualificações profissionais que a lei posterior estabeleça. Note-se que essa lei posterior reduz os efeitos de aplicabilidade da lei anterior que garante a liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão.

Um exemplo muito utilizado pela doutrina é o do Exame aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil aos bacharéis em Direito, para que estes obtenham habilitação para exercer a profissão de advogados. Como é notório, a lei garante a liberdade de trabalho, sendo, no entanto, que a lei posterior, ou seja, o Estatuto da OAB, prevê a realização do exame para que seja possível o exercício da profissão de advogado.

XIV- é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

Este inciso prega a proteção ao direito de liberdade de informação. Aqui estamos tratando do direito de informar, como também o de ser informado. Tal é a importância da proteção desse direito que a própria Constituição trouxe no bojo do seu artigo 5º, mais precisamente no seu inciso XXXIII, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. É importante salientar que no caso de desrespeito a tal direito, há existência de um remédio constitucional, denominado *habeas data*, que tem por objetivo dar às pessoas informações constantes em bancos de dados, bem como de retificá-los, seja através de processo sigiloso, judicial ou administrativo. Cabe ressaltar, ainda, que o referido inciso traz a possibilidade de se resguardar o sigilo da fonte. Esse sigilo diz respeito àquela pessoa que prestou as informações. Todavia, esse sigilo não possui conotação absoluta, haja vista que há possibilidade de revelação da fonte informadora, em casos expressos na lei.

XV- é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

O inciso em questão prega o direito de locomoção. Esse direito abrange o fato de se entrar, permanecer, transitar e sair do país, com ou sem bens. Quando o texto constitucional explicita que qualquer pessoa está abrangida pelo direito de locomoção, não há diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, bem como nenhuma questão atinente aos estrangeiros. Assim, no presente caso a Constituição tutela não somente o direito de locomoção do brasileiro nato, bem como o do naturalizado e do estrangeiro.

Desta forma, como é possível perceber a locomoção será livre em tempo de paz. Porém tal direito é relativo, podendo ser restringido em casos expressamente dispostos na Constituição, como por exemplo, no estado de sítio e no estado de defesa.

XVI- todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Neste inciso encontra-se presente outro direito constitucional, qual seja: o **direito de reunião**. A grande característica da reunião é a descontinuidade, ou seja, pessoas se reúnem para discutirem determinado assunto, e finda a discussão, a reunião se encerra. Cabe ressaltar que a diferença entre reunião e associação está intimamente ligada a tal característica. **Enquanto a reunião não é contínua, a associação tem caráter permanente.**

Explicita o referido inciso, a possibilidade da realização de reuniões em locais abertos ao público, desde que não haja presença de armas e que não frustre reunião previamente convocada. É importante salientar que o texto constitucional não exige que a reunião seja autorizada, mas tão somente haja uma prévia comunicação à autoridade competente.

De forma similar ao direito de locomoção, o direito de reunião também é relativo, pois poderá ser restringido em caso de estado de defesa e estado de sítio.

Assim, segundo a CF/88, alguns requisitos devem ser observados para que a reunião seja protegida:

- a) deve ser pacífica e sem armas
- b) deve acontecer em locais abertos ao público (ruas, praças, parques etc.). Devemos entender como locais de uso comum do povo, excluídas as propriedades particulares.
- c) deve haver o aviso prévio à autoridade competente (não precisa de autorização). O objetivo é o de garantir a segurança necessária ao evento e ainda, o exercício do direito de preferência, em relação a outro evento que pode ser posteriormente agendado.
- d) a finalidade deve ser lícita (este requisito não está expresso na CF/88, mas deve ser observado)



XVII- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Como foi explicitado na explicação referente ao inciso anterior, a maior diferença entre reunião e associação está na descontinuidade da primeira e na permanência da segunda. Este inciso prega a liberdade de associação. É importante salientar que a associação deve ser para fins lícitos, haja vista que a ilicitude do fim pode tipificar conduta criminosa.

O inciso supracitado ainda traz uma vedação, que consiste no fato da proibição de criação de associações com caráter paramilitar. Quando falamos em associações com caráter paramilitar estamos nos referindo àquelas que buscam se estruturar de maneira análoga às forças armadas ou policiais. Assim, para que não haja a existência de tais espécies de associações o texto constitucional traz expressamente a vedação.

XVIII- a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

Neste inciso está presente o desdobramento da liberdade de associação, onde a criação de cooperativas e associações independem de autorização. É importante salientar que o constituinte também trouxe no bojo deste inciso uma vedação no que diz respeito à interferência estatal no funcionamento de tais órgãos. O constituinte vedou a possibilidade de interferência estatal no funcionamento das associações e cooperativas obedecendo à própria liberdade de associação.

XIX- as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

O texto constitucional traz expressamente as questões referentes à dissolução e suspensão das atividades das associações. Neste inciso estamos diante de duas situações diversas. Quando a questão for referente à suspensão de atividades da associação, a mesma somente se concretizará através de decisão judicial. Todavia, quando falamos em dissolução compulsória das entidades associativas, é importante salientar que a mesma somente alcançará êxito através de decisão judicial transitada em julgado.

Logo, para ambas as situações, seja na dissolução compulsória, seja na suspensão de atividades, será necessária decisão judicial. Entretanto, como a dissolução compulsória possui uma maior gravidade exige-se o trânsito em julgado da decisão judicial.

Para uma compreensão mais simples do inciso em questão, o que podemos entender como decisão judicial transitada em julgado? A decisão judicial transitada em julgado consiste em uma decisão emanada pelo Poder Judiciário onde não seja mais possível a interposição de recursos.

XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Aqui se encontra outro desdobramento da liberdade de associação. Estamos diante da liberdade associativa, ou seja, do fato que ninguém será obrigado a associar-se ou a permanecer associado.

XXI- as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

Este inciso expressa a possibilidade das entidades associativas, desde que expressamente autorizadas, representem seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Cabe ressaltar que, de acordo com a legislação processual civil, ninguém poderá alegar em nome próprio direito alheio, ou seja, o próprio titular do direito buscará a sua efetivação. No entanto, aqui estamos diante de uma exceção a tal regra, ou seja, há existência de legitimidade extraordinária na defesa dos interesses dos filiados. Assim, desde que expressamente previsto no estatuto social, as entidades associativas passam a ter legitimidade para representar os filiados judicial ou extrajudicialmente. Quando falamos em legitimidade na esfera judicial, estamos nos referindo à tutela dos interesses no Poder Judiciário. Porém, quando falamos em tutela extrajudicial a tutela pode ser realizada administrativamente.

XXII- é garantido o direito de propriedade;

Este inciso traz a tutela de um dos direitos mais importantes na esfera jurídica, qual seja: a propriedade. Em que pese tenha o artigo 5º, *caput*, consagrado à propriedade como um direito fundamental, o inciso em questão garante o direito de propriedade. De acordo com a doutrina civilista, o direito de propriedade caracteriza-se pelo uso, gozo e disposição de um bem. Todavia, o direito de propriedade não é absoluto, pois existem restrições ao seu exercício, como por exemplo, a obediência à função social da propriedade.

XXIII- a propriedade atenderá a sua função social;

Neste inciso encontra-se presente uma das limitações ao direito de propriedade, qual seja: a função social. A função social da propriedade na área urbana está expressamente prevista no artigo 182, § 2º, da Constituição Federal. Dispõe o referido artigo:



Artigo 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Como é possível perceber no parágrafo supracitado, a propriedade urbana estará atendendo sua função social quando atender as exigências expressas no plano diretor. O plano diretor consiste em um instrumento de política desenvolvimentista, obrigatório para as cidades que possuam mais de vinte mil habitantes. Tal plano tem por objetivo traçar metas que serão obedecidas para o desenvolvimento das cidades.

Não obstante a necessidade de obediência da função social nas propriedades urbanas, há existência da função social da propriedade rural, que se encontra disposta no artigo 186 da Constituição Federal de 1988. Dispõe o referido artigo:

Artigo 186 – A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

- I- aproveitamento racional e adequado;**
- II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;**
- III- observância das disposições que regulam as relações de trabalho;**
- IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.**

O artigo 186, acima disposto, traz, em seu bojo, a função social da propriedade rural. Atualmente, a doutrina apresenta também a função socioambiental da propriedade rural. Essa espécie de função social da propriedade, disposta no inciso II, do artigo 186, explicita a necessidade de utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.

Não obstante a presença dessas espécies restrições ao direito de propriedade, existem outras, como por exemplo: A desapropriação, as limitações administrativas, as servidões administrativas, dentre outras.

Desapropriação ou **expropriação** é o procedimento através do qual o Estado transfere para si a propriedade de um particular.

O inciso XXIV trata de uma hipótese de desapropriação que acontece por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Não existe aqui nenhuma punição, ou seja, o proprietário não usou indevidamente a sua propriedade.

Mas, existe uma justificativa para retirar a propriedade do particular (ex: abertura de uma rua, construção de uma escola ou de uma ponte etc.). Este particular será obrigado a entregar a sua propriedade. Entretanto, receberá uma indenização que será **prévia, justa e em dinheiro**.

Não podemos confundir essa desapropriação com a chamada **desapropriação-sanção**, que pode ser urbana ou rural. Nestes casos, o particular está sofrendo uma punição por usar indevidamente a propriedade.

A **desapropriação urbana** ou **urbanística** está prevista no art. 182, § 4.º, III, da CF/88 nos seguintes termos:

Art.182, § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- I - parcelamento ou edificação compulsórios;**
- II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;**
- III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.**

Já a desapropriação rural, que acontece para fins de reforma agrária e é de competência exclusiva da União, é tratada no art. 184:

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

Temos ainda a situação em que a propriedade é utilizada para a prática de crime e, por isso, pode ser retirada do seu titular, sem o pagamento de qualquer indenização. É a desapropriação-confisco ou, simplesmente, **confisco**. De acordo com o art. 243 da CF/88:



Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Desta forma, a única hipótese em que a indenização será paga em dinheiro é na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social (art. 5.º, XXV).

Como a desapropriação é uma intervenção radical do Estado na esfera particular, ela só pode acontecer nas hipóteses previstas na CF/88.

XXIV- a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

O inciso XXIV traz o instituto da desapropriação. A Desapropriação é o procedimento pelo qual o Poder Público, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente, priva alguém de certo bem, móvel ou imóvel, adquirindo-o para si em caráter originário, mediante justa e prévia indenização. É, em geral, um ato promovido pelo Estado, mas poderá ser concedido a particulares permissionários ou concessionários de serviços públicos, mediante autorização da Lei ou de Contrato

com a Administração. Assim, desde que sejam obedecidos alguns requisitos o proprietário poderá ter subtraída a coisa de sua propriedade. São eles:

- Necessidade pública;
- Utilidade pública;
- Interesse social;
- Justa e prévia indenização; e
- Indenização em dinheiro.

XXV- no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

No caso do inciso XXV estamos diante do instituto da requisição administrativa. Este instituto, como o próprio inciso denota, permite à autoridade competente utilizar propriedades particulares em caso de iminente perigo público. Desta maneira, utilizada a propriedade particular será seu proprietário indenizado, posteriormente, caso seja constatada a existência de dano. Em caso negativo, este não será indenizado. Um exemplo típico do instituto da requisição administrativa é o encontrado no caso de guerras. A título exemplificativo, se o nosso país estivesse em guerra, propriedades particulares poderiam ser utilizadas e, caso fosse comprovada a ocorrência de danos, os proprietários seriam indenizados.

XXVI- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Este inciso traz a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. É importante salientar que a regra de impenhorabilidade da pequena propriedade rural para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva abrange somente aquela trabalhada pela família. Cabe ressaltar que essa proteção acaba por trazer consequências negativas para os pequenos produtores. Tal assertiva se justifica pelo fato de que, não podendo ser a propriedade rural objeto de penhora, com certeza a busca pelo crédito será mais difícil, haja vista a inexistência de garantias para eventuais financiamentos.

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

Este inciso tem por escopo a tutela do direito de propriedade intelectual, quais sejam: a propriedade industrial e os direitos do autor. Como é possível extrair do inciso supracitado esses direitos são passíveis de transmissão por herança, sendo, todavia, submetidos a um tempo fixado pela lei. Desta maneira, não é pelo simples fato de ser herdeiro do autor de uma determinada obra que lhe será garantida a propriedade da mesma, pois a lei estabelecerá um tempo para que os herdeiros possam explorar a obra. Após o tempo estabelecido a obra pertencerá a todos.

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

Este inciso preza a proteção dos direitos individuais do autor quando participe de uma obra coletiva. Um exemplo que pode ilustrar o conteúdo da alínea “a” diz respeito à gravação de um CD por diversos cantores. Não é pelo simples fato da gravação ser coletiva que não serão garantidos os direitos autorais individuais dos cantores. Pelo contrário, serão respeitados os direitos individuais de cada cantor.

Ato contínuo, o inciso “b” traz o instituto do direito de fiscalização do aproveitamento das obras. A alínea em questão expressa que o próprio autor poderá fiscalizar o aproveitamento econômico da obra, bem como os intérpretes, representações sindicais e associações.

XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Este inciso trata, ainda, da tutela do direito de propriedade intelectual, explicitando o caráter não-definitivo de exploração das obras, haja vista a limitação temporal de exploração por lei. Isso ocorre pelo fato de que há imbuído um grande interesse da sociedade em conhecer o conteúdo das pesquisas e inventos que podem trazer maior qualidade de vida à população.

XXX- é garantido o direito de herança;

Como um desdobramento do direito de propriedade, a Constituição consagra, no presente inciso, o direito de herança. Segundo Maria Helena Diniz “o objeto da sucessão *causa mortis* é a herança, dado que, com a abertura da sucessão, ocorre a mutação subjetiva do patrimônio do *de cujus*, que se transmite aos seus herdeiros, os quais se sub-rogam nas relações jurídicas do defunto, tanto no ativo como no passivo até os limites da herança”.

De acordo com a citação da doutrinadora supracitada, podemos concluir que a herança é o objeto da sucessão. Com a morte abre-se a sucessão, que tem por objetivo transferir o patrimônio do falecido aos seus herdeiros. É importante salientar que são transferidos aos herdeiros tanto créditos (ativo) como dívidas (passivo), até que seja satisfeita a totalidade da herança.

Os herdeiros só respondem pelas dívidas de seu sucessor nas forças da herança.

XXXI- a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável à lei pessoal do de cujus;

Neste inciso estamos diante da sucessão de bens de estrangeiros situados no nosso país. A regra, conforme denota o inciso supracitado, é que a sucessão dos bens do estrangeiro será regulada pela lei brasileira. Todavia, o próprio inciso traz uma exceção, que admite a possibilidade da sucessão ser regulada pela lei do falecido, desde que seja mais benéfica ao cônjuge e aos filhos brasileiros.

XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Este inciso traz, em seu conteúdo, a intenção do Estado em atuar na defesa do consumidor, ou seja, da parte hipossuficiente da relação de consumo. O inciso supracitado explicita que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A lei citada pelo inciso entrou em vigor no dia 11 de setembro de 1990 e foi denominada como Código de Defesa do Consumidor, sob o nº 8.078/90.

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Aqui encontramos um desdobramento do direito à informação. Como é cediço é direito fundamental ao cidadão informar e ser informado. Desta maneira, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou de interesse coletivo ou geral. Para que seja efetivado o direito de informação, em caso de descumprimento, o ofendido poderá utilizar-se do remédio constitucional denominado *habeas data*, que tem por escopo assegurar o conhecimento das informações dos indivíduos que estejam em bancos de dados, bem como de retificar informações que estejam incorretas, por meio sigiloso, judicial ou administrativo.

É importante salientar que as informações deverão ser prestadas dentro do prazo estipulado em lei, sob pena de responsabilidade.

Todavia, o final do inciso supracitado traz uma limitação à liberdade de informação qual seja: a restrição aos dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

XXXIV- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Preliminarmente, é importante salientar que tanto o direito de petição ao Poder Público, como o direito de obtenção de certidões em repartições públicas são assegurados, independentemente, do pagamento de taxas. Isso não quer dizer que o exercício desses direitos seja realizado gratuitamente, mas sim, que podem ser isentos de taxas para as pessoas reconhecidamente pobres.

A alínea “a” traz, em seu bojo, o direito de petição. Tal direito consiste na possibilidade de levar ao conhecimento do Poder Público a ocorrência de atos eivados de ilegalidade ou abuso de poder.

Posteriormente, a alínea “b” trata da obtenção de certidões em repartições públicas. De acordo com a Lei nº 9.051/95 o prazo para o esclarecimento de situações e expedição de certidões é de quinze dias. Todavia, se a certidão não for expedida a medida jurídica cabível é a impetração do mandado de segurança e não o habeas data.

XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Neste inciso encontra-se consagrado o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Como explicita o próprio conteúdo do inciso supracitado, não poderão haver óbices para o acesso ao Poder Judiciário. Havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, tal questão deverá ser levada até o Poder Judiciário para que possa ser dirimida. Quando a lesão acontecer no âmbito administrativo não será necessário o esgotamento das vias administrativas. Assim, o lesado poderá ingressar com a medida cabível no Poder Judiciário, independentemente do esgotamento das vias administrativas. Todavia, há uma exceção a essa regra. Tal exceção diz respeito à Justiça Desportiva, que exige para o ingresso no Poder Judiciário, o esgotamento de todos os recursos administrativos cabíveis.

XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Quando este inciso explicita que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a real intenção é a preservação da segurança jurídica, pois com a observância deste estaremos diante da estabilidade das relações jurídicas. Para um melhor entendimento, o conceito dos institutos supracitados estão dispostos no artigo 6º da LICC (Lei de Introdução ao Código Civil). São eles:

- Direito adquirido: Direito que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem;
- Ato jurídico perfeito: Ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou;
- Cosa julgada: Decisão judicial de que não caiba mais recurso.

Estes institutos são de extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro, pois eles garantem a estabilidade de relações jurídicas firmadas. Imaginemos se inexistissem tais institutos e uma lei que trouxesse malefícios entrasse em vigor? Estaríamos diante de total insegurança e anarquia jurídica, pois, transações realizadas, contratos firmados, sentenças prolatadas poderiam ser alteradas pela superveniência de um ato normativo publicado. Assim, com a existência de tais institutos jurídicos, uma lei posterior não poderá alterar o conteúdo de relações jurídicas firmadas, o que enseja ao jurisdicionado um sentimento de segurança ao buscar o acesso ao Poder Judiciário.

XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exceção;

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta no inciso supracitado, a impossibilidade de adoção no ordenamento jurídico brasileiro, do juízo ou tribunal de exceção. São considerados juízos ou tribunais de exceção, aqueles organizados posteriormente à ocorrência do caso concreto. O juízo de exceção é caracterizado pela transitoriedade e pela arbitrariedade aplicada a cada caso concreto. Esse juízo ofende claramente ao princípio do juiz natural, que prevê a garantia de ser julgado por autoridade judiciária previamente competente.

XXXVIII- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

- a) a plenitude da defesa;
- b) o sigilo das votações;
- c) a soberania dos veredictos;
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

A instituição do Tribunal do Júri foi criada originariamente com o escopo de julgar os crimes de imprensa. Todavia, com o passar dos tempos, essa instituição passou a ser utilizada com a finalidade de julgar os crimes dolosos contra a vida.

Os crimes contra a vida, compreendidos entre os artigos 121 a 128 do Código Penal, são os seguintes: homicídio; induzimento; instigação e auxílio ao suicídio; infanticídio e aborto. Cabe ressaltar que a instituição do júri somente é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabendo ao juízo monocrático ou singular o julgamento dos crimes culposos.

Crime doloso, segundo o Código Penal, é aquele onde o sujeito praticante da conduta lesiva quer que o resultado lesivo se produza ou assume o risco de produzi-lo. Já, o crime culposos, é aquele onde o sujeito ativo praticante da conduta agiu sob imprudência, negligência ou imperícia.

Como característica dessa instituição está a plenitude de defesa. A plenitude de defesa admite a possibilidade de todos os meios de defesa, sendo caracterizado como um nível maior de defesa do que a ampla defesa, defendida em todos os procedimentos judiciais, sob pena de nulidade processual.

Outra característica importante acerca da instituição do Tribunal do Júri é o sigilo das votações. No dia do julgamento em plenário, após os debates, o juiz presidente do Tribunal do Júri efetua a leitura dos quesitos formulados acerca do crime para os sete jurados, que compõe o Conselho de Sentença, e os questiona se estão preparadas para a votação. Caso seja afirmativa a resposta, estes serão encaminhados, juntamente com o magistrado até uma sala onde será realizada a votação. Neste ato, o juiz efetua a leitura dos quesitos e um oficial entrega duas cédulas de papel contendo as palavras sim e não aos jurados. Posteriormente, estas são recolhidas, para que seja possível chegar ao resultado final do julgamento. É importante salientar que essa característica de sigilo atribuída à votação deriva do fato que inexistia possibilidade de se descobrir qual o voto explicitado pelos jurados individualmente. Isso decorre que inexistia qualquer identificação nas cédulas utilizadas para a votação.

A última característica referente à instituição do Tribunal do Júri diz respeito à soberania dos veredictos. Essa característica pressupõe que as decisões tomadas pelo Tribunal do Júri não poderão ser alteradas pelo Tribunal de Justiça respectivo. No entanto, um entendimento doutrinário atual considera a possibilidade de alteração da sentença condenatória prolatada no Tribunal do Júri, quando estiver pairando questão pertinente aos princípios da plenitude de defesa, do devido processo legal e da verdade real.

XXXIX- não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Esse princípio, muito utilizado no Direito Penal, encontra-se bipartido em dois subprincípios, quais sejam: subprincípio da reserva legal e subprincípio da anterioridade.

O primeiro explicita que não haverá crime sem uma lei que o defina, ou seja, não será possível imputar determinado crime a um indivíduo, sem que a conduta cometida por este esteja tipificada, ou seja, prevista em lei como crime. Ainda o subprincípio da reserva legal explicita que não haverá pena sem cominação legal.

Já, o subprincípio da anterioridade, demonstra que há necessidade uma lei anterior ao cometimento da conduta para que seja imputado o crime ao sujeito ativo praticante da conduta lesiva. Outrossim, não será possível a aplicabilidade de pena, sem uma cominação legal estabelecida previamente.

Não teria sentido adotarmos o princípio da legalidade, sem a correspondente anterioridade, pois criar uma lei, após o cometimento do fato, seria totalmente inútil para a segurança que a norma penal deve representar a todos os seus destinatários.

O indivíduo somente está protegido contra os abusos do Estado, caso possa ter certeza de que as leis penais são aplicáveis para o futuro, a partir de sua criação, não retroagindo para abranger condutas já realizadas.

A lei penal produz efeitos a partir de sua entrada em vigor, não se admitindo sua retroatividade maléfica. Não pode retroagir, salvo se beneficiar o réu.

É proibida a aplicação da lei penal inclusive aos fatos praticados durante seu período de *vacatio*. Embora já publicada e vigente, a lei ainda não estará em vigor e não alcançará as condutas praticadas em tal período.

Vale destacar, entretanto, a existência de entendimentos no sentido de aplicabilidade da lei em *vacatio*, desde que para beneficiar o réu.



Vacatio refere-se ao tempo em que a lei é publicada até a sua entrada em vigor. A lei somente será aplicável a fatos praticados posteriormente a sua vigência.

XL- a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Nesse caso estamos diante da irretroatividade da lei penal. Como é possível perceber, o inciso em questão veda expressamente a retroatividade da lei penal. Todavia, a retroatividade, exceção expressamente prevista, somente será possível no caso de aplicação de lei benéfica ao réu.

Cabe ressaltar que o réu é o sujeito ativo praticante da conduta criminosa. No caso específico deste inciso estamos diante de aplicação de leis penais no tempo. A critério exemplificativo, imaginemos: o artigo 121, *caput*, do Código Penal explicita que o indivíduo que cometa o crime de homicídio (matar alguém) terá contra si aplicada pena de 6 a 20 anos. Um indivíduo que cometa essa conduta na vigência desta lei terá contra si aplicada a pena supracitada. Agora, imaginemos que após a realização de tal conduta seja publicada uma lei que aumente o limite de pena a ser aplicada aos praticantes do crime de homicídio para 10 a 30 anos. Essa lei poderá retroagir e atingir a situação processual do indivíduo que cometeu o crime sob a égide da lei anterior mais benéfica? A resposta é negativa. Isso ocorre pelo fato de que não é possível a retroatividade de lei maléfica ao réu.

Agora, imaginemos que após a realização da conduta criminosa haja a superveniência de uma lei que reduza a pena aplicada ao sujeito ativo praticante do crime de homicídio para 1 a 3 anos ou determine que a prática de tal conduta não será mais considerada como crime pelo ordenamento jurídico. Tal lei poderá retroagir? A resposta é afirmativa. Isso ocorre pelo fato de que a existência de lei mais benéfica ao réu retroagirá.

XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

Este inciso garante que a lei punirá qualquer conduta discriminatória que atente contra os direitos e liberdades fundamentais. Todavia, como é possível perceber há necessidade da existência de uma lei que descreva a punição aos sujeitos praticantes dessas condutas, tendo em vista a obediência ao princípio da legalidade.

XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Atualmente, um dos grandes objetivos da sociedade global é a luta pela extinção do racismo no mundo. A nossa Constituição no inciso supracitado foi muito feliz em abordar tal assunto, haja vista a importância do mesmo dentro da conjectura social do nosso país.

De acordo com o inciso XLII, a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. O caráter de inafiançabilidade deriva do fato que não será admitido o pagamento de fiança em razão do cometimento de uma conduta racista. Como é cediço, a fiança consiste na prestação de caução pecuniária ou prestação de obrigações que garantem a liberdade ao indivíduo até sentença condenatória.

Outrossim, a prática do racismo constitui crime imprescritível. Para interpretar de maneira mais eficaz o conteúdo do inciso supracitado é necessário entendermos em que consiste o instituto da prescrição. A prescrição consiste na perda do direito de punir pelo Estado, em razão do elevado tempo para apuração dos fatos. Assim, o Estado não possui tempo delimitado para a apuração do fato delituoso, podendo o procedimento perdurar por vários anos. Cabe ressaltar que existem diversas espécies de prescrição, todavia, nos ateremos somente ao gênero para uma noção do instituto tratado.

Ademais, o inciso estabelece que o crime em questão será sujeito à pena de reclusão. A reclusão é uma modalidade de pena privativa de liberdade que comporta alguns regimes prisionais, quais sejam: o fechado, o semiaberto e o aberto.

XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

O inciso em questão tem por objetivo vetar alguns benefícios processuais aos praticantes de crimes considerados como repugnantes pela sociedade. Os crimes explicitados pelo inciso são: tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os hediondos.

Os crimes hediondos, expressamente dispostos no artigo 1º, da Lei nº 8.072/90, são os seguintes:

- a) homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente e homicídio qualificado;
- b) lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;
- c) latrocínio (roubo seguido de morte);
- d) extorsão qualificada pela morte;
- e) extorsão mediante sequestro e na forma qualificada;
- f) estupro;
- g) estupro de vulnerável;
- h) epidemia com resultado morte;
- i) falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais;
- j) favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável;
- k) genocídio (crime cometido com a intenção de aniquilar um grupo humano, nacional, étnico, racial ou religioso. O genocídio é cometido mais frequentemente por grupos organizados, geralmente pelos governos, do que por indivíduos).

Como é possível perceber, tanto os crimes hediondos como os demais citados anteriormente são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O legislador buscou com essa vedação não garantir a possibilidade de extinção da punibilidade aos autores dos crimes em questão. Ademais, cabe ressaltar que as consequências pela prática desses delitos abrangem os autores, mandantes, executores e os que se omitiram, quando da possibilidade de evitar que o mesmo se perpetuasse.

LXIV- constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Este inciso demonstra o caráter inafiançável e imprescritível da ação de grupos, armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Como já foi explicitado anteriormente, o cometimento de tais crimes não são submetidos ao pagamento de fiança, para que o sujeito praticante do mesmo possa aguardar em liberdade eventual sentença condenatória. Não obstante, a prática de tais ações se caracteriza como imprescritíveis, ou seja, o Estado não possui um tempo delimitado para apuração dos fatos, podendo levar anos para solucionar o caso.

XLV- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

Neste inciso estamos diante do princípio da personalização da pena. Preliminarmente, para melhor compreensão do inciso é necessário explicitar que estamos diante de responsabilidades nos âmbitos civil e penal.

No âmbito penal, a pena é personalíssima, ou seja, deverá ser cumprida pelo sujeito praticante do delito, não podendo ser transferida a seus herdeiros. Esta assertiva se justifica pelo fato de que se o condenado falecer, de acordo com o artigo 107 do Código Penal, será extinta sua punibilidade.

Todavia, quando tratamos de responsabilidade no âmbito civil, a interpretação é realizada de maneira diversa. De acordo com o inciso supracitado, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens podem se estender aos sucessores do condenado e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso ocorre pelo fato que no âmbito civil a pena não possui o caráter personalíssimo.

XLVI- a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição de liberdade;

- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

Este inciso expressa o princípio da individualização da pena. Desta maneira, além do princípio da personalização da pena, há o emprego da individualização no cumprimento da pena, pois é necessário que exista uma correspondência entre a conduta externalizada pelo sujeito e a punição descrita pelo texto legal.

Nesse passo, o inciso XLVI traz, em seu bojo, as espécies de penas admissíveis de aplicação no Direito Pátrio. São elas:

- a) privação ou restrição de direitos
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos.

Assim, o inciso apresenta um rol exemplificativo das penas admissíveis no ordenamento jurídico brasileiro, para, posteriormente, no inciso subsequente expressar as espécies de penas vedadas.

XLVII- não haverá penas:

- a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, XIX;
- b) de caráter perpétuo;
- c) de trabalhos forçados;
- d) de banimento;
- e) cruéis;

Aqui estamos diante do rol taxativo de penas não passíveis de aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São elas:

- **Pena de morte:** em regra, não será admitida sua aplicação no Direito Pátrio. Porém, a própria alínea “a” demonstra a possibilidade de aplicação de tal pena nos casos de **guerra declarada**.

- **Pena de caráter perpétuo:** Não é admissível sua aplicação, pois uma das características inerentes da pena é o caráter de provisoriedade.

- **Pena de trabalhos forçados:** Essa espécie de pena proíbe o trabalho infamante, prejudicial ao condenado, em condições muito difíceis. No entanto, é importante salientar que a proibição de trabalhos forçados não impede o trabalho penitenciário, utilizado como sistemática de recuperação.

- **Pena de banimento:** A pena de banimento consiste na expulsão do brasileiro do território nacional. Tal pena é proibida pela nossa Constituição sem qualquer ressalva.

- **Pena cruel:** Essa espécie de pena é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, a definição de crueldade é complexa, haja vista se tratar de questão subjetiva, pois cada pessoa pode atribuir um conceito diverso a tal expressão.

XLVIII- a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

De acordo com o inciso supracitado a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, devendo-se levar em conta critérios, como: natureza do delito, idade e sexo do apenado. Um exemplo a ser citado é o da Fundação CASA, para onde são destinados os adolescentes que cometem atos infracionais.

XLIX- é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

A tutela do preso cabe ao Estado. Assim, sua integridade física e moral deve ser preservada, sob pena de responsabilização do Estado pela conduta dos seus agentes e dos outros presos. O fato de estar preso não significa que ele poderá receber tratamento desumano ou degradante.

É importante salientar que este inciso é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, pois, independentemente do instinto criminoso, o preso é uma pessoa que possui seus direitos protegidos pela Carta Magna.

L- às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

Neste inciso não se busca a proteção dos direitos da presidiária, mas sim dos filhos, pois, como é cediço, é de extrema importância a alimentação das crianças com leite materno, bem como a convivência com a mãe nos primeiros dias de vida.

LI- nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

O presente inciso demonstra a impossibilidade de extradição do brasileiro nato. Em hipótese alguma o brasileiro nato será extraditado. Contudo, o brasileiro naturalizado, poderá ser extraditado desde que ocorram as seguintes situações:

- **Antes da naturalização:** prática de crime comum ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

- **Depois da naturalização:** comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

LII- não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Este inciso traz as únicas hipóteses em que o estrangeiro não será extraditado, quais sejam: O cometimento de crime político ou de opinião. É importante não confundir a expressão “crime político” com a expressão “crime eleitoral”. Essa diferenciação é de extrema importância, pois crimes políticos são aqueles que atentam contra a estrutura política de um Estado, enquanto os crimes eleitorais são aqueles referentes ao processo eleitoral, explicitados pelo respectivo Código.

Com relação aos crimes de opinião, podemos defini-los como aqueles que sua execução consiste na manifestação de pensamento. Sendo estes a calúnia, a difamação e a injúria.

LIII- ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente;

Este inciso expressa a existência de dois princípios consagrados pela doutrina. O primeiro diz respeito ao princípio do promotor natural e o segundo ao princípio do juiz natural. O princípio do promotor natural consiste no fato que ninguém será processado, senão por autoridade competente, ou seja, será necessária a existência de um Promotor de Justiça previamente competente ao caso, não se admitindo, portanto, a designação de uma autoridade para atuar em determinado caso. Já a segunda parte do inciso demonstra a presença do princípio do juiz natural, onde há a consagração que ninguém será sentenciado, senão por autoridade competente. Isso importa dizer que não será possível existência de juízos ou tribunais de exceção, ou seja, especificamente destinados à análise de um caso concreto.

LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Este inciso denota o princípio constitucional do devido processo legal. Vislumbra-se que para que haja um processo legal, há necessidade da observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não poderão ser utilizadas provas ilícitas bem como julgamento por autoridade incompetente. Assim, como é possível perceber, o princípio do devido processo legal abrange vários outros princípios, visando, desta maneira, chegar a um provimento jurisdicional satisfativo.

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Neste inciso estamos diante dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios, definitivamente, são dois dos mais importantes existentes no ordenamento jurídico. É importante salientar

que o contraditório e a ampla defesa devem ser observados não somente em processos judiciais, mas também nos administrativos.

Todavia, existem questões controversas acerca do contraditório e da ampla defesa. Uma delas diz respeito ao inquérito policial, onde para alguns doutrinadores não há que se cogitar a aplicação destes princípios, já que no inquérito inexistente acusação, sendo este apenas um instrumento administrativo tendente à coleta de provas que visem embasar a propositura da ação penal pelo membro do Ministério Público.

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

A Constituição ao explicitar serem inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, diz respeito às provas adquiridas em violação a normas constitucionais ou legais. Em outras palavras: prova *ilícita* é a que viola regra de direito material, seja constitucional ou legal, no momento de sua obtenção (ex.: confissão mediante tortura). Por outro lado, as provas que atingem regra de direito processual, no momento de sua produção em Juízo, como por exemplo, interrogatório sem a presença de advogado; colheita de depoimento sem a presença de advogado, não são taxadas de ilícitas, mas sim de *ilegítimas*. Em que pese essas considerações, ambos os tipos de provas são inadmissíveis no processo, sob pena de nulidade.

LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória;

Aqui estamos diante do princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade. Conforme dispõe o próprio inciso, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando falamos em trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estamos diante de uma sentença que condenou alguém pela prática de um crime e não há mais possibilidade de interposição de recursos. Assim, após o trânsito em julgado da sentença será possível lançar o nome do réu no rol dos culpados.

A sentença de pronúncia é aquela que encerra a primeira fase do procedimento do júri, após verificadas a presença de autoria e materialidade. Como já dito anteriormente, não é possível efetuar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados após essa sentença, pois este ainda será julgado pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Outro ponto controverso diz respeito à prisão preventiva. Muito se discutiu se a prisão preventiva afetaria ao princípio da presunção de inocência. Porém, esse assunto já foi dirimido pela jurisprudência, ficando decidido que a prisão processual não afeta o princípio esposado no inciso em questão.

Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o acusado não pode ser considerado culpado. Cabe à acusação provar a sua culpa. A prisão, antes da condenação definitiva, só é possível em casos de flagrante delito ou por ordem fundamentada do juiz (preventiva ou temporária).



LVIII- o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

A regra admitida pelo Texto Constitucional é que o indivíduo já identificado civilmente não deverá ser submetido à outra identificação, para fins criminais. Todavia, o inciso supracitado, traz, em sua parte final, uma exceção à regra, admitindo a identificação criminal aos civilmente identificados, desde que haja previsão legal.

A Lei nº 10.054/00, traz em seu artigo 3º, as hipóteses em que o civilmente identificado deverá proceder à identificação criminal. São elas:

- Estiver indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, crime de receptação qualificada, crimes contra a dignidade sexual ou crime de falsificação de documento público;
- Houver fundada suspeita de falsificação ou adulteração de documento de identidade;
- O estado de conservação ou a distância temporal da expedição de documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais;
- Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;

- Houver registro de extravio do documento de identidade;
- Indiciado ou acusado não comprovar, em quarenta e oito horas, sua identificação civil.

LIX- será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

O inciso LIX consagra a possibilidade de ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública. Preliminarmente, antes de tecer quaisquer comentários acerca dessa espécie de ação, cabe ressaltar que as ações penais se dividem em: ações penais públicas e ações penais privadas.

As ações penais públicas, que possuem o Ministério Público como legitimado privativo na sua proposição, se dividem em ações penais públicas incondicionadas e ações penais públicas condicionadas.

As ações penais públicas incondicionadas independem de qualquer espécie de condição para a sua propositura. Neste caso, se o membro do Ministério Público, após a análise do caso concreto, se convencer da ocorrência de crime, deverá oferecer a denúncia, peça processual inaugural da ação penal. Neste caso, o membro do Ministério Público poderá iniciar a ação penal sem a necessidade de obediência de qualquer condição.

Noutro passo, as ações penais condicionadas dependem da obediência de algumas condições para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, e assim, dar início à ação penal que levará a uma sentença penal que poderá ter cunho condenatório ou absolutório. As condições a serem obedecidas são as seguintes: representação do ofendido e requisição do Ministro da Justiça.

É importante salientar que os crimes onde seja necessário o ajuizamento de ação penal pública condicionada e os de ação penal privada serão expressamente dispostos. Assim, podemos chegar à conclusão de que, subtraídos os crimes de ação penal pública condicionada e os crimes de ação penal privada, os demais serão de ação penal pública incondicionada.

Os crimes de ação penal privada são aqueles em que o Estado transferiu a titularidade do ajuizamento da ação ao ofendido, ou seja, à vítima do crime.

A ação penal privada se divide em algumas espécies, mas vamos nos ater à ação penal privada subsidiária da pública, objeto do inciso em estudo.

Essa espécie de ação penal privada irá entrar em cena quando o Ministério Público, legitimado privativamente ao exercício da ação penal pública, ficar inerte, não agir, como por exemplo, deixar de oferecer a denúncia.

Assim, em caso de inércia do Ministério Público, o próprio ofendido poderá ajuizar a ação penal. Cabe ressaltar, no presente caso, que mesmo havendo a inércia do Ministério Público e o eventual ajuizamento da ação pelo ofendido, a legitimidade privativa no ajuizamento da ação penal conferida ao Ministério Público não é transferida.

LX- a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

A regra, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é a publicidade de todos os atos processuais. Contudo o inciso LX, dispõe que poderá haver restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Um exemplo do presente caso diz respeito às questões referentes ao Direito de Família (ex.: ação de reconhecimento de paternidade).

LXI- ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

A liberdade é um direito do cidadão constitucionalmente tutelado. Porém, a prisão constitui uma das restrições à aplicabilidade do direito à liberdade. Este inciso explicita que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. De acordo com este inciso só existem duas maneiras de se efetuar a prisão de um indivíduo. A primeira se dá através da prisão em flagrante, ou seja, quando, em regra, o indivíduo é flagrado praticando o crime. É importante salientar que existem diversas espécies de prisão em flagrante, todavia, nos ateremos somente ao gênero para entendimento deste inciso. Cabe ressaltar que a prisão em flagrante não pressupõe a existência de

ordem escrita e fundamentada de juiz competente, pois este tipo de prisão pode ser realizada por qualquer pessoa.

Já a segunda maneira é a prisão realizada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (ou seja, mandado de prisão). É importante ressaltar que existem outras espécies de prisão, tais como: prisão preventiva e prisão temporária. Essas prisões para se efetivarem, necessitam da existência de um mandado de prisão assinado pelo juiz competente.

Em que pese à garantia de que ninguém será preso senão através das hipóteses supracitadas, cabe ressaltar que para os militares existem algumas ressalvas. De acordo com a parte final do inciso comentado, os militares poderão ser presos em razão de transgressão militar ou pelo cometimento de crime militar, previstos em lei.

LXII- a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família ou à pessoa por ele indicada;

Este inciso demonstra alguns dos direitos do preso, dentre eles a comunicação à família ou pessoa por ele indicada. Ademais, é importante salientar que o juiz competente também será comunicado para que tome as medidas cabíveis.

LXIII- o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

Neste inciso, outros direitos do preso estão presentes, quais sejam: o de permanecer calado, de assistência da família e de advogado. O primeiro deles trata da possibilidade do preso permanecer calado, haja vista que este não é obrigado a produzir prova contra si. Ademais, os outros garantem que seja assegurado este a assistência de sua família e de um advogado.

LXIV- o preso tem direito a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

Este inciso visa à identificação das pessoas ou autoridades responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório, pois com a identificação destes há facilidade de responsabilização em caso de eventuais atos abusivos cometidos contra o preso.

LXV- a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

Este inciso é de extrema relevância, pois permite o relaxamento da prisão do indivíduo que porventura tenha sofrido cerceamento em sua liberdade por uma prisão que esteja eivada de ilegalidade. Esta ilegalidade pode ocorrer por diversos motivos, como por exemplo, nulidades, abuso de autoridade no ato da prisão, dentre outros.

Desta maneira, comprovada a ilegalidade da prisão, o relaxamento desta é medida indispensável, ou seja, deverá ser libertado o indivíduo do cárcere.

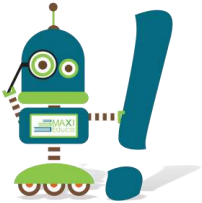
LXVI- ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

Diferentemente do inciso anterior, onde a prisão encontrava-se eivada de ilegalidade, aqui estamos diante de prisão legalmente realizada, sem ocorrência de nulidades, vícios ou abusos. Todavia, o Código de Processo Penal brasileiro admite que o indivíduo responda ao processo pelo crime que cometeu em liberdade, desde que, previamente, efetue o pagamento de fiança. Contudo, existem outros casos em que é admissível a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança.

Cabe ressaltar que a liberdade provisória com o pagamento de fiança constitui dever tanto do Juiz de Direito como do Delegado de Polícia (sendo deste somente nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos). Já, a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança deverá ser analisada somente pelo Juiz de Direito.

LXVII- não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Este inciso consagra, em regra, a impossibilidade de prisão civil por dívida no ordenamento jurídico brasileiro. A prisão civil é medida privativa de liberdade, sem caráter de pena, com a finalidade de compelir o devedor a satisfazer uma obrigação. Nos termos da Constituição Federal a prisão civil será cabível em duas situações, no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e no caso do depositário infiel. Porém, o *Pacto de San José da Costa Rica*, ratificado pelo Brasil (recepção de forma equivalente a norma constitucional), autoriza a prisão somente em razão de dívida alimentar. Desta forma, com base no pacto não se admite, por manifesta inconstitucionalidade, a prisão civil por dívida no Brasil, quer do alienante fiduciário, quer do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que só é possível a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.



Súmula Vinculante Nº 25 do STF: "É ilícito a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito"

LXVIII- conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Neste inciso estamos diante de um dos remédios constitucionais processuais mais importantes existentes no ordenamento jurídico, qual seja: o habeas corpus.

Este remédio constitucional tem por escopo assegurar a efetiva aplicação do direito de locomoção, ou seja, o direito de ir, vir e permanecer em um determinado local.

Como é possível perceber, este remédio constitucional poderá ser utilizado tanto no caso de iminência de violência ou coação à liberdade de locomoção, como no caso de efetiva ocorrência de ato atentatório à liberdade supracitada.

Assim, são duas as espécies de habeas corpus:

- **Preventivo ou salvo-conduto:** Neste caso o habeas corpus será impetrado pelo indivíduo que se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Esta espécie de habeas corpus será impetrada na iminência de ocorrência de violência ou coação à liberdade de locomoção, com a finalidade de obter um salvo-conduto, ou seja, um documento para garantir o livre trânsito em sua liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer). Por exemplo, Fulano está sendo acusado de cometer um crime de roubo, porém existem indícios de que não foi ele que comete o crime, este impetra o Habeas Corpus preventivo, o juiz reconhecendo legítimos seus argumentos concede a este o salvo-conduto, que permitirá que este se mantenha solto até a decisão final do processo.

- **Repressivo ou liberatório:** Aqui haverá a impetração quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, estamos diante de um ato atentatório já realizado contra a liberdade de locomoção do indivíduo. Nesse passo, o habeas corpus será impetrado com a finalidade de obter a expedição de um alvará de soltura (documento no qual consta ordem emitida pelo juiz para que alguém seja posto em liberdade).

LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público;

O mandado de segurança é outro importante remédio constitucional que tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De acordo com o inciso supracitado, o objeto desta ação constitucional é a proteção de direito líquido e certo.

Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, através de prova pré-constituída, sendo, portanto, dispensada a dilação probatória.

É importante salientar que somente será possível a impetração de mandado de segurança, nos casos não amparados por habeas corpus ou habeas data. Isso ocorre pelo fato de que é necessário utilizar o remédio processual adequado ao caso. Caber ressaltar que um dos requisitos mais importantes para a

impetração do mandado de segurança é a identificação da autoridade coatora pela ilegalidade ou abuso do poder. De acordo com o inciso em questão a autoridade poderá ser pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições de Poder Público. Para fins de impetração de mandado de segurança, autoridade é o agente investido no poder de decisão. É importante tal caracterização, pois, desta maneira, não há o risco de ilegitimidade passiva na impetração do mandado de segurança.

Similarmente ao habeas corpus, existem duas espécies de mandado de segurança:

- Preventivo: Quando estamos diante de ameaça ao direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder.

- Repressivo: Quando a ilegalidade ou abuso de poder já foram praticados.

LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Neste inciso encontra-se presente o remédio constitucional denominado de mandado de segurança coletivo. Este remédio constitucional tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder referente à proteção ou reparação de interesses da coletividade.

É importante salientar que somente serão legitimados para a impetração do mandado de segurança coletivo os dispostos no inciso supracitado. São eles:

- Partido político com representação no Congresso Nacional;

- Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Cabe frisar que deverão ser obedecidos todos os requisitos estabelecidos para que seja possível a impetração do remédio constitucional. Ressalta-se ainda, que uma associação legalmente constituída há menos de um ano não pode impetrar mandado de segurança coletivo, pois há necessidade da constituição legal desta por, no mínimo, um ano. Ademais, há necessidade de que o objeto da tutela seja a defesa dos interesses dos membros ou associados, sob pena da não consagração do remédio constitucional supracitado.

Outrossim, para que os partidos políticos sejam legitimados ativos para a impetração de mandado de segurança coletivo há necessidade de que estes possuam representação no Congresso Nacional.

LXXI- conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Este inciso traz, em seu bojo, o mandado de injunção, que tem por escopo principal combater a inefetividade das normas constitucionais. Para que seja possível a impetração de mandado de injunção há necessidade da presença de dois requisitos:

- Existência de norma constitucional que preveja o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

- Inexistência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

A grande consequência do mandado de injunção consiste na comunicação ao Poder Legislativo para que elabore a lei necessária ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

LXXII- conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

O habeas data, considerado como um remédio constitucional tem por escopo assegurar o direito de informação consagrado no artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. De acordo com o princípio da informação todos têm direito de receber informações dos órgãos públicos, sendo apresentadas algumas ressalvas. Assim, o habeas data é o remédio constitucional adequado à tutela do direito de informação, pois, através dele busca-se assegurar o conhecimento de informações

relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Não obstante, o habeas data é utilizado para a retificação de dados do impetrante, sempre que não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Neste inciso estamos diante da Ação Popular, efetivo instrumento processual utilizado para anulação de atos lesivos ao patrimônio público e para a defesa de alguns interesses de extrema importância como o meio ambiente.

Tal instrumento, regido pela Lei nº 4.717/65, confere legitimidade de propositura ao cidadão, imbuído de direitos políticos, civis e sociais. Este remédio constitucional, cuja legitimidade para propositura, é do cidadão, visa um provimento jurisdicional (sentença) que declare a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público.

Quando o inciso em questão explicita que qualquer cidadão poderá ser parte legítima para propor a ação popular, é necessário ter em mente que somente aquele que se encontra no gozo dos direitos políticos, ou seja, possa votar e ser votado, será detentor de tal prerrogativa.

Existe um grande debate na doutrina sobre um eventual conflito de aplicabilidade entre a ação popular e a ação civil pública.

A ação civil pública, explicitada pela Lei nº 7.347/85, é um instrumento processual tendente a tutelar interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Neste caso, a Lei da Ação Civil Pública, dispõe, em seu artigo 5º, um rol de legitimados à propositura da ação, como por exemplo: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, o Ministério Público, dentre outros. Desta maneira, se formos analisar minuciosamente o conteúdo disposto no artigo 5º, podemos perceber que o cidadão individualmente considerado, detentor de direitos políticos, não é legitimado para a propositura de tal ação. Assim, não há que cogitar de conflito entre essas ações, pois, indubitavelmente, ambas se completam em seus objetos.

LXXIV- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

De acordo com o inciso supracitado será dever do Estado à prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desta maneira, com a finalidade de atender aos indivíduos mais necessitados, a própria Constituição em seu artigo 134, trata da Defensoria Pública, instituição especificamente destinada a esse fim. De acordo com o artigo 134, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV.

LXXV- o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Este inciso consagra o dever de indenização do Estado no caso de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença. Aqui estamos diante de responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, será exigível a indenização, independentemente da comprovação de culpa ou dolo.

LXXVI- são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- a) o registro civil de nascimento;
- b) a certidão de óbito;

Conforme explicita o inciso em tela, a Constituição garante aos reconhecidamente pobres a gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. É importante salientar que a gratuidade somente alcança aos reconhecidamente pobres.

LXXVII- são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania;

Este inciso expressa a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, como por exemplo, a emissão do título de eleitor, que garante ao indivíduo o caráter de cidadão, para fins de propositura de ação popular.

LXXVIII- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Visando combater a morosidade do Poder Judiciário, este inciso trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a garantia de razoabilidade na duração do processo. Como é possível perceber, a duração razoável do processo deverá ser empregada tanto na esfera judicial, como administrativa, fazendo com que o jurisdicionado não necessite aguardar longos anos à espera de um provimento jurisdicional. Não obstante, o inciso em questão ainda denota que serão assegurados os meios que garantam a celeridade da tramitação do processo.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

O parágrafo em tela demonstra que os direitos e garantias fundamentais constantes no bojo de toda a Carta Magna passaram a ter total validade com a entrada em vigor da Constituição, independentemente, da necessidade de regulamentação de algumas matérias por lei infraconstitucional.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

O parágrafo 2º explicita que os direitos e garantias expressos em toda a Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Desta maneira, além dos direitos e garantias já existentes, este parágrafo consagra a possibilidade de existência de outros decorrentes do regime democrático. Não obstante, o parágrafo supracitado não exclui outros princípios derivados de tratados internacionais em que o Brasil seja signatário. Quando o assunto abordado diz respeito aos tratados, cabe ressaltar a importante alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 45/04, que inseriu o parágrafo 3º, que será analisado posteriormente.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Este parágrafo trouxe uma novidade inserida pela Emenda Constitucional nº 45/04 (Reforma do Judiciário). A novidade consiste em atribuir aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos o mesmo valor de emendas constitucionais, desde que sejam aprovados pelo rito necessário. Para que as emendas alcancem tal caráter é necessária à aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros. Contudo, cabe ressaltar que este parágrafo somente abrange os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Assim, os demais tratados serão recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro com o caráter de lei ordinária, diferentemente do tratamento dado aos tratados de direitos humanos, com a edição da Emenda nº 45/04.

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

Este parágrafo é outra novidade inserida ao ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 45/04. Nos moldes do parágrafo supracitado o Brasil se submete à jurisdição do TPI (Tribunal Penal Internacional), a cuja criação tenha manifestado adesão. Referido tribunal foi criado pelo Estatuto de Roma em 17 de julho de 1998, o qual foi subscrito pelo Brasil. Trata-se de instituição permanente, com jurisdição para julgar genocídio, crimes de guerra, contra a humanidade e de agressão, e cuja sede se encontra em Haia, na Holanda. Os crimes de competência desse Tribunal são imprescritíveis, dado que atentam contra a humanidade como um todo. O tratado foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 112, de 6 de junho de 2002, antes, portanto, de sua entrada em vigor, que ocorreu em 1 de julho de 2002.

Tal tratado foi equiparado no ordenamento jurídico brasileiro às leis ordinárias. Em que pese tenha adquirido este caráter, o mencionado tratado diz respeito a direitos humanos, porém não possui

característica de emenda constitucional, pois entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico antes da edição da Emenda Constitucional nº 45/04. Para que tal tratado seja equiparado às emendas constitucionais deverá passar pelo mesmo rito de aprovação destas.

O tema **Processo Eleitoral** foi tratado no tópico anterior, ao qual remetemos o leitor.



21 Princípio da legalidade.

O **princípio da legalidade**, um dos mais importantes princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permite. É importante demonstrar a diferenciação entre o princípio da legalidade estabelecido ao administrado e ao administrador. Como já explicitado para o administrador, o princípio da legalidade estabelece que ele somente poderá agir dentro dos parâmetros legais, conforme os ditames estabelecidos pela lei. Já, o princípio da legalidade visto sob a ótica do administrado, explicita que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude lei. Esta interpretação encontra abalamento no artigo 5º, II, da Constituição Federal de 1988.



22. Princípio da isonomia.

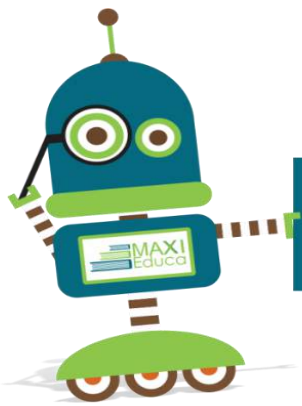
O inciso I do art. 5º traz, em seu bojo, um dos princípios mais importantes existentes no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da isonomia ou da igualdade. Tal princípio igualou os direitos e obrigações dos homens e mulheres, todavia, permitindo as diferenciações realizadas nos termos da Constituição.

Quando falamos em igualdade, podemos fazer a distinção entre igualdade material e igualdade formal. A igualdade material é aquela efetiva, onde realmente é possível perceber que há aplicabilidade da máxima que “os iguais serão tratados igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades”. Já, a igualdade formal é aquela explicitada pela lei, que nem sempre é vista na realidade de modo efetivo. Desta maneira, é importante salientar que nem sempre a igualdade formal corresponde à igualdade material.

Tal princípio vem sendo muito discutido ultimamente, principalmente no que diz respeito às cotas raciais utilizadas pelos negros com a finalidade de ingressarem em faculdades públicas.

De acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma vinculante, ninguém pode ser privado de direitos, nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica, em razão de sua orientação sexual, como, por exemplo, a percepção de benefício pela morte de companheiro do mesmo sexo. Com base no mesmo entendimento, a Suprema Corte, deu interpretação conforme ao art. 1.723 do

Código Civil, para assegurar o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo de forma contínua, pública e duradoura como entidade familiar.



23. Regime constitucional da propriedade. Função social da propriedade

O regime jurídico da propriedade tem a base constitucional, ao garantir o direito de propriedade, desde que atenda a sua função social (art. 5º, XXII e XXIII, da CF/88). Esse conjunto de normas denota que ela deveria ser olhada somente como uma instituição de ordem e relações econômicas (art. 170, II e III), porque os princípios gerais da atividade econômica são preordenados para o fim de “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (art. 170, caput).

A Constituição garante o direito de propriedade em geral (art. 5º, XXII), mas garante a propriedade urbana (art. 182, § 2º) e a propriedade rural (arts. 5º, XXVI, e 184 a 186), com seus regimes próprios.

O regime jurídico da propriedade é um complexo de normas administrativas, urbanísticas, empresariais e civis, sob fundamento das normas constitucionais.

A propriedade pública é a que tem como titular entidades de direito público: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Além das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (arts. 20, XI, e 231), a Constituição reconhece a propriedade pública, ao enumerar os bens da União (art. 20) e os dos Estados (art. 26), autoriza a desapropriação e faculta a exploração direta de atividade econômica pelo Estado e o monopólio (art. 177), que importam a apropriação pública dos bens de produção.

Função social da propriedade

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências constantes do Plano Diretor (art. 182, §2º, CF).

Conforme dispõe o art. 182, §4º da CF, é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- a) Parcelamento ou edificação compulsórios;
- b) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
- c) Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

O texto constitucional consagra expressamente a função social da propriedade rural, quando, em seu artigo 186, dispõe:

"Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

- I – aproveitamento racional e adequado;**
- II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;**
- III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;**
- IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores."**

O exercício da propriedade rural resta, portanto, condicionado ao cumprimento da função social que, in casu, manifesta-se no efetivo aproveitamento. Entretanto, o mero aproveitamento não basta por si só, mas necessita ser exercido de forma proveitosa ao interesse público.



24. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data.

Os remédios constitucionais, também conhecidos como “**tutela constitucional das liberdades**”, são direitos-garantia que servem de instrumento para a efetivação da tutela ou proteção dos direitos fundamentais. Em geral, são ações judiciais que procuram proteger os direitos públicos subjetivos.

Esses meios são utilizados quando o simples enunciado de direitos fundamentais não é suficiente para assegurar o respeito a eles. São instrumentos colocados à disposição dos indivíduos pela Constituição para a proteção de seus enunciados de direitos fundamentais.

Tem por objetivo exigir do destinatário (normalmente o Estado) uma ação ou omissão que seja suficiente para evitar uma lesão ou reparar a lesão causada. Esses remédios, quando visam provocar a atividade jurisdicional do Estado, são denominadas “ações constitucionais”, porque previstas na própria Constituição.

Habeas corpus

O habeas corpus tem sua origem remota no direito romano, onde todo o cidadão podia reclamar a exibição do homem livre detido ilegalmente por meio de uma ação privilegiada, conhecida por ***interdictum de libero homine exhibendo***. Parte da doutrina, porém, aponta sua origem na Magna Carta, outorgada pelo rei João Sem Terra em 1215.

No Brasil o ***habeas corpus*** entrou, pela primeira vez, na nossa legislação, de forma expressa com a promulgação do Código de Processo Criminal, em 1832, e **com exceção da Constituição de 1824, passou a ser prevista nas demais, iniciando-se na de 1891** (“dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer violência, ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder”, ou seja, servia até mesmo para anular um ato administrativo de cancelamento de uma matrícula escolar, para garantir a realização de comícios, etc). Atualmente, na Constituição da República de 1988, o ***habeas corpus*** está previsto no art. 5º, inciso LXVII.

Foi na constituição de 1926 que o HC teve seu âmbito de proteção reduzido, ficando vedada a sua aplicação para proteção de outros direitos que não a liberdade de ir e vir, além do que, vigorou, sem qualquer exceção, nas demais constituições, ficando suspensa apenas pelo AI-5 de 1968, no que concerne aos crimes políticos, contra a segurança nacional, contra a ordem econômica e social e contra a economia popular.

Este remédio constitucional tem por escopo assegurar a efetiva aplicação do direito de locomoção, ou seja, o direito de ir, vir e permanecer em um determinado local.

O HC é uma ação constitucional de caráter penal, possui procedimento especial, rito sumaríssimo – sem dilação probatória – e é gratuito para todos independentemente de condição social.

São partes do habeas corpus: o impetrante, o paciente e a autoridade coatora.

O ***impetrante*** é a pessoa que ingressa com a ação de habeas corpus. Qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pode com ela ingressar.

O ***paciente*** é a pessoa em favor de quem é impetrada à ordem de habeas corpus. Trata-se da pessoa que está sofrendo ou na iminência de sofrer constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir.

A ***Autoridade coatora*** (legitimidade passiva) é a pessoa em relação a quem é impetrada a ordem de habeas corpus, apontada como a responsável pela coação ilegal.

Em princípio a ordem somente deveria ser contra autoridades públicas, mas em face da realidade a jurisprudência tem admitido habeas corpus impetrado contra atos de particulares, como diretores de estabelecimentos psiquiátricos, casa clínicas de repouso e donos de fazenda.

Como é possível perceber, este remédio constitucional poderá ser utilizado tanto no caso de iminência de violência ou coação à liberdade de locomoção, como no caso de efetiva ocorrência de ato atentatório à liberdade supracitada.

Assim, são duas as espécies de habeas corpus:

- **Preventivo:** Neste caso o habeas corpus será impetrado pelo indivíduo que se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Esta espécie de habeas corpus será impetrada na iminência de ocorrência de violência ou coação à liberdade de locomoção, com a finalidade de obter um salvo-conduto, ou seja, para garantir um livre trânsito em sua liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer).

- **Repressivo:** Aqui haverá a impetração quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, estamos diante de um ato atentatório já realizado contra a liberdade de locomoção do indivíduo. Nesse passo, o habeas corpus será impetrado com a finalidade de obter a expedição de um alvará de soltura.

Algumas hipóteses de cabimento

Para desentranhar prova ilícita em processo penal: É possível utilizar o HC para impugnar a inserção de provas ilícitas em procedimento penal e postular o seu desentranhamento, sempre que, da imputação prevista no processo penal (ou inquérito), possa advir condenação a uma pena privativa de liberdade.

Neste caso o impetrante usa o HC preventivamente para manter o status de liberdade que atualmente possui.

Contra quebra de sigilo bancário: Pode-se utilizar o HC para impugnar a validade da decisão que decreta a quebra de sigilo bancário em processo penal uma vez que tal procedimento pode advir medida restritiva à liberdade de locomoção se a pena a ser aplicada for privativa de liberdade.

Contra a imposição de suspensão condicional da pena (sursis): Sendo o sursis um benefício concedido ao apenado para que fique em liberdade em troca da condição estabelecida, então, é cabível o pedido de HC em favor de paciente beneficiado com a suspensão condicional da pena porque caso não seja adimplente na condição prevista poderá ter sua liberdade cerceada.

Contra convocação de Comissões Parlamentares de Inquérito: Em caráter preventivo, é cabível contra ameaça de constrangimento à liberdade de locomoção, materializada na intimação do paciente para depor em CPI. A convocação contém em si a possibilidade de condução coercitiva da testemunha que se recuse a comparecer, ou seja, quando a pessoa convocada a depor perante a CPI entende que não foi convocada de forma correta ou que não tem envolvimento com o caso.

Também é cabível para aquele que foi convocado como testemunha e quer ver assegurado o seu direito de permanecer em silêncio.

Contra excesso de prazo em prisões cautelares: Para reprimir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, em face de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual penal.

Trancamento da ação penal ou do inquérito policial: O STF aceita que o HC seja utilizado como forma de trancar ação penal ou inquérito policial que se mostre descabido, abusivo e com possibilidade de ferir-se a honra do eventual impetrante do habeas.

Mandado de segurança individual e coletivo

O mandado de segurança é outro importante remédio constitucional que tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De acordo com o inciso supracitado, o objeto desta ação constitucional é a proteção de direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, através de prova pré-constituída, sendo, portanto, dispensada a dilação probatória.

É importante salientar que somente será possível a impetração de mandado de segurança, nos casos não amparados por habeas corpus ou habeas data. Isso ocorre pelo fato de que é necessário utilizar o remédio processual adequado ao caso.

Cabe ressaltar que um dos requisitos mais importantes para a impetração do mandado de segurança é a identificação da autoridade coatora pela ilegalidade ou abuso do poder. De acordo com o inciso em questão a autoridade poderá ser pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições de Poder Público. Para fins de impetração de mandado de segurança, autoridade é o agente investido no poder de decisão. É importante tal caracterização, pois, desta maneira, não há o risco de ilegitimidade passiva na impetração do mandado de segurança.

O direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. A jurisprudência entende que direito líquido e certo é o que pode ser comprovado de plano, pela apresentação de documentos. No mandado de segurança não se admite a abertura de fase instrutória.

Similarmente ao habeas corpus, existem duas espécies de mandado de segurança:

Preventivo: Quando estamos diante de ameaça ao direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder.

Repressivo: Quando a ilegalidade ou abuso de poder já foram praticados.

Legitimidade ativa: a pessoa que ingressa em juízo com o mandado de segurança é denominado impetrante, podendo ser qualquer pessoa física ou jurídica, que esteja sofrendo ou na autoridade pública em direito líquido e certo.

Sobre o assunto:

O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência do impetrado mesmo após a prolação da sentença de mérito. STJ. 2ª Turma. REsp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013 (Info 533).

No mandado de segurança, se o impetrante morre, os seus herdeiros não podem se habilitar para continuar o processo. Assim, falecendo o impetrante, o mandado de segurança será extinto sem resolução do mérito, ainda que já esteja em fase de recurso. Isso ocorre em razão do caráter mandamental e da natureza personalíssima do MS. STJ. 3ª Seção. EDcl no MS 11.581-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/6/2013 (Info 528).

Legitimidade passiva: A pessoa em relação a quem é proposto o mandado de segurança é denominada autoridade coatora, isto é, a autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público responsável pela violação ou ameaça de violação de direito líquido e certo. Equiparam-se às autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Não cabe mandado de segurança contra: I- ato do qual caiba recurso com efeito suspensivo, independentemente de caução; II- decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III- decisão judicial transitada em julgado.

O prazo para impetração do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, do interessado, do ato impugnado. Superado o prazo, ocorre a decadência do direito de impetrar esse remédio, não a perda do direito material, podendo valer-se o titular do direito líquido e certo violado somente das vias ordinárias.

O mandado de segurança coletivo tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder referente à proteção ou reparação de interesses da coletividade.

O interesse pertence à categoria, o impetrante age como substituto processual – legitimação extraordinária sem necessidade de autorização expressa (impetram em seu nome, mas na defesa dos interesses de seus membros ou associados).

É importante salientar que somente serão legitimados para a impetração do mandado de segurança coletivo o disposto no inciso supracitado. São eles:

- Partido político com representação no Congresso Nacional;
- Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Deverão ser obedecidos todos os requisitos estabelecidos para que seja possível a impetração do remédio constitucional. Cabe ressaltar que uma associação legalmente constituída há **menos** de um ano não pode impetrar mandado de segurança coletivo, pois há necessidade da constituição legal desta por, no mínimo, um ano. Ademais, há necessidade de que o objeto da tutela seja a defesa dos interesses dos membros ou associados, sob pena de não consagração do remédio constitucional supracitado.

Outrossim, para que os partidos políticos sejam legitimados ativos para a impetração de mandado de segurança coletivo há necessidade de que os mesmos possuam representação no Congresso Nacional.

Os direitos tutelados pelo mandado de segurança são:

I- coletivos, assim entendidos, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II- individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante (Lei n. 12.016/09, art. 21).

A impetração de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ações individuais, pois os direitos postulados são distintos.

Podemos citar como os dois maiores objetivos buscados com a criação do mandado de segurança coletivo o fortalecimento das organizações classistas e pacificar as relações sociais pela solução que o Judiciário dará a situações controvertidas que poderiam gerar milhares de litígios com a consequente desestabilização da ordem social.

As demais particularidades acerca do mandado de segurança e seus procedimentos estão previsto na Lei nº 12.016/2009.

Mandado de injunção

O mandado de injunção, que tem por escopo principal combater a inefetividade das normas constitucionais. Ação constitucional para a tutela de direitos previstos na Constituição inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania que não possam ser exercidos em razão da falta de norma regulamentadora.

Para que seja possível a impetração de mandado de injunção há necessidade da presença de dois requisitos:

- Existência de norma constitucional que preveja o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
- Inexistência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Legitimidade ativa: o mandado de injunção poderá ser proposto por qualquer pessoa física ou jurídica titular de direito previsto na Constituição inerentes à nacionalidade, soberania ou cidadania, que possa ser exercido por falta de norma infraconstitucional regulamentadora

Legitimidade ativa: o mandado de injunção deverá ser proposto contra a pessoa ou órgão responsável pela omissão normativa que inviabilize a concretização do direito previsto na Constituição. Tratando-se de inércia legislativa, a ação terá como réu o próprio Legislativo da respectiva esfera da federação. Tratando-se de projeto de lei que depende de iniciativa reservada, seja do Presidente da República, ou de Tribunal, a medida deverá ser oferecida contra a autoridade ou órgão que deixar de cumprir a obrigação constitucional.

O procedimento previsto para o mandado de injunção, no que couber, é o mesmo aplicado ao mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica, nos termos do disposto na Lei nº 8.038/90, art. 24, parágrafo único.

A grande consequência do mandado de injunção consiste na comunicação ao Poder Legislativo para que elabore a lei necessária ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

Habeas data

O habeas data, considerado como um remédio constitucional tem por escopo assegurar o direito de informação consagrado no artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. De acordo com o princípio da informação todos têm direito de receber informações dos órgãos públicos, sendo apresentadas algumas ressalvas. Assim, o habeas data é o remédio constitucional adequado à tutela do direito de informação, pois, através dele busca-se assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Não obstante, o habeas data é utilizado para a retificação de dados do impetrante, sempre que não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Legitimidade ativa: Qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, pode ingressar com uma ação de habeas data.

Legitimidade passiva: No polo passivo, podem estar:

- a) entidades governamentais da Administração direta ou indireta; ou
- b) pessoas jurídicas de direito privado que mantenham banco de dados aberto ao público.

O direito de informação deve ser compatibilizado com os dispositivos constitucionais que autorizam o sigilo de dado “imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Ação civil pública e ação popular

A **Ação Popular**, efetivo instrumento processual utilizado para anulação de atos lesivos ao patrimônio público e para a defesa de alguns interesses de extrema importância como o meio ambiente.

Tal instrumento, regido pela Lei nº 4.717/65, confere legitimidade de propositura ao cidadão, imbuído de direitos políticos, civis e sociais. Este remédio constitucional, cuja legitimidade para propositura, é do cidadão, visa um provimento jurisdicional (sentença) que declare a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público.

Quando o inciso em questão explicita que qualquer cidadão poderá ser parte legítima para propor a ação popular, é necessário ter em mente que somente aquele que se encontra no gozo dos direitos políticos, ou seja, possa votar e ser votado, será detentor de tal prerrogativa.

Assim, a propositura da ação popular exige a presença de três requisitos:

- a) condição de eleitor;
- b) ilegalidade; e
- c) lesividade.

Importante destacar que a ação popular para tutela de direitos ligados ao meio ambiente dispensa o requisito de ilegalidade do ato, bastando seja configurada a lesividade para dar aso à tutela pretendida. A lesividade ao meio ambiente, para além de ato ilegal em sentido lato, é ato inconstitucional que viola o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.

Existe um grande debate na doutrina sobre um eventual conflito de aplicabilidade entre a ação popular e a ação civil pública.

A **Ação Civil Pública**, explicitada pela Lei nº 7.347/85, é um instrumento processual tendente a tutelar interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Neste caso, a Lei da Ação Civil Pública, dispõe, em seu artigo 5º, um rol de legitimados à propositura da ação, como por exemplo: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, o Ministério Público, dentre outros. Desta maneira, se formos analisar minuciosamente o conteúdo disposto no artigo 5º, podemos perceber que o cidadão individualmente considerado, detentor de direitos políticos, não é legitimado para a propositura de tal ação. Assim, não há que cogitar de conflito entre essas ações, pois, indubitavelmente, ambas se completam em seus objetos.

Sobre o assunto:

Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

A **Defensoria Pública como parte legítima em ações coletivas:** É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos,

coletivos e individuais homogêneos. STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 (Info 784).

Direito à petição

O inc. XXXIV do art. 5.º da CF estabelece que, independentemente do pagamento de taxas, a todos são assegurados:

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Pode a petição ser dirigida a qualquer autoridade do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário e a autoridade a quem é dirigida deve apreciá-la, motivadamente, mesmo que apenas para rejeitá-la, pois o silêncio pode caracterizar o abuso de autoridade por omissão.

b) O direito de petição, classificado como direito de participação política, pode ser exercido por pessoa física ou jurídica e não precisa observar forma rígida. Não se exige interesse processual, pois a manifestação está fundada no interesse geral de cumprimento da ordem jurídica.

c) O direito de petição não se confunde como direito de ação, já que, por este último, busca-se uma tutela de índole jurisdicional e não administrativa.



25. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no Direito Brasileiro e no direito comparado

Dentre os direitos e garantias fundamentais, o direito de liberdade é consagrado na CF/88, sendo tratado sob vários aspectos:

1) Liberdade de Pensamento (art. 5.º, IV e V): É importante que o Estado assegure a liberdade das pessoas de manifestarem o seu pensamento. Foi vedado o anonimato para que a pessoa assumo aquilo que está manifestando caso haja danos materiais, morais ou à imagem. O limite na manifestação do pensamento se encontra no respeito à imagem e à moral das outras pessoas.

Caso ocorram danos, o ofendido poderá se valer de dois direitos:

a) Indenização por dano material, moral ou à imagem: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato – Súmula n. 37 do STJ”;

b) Direito de resposta, consiste essencialmente no poder, que assiste a todo aquele que seja pessoalmente afetado por notícia, comentário ou referência saída num órgão de comunicação social, de fazer publicar ou transmitir nesse mesmo órgão, gratuitamente, um texto seu desmentido, retificação ou apresentando defesa a esta informação. Este instrumento deve realmente ser usado para defesa e não para ataque ao ofensor. Se o direito de resposta for negado pelo veículo de comunicação, caberá medida judicial.

2) Liberdade de Consciência, de Crença e de Culto (art. 5.º, VI, VII e VIII): A liberdade de consciência refere-se à visão que o indivíduo tem do mundo, ou seja, são as tendências ideológicas, filosóficas, políticas, etc. de cada indivíduo. A liberdade de crença tem um significado de cunho religioso, ou seja, as pessoas têm a liberdade de cultuar o que elas acreditam. A CF proíbe qualquer distinção ou privilégio entre as igrejas e o Estado. O que se prevê é que o Estado poderá prestar auxílio a qualquer igreja quando se tratar de assistência à saúde, à educação, etc. Seja qual for a crença, o indivíduo tem direito a praticar o culto. A CF/88 assegura, também, imunidade tributária aos templos quando se tratar de qualquer valor auferido em razão de realização do culto. Ainda, a CF assegura o atendimento religioso

às pessoas que se encontrem em estabelecimentos de internação coletiva, como manicômios, cadeias, quartéis militares, etc.

3) Liberdade de Atividade Intelectual, Artística, Científica e de Comunicação (art. 5.º, IX): A CF estabelece que a expressão das atividades intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, não se admitindo a censura prévia. É uma liberdade, no entanto, com responsabilidade, ou seja, se houver algum dano moral ou material a outrem, haverá responsabilidade por indenização. O direito do prejudicado se limita à indenização por danos, não se podendo proibir a circulação da obra. Apesar de não haver previsão na CF/88 quanto à proibição de circulação de obras, o Judiciário está concedendo liminares, fundamentando-se no fato de que deve haver uma prevenção para que não ocorra o prejuízo e não somente a indenização por isso. Os meios de comunicação são públicos, sendo concedidos a terceiros. Caso a emissora apresente programas que atinjam o bem público, ela poderá sofrer sanções, inclusive a não renovação da concessão.

Veda-se a censura de natureza política, ideológica, artística (art. 220, § 2º), porém, apesar da liberdade de expressão acima garantida, lei federal deverá regular as diversões e os espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

4) Liberdade de Trabalho, Ofício ou Profissão (art. 5.º, XIII): É assegurada a liberdade de escolher qual a atividade que se exercerá. Essa é uma norma de eficácia contida porque tem uma aplicabilidade imediata, no entanto traz a possibilidade de ter o seu campo de incidência contido por meio de requisitos exigidos por lei. A lei exige que certos requisitos de capacitação técnica sejam preenchidos para que se possa exercer a profissão (Exemplo: O advogado deve ser bacharel em direito e obter a carteira da OAB por meio de um exame; O engenheiro deve ter curso superior de engenharia; etc.).

5) Liberdade de Locomoção (art. 5.º, XV): É a liberdade física de ir, vir, ficar ou permanecer. Essa liberdade é considerada pela CF como a mais fundamental, visto que é requisito essencial para que se exerça o direito das demais liberdades. Todas as garantias penais e processuais penais previstas no art. 5.º são normas que tratam da proteção da liberdade de locomoção. Por exemplo, o habeas corpus é voltado especificamente para a liberdade de locomoção. Essa norma também é de eficácia contida, principalmente no que diz respeito à liberdade de sair, entrar e permanecer em território nacional. A lei pode estabelecer exigências para sair, entrar ou permanecer no país, visando a proteção da soberania nacional.

6) Liberdade de Reunião (art. 5.º, XVI): É a permissão constitucional para um agrupamento transitório de pessoas com o objetivo de trocar ideias para o alcance de um fim comum. O direito de reunião pode ser analisado sob dois enfoques: De um lado a liberdade de se reunir para decidir um interesse comum e de outro lado à liberdade de não se reunir, ou seja, ninguém poderá ser obrigado a reunir-se. Para a caracterização desse direito, devem ser observados alguns requisitos a fim de que não se confunda com o direito de associação. São eles:

a) Pluralidade de participantes: Trata-se de uma ação coletiva, ou seja, deve haver várias pessoas para que possa haver uma reunião. A diferença é que, na reunião, não existe um vínculo jurídico entre as pessoas reunidas, diferentemente da associação, em que as pessoas estão vinculadas juridicamente.

b) Tempo: A reunião tem duração limitada, enquanto na associação, a duração é ilimitada.

c) Finalidade: A reunião pressupõe uma organização com o propósito determinado de atingir certo fim. É a finalidade que vai distinguir a reunião do agrupamento de pessoas. Essa finalidade deve ter determinadas características, ou seja, a reunião deve ter uma finalidade lícita, pacífica e não deve haver armamento.

d) Lugar: Deve ser predeterminado para a realização da reunião. Não é necessária a autorização prévia para que se realize a reunião, no entanto, o Poder Público deve ser avisado com antecedência para que não se permita que haja reunião de grupos rivais em mesmo local e horário. O objetivo do aviso ao Poder Público também é garantir que o direito de reunião possa ser exercitado com segurança.

O direito de reunião tem algumas restrições, quais sejam:

- Não pode ser uma reunião que tenha por objetivo fins ilícitos;

- Não pode haver reunião que não seja pacífica e não deve haver utilização de armas (art. 5.º, XLIV).

A presença de pessoas armadas em uma reunião não significa, no entanto, que a reunião deva ser dissolvida. Nesse caso, a polícia deve agir no sentido de desarmar a pessoa, mas sem dissolver a reunião. Em caso de passeata, não poderá haver nenhuma restrição quanto ao lugar em que ela será realizada;

- Durante o Estado de Defesa (art. 136, § 1.º, I, “a”) e o Estado de Sítio (art. 139, IV), poderá ser restringido o direito de reunião.
- Este direito poderá ser exercido independentemente de prévia autorização do Poder Público, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse prévio aviso é fundamental para que a autoridade administrativa tome as providências necessárias relacionadas ao trânsito, organização etc.

7) Liberdade de Associação (art. 5.º, XVII a XXI): Normalmente, a liberdade de associação se manifesta por meio de uma reunião. Logo, existe uma relação muito estreita entre a liberdade de reunião e a liberdade de associação. A reunião é importante para que se exerça a associação, visto que normalmente a associação começa com uma reunião. É o direito de coligação voluntária de algumas ou muitas pessoas físicas, por tempo indeterminado, com o objetivo de atingir um fim lícito sob direção unificante. A associação, assim como a reunião, é uma união de pessoas que se distingue pelo tempo, visto que o objetivo que se quer alcançar não poderá ser atingido em um único momento na associação, enquanto na reunião, o objetivo se exaure em tempo determinado.

No direito constitucional comparado há uma correspondência normativa sobre as liberdades, em especial sobre a liberdade de expressão. As comparações, entre as diversas normas ocidentais, indicam similaridade na proteção dos mesmos direitos fundamentais de liberdade.



26. Direitos sociais e sua efetivação.

Evolução histórica

Desde o surgimento do constitucionalismo, século XVIII, os direitos fundamentais representam a principal garantia dos cidadãos de que o Estado se conduzirá pela liberdade e pelo respeito da pessoa humana. Heranças da tradição francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade podem ser consideradas como os pilares de sustentação da doutrina dos direitos fundamentais. A cada um destes pilares corresponde uma dimensão de tal gênero de direitos.

Segundo doutrina de **Rafael Grandulpho Bertramello**⁴⁹ as declarações de direitos norte-americanas, bem como a francesa de 1789, representaram a **“emancipação histórica do indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, o estamento, as organizações religiosas”**.⁵⁰

Em contrapartida, a ascensão do indivíduo na história trouxe-lhe a perda da proteção por parte desses grupos, o deixando à deriva, às vicissitudes da vida. Em troca da ruptura, a sociedade liberal ofereceu-lhe a suposta segurança da legalidade, com a garantia de igualdade de todos perante a lei.

Com o avanço do capitalismo, os trabalhadores viram-se compelidos a empregarem-se nas fábricas, sem garantias condignas com a dignidade da pessoa humana. A lei os considerava, patrão e operário, iguais. Igualdade que se revelou fútil e inócua, a ponto de provocar a reunião da classe trabalhadora, sob a bandeira socialista, a lutar pelo reconhecimento de direitos humanos de caráter econômico e social.

Como causa desta desigualdade material aponta-se o liberalismo econômico, isto é, livre iniciativa num mercado concorrencial, propiciado pelas instituições e sem qualquer interferência estatal (Estado abstencionista). Tal fato gerou um acréscimo de riqueza jamais visto, em contrapartida, a classe

⁴⁹ BERTRAMELLO, Rafael Grandulpho. Os Direitos Sociais: conceito, finalidade e teorias. 2013; Disponível em: <http://rafaelbertramello.jusbrasil.com.br/artigos/121943093/os-direitos-sociais-conceito-finalidade-e-teorias>, acesso em 17/06/2015.

⁵⁰ COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 65 e ss.

trabalhadora contava com condições precaríssimas de trabalho; trabalho que, na lógica de mercado, equivale à mercadoria, sujeita à lei da oferta e da procura.⁵¹

A classe operária, produtora da riqueza, mas excluída de seus benefícios, passou a organizar-se na fórmula marxista da luta de classes, situação que ameaçava as instituições liberais e, por decorrência lógica, a estabilidade do desenvolvimento econômico. Surge a ideia de “vida humana digna” e os argumentos favoráveis ao reconhecimento do direito ao trabalho (de ter um trabalho), à subsistência, à educação, entre outros, que são direitos sociais por excelência.

Nessa perspectiva é que surgem os direitos sociais, intimamente relacionados ao princípio da solidariedade, denominados de direitos humanos de segunda dimensão.

Os direitos sociais *“se realizam pela execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de recursos próprios para viver dignamente”*.⁵²

Tais direitos adquiriram certa relevância histórica a partir do momento em que as Constituições passaram a discipliná-los sistematicamente, o que teve início com a Constituição mexicana de 1917, primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades e os direitos políticos (artigos 5º e 123).

Registra-se, todavia, que o reconhecimento dos direitos de segunda dimensão já se encontra na Constituição Francesa de 1791, que no seu título 1º *“previa a instituição do secours publics para criar crianças abandonadas, aliviar os pobres doentes e dar trabalho aos pobres inválidos que não o encontrassem”*.⁵³

No Brasil, a primeira Constituição a disciplinar os direitos sociais, inscrevendo-os num título sobre a ordem econômica e social, foi a de 1934. Esta foi notavelmente influenciada pela Constituição alemã de Weimar, de 1919⁵⁴, responsável pela introdução de um novo espírito, de cunho social, nas constituições.

Foi na Constituição de Weimar que a propriedade se viu, talvez pela primeira vez, submetida à função social. Essa e outras características fizeram dela um modelo, depois imitado pelo direito brasileiro.

A Constituição Federal de 1934, embora vigente por tão pouco tempo e em tão conturbado contexto histórico, refletiu com bastante veemência as aspirações por um sistema jurídico fincado nos direitos econômicos e sociais, sobretudo o direito ao trabalho.

A Constituição Federal de 1988, como fruto da exposição histórica que ora colacionamos, estipulou com *certa eficácia* um extenso rol de direitos fundamentais de segunda dimensão, especialmente em seu Artigo 6º: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade etc.

Conceito

Os direitos sociais pertencem à segunda dimensão de Direitos Fundamentais, que está ligada ao valor da igualdade material (a igualdade formal já havia sido consagrada na primeira geração, junto com os direitos de liberdade). Não são meros poderes de agir – *como o são as liberdades públicas* –, mas sim poderes de exigir, chamados, também, de **direitos de crédito**:

*Há, sem dúvida, direitos sociais que são antes poderes de agir. É o caso do direito ao lazer. Mas assim mesmo quando a eles se referem, as constituições tendem a encará-los pelo prisma do dever do Estado, portanto, como poderes de exigir prestação concreta por parte deste.*⁵⁵

Em didática definição, André Ramos Tavares conceitua direitos sociais como direitos *“que exigem do Poder Público uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na implementação da igualdade social dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos a prestação, ou direitos prestacionais”*.⁵⁶

Segundo José Afonso da Silva, os direitos sociais *“são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade”*.

⁵¹ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª ed. Rev. E aum. – São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 42-43.

⁵² COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 77.

⁵³ LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. – São Paulo: Cia das Letras, 2009 (7ª reimpressão), p. 128.

⁵⁴ SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 285.

⁵⁵ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª ed. Rev. E aum. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50.

⁵⁶ TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 837.

Uadi Lammêgo Bulos esclarece que tais “*prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os direitos sociais*”, e acrescenta que sua finalidade “*é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real*”.⁵⁷

Os direitos sociais exigem a intermediação dos entes estatais para sua concretização; consideram o homem para além de sua condição individualista, e guardam íntima relação com o cidadão e a sociedade, porquanto abrangem a pessoa humana na perspectiva de que ela necessita de condições mínimas de subsistência.

Por tratarem de direitos fundamentais, há de reconhecer a eles aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º da CF), e no caso de omissão legislativa haverá meios de buscar sua efetividade, como o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Classificação

A amplitude dos temas inscritos no art. 6º da Constituição deixa claro que os direitos sociais não são somente os que estão enunciados nos artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11. Eles podem ser localizados, principalmente, no Título VIII - Da Ordem Social, artigos 193 e seguintes.

Os direitos sociais podem ser agrupados em grandes categorias:

- a) os direitos sociais dos trabalhadores, por sua vez subdivididos em individuais e coletivos;**
- b) os direitos sociais de seguridade social;**
- c) os direitos sociais de natureza econômica;**
- d) os direitos sociais da cultura;**
- e) os de segurança.**

Uadi Lammêgo Bulos⁵⁸ destaca que os direitos sociais da seguridade social envolvem o direito à saúde, à previdência social, à assistência social, enquanto que os relacionados à cultura abrangem a educação, o lazer, a segurança, a moradia e a alimentação.

José Afonso da Silva, em Curso de Direito Constitucional positivo, propõe a divisão dos direitos sociais em: **i) relativos aos trabalhadores; ii) relativos ao homem consumidor**. Na primeira classificação, isto é, direitos sociais do homem trabalhador, teríamos os direitos reais ao salário, às condições de trabalho, à liberdade de instituição sindical, o direito de greve, entre outros (CF, artigos 7º a 11).

Na segunda classificação, ou seja, direitos sociais do homem consumidor, teríamos o direito à saúde, à educação, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos à instrução, à cultura e garantia ao desenvolvimento da família, que estariam no título da ordem social.

Princípio da máxima efetividade

Segundo Paulo Bonavides, os direitos sociais tomaram corpo após expansão da ideologia e da reflexão antiliberal. O jurista adverte que tais direitos passaram por um “ciclo de baixa normatividade, ou tiveram eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos”.⁵⁹

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 explicitou amplo rol de direitos sociais, tornando ainda mais relevante o tema de sua eficácia. De fato, apenas positivar direitos, reconhecê-los e apontar sua importância não é suficiente; quanto maior a consagração formal de direitos sociais, maior a dificuldade de lhes garantir uma aplicação efetiva.

Como se tratam de direitos a prestações, que envolvem um custo especial, deve-se refletir em que medida os direitos sociais, por força do disposto no § 1º, artigo 5º da CF, estão em condições de serem diretamente aplicáveis. Sem esquecer, aliás, que inexistia norma constitucional destituída de eficácia e aplicabilidade.

Observa-se pela história que a obrigação de atender aos direitos sociais ditou ao Estado a expansão dos serviços públicos, especialmente dos anos vinte para frente. Hoje, em que pese o notável avanço,

⁵⁷ BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 789.

⁵⁸ BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 790.

⁵⁹ BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Atual. – São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 582-583.

permanece válido discutir até que ponto o Estado deve dar o atendimento a esses direitos ou apenas amparar sua busca.

Os operadores do direito, hoje, trabalham com essa nova perspectiva, com a dificuldade de se determinar até que ponto os direitos sociais são exigíveis, até que ponto não operam eficácia imediata.

A doutrina mais acurada entende que o artigo 5º, § 1º da CF/88 não deve ser interpretado como regra, mas como um princípio, isto é, deve-se garantir a máxima efetividade possível. Para Luís Roberto Barroso, *“o intérprete constitucional deve ter compromisso com a efetividade da Constituição: entre interpretações alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquele que permita a atuação da vontade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se refugiem no argumento da não aplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão do legislador”*.⁶⁰

Esta aplicação imediata é o desejável. Todavia, seria utópico concluir que o Estado brasileiro, no seu atual estágio de evolução, poderia assegurar o pleno exercício dos direitos sociais a todos.

Teresa Arruda Alvim Wambier destaca que **“a plena e efetiva realização do ordenamento jurídico no plano social, embora, embrionariamente, já esteja concebida no plano normativo (em sentido amplo), depende de fatores econômicos, éticos e culturais”**.⁶¹ Dissemina-se, no entanto, o raciocínio de que a aplicação desses direitos deve se pautar na máxima efetividade possível.

Reserva do possível

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet⁶², a *reserva do possível* apresenta tríplice dimensão: a) efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição de receitas e competências tributárias, orçamentárias etc; c) proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade.

A reserva do possível, nas suas diversas dimensões, está ligada diretamente às limitações orçamentárias que o Estado possui. Para se determine a razoabilidade de determinada prestação estatal é importante pensar no contexto: a saída adequada para A deve ser a saída adequada para todos os que se encontram na mesma situação que A.

Trata-se, também, de atenção ao princípio da isonomia, capitulado no artigo 5º da Constituição.

Alguns autores denominam este princípio como a reserva do “financeiramente possível”, relacionando-o com a necessidade de disponibilidade de recursos, principalmente pelo Estado, para sua efetiva concretização.

Aponta-se este princípio como limitador de certas políticas públicas. Por exemplo, não seria possível a edição de uma lei para aumentar o valor do salário mínimo, se tal medida implicasse negativamente e de forma desastrosa nas contas da previdência social, outros gastos públicos. Certamente, medidas não razoáveis ou em desacordo com o momento e evolução históricos implicam resultados contrários à própria eficácia dos direitos.

A cláusula da reserva do possível não pode servir de argumento, ao Poder Público, para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. A noção de “mínimo existencial” é extraída implicitamente de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), e compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos.

Mínimo existencial

O mínimo existencial deve ser visto como a base e o alicerce da vida humana. Trata-se de um direito fundamental e essencial, vinculado à Constituição Federal, e não necessita de Lei para sua obtenção, tendo em vista que é inerente a todo ser humano. Como conceito de *mínimo existencial*, temos que refere-se ao “conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da

⁶⁰ BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 329.

⁶¹ DIDIER JR, Fredie – Org. Ações Constitucionais. 6ª ed. Rev., ampl. E atual. – Salvador: Editora Juspodivm, 2012, p. 21.

⁶² SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed. Rev. Atual. E ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, 287.

dignidade para qualquer pessoa. Se alguém viver abaixo daquele patamar, o mandamento constitucional estará sendo desrespeitado”.⁶³

No caso de o Poder Público abster-se de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no texto constitucional, transgredir a própria Constituição.⁶⁴ A inércia estatal configura desprezo e desrespeito à Constituição e, por isso mesmo, configura comportamento juridicamente reprovável.

Vedação do retrocesso

A vedação do retrocesso não está expressamente prevista no vigente texto constitucional, mas foi acolhida pela doutrina moderna.

Esse princípio, no dizer de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, “*visa a impedir que o legislador venha a desconstituir pura e simplesmente o grau de concretização que ele próprio havia dado às normas da Constituição, especialmente quando se trata de disposições constitucionais que, em maior ou menor escala, acabam por depender dessas normas infraconstitucionais para alcançarem sua plena eficácia e efetividade*”.⁶⁵

Em síntese, não pode o legislador diminuir ou radicar os direitos humanos fundamentais, aqui inseridos os de segunda dimensão. Muito embora o constituinte originário tenha elevado à condição de cláusulas pétreas apenas os direitos e garantias individuais, a doutrina e a jurisprudência parecem corroborar o entendimento de ser legítima a manutenção de estabilidade nas conquistas dispostas na Carta Política.

Não se trata de conferir imutabilidade às normas relativas a direitos sociais, mas segurança jurídica ao assegurar que os tais não sejam suprimidos, ou diminuídos em sua importância e alcance.

Tal princípio vincula não só o legislador infraconstitucional, bem como o legislador constituinte derivado, ao elaborar Emendas à Constituição.

Direitos sociais em espécie

Educação

O direito à educação está tratado nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal. Esse direito tem por sujeito passivo o Estado e a família. O Estado tem o dever de promover políticas públicas de acesso à educação de acordo com os princípios elencados na própria CF (art. 206), e, por expressa disposição, obriga-se a fornecer o ensino fundamental gratuito (art. 208, § 1º).

Vale destacar, ainda, que o STF editou a súmula vinculante de número 12, para evitar a violação do disposto no artigo 206, IV da CF: “*A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal*”.

Saúde

Apenas em 1988 foi que a saúde passou a ser tratada, pela ordem constitucional brasileira, como direito fundamental.

Gomes Canotilho e Vital Moreira sinalizam que o direito à saúde comporta duas vertentes: “***uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenha de qualquer acto que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando à prevenção das doenças e ao tratamento delas***”.⁶⁶

⁶³ BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 202. Cf., a propósito, Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, 2002, p. 305: “Esse núcleo, no tocante aos elementos matérias da dignidade, é composto pelo mínimo existencial, que consiste em um conjunto de prestações mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade (...) Uma proposta de concretização do mínimo existencial, tendo em conta a ordem constitucional brasileira, deverá incluir os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à assistência no caso de necessidade e ao acesso à justiça”.

⁶⁴ ADI 1.484/DF, Rel. Min. Celso de Mello.

⁶⁵ PAULO, Vicente. Resumo de direito constitucional descomplicado/Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 6ª ed. – São Paulo: Método, 2012, p. 101.

⁶⁶ Apud José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 188.

Trabalho

O direito ao trabalho, isto é, de ter um trabalho ou de trabalhar, é o meio mais expressivo de se obter uma existência digna⁶⁷, e está previsto na CF/88 como um direito social, e não mais como uma obrigação social, tal como previa a Constituição de 1946.

Constitui um dos fundamentos do Estado democrático de Direito os valores sociais do trabalho (CF, artigo 1º, inciso IV), ademais, o artigo 170 da CF funda a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tudo a assegurar uma existência digna a todos, em atenção à justiça social.

Nos termos do art. 22, I, da CF, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, não estando ela obrigada a utilizar-se de lei complementar para disciplinar a matéria, que somente é exigida, nos termos do art. 7º, I, da mesma Carta, para reger a dispensa imotivada.

Moradia

O direito à moradia não é necessariamente direito a uma casa própria, mas sim a um teto, um abrigo em condições adequadas para preservar a intimidade pessoal dos membros da família (art. 5, X e XI), uma habitação digna e adequada.

Não há dúvidas de que a casa própria seria o meio mais efetivo de se concretizar o direito à moradia, todavia, esta não é a realidade social vigente.

A própria impenhorabilidade do bem de família, levada a efeito pela Lei nº 8009/90, encontra fundamento no artigo 6º da Constituição Federal.

Lazer

A Constituição dispõe, no § 3º do Artigo 217 que **“o Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social”**. Tal direito está relacionado com o direito ao descanso dos trabalhadores, ao resgate de energias para retomada das atividades.

Costuma-se condenar os empregadores que, entregando excessiva carga de trabalho ao empregado, retiram-lhe o intervalo interjornada de modo a inibir o convívio social e familiar, suprimindo a oportunidade de ócio, isto é, de tempo destinado ao lazer, garantida constitucionalmente.

Segurança

A segurança tem o condão de conferir garantia ao exercício pleno, e tranquilo, dos demais direitos e liberdades constitucionais. Na dimensão de direito social está intimamente relacionada com o conceito de segurança pública, tratada no artigo 144 da Constituição Federal.

Ensina José Afonso da Silva que segurança “assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica (...) A segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e defesa de seus legítimos interesses”.⁶⁸

O STF afirmou que o direito à segurança “é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.”⁶⁹

Previdência social

No texto constitucional, estão previstas prestações previdenciárias de dois tipos: os benefícios, que são prestações pecuniárias para a) aposentadoria por invalidez (CF, art. 201, I), por velhice e por tempo de contribuição (CF, art. 201, § 7º) b) nos auxílios por doença, maternidade, reclusão e funeral (art. 201, I, II, IV e V); c) no salário-desemprego (artigos 7º, II, 201, II, e 239); d) na pensão por morte do segurado (art. 201, V).

⁶⁷ SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 189.

⁶⁸ SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 649.

⁶⁹ RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 24-6-2011.

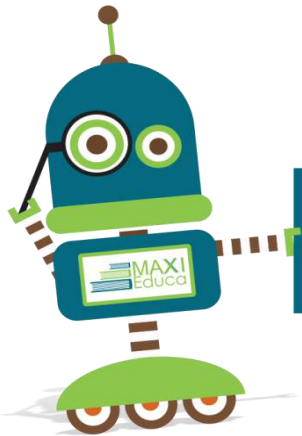
Os serviços que são prestações assistenciais: médica, farmacêutica, odontológico, hospitalar, social e de reeducação ou readaptação profissional.

Proteção à maternidade e à infância

Tal direito está inserido como direito previdenciário (artigo 201, II), e como direito assistencial (artigo 203, I e II). Destaca-se, também, no artigo 7º, XVIII da CF a previsão de licença à gestante.

Assistência aos desamparados

A Constituição Federal estabelece que a assistência social será prestada aos necessitados, independentemente contribuírem ou não com a previdência social.



27 O Direito à saúde na ordem constitucional e legal.

O direito à saúde pública encontra-se positivado na Constituição Federal expressamente nos artigos 6º e 196, sendo um direito social e fundamental, é um dever do Estado. A saúde é inerente ao ser humano, bem como à sua vida com dignidade, sendo fundamento da República Federativa do Brasil, expresso na Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III.

Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º apresenta expressamente a busca por uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e por fim promoção do bem de todos. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196 apresenta a concepção de saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizado pela Lei Federal nº 8.080, em 1990 – Lei Orgânica da Saúde (LOS) – possui, como princípios, a universalidade de acesso aos serviços de saúde e a integralidade da assistência, cabendo a ele a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º). Ambas, a Constituição Federal e a Lei Federal nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – definem o objeto do direito à saúde incorporando o conceito da Organização Mundial da Saúde: “[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a simples ausência de doenças e outros danos”.

O direito à saúde é um dever Estado, sendo inerente ao direito à vida com dignidade, concretizando assim o direito fundamental e social, conforme considera **Pedro Lenza**, o ser humano é o destinatário destes direitos tutelados na atual Constituição Federal da República de 1988.⁷⁰

As políticas de saúde (SUS), de previdência social e de assistência social se pautam pelos princípios constitucionais relacionados pelo legislador:

- a universalidade de cobertura e atendimento;
- uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
- seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços;

⁷⁰ LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 12 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.

- irredutibilidade do valor dos benefícios;
- equidade da forma de participação no custeio;
- diversidade da base de financiamento;
- caráter democrático e descentralizado de administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

Texto constitucional a respeito do assunto:

SEÇÃO II DA SAÚDE

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar

assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.



28 Direito à saúde como direito humano.

Os direitos humanos, direitos positivados na seara do direito internacional, têm uma íntima aproximação com os direitos fundamentais, que são direitos reconhecidos e protegidos pelo constitucional interno de cada Estado, na medida em que são inter-relacionados, independentemente de suas diferentes positivações.

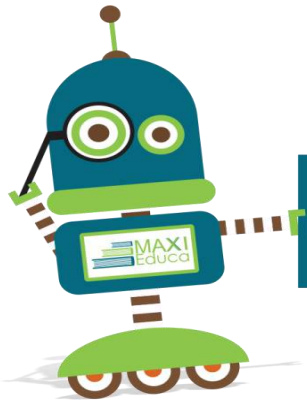
Com surgimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1946, a saúde foi definida como o completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças ou agravos, bem como,

reconhecida como um dos direitos fundamentais de todo ser humano, seja qual sua condição social ou econômica e sua crença religiosa ou política.

Os direitos fundamentais compreendem a positivação dos direitos humanos de segunda geração que foram incorporados pelo texto constitucional, considerando a sua essencialidade, elevando eles a nível constitucional.

O direito fundamental à saúde está entre os mais importantes direitos consagrados pelo texto constitucional de 1988, pois visa contemplar de forma direta o bem da vida, sendo corolário deste, representando na Constituição um bem de relevância extrema.

Portanto, a saúde é uma condição essencial à dignidade da pessoa humana, cabendo assim, ao Estado, por meio de políticas públicas e de seus órgãos, assegurá-la como direito de todos os cidadãos. O direito à saúde se consubstancia em um direito público subjetivo, exigindo do Estado atuação positiva para sua eficácia e garantia.



29 Sistema Único de Saúde. Atribuições da União, dos Estados e dos Municípios.

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

(Comentada)

(Atualizada em fevereiro de 2015)

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição Federal em 1988, quando criou o Sistema Único de Saúde (SUS).

A Lei n. 8.080 de 1990 é a principal lei do sistema de Saúde Pública brasileiro. Ela estabelece as regras de funcionamento do SUS. É, também, conhecida como Lei Orgânica da Saúde.

Como sabemos, o surgimento do SUS ocorreu após a VII Conferência Nacional de Saúde e criou vida legalmente no texto da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Esta lei vem, então, explicar o funcionamento e a organização do Sistema Único de Saúde em todo território nacional.

As bases do movimento da Reforma Sanitária, efetivadas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, apontaram o rumo da construção do modelo de atenção à saúde fundamentado nas necessidades e demandas da população por ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. As ações do SUS visam garantir o enfrentamento das iniquidades com integralidade e racionalidade.

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

A Lei n. 8.080/90 trata:

- a.** da organização, da direção e da gestão do SUS;
- b.** da definição das competências e das atribuições das três esferas de governo;
- c.** do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde;
- d.** da política de recursos humanos;
- e.** dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento.

Conforme a definição de saúde apresentada pela OMS “saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social.” Para que o ser humano tenha a sua saúde íntegra, torna-se necessário promover hábitos saudáveis, evitar comportamentos nocivos e prevenir doenças. Quando a doença estiver instalada, torna-se necessário aderir ao tratamento com a finalidade de recuperar o equilíbrio e o bem-estar como um todo. Assim, entende-se que o SUS deve garantir o acesso a todo cidadão brasileiro aos

serviços de saúde em todos os ciclos de vida e em todos os níveis de atenção à saúde. O SUS deve garantir a integralidade da assistência por meio da promoção, proteção e recuperação da saúde.

Os serviços de saúde ofertados à população não são encontrados apenas nos Estabelecimentos de Atenção à Saúde (hospitais, unidades básicas de saúde, clínicas e consultórios particulares, policlínicas, hospital-dia, laboratórios etc.). Os serviços que garantem a saúde dos brasileiros estão presentes, também, nas fiscalizações de produção de medicamentos, de alimentos, de bebidas, de cosméticos etc. Entenderemos melhor ao estudarmos as ações das Vigilâncias, em especial a Epidemiológica e a Sanitária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

Entende-se assim, que qualquer estabelecimento de saúde ou que tenha a saúde do ser humano ligada direta ou indiretamente, seja público ou privado, o Estado, por meio do Ministério da Saúde na esfera federal, da Secretaria Estadual de Saúde na esfera estadual, e da secretaria municipal de saúde na esfera municipal, tem a responsabilidade de regular, coordenar, acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações voltadas à saúde dos cidadãos brasileiros.

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Esta afirmação encontra-se na CF/88 e foi conquistada por meio do movimento Reforma Sanitária. Princípio doutrinário do SUS – Universalidade. Basta nascer ou morar em território brasileiro para ter direito à Saúde Pública.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Esta é a continuação da redação presente no Art. 196 da CF/88. Princípio doutrinário – Integralidade.

Cabe lembrar que antes da criação do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde desenvolvia quase que exclusivamente ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, como campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação do setor público na chamada assistência médico-hospitalar era prestada por intermédio do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), autarquia do Ministério da Previdência e Assistência Social, e a Assistência à Saúde desenvolvida beneficiava apenas os trabalhadores da economia formal, segurados do INPS e seus dependentes, não tendo caráter universal (SOUZA, 2002).

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Todos somos responsáveis pela manutenção e recuperação da nossa saúde. Podemos considerar que 50% das ações necessárias à integridade da saúde depende de nós.

Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013)

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

A Constituição Federal de 1988 define o conceito de saúde, incorporando novas dimensões. Para se ter saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, como alimentação, moradia, emprego, lazer, educação etc.

Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham ou “as características sociais dentro das quais a vida transcorre” (Tarlov, 1996).

Ao atuarmos sobre as causas das desigualdades de saúde e doença, temos a oportunidade de melhorar a saúde em qualquer localidade, em especial nas regiões mais vulneráveis. Para garantir o desenvolvimento e a economia de um país, garantir a saúde, em especial da população economicamente ativa é primordial. Assim, torna-se essencial, que o cidadão tenha acesso garantido à alimentação, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, à educação, à atividade física, ao transporte, ao lazer e aos bens e serviços essenciais.

TÍTULO II **DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS não é, porém, uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de cidadania. Insere-se no contexto das políticas públicas de seguridade social, que abrangem, além da Saúde, a Previdência e a Assistência Social.

Complementariedade do setor privado: A CF/88 definiu que, quando por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob três condições:

1ª - a celebração de contrato, conforme as normas de direito público, ou seja, interesse público prevalecendo sobre o particular;

2ª - a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, equidade etc., como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste;

3ª - a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região, deverá estar claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados contratados, quem vai fazer o que, em que nível e em que lugar.

Dentre os serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos, conforme determina a Constituição.

CAPÍTULO I **Dos Objetivos e Atribuições**

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social, especialmente no que refere à saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos da cidadania.

Identificar as causas do aparecimento de doenças na população e divulgá-las por meio da educação em saúde; assim como identificar e divulgar as potencialidades geradoras e mantenedoras da saúde por meio do protagonismo do cidadão ao modificar os hábitos de vida que diminuem o risco de adoecer exemplificam o primeiro inciso deste artigo. O inciso III reforça a proposta de ofertar ao usuário do SUS, serviços de saúde de forma integral.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações: (grifo nosso)

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; (este assunto será tratado no Capítulo VII)

Através da Portaria Ministerial n. 3.252, de 22 de dezembro de 2009, os estados, Distrito Federal e municípios são fortalecidos no papel de gestores da vigilância, bem como se ampliam as ações denominadas de Vigilância em Saúde, abrangendo:

Vigilância Epidemiológica: vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos;

Vigilância da Saúde do Trabalhador: visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos; e

Vigilância Sanitária: conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

A portaria supracitada trata, ainda, da Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância da situação de saúde e da Promoção da Saúde.

Os próximos incisos que fazem parte do campo de atuação do SUS terão grifos nossos para fixar melhor os estudos.

II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

Deixaremos em destaque os três próximos parágrafos que definem as ações das vigilâncias sanitária e epidemiológica e da saúde do trabalhador:



§ 1º Entende-se por **vigilância sanitária** um conjunto de ações capaz de **eliminar, diminuir ou prevenir** riscos à saúde e de **intervir** nos **problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:**

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

É muito comum encontrarmos em concursos questões relacionadas às ações das vigilâncias. Por isso, reforçamos aqui a importância de fixar tais conceitos.



§ 2º Entende-se por **vigilância epidemiológica** um conjunto de ações que proporcionam o **conhecimento**, a **detecção** ou **prevenção** de qualquer **mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva**, com a **finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.**



§ 3º Entende-se por **saúde do trabalhador**, para fins desta lei, **um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho**, abrangendo:

I - **assistência** ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;

II - **participação**, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, **avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho**;

III - **participação**, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da **normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador**;

IV - **avaliação** do impacto que as tecnologias provocam à saúde;

V - **informação** ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;

VI - **participação** na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;

VII - **revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho**, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

CAPÍTULO II

Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

"A saúde é um direito de todos", como afirma a Constituição Federal. Naturalmente, entende-se que o Estado tem a obrigação de prover atenção à saúde, ou seja, é impossível tornar todos sadios por força de lei. Significa que o Sistema de Saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo.

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos. Em outras palavras, as necessidades de saúde das pessoas (ou de grupos) devem ser levadas em consideração mesmo que não sejam iguais às da maioria.

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

Este é o princípio da **equidade**. Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde; como, no entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais, as necessidades de saúde variam. Por isso, enquanto a Lei Orgânica fala em igualdade, tanto o meio acadêmico quanto o político consideram mais importante lutar pela equidade do SUS.

Trata-se da igualdade da atenção à Saúde, sem privilégios ou preconceitos. O SUS deve disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. O que determina o tipo de atendimento é a complexidade do problema de cada usuário.

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

O controle social, como também é chamado esse princípio, foi melhor regulado pela Lei nº 8.142. Os usuários participam da gestão do SUS através das Conferências de Saúde, que ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis, e através dos Conselhos de Saúde, que são órgãos colegiados também em todos os níveis. Nos Conselhos de Saúde ocorre a chamada paridade: enquanto os usuários têm metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores outro quarto.

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

O SUS existe em três níveis, também chamado de esferas: nacional, estadual e municipal, cada uma com comando único e atribuições próprias. Os municípios têm assumido papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde; as transferências passaram a ser "fundo-a-fundo", ou seja, baseadas em sua população e no tipo de serviço oferecido, e não no número de atendimentos.

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

Municipalização: Estratégia adotada no Brasil que reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua população. Municipalizar é transferir para as cidades a responsabilidade e os recursos necessários para exercerem plenamente as funções de coordenação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria da saúde local, controlando os recursos financeiros as ações e os serviços de saúde prestados em seu território. O princípio da descentralização político-administrativa da saúde foi definido pela Constituição de 1988, preconizando a autonomia dos municípios e a localização dos serviços de saúde na esfera municipal, próximos dos cidadãos e de seus problemas de saúde. O Brasil apresenta grandes diversidades econômicas, sociais, climáticas e culturais que tornam a descentralização administrativa fundamental: ela possibilita que os municípios assumam a gestão da saúde em seus territórios de acordo com as necessidades e características de suas populações. Estimula, na esfera municipal, novas competências e capacidades político-institucionais. Os estados e a União devem contribuir para a descentralização do SUS, fornecendo cooperação técnica e financeira para o processo de municipalização.

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

Os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade; o nível primário deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os outros devem ser utilizados apenas quando necessário. Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde tem uma área de abrangência, ou seja, é responsável pela saúde de uma parte da população. Os serviços de maior complexidade são menos numerosos e por isso mesmo sua área de abrangência é mais ampla, abrangência a área de vários serviços de menor complexidade.

Um dos princípios que orientam a organização do SUS definidos pela Constituição Federal Brasileira e pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990). Constitui eixo estruturante do Pacto de Gestão do SUS, definido pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de 26 de janeiro de 2006, e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 9 de fevereiro de 2006, o que evidencia a importância da articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados, que possibilitem acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população.

A regionalização deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde. Neste processo são identificadas e constituídas as regiões de saúde – espaços territoriais nos quais serão desenvolvidas as ações de atenção à saúde objetivando alcançar maior resolutividade e qualidade nos resultados, assim como maior capacidade de cogestão regional. Os principais instrumentos de planejamento da regionalização são o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde (PPI). A política de regionalização prevê a formação dos colegiados de gestão regionais que têm a responsabilidade de instituir processo de planejamento regional que defina prioridades e pactue soluções para organizar a rede de ações e serviços de atenção à saúde das populações locais.

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

Resolubilidade: É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CAPÍTULO III

Da Organização, da Direção e da Gestão

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

A regionalização deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde. Neste processo são identificadas e constituídas as regiões de saúde – espaços territoriais nos quais serão desenvolvidas as ações de atenção à saúde objetivando alcançar maior resolutividade e qualidade nos resultados, assim como maior capacidade de cogestão regional. A política de regionalização prevê a formação dos colegiados de gestão regionais que têm a responsabilidade de instituir processo de planejamento regional que defina prioridades e pactue soluções para organizar a rede de ações e serviços de atenção à saúde das populações locais.

Os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade; o nível primário deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os outros (secundários e terciários, de maior complexidade) devem ser utilizados apenas quando necessário (por meio de encaminhamentos). Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde tem uma área de abrangência (região de saúde), ou seja, é responsável pela saúde de uma parte da população. Os serviços de maior complexidade são menos numerosos e por isso mesmo sua área de abrangência é mais ampla (com condições de atender vários municípios de uma mesma região de saúde).



Em síntese: *os serviços de saúde devem ser organizados em bases territoriais definidas, de acordo com a distribuição da população e o nível de complexidade dos serviços. Os serviços de saúde devem estar dispostos de maneira regionalizada, pois nem todos os municípios conseguem atender todas as demandas e todo tipo de problemas de saúde. Os serviços de saúde devem se organizar regionalmente e também obedecer a uma hierarquia entre eles. As questões menos complexas devem ser atendidas nas unidades básicas de saúde, passando pelas unidades especializadas, pelo hospital geral até chegar ao hospital especializado.*

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;**
- II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e**
- III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.**

O SUS existe em três níveis, também chamado de esferas: nacional, estadual e municipal, cada uma com comando único e atribuições próprias.

Mais do que um administrador, o gestor do SUS é a “autoridade sanitária” em cada esfera de governo, cuja ação política e técnica deve estar pautada pelos princípios da reforma sanitária brasileira.

Gestores são as entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implantado e funcione adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias, da lógica organizacional e seja operacionalizado dentro dos princípios anteriormente esclarecidos. Haverá gestores nas três esferas do Governo, isto é, no nível municipal, estadual e federal.

Destaca-se aqui a importância de um outro princípio organizativo do SUS, a Municipalização, que trata-se de uma estratégia adotada no Brasil que reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua população. Municipalizar é transferir para as cidades a responsabilidade e os recursos necessários para exercerem plenamente as funções de coordenação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria da saúde local, controlando os recursos financeiros as ações e os serviços de saúde prestados em seu território. O princípio da descentralização político-administrativa da saúde foi definido pela Constituição de 1988, preconizando a autonomia dos municípios e a localização dos serviços de saúde na esfera municipal, próximos dos cidadãos e de seus problemas de saúde. O Brasil apresenta grandes diversidades econômicas, sociais, climáticas e culturais que tornam a descentralização administrativa fundamental: ela possibilita que os municípios assumam a gestão da saúde em seus territórios de acordo com as necessidades e características de suas populações. Estimula, na esfera municipal, novas competências e capacidades político-institucionais. Os estados e a União

devem contribuir para a descentralização do SUS, fornecendo cooperação técnica e financeira para o processo de municipalização.

Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

O consórcio constitui meio eficiente para o alcance de meta prioritária, que é a habilitação de municípios às condições de gestão descentralizada. Com isso, o Ministério da Saúde, junto com os gestores estaduais e municipais, soma esforços para vencer o desafio representado pela descentralização da gestão, o que certamente permitirá ao município oferecer ações dirigidas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população.

O consórcio intermunicipal na área da saúde é vista como uma associação entre municípios para a realização de atividades conjuntas referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde de suas populações. Como iniciativa eminentemente municipal, reforça o exercício da gestão conferida constitucionalmente aos municípios no âmbito do (SUS).

O consórcio está estreitamente relacionado a cada um dos sistemas municipais, na medida em que se desenvolvem ações destinadas a atender necessidades das populações destes sistemas. Não pode, portanto, configurar uma nova instância no âmbito do estado, intermediária ao município.

Utilizado como instrumento de estímulo ao planejamento local e regional em saúde, o consórcio possibilita, além disso, a viabilização financeira de investimentos e contribui para a superação de desafios locais no processo de implementação do Sistema.

A prestação de serviços e a implementação de ações de forma consorciada configuram condições altamente favoráveis para que o município venha a assumir as responsabilidades pela gestão do seu sistema de saúde. Para desenvolver suas funções, o consórcio necessita de equipes técnicas e administrativa, compostas por recursos humanos oriundos dos municípios integrantes ou contratados mediante seleção pública, sob o regime da CLT. Os Conselhos de Saúde cumprirão o seu papel de agente fiscalizador da execução das ações e serviços de saúde contidos no Plano Municipal de Saúde, inclusive os realizados mediante consórcio. (BRASIL, 1997)

Art. 11. (Vetado).

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo dessas **instâncias (comissões)** é propiciar o debate e a negociação entre os três níveis de governo no processo de formulação e implementação da política de saúde, devendo submeter-se ao poder fiscalizador e deliberativo dos conselhos de saúde participativos.

Instâncias de Pactuação: São espaços intergovernamentais, políticos e técnicos onde ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública. As decisões se dão por consenso (e não por votação), estimulando o debate e a negociação entre as partes.

- **Comissão Intergestores Tripartite (CIT):** Atua na direção nacional do SUS, formada por composição paritária de 15 membros, sendo cinco indicados pelo Ministério da Saúde, cinco pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e cinco pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados e municípios nessa Comissão é, portanto regional: um representante para cada uma das cinco regiões existentes no País.

- **Comissões Intergestores Bipartites (CIB):** São constituídas paritariamente por representantes do governo estadual, indicados pelo Secretário de Estado da Saúde, e dos secretários municipais de saúde, indicados pelo órgão de representação do conjunto dos municípios do Estado, em geral denominado Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). Os secretários municipais de Saúde costumam debater entre si os temas estratégicos antes de apresentarem suas posições na CIB. Os Cosems são

também instâncias de articulação política entre gestores municipais de saúde, sendo de extrema importância a participação dos gestores locais nesse espaço.

Em alguns estados existem CIBs regionais, também de composição paritária, com o objetivo de permitir a discussão dos problemas de saúde e da organização da rede de serviços das diversas regiões dentro do estado, bem como de propor soluções mais apropriadas às distintas realidades territoriais. As CIBs regionais funcionam de forma bastante diversificada, mas em geral suas propostas ou decisões relevantes são referendadas pela CIB estadual.

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- I - alimentação e nutrição;**
- II - saneamento e meio ambiente;**
- III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;**
- IV - recursos humanos;**
- V - ciência e tecnologia; e**
- VI - saúde do trabalhador.**

Mais recentemente, no âmbito da regulamentação do Pacto pela Saúde em 2006, foi proposta a criação dos Colegiados de Gestão Regional (CGR). Tais Colegiados, a serem conformados de acordo com os processos de regionalização em cada estado, devem se constituir num espaço de decisão conjunta por meio da “identificação, definição de prioridades e de pactuação de soluções para a organização de uma rede regional de ações e serviços de saúde, integrada e resolutiva” (Brasil, 2006). A composição dos Colegiados Regionais também envolve representantes de estados e municípios.

No entanto, diferentemente das CIBs regionais, os CGRs, a princípio, não são paritários entre os dois grupos, pois devem envolver representantes de todos os municípios que integram uma dada região ou microrregião, visando ao planejamento integrado da rede de serviços regional (Brasil, 2009).

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

São instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes, criadas para apoiar a condução e desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

O Parágrafo 2º da Portaria GM/MS 1.996 que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde traz a seguinte definição: “Instâncias Intersectoriais e Interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no artigo 14 da lei 8080/90 e na NOB/RH-SUS”

A educação permanente permeia pelos processos de aprendizagem no trabalho, a partir da sua reflexão, levantando problemas e necessidades de natureza pedagógica, em que as estratégias de enfrentamento acontecem preferencialmente nos ambientes de trabalho.

Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde; (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados; (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

§ 1º O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

§ 2º Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

O que a Lei 12.466, de 2011, introduz no SUS: reconhece a importância da articulação federativa e portanto, a interdependência dos entes federativos na garantia do direito à saúde, ou melhor dizendo, da integralidade da assistência à saúde. Isso porque o direito à saúde previsto no art. 196 da CF tem conceito mais amplo que aquele que compete ao SUS.

Ao SUS compete a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde de promoção, proteção e recuperação, enquanto o direito à saúde tem conceito mais amplo por englobar as políticas sociais e econômicas que evitem o agravamento à saúde. Este campo diz respeito à qualidade de vida, às condições determinantes e condicionantes da saúde. E esta parte do direito não é competência do SUS, mas sim do Estado como um todo, da sociedade, das pessoas, das empresas.

No SUS deve-se garantir a integralidade da assistência à saúde e isso somente é possível se os entes federativos integrarem seus serviços, suas ações, o financiamento etc.

O que muda com esta institucionalidade trazida pela Lei:

1. CIT, CIB e CIR passam a ser reconhecidas como instâncias de decisão do SUS e não do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado da Saúde. Passa-se a falar em instância do SUS e não em fóruns de um ou outro ente federativo.

2. As decisões dos entes federativos – que somente pode ser por consenso – passam a ser publicadas pela própria instância, as comissões intergestores.

3. As decisões publicadas no diário oficial passam a ter validade jurídica ante o reconhecimento legal, desde que não ultrapassem o seu campo de competência.

4. o CONASS e o CONASEMS passam a ser oficializados no sentido de seu reconhecimento legal como associações representantes dos estados e municípios no setor saúde, tanto que passam a poder receber recursos orçamentários da União para o custeio de suas atividades estatutárias.

5. O SUS se fortalece por poder contar com essas instâncias legais de pactuação, reafirmando o seu papel de um sistema que é único ao mesmo tempo em que é interdependente. Todos devem cuidar da saúde, mas devem fazê-lo de maneira integrada, integrando suas ações e seus serviços de saúde, planejando integradamente as políticas de saúde. (SANTOS, 2011)



O Capítulo IV costuma ser abordado nas questões da maioria dos concursos públicos. Atente-se ao seu conteúdo e reforce os estudos neste ponto.

CAPÍTULO IV Da Competência e das Atribuições

Seção I Das Atribuições Comuns

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;

- III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
- IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
- V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
- VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;
- VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
- VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
- IX - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
- X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde;
- XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
- XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
- XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
- XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
- XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
- XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;
- XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde;
- XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
- XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;
- XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

Seção II Da Competência

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- II - participar na formulação e na implementação das políticas:
 - a) de controle das agressões ao meio ambiente;
 - b) de saneamento básico; e
 - c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
- III - definir e coordenar os sistemas:
 - a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
 - b) de rede de laboratórios de saúde pública;
 - c) de vigilância epidemiológica; e
 - d) vigilância sanitária;
- IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
- V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;
- VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
- VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
- VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;

IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal. (Vide Decreto nº 1.651, de 1995)

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) de vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição; e

d) de saúde do trabalhador;

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana;

VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;

VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho;

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde;

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde;

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

- I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
- II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
- III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
- IV - executar serviços:
 - a) de vigilância epidemiológica;
 - b) vigilância sanitária;
 - c) de alimentação e nutrição;
 - d) de saneamento básico; e
 - e) de saúde do trabalhador;
- V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;
- VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;
- VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;
- VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
- IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
- X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
- XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
- XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.

CAPÍTULO V

Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999 - Lei Arouca)

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

E m 31 de agosto de 1999, o Senado Federal aprovou, sem emendas, o projeto de lei originário da Câmara dos Deputados que criou o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. A lei, sancionada em setembro do mesmo ano e de autoria do então deputado federal Sérgio Arouca, pode ser considerada o marco regulatório da atenção à vida das populações indígenas do Brasil. Com o surgimento da nova legislação a responsabilidade formal e de toda a estrutura de Estado relacionada ao atendimento à saúde indígena, incluindo as unidades de saúde, os funcionários, as funções de confiança e os recursos orçamentários, passou a ser da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde com a missão de “Realizar ações de saneamento ambiental em todos os municípios brasileiros e de atenção integral à saúde indígena, promovendo a saúde pública e a inclusão social, com excelência de gestão, em consonância com o SUS e com as metas de desenvolvimento do milênio”.

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 1º O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 2º O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 3º As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

CAPÍTULO VI DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2º O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Segundo a portaria 2.527, a **Atenção Domiciliar (AD)** constitui-se como uma “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde” (BRASIL, 2011). Um dos eixos centrais da AD é a “desospitalização” - tanto na fase pré como na pós hospitalar – aumentando, consequentemente, a rotatividade de leitos, especialmente os de clínica médica. A AD possibilita, assim, a desinstitucionalização de pacientes que se encontram internados nos serviços hospitalares, além de evitar hospitalizações desnecessárias a partir de serviços de pronto atendimento e de apoiar as equipes de atenção básica no cuidado àqueles pacientes que necessitam (e se beneficiam) de atenção à saúde prestada no domicílio, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial, acesso, acolhimento e humanização.

Internação Domiciliar: modalidade de atenção realizada por uma equipe multiprofissional específica para esse fim, que presta assistência domiciliar a pessoas com quadros clínicos crônicos e agravados, porém estáveis, que exijam cuidados que superam aqueles que possam ser oferecidos pela Atenção

Primária. A Internação Domiciliar possibilita humanizar o atendimento e o cuidado ao paciente; Garantir cuidados e insumos mínimos com economia da hotelaria, redução de internações e reinternações, disponibilização de leitos hospitalares e, conseqüentemente, diminuição de custos de assistência; Desenvolver parceria entre a equipe de saúde e o paciente/família no processo de tomada de decisões relacionados ao cuidado a saúde, com responsabilidade equitativamente distribuída.

CAPÍTULO VII
DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E
PÓS-PARTO IMEDIATO
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 3º Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.895, de 2013)

Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Essa conquista é resultado de esforços de entidades, movimentos sociais e, principalmente, da campanha organizada pela Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (REHUNA) em prol do direito à presença de um acompanhante de livre escolha da mulher. Possibilitar que a mulher tenha um acompanhante, de sua livre escolha, no trabalho de parto, parto e pós-parto, é considerada uma prática benéfica que deve ser encorajada e está amparada pelas evidências científicas.¹⁻² As mulheres que recebem apoio contínuo durante o trabalho de parto, quando comparadas com as que não possuem um provedor de apoio, têm mais chance de não serem submetidas à cesariana e de terem um parto normal sem uso de analgesia; tempo de trabalho de parto reduzido; menor insatisfação com a experiência do processo de nascimento; e um recém-nascido com melhores índices de Apgar nos primeiros cinco minutos de vida. No Brasil, a pessoa escolhida pela mulher para acompanhá-la durante o trabalho de parto e parto, geralmente, tem sido responsável pelo apoio, desenvolvendo medidas que contemplam, de modo especial, os aspectos emocionais e de conforto físico. No entanto, para que o acompanhante desempenhe esse papel, é necessário acolhê-lo e inseri-lo no contexto institucional, fornecendo-lhe as orientações necessárias. (FRUTUOSO; BRÜGGEMANN, 2013)

CAPÍTULO VIII
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE
TECNOLOGIA EM SAÚDE”

Não há mais competência da Justiça Estadual nos caso de ações judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não se encontram nas relações do gestor federal, ou para patologias sem protocolo clínico ou diretriz terapêutica.

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.



Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são adotadas as seguintes definições:

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos;

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua

prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 1º O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos, na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no § 2º do art. 19-Q; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-S. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.”

Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

A Lei nº 12.401, de 2011 traz como novidade definir que a assistência terapêutica integral no âmbito do Sistema Único de Saúde se dará em conformidade com os Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para as doenças.

A relevância salta aos olhos, pois embora houvessem normas administrativas definindo a forma de elaboração dos protocolos clínicos, positivou-se por lei, não apenas em portarias ou regulamentos, a obrigatoriedade de serem respeitadas as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico ou, na ausência desses, a relação de medicamentos instituída pelo SUS.

A competência para a constituição de protocolo clínico é atribuição da União, por meio do Ministério da Saúde. Nada impede, entretanto, que os Estados adotem protocolos clínicos no âmbito de competência estadual, mas a responsabilidade pelo financiamento dos fármacos, nestes casos, será das próprias Secretarias Estaduais da Saúde.

Interessante é a solução dada pelo legislador nos casos de patologias em que ainda não há definição dos protocolos clínicos. A lei previu regramento específico para a dispensação. Ela será realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, e de forma complementar com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais e pelos gestores municipais do SUS, no âmbito de sua competência. Há vedação expressa, ainda, que o SUS pague por medicamentos, produtos ou procedimentos clínicos e cirúrgicos experimentais ou não autorizados ou não registrados pela ANVISA.

Os medicamentos instituídos pelo gestor federal do SUS estão relacionados, principalmente, nas Portarias nº 2981/2009 (regulamenta o componente especializado da assistência farmacêutica) e nº 2982/2009 (regulamenta o componente básico da assistência farmacêutica).

De outro lado, esvazia-se a competência da Justiça Estadual nos caso de ações judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não se encontram nas relações do gestor federal, ou para patologias sem protocolo clínico ou diretriz terapêutica. Isso porque está positivado no já mencionado artigo 19-Q ser atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a constituição ou a alteração de protocolo clínico. Demandas que pleiteiem fármacos nestas condições deverão ser julgados na Justiça Federal, em face da responsabilidade da União, por eventual omissão. (CANTERI, 2011)

Conclui-se, assim, que a Lei nº 12.401/11 introduz regras claras e propicia maior segurança jurídica no âmbito da dispensação farmacêutica e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

TÍTULO III **DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

CAPÍTULO I **Do Funcionamento**

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Desde que estejam dentro das normas propostas pelo SUS, os estabelecimentos de atenção à saúde privados podem atuar legalmente.

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

O cidadão pode ser atendido no sistema privado (particular ou convênio) desde que cumpra as condições apresentadas pelos serviços.

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Os serviços contratados deverão cumprir as normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, ou seja, mesmo sendo o serviço privado, este deverá cumprir as normas de funcionamento do SUS, que fará a fiscalização dos estabelecimentos e dos meios da prestação de serviços à clientela.

Art. 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

I - doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar: (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; e (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

b) ações e pesquisas de planejamento familiar; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social; e (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

IV - demais casos previstos em legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

O Art. 142 da Lei nº 13.097 de 2015 permite a entrada de capital ou empresas estrangeiras no setor Saúde, dando-lhes o direito de possuírem hospitais e clínicas, inclusive filantrópicas atuando na complementariedade do SUS.

Diversos estudiosos na área de Direito Sanitário consideram tal ação inconstitucional, pois acreditam que a lei viola o dispositivo constitucional que veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país (artigo 199, parágrafo 3º). Além disso, trata-se, também, de violação aos artigos 196 e 197 da Constituição, que classificam a saúde como garantia e direito constitucional a ser assegurado e fiscalizado pelo Estado.

CAPÍTULO II

Da Participação Complementar



Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

A complementariedade do setor privado é bastante abordada em concursos. Dediquem um tempo a mais para os estudos neste ponto.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

§ 1º Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.

§ 2º Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

§ 3º (Vetado).

§ 4º Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

TÍTULO IV

DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;

II - (Vetado)

III - (Vetado)

IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

A contratação dos profissionais por meio de concursos públicos em seus diferentes cargos fica sob responsabilidade dos governos municipais, estaduais e federal.

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

§ 1º Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.

Sendo que em virtude da constituição federal, não se pode acumular cargo público, como por exemplo trabalhar em dois ou mais cargos numa mesma esfera pública (Prefeitura), ou em prefeituras de diferentes

municípios. Porém é permitido exercer o mesmo cargo em esferas diferentes como município e estado ou federal desde que não haja incompatibilidade de carga horária.

Art. 29. (Vetado).

Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

Fica assim permitida e regulamentada o uso de entidades profissionais para uso de estágio supervisionado de estudantes e profissionais.

**TÍTULO V
DO FINANCIAMENTO**

**CAPÍTULO I
Dos Recursos**

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De acordo com as propostas elaboradas e apresentadas pelo sistema único de saúde fica uma porcentagem do rendimento do seguro social destinado às realizações dos serviços do SUS.

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:

I - (Vetado)

II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;

III - ajuda, contribuições, doações e donativos;

IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital;

V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.

§ 1º Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados.

§ 2º As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

§ 4º (Vetado).

§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.

§ 6º (Vetado).

**CAPÍTULO II
Da Gestão Financeira**

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Todo fundo arrecadado é administrado, distribuído e fiscalizado pelo ministério da saúde para os estados e municípios e se constatada má administração dos recursos cabe ao ministério da saúde a aplicação das medidas cabíveis.

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.

Os recursos repassados ao sistema único de saúde obedecem a proporção das despesas apresentadas pelo mesmo.

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

I - perfil demográfico da região;

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;

VI - previsão do plano quinquenal de investimentos da rede;

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.

§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. (Revogado pela Lei Complementar nº 141, de 2012) (Vide Lei nº 8.142, de 1990)

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.

§ 3º (Vetado).

§ 4º (Vetado).

§ 5º (Vetado).

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos.

CAPÍTULO III Do Planejamento e do Orçamento

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

O orçamento destinado ao SUS deverá ser utilizado exclusivamente para os programas de saúde, salvo os casos citados no parágrafo 2º.

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

Cabe ao conselho nacional de saúde estabelecer normas e diretrizes para a elaboração dos planos de saúde levando em consideração as particularidades de cada esfera administrativa.

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Os recursos repassados para o SUS é de uso exclusivo de instituições públicas sem fins lucrativos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39. (Vetado).

§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

§ 4º (Vetado).

§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social.

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento.

§ 7º (Vetado).

§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.

Art. 40. (Vetado)

Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia.

LEI No 8.246, DE 22 DE OUTUBRO DE 1991. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais e dá outras providências. Fica sob responsabilidade do INCA a prestação de serviços relacionados a cuidados do câncer e cabe à direção do SUS sua supervisão.

Art. 42. (Vetado).

Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressaltando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.

Fica proibida qualquer tipo de cobrança do usuário do sistema único de saúde pelos serviços prestados nos estabelecimentos de saúde públicos.

Art. 44. (Vetado).

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação

ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.

Os hospitais universitários mesmo que particulares podem firmar convênio com o sistema único de saúde. Fica sob a responsabilidade da instituição a administração e devidos custos, cabendo ao SUS o repasse destinado para os devidos fins.

Art. 46. O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.

É permitido ao SUS estabelecer parcerias com setores privados para investimento em ciências e tecnologia para melhorias do sistema de atendimento.

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.

Fica assim estabelecida uma rede de comunicação interligada entre as diferentes esferas administrativas com o fim de cruzamento de dados e acompanhamento dos programas de saúde.

Art. 48. (Vetado).

Art. 49. (Vetado).

Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No período de 1983 a 1993 é possível identificar três movimentos com repercussões importantes na configuração do setor saúde: Ações Integradas de Saúde - AIS (1983-1987), Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados - SUDS (1988-1989) e Sistema Único de Saúde - SUS (a partir de 1990).

Art. 51. (Vetado).

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei.

Art. 53. (Vetado).

Art. 53-A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 6.229, de 17 de julho de 1975, e demais disposições em contrário.



30 Princípios constitucionais do trabalho.

A Constituição contempla direitos sociais relativos aos trabalhadores tanto isolada como coletivamente considerados. Entre os direitos sociais coletivos podemos apontar a liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º), os direitos de greve (art. 9º), de participação em órgãos colegiados (art. 10) e de representação nas empresas com mais de duzentos empregados (art. 11).

Destinatários dos direitos sociais dos trabalhadores (art. 7.º) da CF:

- Urbanos: atividade industrial, comercial, prestação de serviços.
- Rurais: exploração agropastoril.
- Domésticos: auxiliares da administração residencial de natureza não lucrativa.

Direitos reconhecidos aos trabalhadores: São direitos reconhecidos aos trabalhadores os do art. 7.º e outros compatíveis com a finalidade de melhoria da condição social do trabalhador. O trabalho não é definido ou conceituado na Carta Constitucional, mas seu papel de relevo na vida do homem é destacado em todo o sistema constitucional:

- Art. 6.º trata-o como direito social:
- Art. 1.º, IV: Traz como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil os “valores sociais do trabalho”.
- Art. 170: A ordem econômica se funda na “valorização do trabalho”.
- Art. 193: A ordem social tem por princípio o “primado do trabalho”.

Os direitos sociais, genericamente referidos no artigo 6.º da Constituição Federal (CF), estão presentes em toda a Constituição, em especial em seus artigos 7.º e 193 a 230. Direitos sociais são direitos coletivos e não direitos individuais, embora algumas vezes possam ocupar as duas posições. Por isso, em regra, são passíveis de modificação por emenda constitucional (apenas os direitos e garantias individuais estão previstos como cláusula pétrea).

Nos termos do artigo 6.º da Constituição Federal, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.

A CF relaciona os direitos sociais em três grupos:

- Direitos sociais fundamentais;
- Direitos dos trabalhadores em geral;
- Direitos coletivos dos trabalhadores.

O art. 6º aponta os direitos sociais fundamentais, sendo todos voltados à garantia de perfeitas condições de vida. Tais direitos visam garantir:

- Saúde;
- Educação;
- Trabalho;
- Alimentação;
- Lazer;

- Segurança;
- Previdência social;
- Proteção à maternidade e à infância;
- Assistência aos desamparados;
- Moradia.

Os direitos sociais têm conteúdo econômico e, às vezes, são apresentados como direitos econômicos, posto ser o trabalho componente das relações de produção e primado básico da ordem social – arts. 7.º e 193. Mas direitos sociais não se confundem com os direitos econômicos:

- Direitos Econômicos: Dimensão institucional.
- Direitos Sociais: Formas de tutela pessoal; disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais. O direito econômico é pressuposto de existência de direitos sociais.

O homem tem direito social ao trabalho como condição de efetividade da existência digna, da dignidade da pessoa humana. Tem-se, por exemplo: direito individual – liberdade de profissão ou ofício; direito social – acesso ao emprego e à formação profissional.

a) Direito ao trabalho: Garantia de permanência no emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Protege-se o emprego, garantindo-se a indenização compensatória da rescisão do contrato de trabalho; seguro-desemprego; aviso-prévio.

b) Direito ao salário mínimo: O salário percebido pelo trabalhador não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo, salvo quando convencionado em contrato coletivo de trabalho.

c) Direito ao repouso e à inatividade remunerada:

- Repouso semanal remunerado.
- Licença-maternidade (gestante – 120 dias, pode ser prorrogada até 180 dias).
- Licença-paternidade (5 dias; artigo 10, § 1.º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
- Gozo de férias anuais, que devem ser pagas antes do início, com acréscimo de 1/3 (A CF não fixa o número de dias, cabendo à lei disciplinar).
- Aposentadoria.

d) Proteção dos trabalhadores

- Proteção do mercado de trabalho da mulher.
- Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- Segurança do trabalho – proteção contra riscos, em face da automação e a obrigatoriedade de seguro.

e) Direitos relativos aos dependentes: Salário-família para os dependentes de trabalhadores de baixa renda. Assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

f) Participação nos lucros e cogestão: Assegura a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa.

Vejamos a letra da Constituição Federal no que se refere aos direitos sociais:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
- II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
- III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV – salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI – aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV - aposentadoria;

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do

cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013).



Observação: Com a Emenda Constitucional nº 72, de 2013 foram estendidos aos **trabalhadores domésticos** direitos antes garantidos apenas aos trabalhadores urbanos e rurais, sendo estes:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Sendo previsto ainda, a possibilidade da inscrição do trabalhador doméstico na previdência social, podendo esta ser realizada por este mesmo ou pelo empregador.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

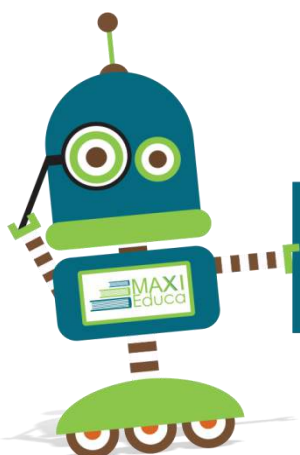
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.



31 Estado federal: conceito e sistemas de repartição de competência; direito comparado.

Estado pode ser definido como uma ordenação global das relações sociais entre os indivíduos integrantes de um povo sobre um determinado território.

José Afonso da Silva destaca que:

“O Estado, como se nota, constitui-se de quatro elementos essenciais: um *poder soberano de um povo* situado num *território* com certas *finalidades*. E a *constituição*, como dissemos antes, é o conjunto de normas que organizam estes elementos constitutivos do Estado: *povo, território, poder e fins*”⁷¹.

Por seu turno, a forma de exercício do poder político em relação ao território denomina-se forma de Estado, podendo ser **unitário ou federal**.

O Estado é **unitário** quando há uma concentração de poder em relação ao território, pessoas e bens.

Saraiva (1992), citado por Moraes (2005), conceitua Estado unitário como aquele **“rigorosamente centralizado, no seu limiar, e identifica um mesmo poder, para um mesmo povo, num mesmo território”**.

O Estado **federal**, por sua vez, é aquele que prevê uma maior descentralização do poder, de forma que seus entes integrantes possuam uma parcela desse poder. Caracteriza-se pela existência de uma repartição de competências, bem como pela autonomia e igualdade entre os entes federados.

Dallari (1985), citado por Moraes (2005), define federalismo como “uma aliança ou união de Estados”, baseada em uma Constituição, onde “os Estados que ingressam na federação perdem sua soberania no momento mesmo do ingresso, preservando, contudo, uma autonomia política limitada”.

O ponto de partida para a adoção do federalismo consiste na decisão do poder constituinte de criação do Estado Federal e suas partes indissociáveis⁷².

A história moderna do federalismo começa com a matriz clássica da Constituição americana de 1787, que estruturou uma divisão do poder estatal baseada em uma rígida separação de responsabilidades entre dois centros de governo, o total (União) e os parciais (Estados), que as exerceriam com independência e autonomia em seu âmbito.

Também a tradição continental europeia adotava a forma confederativa como forma de organização dos Estados, marcada por características próprias, que resultou na criação de outras matrizes federativas, como é o caso da Suíça, que passou da forma confederativa a uma Federação em 1848, e o Império alemão, estruturado sob a forma federativa em 1871 por Bismarck. Entretanto, esses Estados apostaram em um modelo federativo caracterizado por relações de co-decisão e cooperação entre os governos federal e estaduais.

Conforme observam Marcelo Augusto Biehl Ortolan e Fernando Santos de Camargo⁷³, **“Atualmente, dos 192 estados politicamente soberanos reconhecidos pelas Nações Unidas, 25 podem ser classificados como Federações, formadas por mais de 510 unidades constitutivas, que compreendem cerca de 2 bilhões de pessoas ou 40% da população mundial (WATTS, 2008, p. 4-5). Além disto, é cada vez mais nítido fenômeno global de diminuição da soberania dos Estados-nações em prol do fortalecimento de entidades supra estatais com características federativas, sendo a União Europeia o protótipo por excelência desse influxo.”**

⁷¹ SILVA, 2005, p. 98

⁷² MORAES, 2005, p. 246.

⁷³ Análise comparativa dos modelos de repartição de competências legislativas nos estados federados, disponível em: http://www.academia.edu/1540012/PAPER_7o_ABCP_-_AN%C3%81LISE_COMPARATIVA_DOS_MODELOS_DE_REPARTI%C3%87%C3%83O_DE_COMPET%C3%81NCIAS_LEGISLATIVAS_NOS_ESTADOS_FEDERADOS



32 Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. Intervenção Federal nos Estados membros. Lei n.º 12.562/2011.

A Constituição Federal de 1988 adotou o federalismo como forma de Estado. Nesse contexto, proibiu qualquer deliberação sobre proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado; dessa forma, a Carta Maior garantiu autonomia aos entes federados e consagrou o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo.

O art. 1º da Constituição Federal destaca que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Por sua vez, o art. 18 da Lei Maior, que trata da organização político-administrativa, dispõe que a República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo todos autônomos.

Assim, os entes federados são pessoas jurídicas de direito público interno que integram o Estado Federal. Em outras palavras, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios compõem o Estado Federal.

Aqui, cabe destacar que soberania pode ser entendida como uma autodeterminação plena conferida ao Estado Federal que o coloca em posição de coordenação com os demais integrantes do cenário internacional.

A autonomia constitui a capacidade para desenvolver atividades dentro de limites previamente estabelecidos pelo ente soberano. Caracteriza-se pela existência da capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração dos entes federados, observadas as restrições impostas pela Constituição Federal.

O Estado Federal é o único detentor da soberania, de forma que os entes federados possuem apenas autonomia. Paulo Gustavo Gonet Branco ensina que **“a soberania, no federalismo, é atributo do Estado Federal como um todo. Os Estados-membros dispõem de outra característica – a característica da autonomia, que não se confunde com o conceito de soberania”**.

Ainda, merece destaque o ensinamento de José Afonso da Silva:

“No Estado federal há que se distinguir soberania e autonomia e seus respectivos titulares. Houve muita discussão sobre a natureza jurídica do Estado federal, mas, hoje, já está definido que o Estado federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo Direito internacional, é o único titular da soberania, considerada poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. Os Estados federados são titulares tão-só de autonomia, compreendida como governo próprio dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição Federal”⁷⁴.

Cabe salientar que a União, em que pese constituir ente federativo autônomo, exerce as prerrogativas de soberania do Estado Federal brasileiro, como destaca Alexandre de Moraes:

A União é entidade federativa autônoma em relação aos Estados-membros e municípios, constituindo pessoa jurídica de Direito Público Interno, cabendo-lhe exercer as atribuições da soberania do Estado brasileiro. Não se confundindo com o Estado Federal, este sim pessoa jurídica de Direito Internacional e formado pelo conjunto de União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Ressalte-se, porém, que a União poderá agir em nome próprio, ou em nome de toda Federação, quando, neste último caso, relaciona-se internacionalmente com os demais países.⁷⁵

⁷⁴ SILVA, 2005, p. 100.

⁷⁵ MORAES, 2005, p. 248.

Como dito, a autonomia consiste na capacidade de **auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração** dos entes federados, observadas as restrições impostas pela Constituição Federal.

A **auto-organização** permite que os entes federados se organizem, na forma do poder constituinte decorrente, por meio da edição de Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. Assim, eles se auto-organizam, mas sempre dentro dos limites impostos pela Constituição Federal, que representa a norma suprema do ordenamento jurídico.

A **autolegislação** garante que os entes federados exerçam, por meio de seu Poder Legislativo, as competências a ele atribuídas. Assim, podem adotar suas próprias leis, desde que observados os princípios e normas basilares da Constituição Federal.

O **autogoverno** permite que os entes federados possuam representantes eleitos diretamente, sem qualquer ingerência ou vínculo de subordinação entre si. Desse modo, cada Estado possui Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, sendo que inexistente vinculação hierárquica em relação à União ou aos outros Estados-membros. Os Municípios, por sua vez, elegem seus representantes dos Poderes Executivo e Legislativo. Não possuem, contudo, um Poder Judiciário próprio.

A **auto-administração** assegura aos entes estatais a capacidade de organizar sua própria Administração Pública, seus serviços públicos e seu quadro de servidores públicos, com base nas competências administrativas, legislativas e tributárias definidas na Constituição. Essa capacidade de auto-administração deve ser assegurada pela previsão de um mínimo de rendas próprias, a fim de o ente não dependa inteiramente de repasse de verbas, o que ensejaria, inclusive, uma forma de indevida intervenção.

Por seu turno, o **princípio da indissolubilidade do vínculo federativo** veda qualquer pretensão de separação dos entes federados. Ou seja, não existe a possibilidade de direito de secessão, sendo observado que os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – ocupam o mesmo patamar hierárquico, com igualdade entre eles impondo um tratamento igualitário.

O pressuposto da autonomia dos entes federados nos conduz às características da federação, apartando essa forma de Estado daquelas outras, politicamente centralizadas. O grau de centralização ou de descentralização política de um Estado Federal é medido pela quantidade e qualidade de atribuições concedidas às entidades federativas. Quanto maior a centralização política, maiores serão as atribuições do governo central.

Deste modo, aponta a doutrina o que seria a moldura do Estado Federal. Ensina ser da sua essência a **capacidade de auto-organização**, por meio da edição de suas próprias constituições; a **participação da vontade parcial na formação da vontade geral** e a **atribuição de funções, efetuada diretamente do Texto Constitucional Federal**, corolário, esta última, da própria ideia de autonomia política e administrativa.

No Estado brasileiro esses caracteres encontram-se presentes, com o que podemos afirmar revestir ele a forma federal. Tal assertiva não desconhece, à evidência, as especiais características que podem ser impressas à Federação, em cada Estado, como resultado dos atributos da atividade constituinte originária, a que se reconhece ser inicial, autônoma e incondicionada.

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades federativas é o da **predominância do interesse**. Assim, a União atende interesses gerais, os Estados-membros, interesses regionais, os municípios interesses locais e o Distrito Federal, interesses regionais e locais. Todavia, na prática não é fácil distinguir o que seja interesse geral, regional ou local.

Na repartição das competências materiais (matéria administrativa) e legislativas (edição de leis), a Constituição brasileira optou por enumerar as atribuições da União (arts. 21 e 22 da CF) e dos Municípios (art. 30) e reservar o restante, as remanescentes, aos Estados (art. 25, §1º).

Assim, as competências dividem-se em dois grandes grupos: **material** e **legislativa**. Podem ser:

- **Exclusiva**: atribuída a uma entidade, com exclusão das demais.
- **Privativa**: própria de uma entidade, com a possibilidade de delegação ou suplementação.
- **Comum, cumulativa ou paralela**: comum a várias entidades, em pé de igualdade.
- **Concorrente**: possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade, porém, com a primazia da União no que tange as normas gerais.
- **Suplementar**: decorre da competência concorrente, consubstanciando o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas.
- **Residual ou remanescente**: É a competência remanescente, não abrangida por aquelas expressamente atribuídas pela Constituição Federal.

Desta forma, no tocante às atribuições da **União**, temos em nível constitucional, os termos do artigo 21, caracterizadores da competência administrativa ou material; do artigo 22, outorgando a esse ente político a competência legislativa privativa; do artigo 23, autorizando o exercício de atribuições de desempenho comum às três esferas – geral, regional e local – e finalmente os termos do artigo 24, consagrador da **competência legislativa concorrente** entre União, Estados e Distrito Federal, não se olvidando o fato de que conquanto ausente, neste ponto, a figura do Município, impõe-se análise sistemática, integradora daquele ente nessa modalidade de competência, por força do que preceitua o artigo 30, inciso II, do mesmo Texto Constitucional, que afirma ser de sua alçada a *suplementação da legislação federal e estadual, no que couber*.

No tocante aos **Estados** e ao **Distrito Federal**, cuidam de tal outorga os termos do artigo 25 e incisos. Finalmente, quanto às atribuições **municipais**, são aquelas trazidas pelo artigo 30 e incisos, sobressaindo à dicção do inciso I, segundo o qual essa pessoa política legisla sobre **assuntos locais**. Aliás, nessa seara, campeiam as mesmas dificuldades observadas em torno da extensão do termo **normas gerais**. Com efeito, tem a doutrina e a jurisprudência tratado de modo casuístico o que vem a ser a extensão da locução *assuntos de interesse local*.

Intervenção Federal

A intervenção é o ato político que consiste na incursão de uma entidade (interventora) nos negócios de outra entidade que tem sua autonomia temporariamente suprimida. Trata-se de medida de defesa do Estado Federal. A intervenção é um dos assuntos mais delicados da federação em razão de se tratar de uma exceção à regra de que cada entidade possui suas próprias competências (regra de ouro da federação). Isso ocorre como forma de proteção de determinados bens jurídicos, e somente pode ocorrer diante de algumas hipóteses em que o próprio sistema federativo se vê ameaçado por uma de suas entidades. Assim, os motivos que justificam a intervenção devem ser relevantes e encontram-se devidamente previstos na Constituição da República.

A intervenção sujeita-se à ocorrência de determinados **motivos** e deve obedecer certas **formalidades**. A prática desse ato excepcional foge à regra da federação, já que um ente político não pode por qualquer motivo ou sob qualquer forma afastar a competência do outro.

Pela redação do artigo 34 da CF/88, verifica-se que a regra é a não intervenção.

A competência para decretar a intervenção é exclusiva dos chefes do executivo da União e dos Estados. A forma da intervenção não é fixa, e irá variar de acordo com o motivo. A forma básica é o decreto (privativo do Chefe do Executivo), e o que varia no procedimento é a fase antecedente ao decreto do Executivo.

A intervenção federal é medida excepcional de supressão temporária da autonomia de determinado ente federativo, nas **hipóteses taxativamente previstas** na CR/88, destinada a:

- a) **Tornar efetiva a intangibilidade do vínculo federativo;**
- b) **Fazer respeitar a integridade territorial das unidades federadas;**
- c) **Promover a unidade do Estado Federal;**
- d) **Preservar a incolumidade dos princípios fundamentais.**

Nenhuma das constituições brasileiras do período republicano (1889, recorde-se) deixou de consagrar o instituto da intervenção, exatamente porque consubstancia ferramenta essencial à garantia da unidade do Estado Federado e de sua própria sobrevivência. É essa finalidade, aliás, que justifica a extraordinária limitação da autonomia político-administrativa dos entes federados.

Quando a União atua como sujeito ativo da intervenção, ela atua não somente em nome da própria pessoa jurídica, mas sim no interesse da República.

A União nunca poderá intervir em município localizado em Estado-membro, mas tão-somente naqueles situados em Territórios federais

A intervenção é **ato político**, executado sempre, **exclusivamente, pelo chefe do poder executivo**. Ela funciona também como **meio de controle de constitucionalidade**, já que é medida coercitiva última para o restabelecimento da obediência à CF/88 pelos entes federativos. Evidentemente, então, já que é política, não pode a intervenção ter natureza administrativa.

Numa federação não há hierarquia entre entidades federativa. Mas existem áreas administrativas estratégicas na concepção do constituinte em que deve ser organizada uma rede integrada de órgão de todas as entidades federativas e de natureza hierárquica. Isso ocorre como exemplo na área da saúde e na área de assistência social. Então, apesar de não haver hierarquia entre a União, os Estados e os

municípios, quando a CF/88 trata do SUS, ela estrutura o SUS como um sistema integrado e hierarquizado.

Existem 4 fases na intervenção:

- a) A primeira fase é a fase de iniciativa.
- b) A segunda fase, que não ocorre sempre, é a fase do controle judicial prévio.
- c) A terceira fase é a fase da decretação, a formalização do decreto, a edição do decreto de intervenção.
- d) A quarta fase é a fase de controle político. O controle político que é exercido pelo CN. Não é um ato da Câmara ou do Senado. É um ato do CN como um todo, Câmara e Senado. É um ato em conjunto da Câmara e do Senado.

Pode-se indicar como suas características primordiais:

- a) **Excepcionalidade;**
- b) **Temporariedade;**
- c) **Restrição interpretativa.**

Intervenção Federal Espontânea

São hipóteses em que a CF/88 autoriza a intervenção diretamente e por iniciativa própria do Chefe do Poder Executivo. Ocorre nas seguintes hipóteses:

a) Defesa da unidade nacional (art. 34, I e II, CF/88):

- Manter a integridade nacional;
- Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;

b) Por termo a grave comprometimento da ordem pública (art. 34, III, CF/88);

c) Reorganizar as finanças da unidade da Federação que (art. 34, V, CF/88):

- Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
- Deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei.

Intervenção Federal Provocada

Ocorre quando a medida decorre de provocação de algum órgão ao qual a CF/88 conferiu tal competência. Nestas hipóteses, não poderá haver iniciativa de ofício do Chefe do Executivo. Poderá ocorrer sob duas formas:

a) Por solicitação: haverá juízo de discricionariedade sobre a decretação ou não da intervenção por parte do Chefe do Executivo;

b) Por requisição: se requisitado, obrigado estará o Chefe do Executivo a decretar a intervenção.

Possuem legitimidade para a intervenção provocada:

– **Poder Legislativo** (Estadual ou Distrital) ou Poder Executivo Local (Governador de Estado ou do DF: far-se-á solicitação diretamente ao Presidente da República, para que este garanta o livre exercício desses Poderes (art. 36, I).

– **Supremo Tribunal Federal:** se o Poder Judiciário local estiver sendo coagido, o TJ deverá solicitar ao STF que requirite a intervenção federal. Se o STF entender cabível, fará a requisição (art. 36, I).

– **STF, STJ ou TSE:** no caso de desobediência à ordem judicial, a intervenção federal dependerá da requisição de um desses tribunais ao Presidente. Terá competência para requisitar o Tribunal cuja ordem descumprida seja afeta à sua área (art. 36, II).

Nas hipóteses de descumprimento de ordem ou decisão da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, a requisição deverá ser feita diretamente ao STF, mesmo que haja unicamente questões infraconstitucionais envolvidas. É pressuposto dessas intervenções o trânsito em julgado da decisão que se quer fazer cumprir.

Nesse sentido:

“O descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. Para que seja decretada a intervenção federal em um Estado-membro que tenha deixado de pagar precatórios é necessário que fique comprovado que esse descumprimento é voluntário e intencional. Se ficar demonstrado que o ente não pagou por dificuldades financeiras não há intervenção. STF. Plenário. IF 5101/RS, IF 5105/RS, IF 5106/RS, IF 5114/RS, Min. Cezar Peluso, 28.3.2012 (Info 660 STF)”.

– **Procurador-Geral da República:** no caso de recusa à execução de lei federal (art. 34, VI) e de ofensa aos princípios sensíveis (art. 34, VII, CF/88), a intervenção dependerá de representação interventiva do PGR perante o STF (art. 36, III).

No primeiro caso, temos a ação de executoriedade de lei federal, já que se visa a obrigar o ente federado ao cumprimento de lei.

No segundo caso, temos a representação interventiva ou ação direta de inconstitucionalidade interventiva. O STF nunca decretará a intervenção, quem o faz e a executa é o chefe do poder executivo. Nesses casos, se negado provimento à representação do PGR, o STF determinará o arquivamento do processo. Se provido, ele provocará o Presidente da República para que realize a intervenção, de forma obrigatória.

Decreto Interventivo

A intervenção se implementa por decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo. Ele especificará a amplitude, o prazo e as condições da intervenção, além de nomear o interventor.

Nas hipóteses de intervenção não vinculada (espontânea e provocada mediante representação), o Presidente deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, cujos pareceres são não vinculantes.

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a eles tornarão e não poderá haver emenda da Constituição da República durante a intervenção federal.

Controle Político

O decreto interventivo gera efeitos imediatamente, mas deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional em 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas. O Congresso poderá aprovar a medida, mediante decreto legislativo, ou determinar a suspensão do ato.

Caso não aprovado, o ato deverá cessar imediatamente, já que se tornou inconstitucional; se mantido, caracterizará crime de responsabilidade do Presidente.

Só há controle político do congresso quando a intervenção for espontânea ou provocada por solicitação. Quando provocada por requisição, não é possível.

Controle Judicial

Não existe controle jurisdicional propriamente dito, a não ser que haja manifesta violação às normas constitucionais, quando tenha sido determinada a suspensão pelo Congresso ou quando os atos do interventor prejudiquem interesses de terceiros.

Excepcionalidade da Intervenção

O STF é altamente conservador em pedir intervenção, pois representa uma medida muito drástica; entende também que, no caso de quebra de ordem de pagamento de precatório, somente se pode declarar a intervenção se ficar comprovado o inequívoco ânimo de não cumprir a decisão judicial.

Intervenção dos estados nos municípios (e da União em Municípios dos Territórios)

A intervenção em Município será feita mediante **decreto expedido pelo Governador**. Ela ocorrerá nas seguintes hipóteses:

- a) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos a dívida fundada;
- b) Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; **essa intervenção não será mais cabível se as contas vierem a ser protocoladas posteriormente no órgão de contas;**
- c) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
- d) O **TJ** der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Nesse caso, o provimento será da representação interventiva feita pelo Procurador-Geral de Justiça, **não cabendo contra a decisão do TJ recurso extraordinário (nem REsp), já que a decisão tem natureza jurídico-administrativa** (Súmula 637, **STF**). Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 637-STF. I. - **A decisão do tribunal de justiça que determina a intervenção estadual em município possui natureza político-administrativa, não se qualificando, assim, como causa a desafiar o manejo do recurso extraordinário.** Incidência, no caso, da Súmula 637-STF. II. - Agravo não provido.

(AI 520166 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08/03/2005, DJ 08-04-2005 PP-00032 EMENT VOL-02186-09 PP-01600)

Texto Constitucional sobre o assunto

CAPÍTULO VI DA INTERVENÇÃO

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

- I - manter a integridade nacional;**
- II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;**
- III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;**
- IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;**
- V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:**
 - a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;**
 - b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;**
- VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;**
- VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:**
 - a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;**
 - b) direitos da pessoa humana;**
 - c) autonomia municipal;**
 - d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.**
 - e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.**

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

- I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;**
- II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;**
- III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;**

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;

III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.

§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas.

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.

LEI Nº 12.562, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.

Regulamenta o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da representação interventiva prevista no inciso III do art. 36 da Constituição Federal.

Art. 2º A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal.

Art. 3º A petição inicial deverá conter:

I - a indicação do princípio constitucional que se considera violado ou, se for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas;

II - a indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto ou da omissão questionados;

III - a prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei federal;

IV - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial será apresentada em 2 (duas) vias, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de representação interventiva, faltar algum dos requisitos estabelecidos nesta Lei ou for inepta.

Parágrafo único. Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na representação interventiva.

§ 1º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

§ 2º A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva.

Art. 6º Apreciado o pedido de liminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, que as prestarão em até 10 (dez) dias.

§ 1º Decorrido o prazo para prestação das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários, na forma do regimento interno.

Art. 7º Se entender necessário, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que elabore laudo sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Parágrafo único. Poderão ser autorizadas, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo.

Art. 8º Vencidos os prazos previstos no art. 6º ou, se for o caso, realizadas as diligências de que trata o art. 7º, o relator lançará o relatório, com cópia para todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

Art. 9º A decisão sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 (oito) Ministros.

Art. 10. Realizado o julgamento, proclamar-se-á a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação interventiva se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 (seis) Ministros.

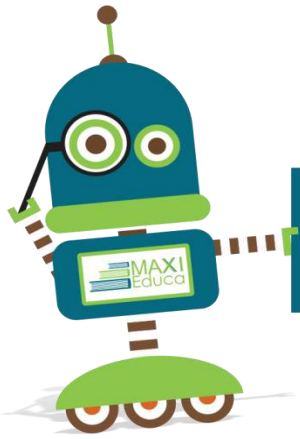
Parágrafo único. Estando ausentes Ministros em número que possa influir na decisão sobre a representação interventiva, o julgamento será suspenso, a fim de se aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão.

Art. 11. Julgada a ação, far-se-á a comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 (quinze) dias, dar cumprimento aos §§ 1º e 3º do art. 36 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União.

Art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



33 Estado Democrático de Direito: fundamentos constitucionais e doutrinários.

O Estado Democrático de Direito, que significa a exigência de reger-se pelo Direito e por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo povo bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais, proclamado no caput do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, adotou, igualmente em seu parágrafo único, o denominado princípio democrático, ao afirmar que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”⁷⁶.

O termo "Estado democrático de direito" conjuga dois conceitos distintos que, juntos, definem a forma de mecanismos tipicamente assumidos pelo Estado de inspiração ocidental. Cada um destes termos possui sua própria definição técnica, mas, neste contexto, referem-se especificamente a parâmetros de funcionamento do Estado Ocidental moderno. Em sua origem grega, "democracia" quer dizer "governo do povo". No sistema moderno, no entanto, não é possível que o povo governe propriamente (o que significaria uma democracia direta). Assim, os atos de governo são exercidos por membros do povo ditos "politicamente constituídos", por meio de eleição.

No Estado Democrático Brasileiro, as funções típicas e indelegáveis do Estado são exercidas por indivíduos eleitos pelo povo para tanto, de acordo com regras pré-estabelecidas que regerão o pleito eleitoral. O aspecto do termo "de Direito" refere-se a que tipo de direito exercerá o papel de limitar o exercício do poder estatal.

No Estado democrático de direito, apenas o direito positivo (isto é, aquele que foi codificado e aprovado pelos órgãos estatais competentes, como o Poder Legislativo) poderá limitar a ação estatal, e somente ele poderá ser invocado nos tribunais para garantir o chamado "império da lei". Todas as outras fontes de direito, como o Direito Canônico ou o Direito natural, ficam excluídas, a não ser que o direito positivo lhes atribua esta eficácia, e apenas nos limites estabelecidos pelo último.

Nesse contexto, destaca-se o papel exercido pela Constituição. Nela delineiam-se os limites e as regras para o exercício do poder estatal (onde se inscrevem os chamados "Direitos e Garantias fundamentais"), e, a partir dela, e sempre a tendo como baliza, redige-se o restante do chamado "ordenamento jurídico", isto é, o conjunto das leis que regem uma sociedade.

O Estado democrático de direito não pode prescindir da existência de uma Constituição. No entanto, toda a conceitualização não deverá restringir o elemento democrático à limitação do poder estatal e a democracia ao instituto da representação política. Esta, em virtude de seus inúmeros defeitos, não pode fundamentar o Estado Democrático de Direito, pelo menos não como ele deveria ser, já que o princípio democrático não se reduz a um método de escolha dos governantes pelos governados.

⁷⁶ Alexandre de Moraes. Direito Constitucional. 21ª Ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2007. p 125



34 Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos.

A separação dos poderes é atribuída ao filósofo grego Aristóteles que, em sua obra “Política” defendeu que o Soberano exercia três diferentes funções, quais sejam: a de editar normas gerais que devem ser obedecidas por todos, a de aplicar essas normas aos casos concretos e a de julgar.

Destaque-se que, embora distinga as funções, o filósofo não as separava, haja vista o fato de todas serem exercidas por uma única pessoa – Soberano – logo, há a concentração do poder.

Montesquieu por meio de sua obra “O Espírito das Leis” aprimorou a divisão feita por Aristóteles ao defender que as três funções deveriam ser exercidas por órgãos distintos, ou seja, ele pregava a desconcentração do poder. Afirmava ainda que esses órgãos deveriam ser dotados de autonomia e independência.

Deve-se também lembrar o importante papel da Revolução Gloriosa, na Inglaterra que originou o *Bill of Rights*, documento inspirado nas ideias de John Locke que separou e limitou os poderes do rei e do parlamento, conferindo ainda independência aos juízes.

A principal **função da separação dos poderes** é também limitá-los de forma que não haja concentração nas mãos de uma só pessoa. Uma vez separados, minimiza-se os abusos e garante-se os direitos fundamentais do homem, principalmente os que reportam à liberdade, por isso mesmo, esse sistema é também chamado de **sistema de freios e contrapesos**.

Dalmo de Abreu Dallari explica que pelo sistema de freios e contrapesos, o Poder Legislativo somente edita atos gerais, ou seja, regras gerais e abstratas que, quando são formuladas não se sabe quem irão atingir, logo, o Legislativo não atua concretamente na vida social, o que o impede de cometer qualquer ato de abuso de poder. Uma vez que a norma geral é emitida, o Poder Executivo executa os chamados atos especiais, ou seja, aplica as normas abstratas aos casos concretos, porém, embora possua meios concretos para agir, esse poder está impossibilitado de agir discricionariamente, uma vez que fica limitado pelos atos gerais emitidos pelo Poder Legislativo.

Havendo qualquer abuso ou tentativa de abuso, o Poder Judiciário se manifesta no sentido de fiscalizar e punir.

A Constituição Federal brasileira adotou a teoria da separação dos poderes na forma tripartida, ou seja, os poderes são separados em três: Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos independentes e harmônicos entre si, conforme prega o art. 2º, vejamos:

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

Dentro dessa divisão cada poder possui funções típicas e atípicas.

As **funções típicas** são aquelas predominantes em um dado poder, ou seja, são as funções inerentes à natureza de determinado órgão. Ex.: a função típica do Poder Legislativo é legislar.

As **funções atípicas**, por sua vez, são aquelas que tem natureza de outro poder. Tendo sido usado o Poder Legislativo como exemplo, tem-se que suas funções atípicas são as executivas e as jurisdicionais, atividades próprias dos poderes Executivo e Judiciário respectivamente.

Ex.: A Constituição Federal conferiu competência para o Senado julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. O Senado é órgão do Poder Legislativo e, por meio dessa competência constitucional está realizando a função jurisdicional.

Não há que se falar em ferimento à independência e harmonia dos poderes por meio das funções atípicas, haja vista que elas são criadas justamente para assegurá-las. Caso assim não fosse um poder ficaria dependente do outro. Imagine que o Poder Judiciário para abrir concurso público, precisasse que o Poder Legislativo redigisse o edital. Como se sabe o edital é lei e a função legislativa é típica do Poder Legislativo. Se não fosse o fato de os poderes possuírem as funções atípicas um ficaria dependente do outro para realizar suas próprias funções e, nesse caso haveria afronta ao disposto no art. 2º da Constituição.

Alguns doutrinadores criticam a expressão “tripartição de poderes” haja vista o poder não ser dividido, posto que esse é uno, indivisível e indelegável. Para eles o que se divide são as funções que cada poder exerce por meio de seus órgãos.

Vigora entre os três poderes o **princípio da indelegabilidade das atribuições**, ou seja, os poderes não podem delegar suas funções para outro ou outros. Contudo, é possível que um órgão exerça atribuições de outro quando houver previsão expressa na Constituição Federal.

Separação de poderes. Mecanismos de freios e contrapesos.

O tema da separação de poderes tem sido objeto de considerações ao longo da história por grandes pensadores e juristas, dentre os quais podemos citar Platão, Aristóteles, Locke, Montesquieu, entre outros, que culminaram no modelo tripartite conhecido atualmente, inclusive como princípio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro (artigo 2º), também utilizado na maioria das organizações de governo das democracias ocidentais, consagrado com a inserção do artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, nos idos de 1789. O modelo tripartite atual consiste em atribuir a três órgãos independentes e harmônicos entre si as funções Legislativa, Executiva e Judiciária.

Essa teoria da separação de poderes em corrente tripartite, foi esboçada primeiramente por Aristóteles em sua obra “A Política”, em que admitia existir três órgãos separados a quem cabiam as decisões do Estado. Eram eles o poder Deliberativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Posteriormente, Locke em sua obra “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”, concebendo o Poder Legislativo como sendo superior aos demais, que inclusive estariam subordinados a ele, quais sejam, o Executivo com a incumbência de aplicar as leis e o Federativo que, muito embora, tivesse legitimidade não poderia ser desvinculado do Executivo, cabendo a este cuidar das relações internacionais do governo.

Todavia é nítido na doutrina um consenso em atribuir a **Montesquieu** a consagração da tripartição de poderes com as devidas repartições de atribuições no modelo mais aceito atualmente por todos, em sua obra “**O Espírito das Leis**”, com a inclusão do poder judiciário entre os poderes fundamentais do Estado. Haja vista, podemos até mesmo dividir a história desta teoria entre antes e depois de Montesquieu, tamanha foi a contribuição que este deixou, numa verdadeira obra de arte de legislação, própria daqueles que se predispõem sem reservas a defender os seus ideais.

Porém, Aristóteles, Locke e Montesquieu, entre outros de sua época, não foram os criadores da presente doutrina e sim quem, com grande brilhantismo e sabedoria, as sistematizou em contornos específicos, baseando-se em teorias já existentes, como podemos verificar em relatos antigos deixados em obras clássicas de célebres autores, como Platão, por exemplo, em “A República”, onde podemos visualizar pontos que deixam clara a concepção de uma teoria que consistia em subdividir as funções do Estado de forma que esta não se concentrasse nas mãos de apenas uma pessoa, o que poderia dar ensejo a trágicos fins, uma vez que, como todos sabem, o homem se desvirtua ante a concentração e a não limitação de poder a ele outorgado.

A Constituição da República Federativa do Brasil predispõe, em seu artigo 2º, que **são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário**. Essa classificação, não foi realizada por obra exclusiva de apenas uma pessoa, mas objeto de anos de desenvolvimento teórico e prático realizados por mentes brilhantes, em diferentes momentos da história, que culminaram nesta legislação aplicada hoje na maioria das democracias do mundo conhecido como o **princípio da Separação de Poderes**.

Trata-se de um princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro que o legislador constituinte originário consagrou, na Carta Política de 1988, expressamente como **cláusula pétrea** no artigo 60, § 4º, III, que estabelece: “**Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] a separação de poderes**”.

A consagração da separação de poderes como **cláusula pétrea**, nos deixa evidenciada o tamanho da importância e do cuidado que o legislador constituinte originário teve ao estabelecer os fundamentos deste princípio na constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O Estado constitucional de Direito assenta-se na ideia de unidade, uma vez que, o poder estatal é uno e indivisível, havendo órgãos estatais, cujos agentes políticos têm a missão precípua de exercerem atos de soberania.

Assim, a Constituição Federal de 1988 atribuiu as funções estatais de soberania aos três tradicionais Poderes do Estado, a saber, **Legislativo, Executivo e Judiciário**. A estes órgãos, a Constituição Federal brindou com autoridade soberana do Estado, garantindo-lhes autonomia e independência, dentro de uma visão harmônica.

Com respeito à independência dos poderes consagrados pela Constituição Federal Brasileira, discorreu com grande autoridade José Afonso da Silva sobre o seu significado:

*“A independência dos poderes significa: (a) que a investidura e a permanência das pessoas num órgão do governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; (b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; (c) que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais; assim é que cabe ao Presidente da República prover e extinguir cargos públicos da Administração federal, bem como exonerar ou demitir seus ocupantes, enquanto é da competência do Congresso Nacional ou dos Tribunais prover os cargos dos respectivos serviços administrativos, exonerar ou demitir seus ocupantes; às Câmaras do Congresso e aos Tribunais compete elaborar os respectivos regimentos internos, em que se consubstanciam as regras de seu funcionamento, sua organização, direção e polícia, ao passo que o Chefe do Executivo incumbe a organização da Administração Pública, estabelecer seus regimentos e regulamentos. Agora, a independência e autonomia do Poder Judiciário se tornaram ainda mais pronunciadas, pois passou para a sua competência também a nomeação dos juízes e tomar outras providências referentes à sua estrutura e funcionamento, inclusive em matéria orçamentária (arts. 95, 96, e 99)”.*⁷⁷

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=10678&n_link=revista_artigos_leitura - ftn9

Mais à frente, o grande mestre também discorreu sobre a harmonia entre os poderes:

“A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem a sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o dano de um em detrimento do outro e especialmente dos governados”.

Com a análise do texto constitucional podemos verificar que, apesar de os poderes do Estado ser **independentes e autônomos** devem também ser **harmônicos entre si**. Portanto não há que se falar em supremacia de um Poder em relação a outro Poder Estatal.

Os poderes, reunidos em órgãos, possuem funções estabelecidas pelo legislador constituinte originário, que as distribuiu de forma que cada um dos poderes tivesse características predominantes concernentes à sua esfera de atuação, sem, contudo, estabelecer exclusividade absoluta no exercício desses misteres. Prova disso, que a todo o momento, um Poder interpenetra-se na esfera de atribuição de outro por essa expressa determinação constitucional, a fim de que se aplique o **mecanismo de freios e contrapesos**, desenvolvido por Montesquieu, como o verdadeiro caracterizador da harmonia entre os poderes.

Dessa forma, haverá um mínimo e um máximo de independência de cada órgão de poder do Estado, sob pena de se comprometer o princípio da separação. Também deverá haver uma delimitação mínima e máxima de instrumentos que favoreçam o exercício harmônico dos poderes, sob pena de, inexistindo limites, um poder se sobrepor a outro.

As Constituições anteriores estabeleciam expressamente a vedação a qualquer dos poderes em delegar atribuições, e aqueles que fossem investidos em um deles não poderiam exercer a de outro, exceto se de acordo com as exceções nelas previstas. Hoje, estas especificações são desnecessárias, pois a Constituição estabelece incompatibilidades relativamente ao exercício das funções dos poderes, por exemplo, no artigo 54 da CF/88, em relação aos Deputados e Senadores. Assim sendo, não há afronta ao princípio da separação dos poderes quando o chefe do poder executivo federal elabora decretos autônomos, pois há uma previsão no texto constitucional, no artigo 84, IV.

⁷⁷ SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 110

Com relação à interpenetração de Poderes do Estado, podemos citar como exemplo a nomeação pelo Presidente da República dos juízes de instâncias superiores, bem como a atividade legislativa exercida através do instituto das Medidas Provisórias. Também vemos as atribuições judiciais do Poder Legislativo, quando este, julga o Presidente da República em crimes de responsabilidade, além das funções legislativas do Poder Judiciário, ao elaborar os regimentos internos de seus Tribunais e ao preencher as lacunas na Lei.

Por outro lado, só será admissível a interferência de um poder na esfera de atribuição de outro, em tese, quando para impedir abusos de poder, seja para propiciar a real harmonia entre os poderes ou ainda para garantir as liberdades e assegurar o pleno exercício das funções específicas. Não será, todavia, admitida, em hipótese alguma, a interferência de um poder diretamente sobre o outro. Por exemplo, o Presidente da República não pode interferir nos trabalhos legislativos para obter aprovação rápida de projetos de sua iniciativa, mas lhe é facultado solicitar urgência para a sua apreciação, conforme dispõe o art. 64 § 1º, sob pena de obstruir a pauta das votações das respectivas Casas Legislativas de acordo com o § 2º do mesmo artigo ambos da CF/88.



35 Da União.

Trata-se de pessoa jurídica de direito público interno. Não obstante, ela representa a pessoa jurídica de direito internacional República Federativa do Brasil. Somente ela tem esse poder de representação, as demais pessoas políticas não.

A União é autônoma em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, não se confundindo com a República Federativa do Brasil. Enquanto a República brasileira é o próprio Estado Federal, equivalendo à ordem jurídica total, a União é entidade integrante do todo, sendo uma ordem jurídica parcial, até mesmo em sua aceção externa.⁷⁸

No plano legislativo, edita tanto leis nacionais — que alcançam todos os habitantes do território nacional e outras esferas da Federação — como leis federais — que incidem sobre os jurisdicionados da União, como os servidores federais e o aparelho administrativo da União.

A União tem bens próprios, definidos na Constituição da República (art. 20). Para efeitos administrativos e visando ao desenvolvimento de regiões a redução das desigualdades regionais, o art. 43 da Constituição faculta criação de regiões, cada qual compreendendo um mesmo complexo geográfico e social.

CAPÍTULO II DA UNIÃO

Art. 20. São bens da União:

- I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;**
- II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;**
- III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;**
- IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto**

⁷⁸ BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 928.

aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;

- V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
- VI - o mar territorial;
- VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
- VIII - os potenciais de energia hidráulica;
- IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
- X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
- XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

Art. 21. Compete à União:

- I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
- II - declarar a guerra e celebrar a paz;
- III - assegurar a defesa nacional;
- IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
- VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
- VII - emitir moeda;
- VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;
- IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
- X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
- XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
- XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
 - a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;
 - b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
 - c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
 - d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
 - e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
 - f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
- XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)
- XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
- XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
- XVII - conceder anistia;
- XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

- XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
- XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
- XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
- XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
- a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
- b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
- c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
- d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
- XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
- XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

- I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
- II - desapropriação;
- III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
- IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
- V - serviço postal;
- VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
- VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
- VIII - comércio exterior e interestadual;
- IX - diretrizes da política nacional de transportes;
- X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
- XI - trânsito e transporte;
- XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
- XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
- XIV - populações indígenas;
- XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
- XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
- XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)
- XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
- XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
- XX - sistemas de consórcios e sorteios;
- XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
- XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
- XXIII - seguridade social;
- XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
- XXV - registros públicos;
- XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
- XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de

economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

§ 1º - Lei complementar disporá sobre:

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.



36 Estado-membro; poder constituinte estadual: autonomia e limitações.

O art. 1º da Constituição Federal destaca que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Por sua vez, o art. 18 da Lei Maior, que trata da organização político-administrativa, dispõe que a República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo todos autônomos.

Assim, os entes federados são pessoas jurídicas de direito público interno que integram o Estado Federal. Em outras palavras, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios compõem o Estado Federal.

Aqui, cabe destacar que soberania pode ser entendida como uma autodeterminação plena conferida ao Estado Federal que o coloca em posição de coordenação com os demais integrantes do cenário internacional.

A autonomia constitui a capacidade para desenvolver atividades dentro de limites previamente estabelecidos pelo ente soberano. Caracteriza-se pela existência da capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração dos entes federados, observadas as restrições impostas pela Constituição Federal.

O Estado Federal é o único detentor da soberania, de forma que os entes federados possuem apenas autonomia. Paulo Gustavo Gonet Branco ensina que **“a soberania, no federalismo, é atributo do Estado Federal como um todo. Os Estados-membros dispõem de outra característica – a característica da autonomia, que não se confunde com o conceito de soberania”**.

Ainda, merece destaque o ensinamento de José Afonso da Silva:

“No Estado federal há que se distinguir soberania e autonomia e seus respectivos titulares. Houve muita discussão sobre a natureza jurídica do Estado federal, mas, hoje, já está definido que o Estado federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo Direito internacional, é o único titular da soberania, considerada poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. Os Estados federados são titulares tão-só de autonomia, compreendida como governo próprio dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição Federal”⁷⁹.

Cabe salientar que a União, em que pese constituir ente federativo autônomo, exerce as prerrogativas de soberania do Estado Federal brasileiro, como destaca Alexandre de Moraes:

A União é entidade federativa autônoma em relação aos Estados-membros e municípios, constituindo pessoa jurídica de Direito Público Interno, cabendo-lhe exercer as atribuições da soberania do Estado brasileiro. Não se confundindo com o Estado Federal, este sim pessoa

⁷⁹ SILVA, 2005, p. 100.

*jurídica de Direito Internacional e formado pelo conjunto de União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Ressalte-se, porém, que a União poderá agir em nome próprio, ou em nome de toda Federação, quando, neste último caso, relaciona-se internacionalmente com os demais países.*⁸⁰

Como dito, a autonomia consiste na capacidade de **auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração** dos entes federados, observadas as restrições impostas pela Constituição Federal.

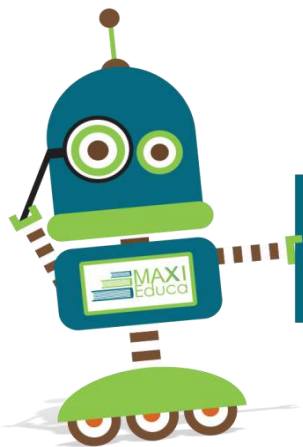
A **auto-organização** permite que os entes federados se organizem, na forma do poder constituinte decorrente, por meio da edição de Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. Assim, eles se auto-organizam, mas sempre dentro dos limites impostos pela Constituição Federal, que representa a norma suprema do ordenamento jurídico.

A **autolegislação** garante que os entes federados exerçam, por meio de seu Poder Legislativo, as competências a ele atribuídas. Assim, podem adotar suas próprias leis, desde que observados os princípios e normas basilares da Constituição Federal.

O **autogoverno** permite que os entes federados possuam representantes eleitos diretamente, sem qualquer ingerência ou vínculo de subordinação entre si. Desse modo, cada Estado possui Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, sendo que inexistente vinculação hierárquica em relação à União ou aos outros Estados-membros. Os Municípios, por sua vez, elegem seus representantes dos Poderes Executivo e Legislativo. Não possuem, contudo, um Poder Judiciário próprio.

A **auto-administração** assegura aos entes estatais a capacidade de organizar sua própria Administração Pública, seus serviços públicos e seu quadro de servidores públicos, com base nas competências administrativas, legislativas e tributárias definidas na Constituição. Essa capacidade de auto-administração deve ser assegurada pela previsão de um mínimo de rendas próprias, a fim de o ente não dependa inteiramente de repasse de verbas, o que ensejaria, inclusive, uma forma de indevida intervenção.

Por seu turno, o **princípio da indissolubilidade do vínculo federativo** veda qualquer pretensão de separação dos entes federados. Ou seja, não existe a possibilidade de direito de secessão, sendo observado que os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – ocupam o mesmo patamar hierárquico, com igualdade entre eles impondo um tratamento igualitário.



37 Estado-membro: competência e autonomia.

Os Estados têm governo próprio, desempenhando as funções dos três poderes estatais — Executivo, Legislativo e Judiciário. A Constituição da República também lhes adjudica bens próprios (art. 26). No âmbito da competência legislativa dos Estados, eles editam as normas e as executam com autonomia. Os governadores são as autoridades executivas máximas e a Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo. A Constituição da República disciplina, com alguma minúcia, tanto as eleições para ambos os poderes, o seu funcionamento, bem como aspectos de remuneração dos seus titulares (arts. 27 e 28 da CF/88).

De acordo com o disposto no art. 25 da CF/88 os Estados-membros organizam-se e se regem pelas Constituições e leis que adotarem, além dos princípios estabelecidos na CF/88. Os Estados-membros

⁸⁰ MORAES, 2005, p. 248.

possuem competência residual, vez que as competências e atribuições da União encontram-se expressas na Constituição e a dos Municípios encontram-se associadas aos interesses locais. Assim, a “residualidade” indica que não havendo atribuição expressa da União ou não se tratando de interesse local, a competência será dos Estados-membros. Os Estados-membros são reconhecidos como entes federativos autônomos.

Diz que lei regulará a iniciativa popular no processo legislativo local e estende aos deputados estaduais as normas de inviolabilidade e imunidade atinentes aos parlamentares no Congresso Nacional.

Os Estados-membros possuem as seguintes prerrogativas:

a) **Autonomia:** pode ser definida como a condição “de gerir os negócios próprios dentro de limites fixados por poder superior”. A autonomia dos Estados federados se consubstancia na sua capacidade de autogoverno, auto-organização, autolegislação, autoadministração, autonomia tributária, financeira e orçamentária. A matéria que for entregue à União deve ser respeitada pelos Estados, que não podem se recusar a aceitar as determinações da União sobre os assuntos de sua competência constitucional. Por tal razão os Estados membros não são soberanos, mas apenas autônomos.

b) **Auto-organização:** derivada do Poder Constituinte Decorrente, com lastro no qual são promulgadas as Constituições Estaduais (a auto-organização se manifesta pela Constituição Estadual, que estabelece a estruturação das funções estatais no Estado-membro). Os Estados possuem um ordenamento autônomo misto, observa Raul Machado Horta, “**parcialmente derivado e parcialmente originário.**” A organização dos Estados é estabelecida pela própria Constituição, observados os limites estabelecidos pela Constituição da República. O STF adota o princípio da simetria, utilizado pela Corte para garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três planos federativos. Ela está consagrada no caput do art. 25, segundo o qual “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”. Os referidos princípios são:

- **Princípios constitucionais sensíveis** – assim denominados, pois sua inobservância pelos Estados no exercício de suas competências legislativas, administrativas ou tributárias, pode acarretar a sanção politicamente mais grave existente em um Estado Federal, a intervenção na autonomia política. Estão previstos no art. 34, VII da CR, sendo eles:

1. Forma republicana, sistema representativo e democrático;
2. Prestação de contas pela Administração Direta e Indireta;
3. Direitos da pessoa humana;
4. Autonomia municipal;
5. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

- **Princípios federais extensíveis** – são normas centrais comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto de observância obrigatória no poder de organização do Estado. A Constituição vigente, em prestígio do federalismo, praticamente eliminou estes princípios, restando apenas a regra segundo a qual os vencimentos dos Ministros do STF é o teto geral para todas as remunerações no serviço público.

- **Princípios constitucionais estabelecidos, indicativos ou expressos** – consistem em determinadas normas que se encontram espalhadas pelo texto da Constituição, e, além de organizarem a própria federação, estabelecem preceitos centrais de observância obrigatória aos Estados-membros em sua auto-organização. Subdividem-se em normas de competência (ex.: arts. 23; 24; 25 etc.) e normas de preordenação (ex.: arts. 27; 28; 37, I a XXI etc.). Segundo Raul Machado Horta, são os que limitam a autonomia organizatória dos Estados. Exemplo: preceitos constantes dos arts. 37 a 41, referentes à administração pública.

- **Cláusulas pétreas** – evidentemente que os Estados também têm que observar as cláusulas pétreas da Constituição da República.

c) **Autolegislação:** os Estados são regidos por leis próprias (CF, art.25), elaboradas segundo o processo legislativo estabelecido em suas Constituições. Em que pese o Poder Legislativo nos Estados

ser unicameral, os princípios básicos do processo legislativo federal são normas de reprodução obrigatória, cujo modelo deve ser seguido pelas Constituições Estaduais.

d) **Autogoverno:** refere-se à autonomia do Estado em eleger seus representantes, tanto do Legislativo quanto do Executivo. O Poder Legislativo estadual é unicameral, formado por Assembleia Legislativa composta de deputados eleitos para mandatos de 04 anos, pelo sistema proporcional. O número de deputados estaduais é calculado com base no número de deputados federais (36 + nº de deputados federais – 12).

É obrigatória a existência de iniciativa popular de lei no processo legislativo estadual. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na Administração Pública, ressalvada a posse em concurso público, hipótese em que ficará afastado do cargo efetivo enquanto durar o mandato, contando-se o tempo de serviço para todos os fins legais. Os subsídios dos deputados estaduais (art. 27, § 2º. 75% dos DF), governador e vice e secretários (art. 28, § 2º) é fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa.

O subsídio do governador será o limite remuneratório de todo o Poder Executivo Estadual, exceto para os procuradores (inclusive os autárquicos) e defensores públicos, que será de 90,25% do que percebem os Ministros do STF (art. 37, XI).

De acordo com o STF, não se aplica a vedação de recondução ao mesmo cargo na mesma legislatura, na Mesa da AL. É vedação opcional na Constituição Estadual, diferentemente do que ocorre no legislativo nacional.

e) **Autoadministração:** a autoadministração refere-se às competências não legislativas próprias. A competência administrativa dos estados é residual, sendo-lhes reservado tudo o que não seja vedado na CR/88. Os Estados podem criar, mediante lei complementar, regiões metropolitanas (Municípios limítrofes com continuidade urbana que se reúnem em torno de um município-polo); aglomerações urbanas (áreas urbanas de municípios limítrofes sem um polo); microrregiões (municípios limítrofes com características homogêneas não ligadas por continuidade urbana). Ademais, têm a competência residual de explorar os serviços locais de gás canalizado.

Incluem-se entre os bens dos Estados:

- As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
- As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
- As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
- As terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Observações gerais:

- O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

- Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

- A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente.

- Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público.

CAPÍTULO III DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

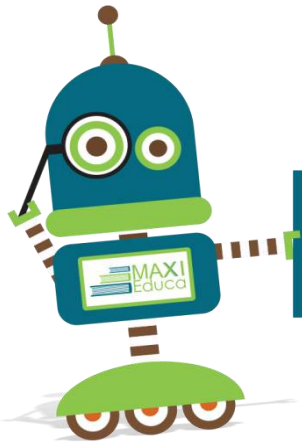
§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.



38 Administração Pública: princípios constitucionais.

É a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados, sob o regime de Direito Público, destinada a atender de modo direto e imediato, necessidades concretas da coletividade. É todo o aparelhamento do Estado para a prestação dos serviços públicos, para a gestão dos bens públicos e dos interesses da comunidade.

A Administração Pública direta e indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Características:

- praticar atos tão somente de execução – estes atos são denominados atos administrativos; quem pratica estes atos são os órgãos e seus agentes, que são sempre públicos;
- exercer atividade politicamente neutra - sua atividade é vinculada à Lei e não à Política;
- ter conduta hierarquizada – dever de obediência - escalona os poderes administrativos do mais alto escalão até a mais humilde das funções;
- praticar atos com responsabilidade técnica e legal – busca a perfeição técnica de seus atos, que devem ser tecnicamente perfeitos e segundo os preceitos legais;
- caráter instrumental – a Administração Pública é um instrumento para o Estado conseguir seus objetivos. A Administração serve ao Estado.
- competência limitada – o poder de decisão e de comando de cada área da Administração Pública é delimitada pela área de atuação de cada órgão.

Disposições gerais.

Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Em outras palavras, administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta.

A Administração Pública direta se constitui dos serviços prestados da estrutura administrativa da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Já, a Administração Pública indireta compreende os serviços prestados pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Podemos definir a Administração Pública como a atividade mediante a qual as autoridades públicas tomam providências para a satisfação das necessidades de **interesse público**, utilizando, quando necessário, as prerrogativas do Poder Público, para alcançar os fins que não sejam os próprios à legislação ou à distribuição da justiça.

Sobre Administração Pública, o professor José Afonso da Silva assim explica: “...É o conjunto de meios institucionais, material, financeiro e humano preordenado à execução das decisões políticas. Essa é uma noção simples de Administração Pública que destaca, em primeiro lugar, que é subordinada ao Poder político; em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo de que se serve para atingir fins definidos e, em terceiro lugar, denota os dois aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do Poder político e as operações, as atividades administrativas” (*in* Curso de Direito Constitucional Positivo).

Por sua vez, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, mas irradia sua força normativa para os demais entes da federação, traz uma série de princípios administrativos no seu

art. 2º, senão vejamos: **Art. 2º “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.**

Princípio da supremacia do interesse público

Este princípio consiste na sobreposição do interesse público em face do interesse particular. Havendo conflito entre o interesse público e o interesse particular, aquele prevalecerá.

Podemos conceituar interesse público como o somatório dos interesses individuais desde que represente o interesse majoritário, ou seja, a vontade da maioria da sociedade.

O interesse público primário é o interesse direto do povo, é o interesse da coletividade como um todo. Já o interesse público secundário é o interesse direto do estado como pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações, em suma, é vontade do estado. Assim, a vontade do povo (interesse público primário) e a vontade do estado (interesse público secundário) não se confundem.

O interesse público secundário só será legítimo se não contrariar nenhum interesse público primário. E, ao menos indiretamente, possibilite a concretização da realização de interesse público primário. Daremos um exemplo para que você compreenda perfeitamente esta distinção.

Este princípio é um dos dois pilares do denominado regime jurídico-administrativo, fundamentando a existência das prerrogativas e dos poderes especiais conferidos à administração pública para que esta esteja apta a atingir os fins que lhe são impostos pela constituição e pelas leis.

O ordenamento jurídico determina que o estado-administração atinja uma gama de objetivos e fins e lhe confere meios, instrumentos para alcançar tais metas. Aqui se encaixa o princípio da supremacia do interesse público, fornecendo à administração as prerrogativas e os poderes especiais para obtenção dos fins estabelecidos na lei.

O princípio comentado não está expresso em nosso ordenamento jurídico. Nenhum artigo de lei fala, dele, porém tal princípio encontra-se em diversos institutos do direito Administrativo. Vejamos alguns exemplos práticos:

- a nossa Constituição garante o direito à propriedade (art. 5º, XXII), mas com base no princípio da Supremacia do Interesse Público, a Administração pode, por exemplo, desapropriar uma propriedade, requisitá-la ou promover o seu tombamento, suprimindo ou restringindo o direito à propriedade.

- a Administração e o particular podem celebrar contratos administrativos, mas esses contratos preveem uma série de cláusulas exorbitantes que possibilitam a Administração, por exemplo, modificar ou rescindir unilateralmente tal contrato.

- o poder de polícia administrativa que confere à Administração Pública a possibilidade, por exemplo, de determinar a proibição de venda de bebida alcoólica a partir de determinada hora da noite com o objetivo de diminuir a violência.

Diante de inúmeros abusos, ilegalidades e arbitrariedades cometidas em nome do aludido princípio, já existem vozes na doutrina proclamando a necessidade de se por fim a este, através da **Teoria da Desconstrução do Princípio da Supremacia**. Na verdade, esvaziar tal princípio não resolverá o problema da falta de probidade de nossos homens públicos. Como afirma a maioria da doutrina, o princípio da Supremacia do Interesse Público é essencial, sendo um dos pilares da Administração, devendo ser aplicado de forma correta e efetiva. Se há desvio na sua aplicação, o Poder Judiciário deve ser provocado para corrigi-lo.

Princípio da indisponibilidade do interesse público

Este princípio é o segundo pilar do regime jurídico-administrativo, funcionando como contrapeso ao princípio da Supremacia do Interesse Público.

Ao mesmo tempo em que a Administração tem prerrogativas e poderes exorbitantes para atingir seus fins determinados em lei, ela sofre restrições, limitações que não existem para o particular. Essas limitações decorrem do fato de que a Administração Pública não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do interesse público, mas sim, mera gestora de bens e interesses alheios que pertencem ao povo.

Em decorrência deste princípio, a Administração somente pode atuar pautada em lei. A Administração somente poderá agir quando houver lei autorizando ou determinando a sua atuação. A atuação da Administração deve, então, atender o estabelecido em lei, único instrumento capaz de retratar o que seja interesse público. Assim, o princípio da Indisponibilidade do Interesse Público tem estreita relação com o princípio da Legalidade, sendo que alguns autores utilizam essas expressões como sinônimas.

Este princípio também se encontra **implícito** em nosso ordenamento, surgindo sempre que estiver em jogo o interesse público. Exemplos da utilização deste princípio na prática:

- os bens públicos não são alienados como os particulares, havendo uma série de restrições a sua venda.
- em regra, a Administração não pode contratar sem prévia licitação, por estar em jogo o interesse público.
- necessidade de realização de concurso público para admissão de cargo permanente.

É importante frisar a Administração Pública deverá se pautar nos cinco princípios estabelecidos pelo “caput” do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os princípios são os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Princípio da legalidade

O **princípio da legalidade**, um dos mais importantes princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permite. É importante demonstrar a diferenciação entre o princípio da legalidade estabelecido ao administrado e ao administrador. Como já explicitado para o administrador, o princípio da legalidade estabelece que ele somente poderá agir dentro dos parâmetros legais, conforme os ditames estabelecidos pela lei. Já, o princípio da legalidade visto sob a ótica do administrado, explicita que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude lei. Esta interpretação encontra abalamento no artigo 5º, II, da Constituição Federal de 1988.

Princípio da impessoalidade

Posteriormente, o artigo 37 da CF/88 estabelece que deverá ser obedecido o **princípio da impessoalidade**. Este princípio estabelece que a Administração Pública, através de seus órgãos, não poderá, na execução das atividades, estabelecer diferenças ou privilégios, uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular. De acordo com os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da impessoalidade estaria intimamente relacionado com a finalidade pública. De acordo com a autora “a Administração não pode atuar com vista a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que deve nortear o seu comportamento”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas, 2005).

Em interessante constatação, se todos são iguais perante a lei (art. 5º, *caput*) necessariamente o serão perante a Administração, que deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando a todos de modo igual, ou quando necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar à igualdade real e material.

Nesse sentido podemos destacar como um exemplo decorrente deste princípio a regra do concurso público, onde a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Princípio da moralidade administrativa

A Administração Pública, de acordo com o princípio da **moralidade administrativa**, deve agir com boa-fé, sinceridade, probidade, lealdade e ética. Tal princípio acarreta a obrigação ao administrador público de observar não somente a lei que condiciona sua atuação, mas também, regras éticas extraídas dos padrões de comportamento designados como moralidade administrativa (obediência à lei).

Não basta ao administrador ser apenas legal, deve também, ser honesto tendo como finalidade o bem comum. Para Maurice Hauriou, o princípio da moralidade administrativa significa um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração.

Trata-se de probidade administrativa, que é a forma de moralidade. Tal preceito mereceu especial atenção no texto vigente constitucional (§ 4º do artigo 37 CF), que pune o ímprobo (pessoa não correto - desonesta) com a suspensão de direitos políticos.

Por fim, devemos entender que a moralidade como também a probidade administrativa consistem exclusivamente no dever de funcionários públicos exercerem (prestarem seus serviços) suas funções com honestidade. Não devem aproveitar os poderes do cargo ou função para proveito pessoal ou para favorecimento de outrem.

Princípio da publicidade

O **princípio da publicidade** tem por objetivo a divulgação de atos praticados pela Administração Pública, obedecendo, todavia, as questões sigilosas. De acordo com as lições do eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles, “o princípio da publicidade dos atos e contratos administrativos, além de assegurar seus efeitos externos, visa a propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados e pelo povo em geral, através dos meios constitucionais...”. (MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2005).

Complementando o princípio da publicidade, o art. 5º, XXXIII, garante a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, matéria essa regulamentada pela **Lei nº 12.527/2011** (Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências).

Os remédios constitucionais do *habeas data* e mandado de segurança cumprem importante papel enquanto garantias de concretização da transparência.

Princípio da eficiência

Por derradeiro, o último princípio a ser abarcado pelo artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é o **da eficiência**.

Se, na iniciativa privada, se busca a excelência e a efetividade, na administração outro não poderia ser o caminho, enaltecido pela EC n. 19/98, que fixou a eficiência também para a Administração Pública.

De acordo com os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o princípio da eficiência “impõe a todo agente público realizar as atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”. (MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2005).

Outrossim, DI PIETRO explicita que o princípio da eficiência possui dois aspectos: “o primeiro pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados, e o segundo, em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas, 2005).

CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,

condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal."

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.



39 Servidores públicos: princípios constitucionais.

Podemos considerar de forma geral que servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ou ainda, é uma definição a todo aquele que mantém um vínculo empregatício com o Estado, e seu pagamento provém da arrecadação pública de impostos, sendo sua atividade chamada de "Típica de Estado", geralmente é originário de concurso público, pois é defensor do setor público, que é diferente da atividade do Político, detentor de um mandato público, que está diretamente ligado ao Governo e não necessariamente ao Estado de Direito, sendo sua atribuição a defesa do Estado de Direito, principalmente contra a Corrupção Política ou Governamental de um eleito, que costuma destruir o Estado (Historicamente); um Estado corrompido demonstra geralmente que essa função, cargo ou serventia não funciona adequadamente.

Antes do estudo do capítulo específico da CF/88 a respeito dos servidores públicos, necessário é o conhecimento de alguns dispositivos aplicáveis aos servidores em geral, previstos no artigo 37, conforme abaixo disposto:

CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Seção I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Súmula vinculante 42-STF: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Com base nesse parâmetro foi promulgada a Lei nº 8.112/90, que demarcou a opção da União pelo regime estatutário, no qual os servidores são admitidos sob regime de Direito Público, podem alcançar estabilidade e possuem direitos e deveres estabelecidos por lei (e que podem, portanto, ser alterados unilateralmente pelo Estado-Legislador).

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Significa dizer que quanto maior o grau de dificuldade, tanto para ingressar no cargo, quanto para desenvolver as funções inerentes a ele, melhor deverá ser a remuneração correspondente.

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

Essas escolas possuem como objetivo a atualização e a formação dos servidores públicos, melhorando os níveis de desempenho e eficiência dos ocupantes de cargos e funções do serviço público, estimulando e promovendo a especialização profissional, preparando servidores para o exercício de funções superiores e para a intervenção ativa nos projetos voltados para a elevação constante dos padrões de eficácia e eficiência do setor público.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Vamos conferir o que diz os referidos incisos, do artigo 7º da Constituição Federal:

- Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

- Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

- Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

- Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

- Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

- Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

- Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

- Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

- Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

- Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

- Licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

- Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que compreende o padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação estatutária.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

O inciso XI do artigo 37 da Constituição refere-se aos tetos remuneratórios, quais sejam:

- Teto máximo: Subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- Teto nos municípios: O subsídio do Prefeito;
- Teto nos Estados e no Distrito Federal: O subsídio mensal do Governador;
- Teto no âmbito do Poder Executivo: O subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo;
- Teto no judiciário: O subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

Esses cursos são importantes para obter o envolvimento e o comprometimento de todos os agentes públicos com a qualidade e produtividade, quaisquer que sejam os cargos, funções ou empregos ocupados, minimizar os desperdícios e os erros, inovar nas maneiras de atender as necessidades do cidadão, simplificar procedimentos, inclusive de gestão, e proceder às transformações essenciais à qualidade com produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

Ou seja, por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, os tetos remuneratórios dispostos no art. 37, X da Constituição Federal.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

Para o regime previdenciário ter equilíbrio financeiro, basta ter no exercício atual um fluxo de caixa de entrada superior ao fluxo de caixa de saída, gerado basicamente quando as receitas previdenciárias superam as despesas com pagamento de benefícios.

Já para se ter equilíbrio atuarial, deve estar assegurado que o plano de custeio gera receitas não só atuais, como também futuras e contínuas por tempo indeterminado, em um montante suficiente para cobrir as respectivas despesas previdenciárias.

Para se manter o equilíbrio financeiro e atuarial é imprescindível que o regime mantenha um fundo previdenciário que capitalize as sobras de caixa atuais que garantirão o pagamento de benefícios futuros.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



*Nos termos do art. 100 dos ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015, até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, **os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União** aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.*

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I- portadores de deficiência;

II- que exerçam atividades de risco;

III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A redução só é permitida nos casos em que o tempo de contribuição é exclusivamente no magistério. Ou seja, não é possível somar o tempo de magistério com o tempo em outra atividade e ainda reduzir 5 (cinco) anos. A soma é possível, no entanto, sem a redução de 5 (cinco) anos.

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.

Os **cargos acumuláveis** são: **Dois de professor; um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.**

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O valor real refere-se ao poder aquisitivo, em outros termos, se no início do recebimento do benefício, o beneficiário conseguia suprir suas necessidades com alimentação, saúde, lazer, educação... Após alguns anos, o mesmo benefício deveria, em tese, propiciar o mesmo poder aquisitivo.

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituíam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.

A Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras providências.

O Sistema Brasileiro de Previdência é formado por um tripé com três regimes previdenciários: a) o Regime Geral, a cargo do INSS, b) o Regime Próprio dos servidores, de responsabilidade do Tesouro, e c) o Regime Complementar.

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), é público e de caráter obrigatório para todos os trabalhadores do setor privado e servidores públicos contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). De amplitude nacional e caráter contributivo, possui teto de contribuição e de benefício. Oferta plano de benefício definido, o regime financeiro é de repartição simples e faz parte do sistema de Seguridade Social, que também custeia as despesas com Saúde e Assistência Social.

Os Regimes Próprios dos Servidores Públicos, de responsabilidade dos respectivos tesouros (União, Estados e Municípios), são públicos e de caráter obrigatório para os detentores de cargo efetivo, no caso dos servidores civis, e para os servidores militares, no caso das Forças Armadas. Os planos ofertados são de benefício definido e, para os servidores civis, passará a ter teto de contribuição e de benefício a partir da instituição do fundo de pensão (Funpresp), que será igual ou o mesmo do INSS ou do RGPS. Faz parte do orçamento fiscal e o regime financeiro é de repartição simples.

O Regime de Previdência Complementar é privado, possui caráter facultativo (voluntário), se organiza sob a forma de entidade aberta (bancos e seguradoras) e entidade fechada (fundo de pensão). É autônomo em relação à Previdência Social oficial e se baseia na constituição de reservas (poupança). Seu regime financeiro, portanto, é o de capitalização.

Com a criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), o valor das aposentadorias e pensões no serviço público civil deixará de ser integral ou de ter por base de cálculo a totalidade da remuneração, e ficará limitado ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), atualmente fixado em R\$ R\$ 4.663,75 (**janeiro de 2015**). E para fazer jus a esse benefício

limitado ao teto, o servidor contribuirá com 11% até esse limite. Essa regra valerá, obrigatoriamente, para todos os servidores que ingressarem no serviço público após a instituição do fundo. Isto valerá, porém para os servidores admitidos após a criação do fundo. Eles serão segurados obrigatórios do Regime Próprio do servidor somente até o teto do INSS. Acima disto poderão aderir à Previdência Complementar, filiando-se à Funpresp.

Ele contribuirá para o Regime Próprio, até o teto do Regime Geral ou do INSS, no percentual de 11%, e acima disto contribuirá com o percentual que desejar para o Fundo de Pensão dos Servidores. O governo, contribui com o mesmo percentual do servidor até o limite de 8,5%. Ou seja, se o servidor contribuir com menos, 5% por exemplo, a contribuição do governo será paritária. Se, entretanto, o servidor resolver contribuir com 12%, o governo para nos 8,5%. Dizendo de outra forma, se for para contribuir com menos de 8,5%, o governo acompanha. Se for para contribuir com mais, o Executivo para nos 8,5%.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Referido instituto corresponde à proteção ao ocupante do cargo, garantindo, não de forma absoluta, a permanência no Serviço Público, o que permite a execução regular de suas atividades, visando exclusivamente o alcance do interesse coletivo.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Reintegração é o instituto jurídico que ocorre quando o servidor retorna a seu cargo após ter sido reconhecida a ilegalidade de sua demissão.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

A disponibilidade é um instituto que permite ao servidor estável, que teve o seu cargo extinto ou declarado desnecessário, permanecer sem trabalhar, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, à espera de um eventual aproveitamento.

Desde já, cumpre-nos ressaltar: o servidor estável que teve seu cargo extinto ou declarado desnecessário não será nem exonerado, nem, muito menos, demitido. Será ele posto em disponibilidade!

Segundo a doutrina majoritária, o instituto da disponibilidade não protege o servidor não estável quanto a uma possível extinção de seu cargo ou declaração de desnecessidade. Caso o servidor não tenha, ainda, adquirido estabilidade, será ele exonerado *ex-officio*.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta de Gestão de Pessoas que corresponde a uma análise sistemática do desempenho do profissional em função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial de desenvolvimento.

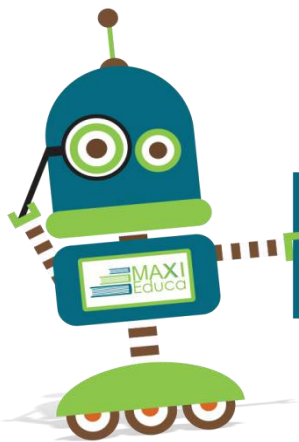
Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

Súmula vinculante 39-STF: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.



40 Poder Legislativo: organização; atribuições; processo legislativo.

O Poder Legislativo, segundo o art. 44 da Constituição Federal de 1988, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É o Poder que mais se sobressai na estrutura de Poderes, já que é a ele que compete inovar o Direito, além de ser onde o povo, teoricamente, manifesta indiretamente a sua vontade.

O Poder Legislativo federal tem estrutura bicameral. O bicameralismo é uma característica da federação, pois é necessária a instalação de um **órgão representativo dos Estados**. Apesar de ser uma característica da federação, nem sempre é o reflexo de um federalismo. Ex.: Inglaterra (Estado Unitário) – câmara dos lordes e câmara dos comuns.

Deve ser lembrado que é da tradição constitucional brasileira a organização do Poder Legislativo em dois ramos, sistema denominado bicameralismo, que vem desde o Império, salvo as limitações contidas nas Constituições de 1934 e 1937, que tenderam para o unicameralismo, sistema segundo o qual o Poder Legislativo é exercido por uma única câmara. Tem-se o bicameralismo como um sistema mais propício ao conservadorismo, enquanto o unicameralismo favoreceria os avanços democráticos, na medida em que canaliza e exprime melhor os anseios da soberania popular por transformações.

A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. São 513 Deputados Federais, com mandato de quatro anos. O número de Deputados é proporcional à população do estado ou do Distrito Federal, com o limite mínimo de oito e máximo de setenta Deputados para cada um deles.

Para o Senado Federal, cada estado e o Distrito Federal elegem três Senadores, com mandato de oito anos, renovados de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. A composição do Senado Federal é de 81 Senadores.

Dentre as competências do Congresso Nacional, temos:

- a) atribuições relacionadas às funções do Poder Legislativo federal;
- b) atribuições das Casas do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), quando atuam separadamente; e
- c) atribuições relacionadas ao funcionamento de comissões mistas e de sessões conjuntas, nas quais atuam juntos os Deputados Federais e os Senadores (embora votem separadamente).

O Poder Legislativo, porém, de modo não típico, também exerce funções de administrar (ao prover cargos da sua estrutura ou atuar o poder de polícia, p. ex.) e de julgar (o Senado processa e julga, por crimes de responsabilidade, o Presidente da República e o Vice-Presidente da República, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes das três Forças Armadas, nos crimes de mesma natureza conexos com os praticados pelo Chefe do Executivo; também processa e julga, por crimes de responsabilidade, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros dos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União).

Órgãos

São órgãos do Congresso Nacional:

a) **Mesa diretora:** órgão responsável pelas questões meramente administrativas e pela condução dos trabalhos legislativos que se desenvolvem em cada Casa. A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado Federal. Os membros da mesa são eleitos para mandato de 02 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo no período subsequente, **dentro de uma mesma legislatura**. Essa proibição de recondução não é aplicável obrigatoriamente para os outros entes, salvo se eles o previrem em suas leis fundamentais.

Sua composição deverá obedecer, tanto quanto possível, à representatividade partidária na Casa. O Presidente do Senado Federal presidirá a Mesa do Congresso Nacional; os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (art. 57, § 5º).

b) **Comissões:** são órgãos colegiados que subsidiam os trabalhos das Casas por meio do estudo, análise e emissão de pareceres sobre os projetos em trâmite. Elas também auxiliam as deliberações plenárias, realizam audiências públicas convocam Ministros de Estado para prestar informações pertinentes, solicitam depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. As comissões podem ser permanentes, perpetuando-se pelas legislaturas, ou temporárias, criadas por prazo certo e para fim específico.

As Comissões podem discutir e votar projeto de lei que dispense, na forma regimental, a competência do Plenário. Trata-se do chamado procedimento legislativo abreviado, ou **deliberação conclusiva**. Abre-se, porém, a possibilidade de 1/10 dos membros da Casa provocar a atuação do Plenário, por meio de recurso, a fim de que seja o projeto afetado à apreciação deste órgão. **É possível, portanto, que um projeto de lei seja aprovado sem jamais haver sido apreciado pelo Plenário, quer da Câmara, quer do Senado.**

c) **Plenário:** é o órgão de deliberação máxima da Casa Legislativa, composto por todos os parlamentares que a integram. Assim, tanto a Câmara quanto o Senado tem seu Plenário.

Funcionamento

Os trabalhos do Congresso Nacional se desenvolvem ao longo da **legislatura**, que compreende o período de quatro anos (art. 44, parágrafo único, da CF/88), coincidente com o mandato dos deputados federais. A legislatura é período relevante; o seu término, por exemplo, impede a continuidade das Comissões Parlamentares de Inquérito por acaso em curso.

As decisões no Congresso Nacional são tomadas por maioria simples de votos, a não ser que a **Constituição** disponha diferentemente em hipóteses específicas (art. 47). Como quórum para funcionamento, exige-se a presença da maioria absoluta dos membros. Portanto, há um quórum para a instalação da sessão e outro para a aprovação de uma proposta de deliberação. Maioria simples de votos significa o maior número de votos orientados para uma direção decisória. Maioria simples não equivale, necessariamente, à metade mais um dos votos dos presentes, pois pode não coincidir com um número inteiro. Nos casos em que há mais de dois sentidos possíveis de voto, ou havendo votos nulos ou em branco, pode-se configurar a maioria de votos sem atingir a marca numérica correspondente à maior grandeza numérica superior à metade dos votos dos presentes. **Veja-se que a Constituição não determina que se alcance a maioria de votos dos presentes, mas, apenas, que se tome a decisão "por maioria de votos"**. A deliberação coincidirá com a proposta que reunir maior contagem de votos.

Em regra, o Congresso Nacional atua por meio das duas Casas **em separado e em momentos independentes**. Há, entretanto, algumas exceções:

- a) **Sessões conjuntas:** hipóteses em que as Casas atuam em separado, mas ao mesmo tempo. Ocorrem nas seguintes hipóteses:
- Inauguração da sessão legislativa;
 - Recebimento do compromisso do Presidente e Vice;
 - Elaboração do regimento comum e na regulação de serviços comuns;
 - Conhecimento e deliberação sobre veto presidencial;
 - Discussão e votação da LOA;
 - Outros casos previstos na CF/88.
- b) **Sessões unicamerais:** hipótese em que ambas as Casas atuam como se uma fosse. Raríssima de acontecer, como no caso do processo de revisão constitucional.

Reuniões

Durante a legislatura ocorrem as sessões legislativas, que podem ser ordinárias, quando correspondem ao período normal de trabalho previsto na Constituição, ou extraordinárias, quando ocorrem no período de recesso do Congresso.

A sessão legislativa ordinária, por sua vez, é partida em dois períodos legislativos. O primeiro se estende de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão legislativa não se interrompe sem que se haja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Esse projeto, de seu turno, deve estar aprovado até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

Nos intervalos dos períodos mencionados, ocorrem os recessos. Nestes, o Congresso Nacional pode ser chamado a se reunir por **convocação extraordinária**, ocorrendo a chamada sessão legislativa extraordinária.

Sessões Extraordinárias

Podem ser convocadas pelo Presidente do Senado ou pelo Presidente da República, Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros de **ambas** as Casas.

O Presidente do Senado, que preside a Mesa do Congresso Nacional, convoca o Congresso Nacional extraordinariamente, nas seguintes situações (art. 57, § 6º, I):

- a) Para a decretação de estado de defesa, intervenção federal ou pedido de autorização para decretação de estado de sítio;
- b) Para o compromisso e posse do Presidente e do Vice-Presidente da República.

Já os outros membros, inclusive o Presidente do Senado, podem realizar convocações extraordinárias nas seguintes hipóteses (art. 57, § 6º, II):

- a) Em caso de urgência ou de interesse público relevante. A verificação da urgência e do interesse público relevante constitui aspecto incluído na margem de discricionariedade política de quem convoca, mas tal juízo passou a ter, com a EC n. 50/2006, de ser confirmado pela maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Somente a convocação feita pelo presidente do senado federal nos casos de posse da presidência da república e nos casos de emergência constitucional é que têm força, por si só, de instaurar a reunião extraordinária do congresso nacional, sem necessidade de ser confirmada pela maioria absoluta das casas.

A sessão legislativa extraordinária difere da ordinária não apenas pelas peculiaridades que marcam a sua instauração, como, igualmente, pelos assuntos que nela se tratam. O ato de convocação extraordinária deve declinar a matéria que motiva a convocação e **somente sobre ela e sobre medidas provisórias em vigor na data da convocação** — elas entram automaticamente na pauta — **é que poderá haver deliberação** (art. 57, § 7º e 8º).

A partir da Emenda Constitucional n. 50/2006, os congressistas e servidores viram-se proibidos de receber parcela indenizatória em decorrência da convocação. Assim, não recebem mais os chamados *Jetons*.

Atribuições do Congresso Nacional

Dentre as atribuições previstas para o Congresso Nacional, há as genéricas e as privativas. As privativas são aquelas exercidas mediante manifestação unilateral de vontade, por meio de Decreto Legislativo, em regra.

Atribuições Não Exclusivas

Ao Congresso Nacional cabe, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de interesse da União, especialmente sobre (hipóteses exemplificativas):

- I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
- VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
- VIII - concessão de anistia;
- IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
- X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
- XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
- XII - telecomunicações e radiodifusão;
- XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I

Importante notar que o *caput* do artigo se refere às matérias de interesse da União. Assim, o Congresso Nacional deve atuar, evidentemente, não somente no interesse nacional, mas também nos interesses específicos da pessoa jurídica União, ou seja, matérias estritamente federais.

Atribuições Exclusivas

Essas atribuições são exercidas mediante **decreto legislativo**, aprovados pelas duas casas por deliberação da maioria simples de ambas, conforme previsto no artigo 49 da CF/88:

- I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;**
- II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;**
- III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;**
- IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;**
- V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;**
- VI - mudar temporariamente sua sede;**
- VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;**
- VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;**
- IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;**
- X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;**
- XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;**
- XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;**
- XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;**
- XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;**

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

Câmara dos Deputados

A **Câmara dos Deputados** é a Casa dos representantes do povo, eleitos para mandato de 04 anos pelo **sistema proporcional** em cada Estado e no Distrito Federal. Seus membros podem ser reeleitos sucessivamente, sendo que **nenhum estado poderá ter menos de 8 e mais de 70 deputados**. Cada Território que vier a ser criado terá direito a 04 deputados federais na Câmara.

O membro da Câmara dos Deputados é o Deputado Federal, que exerce seu mandato por uma legislatura. Legislatura é diferente de mandato. A primeira tem duração de 4 anos e corresponde ao período que vai do início do mandato dos **membros da Câmara dos Deputados** até o seu término (art. 44, parágrafo único).

A CF/88 reserva à Lei Complementar a fixação do número total de Deputados, bem como a representação por Estado e DF, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições.

Art. 45 (...)

(...)

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

Atribuições da Câmara dos Deputados

Essas matérias serão reguladas por **Resolução**, a qual será promulgada pelo Presidente da Mesa, salvo a iniciativa de lei para a fixação da remuneração de seus servidores, evidentemente.

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

A necessidade de autorização da Câmara para processar Ministro de Estado só cabe se o crime for comum ou de responsabilidade, conexo com delito da mesma natureza praticado pelo Presidente ou Vice. Caso contrário, serão normalmente julgados no **STF**, pelo seu foro privilegiado, independentemente de autorização.

Já os crimes praticados por Presidente e Vice Presidente da República sempre precisarão de autorização da Câmara, sejam eles comuns ou de responsabilidade. A autorização pela Câmara para julgar o Presidente por crime de responsabilidade obriga o Senado a julgá-lo. Já a autorização ao STF para processá-lo por crime comum não obriga o STF a instaurar o processo.

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

III - elaborar seu regimento interno;

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

Essa iniciativa de lei para fixar o subsídio se refere somente aos cargos de sua estrutura, e não aos subsídios dos deputados, os quais serão fixados por decreto legislativo, conforme previsão do art. 49, VIII.

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Senado Federal

O **Senado Federal** é composto por três representantes de cada Estado e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema **majoritário simples** (ou seja, sem segundo turno), já que há somente um único turno de votação. O mandato dos senadores é de oito anos (logo, por duas legislaturas), permitidas reeleições sucessivas.

Cada Senador terá dois suplentes, sendo a composição do Senado Federal renovada de quatro em quatro anos, por um e dois terços de seus membros.

Atribuições do Senado Federal

Essas matérias serão reguladas por **Resolução**, a qual será promulgada pelo Presidente da Mesa, salvo a iniciativa de lei para a fixação da remuneração de seus servidores, evidentemente.

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Assim, vê-se que os Ministros de Estado e os Comandantes das Forças Armadas somente serão julgados pelo Senado Federal se praticarem crime conexo com os do Presidente ou Vice. Caso contrário, serão julgados pelo **STF**, sem necessidade de autorização.

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

Nos casos dos incisos I e II, será o presidente do supremo tribunal federal que presidirá a sessão; a condenação se dará pelo voto de 2/3 dos membros do senado, sendo a condenação limitada à perda do mandato e inabilitação para exercício de função pública por 8 anos, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

Essas aprovações revelam atos administrativos compostos, no qual o ato principal é praticado pelo Presidente da República e o ato homologatório (aprovação) é praticado pelo Senado Federal.

- a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;**
- b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;**
- c) Governador de Território;**
- d) Presidente e diretores do banco central;**
- e) Procurador-Geral da República;**
- f) titulares de outros cargos que a lei determinar;**

Essa disposição é importante, pois a Constituição confere à lei a possibilidade de determinar a submissão da escolha dos titulares de determinados cargos à aprovação do Senado, como ocorre com algumas agências reguladoras.

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

Essa suspensão ocorre quando o Supremo declara inconstitucional determinada lei no controle difuso, por recurso extraordinário.

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

XII - elaborar seu regimento interno;

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

O processo legislativo

Disposição geral

O processo legislativo compreende o conjunto de atos observados na proposta e na elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. A Lei Complementar n. 95/98, que regulamenta o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. É denominada “lei das leis”.

Existem três espécies de procedimentos legislativo, três modos diferentes para a elaboração de atos legislativos:

a) ordinário ou Comum: Destinados à elaboração de leis ordinárias.

b) sumário: Destinado à elaboração de leis ordinárias em regime de urgência.

c) especial: Destinados à elaboração e outras normas, como emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e leis financeiras (lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de orçamento anual e de abertura de créditos adicionais).

O processo legislativo **ordinário** é utilizado para a elaboração de leis ordinárias, ato legislativo típico. Esse processo compreende o seguinte conjunto de atos: **iniciativa** (legitimidade para apresentação de proposições legislativas); **emendas** (proposições apresentadas por parlamentares visando alterações no projeto de lei); **votação** ou **deliberação** (envolve três etapas distintas: discussão; votação; e aprovação ou rejeição); **sanção** (é a aquiescência do Presidente da República ao projeto de lei elaborado pelo Congresso Nacional e encaminhado para sua aprovação) ou **veto** (é a discordância do Presidente da República com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo e encaminhado para sua apreciação); **promulgação** (é o ato pelo qual se atesta a existência de uma lei; esta já existe antes de ser promulgada, mas seus efeitos dependem de posterior promulgação e publicação); e **publicação** (é a comunicação feita a todos, pelo Diário Oficial, da existência de uma nova lei, assim como de seu conteúdo).

Sobre o assunto:

É possível que haja emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa dos Poderes Executivo e Judiciário, desde que cumpram dois requisitos: a) guardem pertinência temática com a proposta original (tratem sobre o mesmo assunto); b) não acarretem em aumento de despesas. STF. Plenário. ADI 5087 MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2014 (Info 756). STF. Plenário. ADI 1333/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/10/2014 (Info 765).

A Constituição Federal prevê procedimentos especiais para a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, leis financeiras (seguem o procedimento previsto no art. 166 e seus parágrafos da Constituição Federal), decretos legislativos e resoluções.

Emendas à Constituição

O art. 60 da Constituição Federal dispõe poderá ser emendada mediante proposta:

- De um terço (1/3), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Do Presidente da República;
- De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros (maioria absoluta quanto ao número de Assembleias e maioria simples quanto aos seus membros).

A proposta de Emenda Constitucional é discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos em cada uma, considerando-se aprovada se obtiver, em todos esses turnos (quatro no total), três quintos (3/5) dos votos favoráveis dos respectivos membros (e não apenas dos presentes à sessão).

A Emenda Constitucional aprovada será promulgada (terá sua existência atestada) pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado Federal.

Dessa forma, as emendas constitucionais não estão sujeitas à sanção ou promulgação pelo Presidente da República.

A matéria constante de proposta de Emenda Constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa – ordinariamente fixada entre 15 de fevereiro e 15 de dezembro de cada ano. Não se aplica à Emenda Constitucional rejeitada ou tida por prejudicada, portanto, a regra prevista no art. 67 da Constituição Federal (que autoriza a reapresentação, na mesma sessão legislativa, de proposta de lei relativa à matéria rejeitada, desde que assinada por mais da metade de todos os membros de alguma das Casas).

A Constituição Federal não pode ser emendada na vigência de Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio (limitações circunstanciais).

Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir a forma federativa dos Estados; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais.

Das Leis Complementares e Ordinárias

A iniciativa das leis complementares e ordinárias, segundo o art. 61 da Constituição Federal, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal.

A Iniciativa (fase introdutória do processo legislativo) consiste na competência atribuída a alguém ou a algum órgão para apresentar projeto de lei ao Legislativo, podendo ser concorrente, privativa ou conjunta.

Algumas leis são de iniciativa exclusiva do **Presidente da República**:

I – Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II – Disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública, observado o disposto no art. 84, VI, da CF;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva (art. 61, § 1.º)

A lei ordinária é o ato legislativo típico, podendo dispor sobre toda e qualquer matéria, salvo aquelas reservadas à lei complementar e as de competência exclusiva do Congresso Nacional (que são tratadas por meio de resoluções e decretos legislativos). O seu quórum de aprovação é de maioria simples, conforme art. 47 da CF.

As leis complementares seguem o mesmo procedimento das leis ordinárias para serem aprovadas, mas com a exigência de aprovação por maioria absoluta. Exige-se a aprovação de mais da metade da totalidade da Casa Legislativa, considerando os parlamentares presentes e ausentes.

Leis Delegadas

As leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República que, para tanto, solicita prévia delegação ao Congresso Nacional. Por meio de Resolução, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, o Congresso Nacional delegará poderes ao Presidente da República a fim de que este edite regra jurídica nova.

Não são objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, ou de qualquer uma de suas Casas, para matéria reservada à lei complementar ou a legislação sobre:

- A organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
- Planos plurianuais e matéria orçamentária.

Medidas Provisórias

Em casos de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional (art. 62 da Constituição Federal).

Governador de Estado e Prefeito não podem editar medida provisória, já que o instrumento caracteriza exceção.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que cabe ao Chefe do Poder Executivo e ao Poder Legislativo a avaliação subjetiva da urgência da medida provisória, ressalvada a hipótese em que a falta da urgência é flagrante e pode ser objetivamente avaliada pelo Poder Judiciário.

De acordo com a Emenda Constitucional nº 32/01, a medida provisória perde a eficácia, desde a sua edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias. Admite-se a prorrogação automática do prazo por mais 60 dias, uma única vez, caso os 60 dias originários se esgotem sem a apreciação da medida provisória pelas duas casas do Congresso Nacional.

A prorrogação é automática porque o Presidente da República não pode retirar a medida provisória do Congresso Nacional. Poderá, sim, editar uma nova medida provisória que suspenda os efeitos da primeira, cabendo ao Congresso Nacional deliberar pela conversão em lei de uma delas e regulamentar as relações jurídicas decorrentes das normas rejeitadas.

O art. 62, § 1º da CF, estabeleceu uma série de limites materiais expressos. Estipulando matérias que não podem ser objeto de medidas provisórias, são estas:

I - Relativas à:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvadas as situações excepcionais previstas no art. 167, § 3º, da Constituição.

II – Que vise à detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.

III – Reservada à lei complementar.

IV – Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e dependente de sanção ou veto do Presidente da República.

Decreto Legislativo

O Decreto Legislativo tem como conteúdo matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 da Constituição Federal) e quem o promulga é o Presidente do Senado. Trata-se de norma geral da qual a Constituição não exige a remessa ao Presidente da República para sanção ou promulgação.

O decreto legislativo veicula preferencialmente assuntos de caráter genérico e sua aprovação, em regra, ocorre por maioria simples.

Não deve ser confundido com os antigos decretos-leis, nem com os decretos expedidos pelo Poder Executivo. Exemplo: art. 62, § 3º da CF, para disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medidas

provisórias que perderam a eficácia por não terem sido aprovadas no prazo de sessenta dias, prorrogável, uma única vez, por igual período.

Resoluções

São de competência privativa do Congresso Nacional ou de qualquer uma de suas Casas. As resoluções têm por conteúdo matérias concretas, a exemplo da suspensão de lei declarada inconstitucional e da delegação de poderes legislativos ao Presidente da República.

A promulgação é feita pela mesa da Casa que expedir o ato ou, se do Congresso Nacional, pela mesa do Senado Federal. A aprovação exige, em regra, maioria simples.

Também as resoluções não estão sujeitas à sanção do Presidente da República. A regulamentação dos decretos legislativos e das resoluções consta do regimento interno de cada uma das Casas legislativas.

O Veto

O veto consiste na manifestação de discordância do emitida pelo chefe do Executivo, contrário a um projeto de lei.

O veto ocorre em duas circunstâncias:

- 1) projeto de lei contrário ao interesse público: conhecido como veto político;**
- 2) projeto de lei inconstitucional: denominado veto jurídico**

Deve o veto ser motivado pelo Chefe do Executivo, sendo sempre expreso e nunca tácito. Há possibilidade de ser total ou parcial, abrangendo sempre **texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea**.

Após sua emissão, o veto é submetido ao controle do Congresso Nacional, o qual, em sessão conjunta dos parlamentares, no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, mediante deliberação por voto da maioria de seus membros pode ser derrubado ou mantido, sendo enviado para o Presidente da República para promulgação.

A promulgação e a publicação

A promulgação é o ato pelo qual o Estado atesta a existência da lei. Geralmente é ato do Presidente da República, mas quando o veto é derrubado pelo Congresso e o há recusa do Presidente da República em promulgar a lei, após o decurso de 48 horas, o Presidente do Senado é quem deverá realizar a promulgação.

Após, deve ser feita a publicação, o ato que levará ao conhecimento de todos o conteúdo da nova legislação.

Texto Constitucional sobre o assunto

Seção VIII DO PROCESSO LEGISLATIVO Subseção I Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;**
- II - leis complementares;**
- III - leis ordinárias;**
- IV - leis delegadas;**
- V - medidas provisórias;**
- VI - decretos legislativos;**
- VII - resoluções.**

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

SUBSEÇÃO II DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

- I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

SUBSEÇÃO III DAS LEIS

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

- I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
- II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva

§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.

§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º - Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013).

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

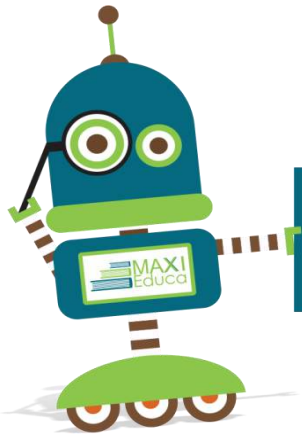
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º - A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.



41 Poder Executivo: presidencialismo e parlamentarismo; ministro de Estado.

O Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo. A Constituição Federal traz como os poderes da União, o Poder Executivo, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si (art. 2º da CF/88).

A função do poder Executivo é administrar e implementar políticas públicas nas mais diversas áreas de atuação do Estado, de acordo com as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. É da atribuição do Poder Executivo o governo e a administração do Estado.

O Poder Executivo é regulado pela Constituição Federal nos seus artigos 76 a 91. É exercido, no âmbito federal, desde 1891, pelo Presidente da República, eleito por sufrágio popular e direto [http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder Executivo do Brasil](http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil) - cite note-
[Constitui.C3.A7.C3.A3o de 1891-1](http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil), em eleição de dois turnos, e substituído em seus impedimentos pelo Vice-Presidente. Colaboram com o chefe do executivo os Ministros de Estado, por ele nomeados.

O Presidente acumula as funções de Chefe de Estado (representação externa e interna do Estado) e Chefe de Governo (liderança política e administrativa dos órgãos do Estado). É eleito com mandato fixo, não dependendo de maioria política no Congresso Nacional para investir-se no cargo ou nele permanecer.

No plano estadual, o Poder Executivo é exercido pelo Governador, substituído em seus impedimentos pelo Vice-Governador, e auxiliado pelos Secretários de Estado [http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder Executivo do Brasil](http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil) - cite note-
[Constitui.C3.A7.C3.A3o Estadual-2](http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil).

Já no plano municipal, é exercido pelo Prefeito, substituído em seus impedimentos pelo Vice-Prefeito e auxiliado pelos Secretários Municipais [http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder Executivo do Brasil](http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil) - cite note-
[Lei Org.C3.A2nica Municipal-3](http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil). A sede de cada município toma seu nome e tem oficialmente a categoria de cidade.

Parlamentarismo

Outro sistema de governo, o parlamentarismo, é um sistema em que o poder legislativo (parlamento) oferece a sustentação política (apoio direto ou indireto) para o poder executivo. Logo, o poder executivo necessita do poder do parlamento para ser formado e também para governar.

Esse sistema é usado tanto em monarquias quanto em repúblicas. Nele, o chefe do Estado, seja ele rei ou presidente, não é o chefe do governo e por isso não tem responsabilidades políticas. Ao invés dele, o chefe de governo é o Primeiro Ministro, o qual é indicado pelo Parlamento. A aprovação do Primeiro Ministro e do seu Conselho de ministros pela Câmara dos Deputados é feita pela aprovação de um plano de governo a eles apresentado. A Câmara ficará encarregada de empenhar-se pelo cumprimento desse plano perante o povo.

Típico das Monarquias Constitucionais, tal sistema de governo acabou por se estender às Repúblicas Europeias. Na Inglaterra, França e Alemanha, esse ainda é o sistema em vigor. O Poder Executivo é exercido pelo Gabinete dos Ministros, estes são indicados pelo primeiro ministro e aprovados pelo parlamento.

No Brasil, o parlamentarismo foi adotado no final do Império, entre 1847 e 1889. Após a proclamação da república o Brasil adotou o presidencialismo como sistema governamental. Porém, com a renúncia de Jânio Quadros o Brasil passou por uma crise política muito grande e o sistema acabou por ser adotado como uma tentativa de solucionar a crise. Isso aconteceu, porém, durante um curto período: de setembro de 1961 a janeiro de 1963.

Ministros de Estado

Os Ministros de Estado são auxiliares do Presidente da República na direção superior da Administração Federal. Os Ministros são de livre nomeação pelo Presidente da República, podendo ser por ele exonerados a qualquer tempo, **sendo desnecessária a sabatina do Senado Federal, salvo para o presidente do BACEN, que é equiparado**.

Poderão ser Ministros quaisquer brasileiros, natos ou naturalizados, maior de 21 anos e no pleno exercício de seus direitos políticos; porém, **somente poderá ser ministro da defesa brasileiro nato**.

São atribuições do Ministro de Estado, além de outras que lhe sejam delegadas pelo Presidente da República, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Federal na área de sua competência e referendar atos e decretos assinados pelo Presidente da República, expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos (CR, art. 87, parágrafo único).

Como visto anteriormente, os Ministros poderão até mesmo editar decretos autônomos, caso lhes seja delegada essa prerrogativa pelo Presidente.

Os Ministros de Estado serão processados e julgados, **nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade**, pelo **STF** (CR, art. 102, I, c).

Nos **crimes de responsabilidade** conexos com os do Presidente da República, serão processados pelo Senado Federal (CR, art. 52, I).

Os mandados de segurança e os *habeas data* impetrados contra atos de Ministro de Estado serão julgados pelo **STJ** (CR, art. 105, b). Também os *habeas corpus* nos quais Ministro de Estado for apontado como autoridade coatora serão julgados pelo **STJ** (CR, art. 105, I, c).

Porém, se o MS for impetrado em face de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado, a competência não será do **STJ**, e sim do juízo competente para julgar demandas em face de tal órgão.

Requisitos Especiais para Determinados Cargos de Ministros e Ministros Equiparados

Tema interessante colocou-se na ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Medida Provisória n. 207, de 2004, convertida na Lei n. 11.036/2004, que transformou o cargo de Presidente do Banco Central em cargo de Ministro de Estado.

Sustentou-se que o Presidente do Banco Central não poderia ser titular de cargo de Ministro de Estado por estar submetido, nos termos da Constituição, a um regime próprio de nomeação — aprovação pelo Senado Federal (CF, arts. 52, III, d, e 84, I e XIV). Suscitou-se que o ato impugnado seria ofensivo ao princípio da separação de Poderes. Quando a Constituição diz, no art. 84, I, que compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os Ministros de Estado, obviamente está implícito que tal nomeação se dará na forma da Constituição e da lei. Não poderá, por exemplo, o Presidente nomear um menor de 21 anos para chefiar um Ministério. Também não poderá nomear alguém que esteja privado de seus direitos políticos (CF, art. 87).

No caso da nomeação do Presidente do Banco Central, por evidente, haverá um procedimento constitucional específico, que terá como pressuposto a aprovação prévia pelo Senado, nos termos do art. 52, III, d. Não vejo, portanto, como interpretar a norma impugnada como autorizadora do afastamento da exigência constitucional de prévia aprovação pelo Senado.

De resto, o modelo constitucional contém algumas situações que demonstram tratamento bastante casuístico no que toca aos cargos mais elevados da República.

Notório exemplo é o do Advogado-Geral da União, que é Ministro por determinação legal. No plano constitucional, o Advogado-Geral, nomeado e diretamente subordinado ao Presidente, possui requisitos para a nomeação que são mais rigorosos em relação aos demais Ministros. Exige-se idade mínima de 35 anos, reputação ilibada e notório conhecimento jurídico. No que toca à prerrogativa de foro, também há um tratamento constitucional diferenciado. O Advogado-Geral, em relação ao crime de responsabilidade, é sempre julgado perante o Senado (CF, art. 52, II), tal como o Presidente da República, o Procurador-Geral da República e os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Já os Ministros de Estado, no que toca aos crimes de responsabilidade, com ressalva de atos conexos a atos do Presidente, em regra são julgados perante o STF (CF, art. 102, I, c).

Outro exemplo interessante de situação singular é o dos Comandantes Militares. Não obstante os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estarem subordinados ao Ministério da Defesa, remanescem eles com foro especial perante o Supremo Tribunal Federal. Note-se que tais autoridades nem sequer possuem status de Ministro. Por fim, estão abrangidos pela mesma disposição que confere prerrogativa de foro aos Comandantes Militares os chefes de missão diplomática de caráter permanente (CF, art. 102, I, c). Também aqui tem-se tratamento idêntico entre autoridades de diferentes hierarquias,

tendo em vista que os chefes de missão diplomática estão subordinados ao Ministro das Relações Exteriores.

Seção IV DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.



42. Presidente da República: poder regulamentar; medidas provisórias.

O Brasil adota o presidencialismo desde a Constituição de 1.891. Nele, o Presidente assume a função de Chefe de Estado (representação externa) e de Chefe de Governo (gerência interna). Os Ministros, seus auxiliares, são livremente escolhidos e demissíveis ad nutum, sem necessidade de fundamentação.

No nosso sistema presidencialista, o Presidente não possui qualquer possibilidade de dissolver o parlamento, sendo a mera tentativa disso uma absoluta afronta à separação dos Poderes, ao contrário do que ocorre na maioria dos regimes parlamentares.

O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A estrutura do Poder Executivo a nível federal, além da Presidência da República e dos ministérios, compreende os gabinetes, Pessoal e de Segurança Institucional, a Casa Civil e vários órgãos de assessoramento.

São requisitos para a candidatura ao cargo de Presidente e Vice:

- Ser brasileiro nato;
- Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
- Ter mais de 35 anos;
- Filiação a partido político;
- Possuir alistamento eleitoral.

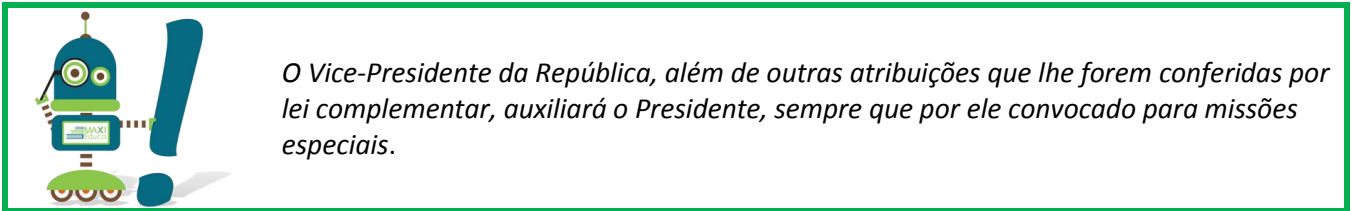
Se antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato a Presidente, será convocado o terceiro colocado nas eleições. Se essas situações recaírem sobre o

Vice, outro deve ser escolhido. Porém, se a morte ou desistência ocorrer após a eleição, mas antes da diplomação, considerar-se-á eleito o vice-presidente.

A posse de Presidente e Vice deverá ocorrer no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Se após decorridos 10 dias da data fixada para a posse, um dos dois candidatos não tiver assumido, o cargo será considerado automaticamente vago, salvo motivo de força maior.

O Vice-Presidente da República

Eleito como companheiro de chapa do presidente, cabe ao Vice-Presidente da República substituir o titular nos seus impedimentos ou suceder-lhe na vacância do cargo. Os requisitos para o cargo são os mesmos do cargo de presidente.



Caso o presidente e o vice estiverem impedidos, ou deixarem vagos os respectivos cargos, serão chamados a assumir a Presidência, pela ordem, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

O Presidente da República e seu vice só poderão ausentar-se do País com licença do Congresso, sob pena de perda do cargo, salvo se a ausência não for superior a 15 dias.

Investidura

O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário de dois turnos (e não o puro ou simples), já que será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. Entretanto, se no primeiro turno essa maioria não for alcançada, necessariamente deverá haver um segundo turno.

Votos válidos são os votos que não são em branco ou nulos (art. 77, §§ 2º e 3º).

O Presidente é eleito simultaneamente ao Vice, por meio de sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, em eleição realizada no primeiro e no último domingo de outubro do ano eletivo, para o primeiro e segundo turno, respectivamente.

O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

Das atribuições do Presidente da República

Tradicionalmente, o Poder Executivo tem a função de governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, e função administrativa, manifestada pela intervenção, fomento e prestação de serviços públicos.

Compete privativamente ao Presidente da República:

- I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
- II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
- IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; Sobre os decretos regulamentares, tem-se:

A diferença entre lei e regulamento, no Direito brasileiro, não se limita à origem ou à supremacia daquela sobre este. A distinção substancial reside no fato de que a lei pode inovar originariamente no ordenamento jurídico, enquanto o regulamento não o altera, mas tão-somente fixa as regras orgânicas e processuais destinadas a colocar em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ele circunscrita, isto é, às diretrizes por ela determinada.

- V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI - dispor, mediante decreto, sobre: **(trata-se, aqui, de decreto autônomo, com força de lei. Atribuição delegável).**

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

o referendo se dá por decreto legislativo

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; **o Estado de sítio somente é decretado após autorização do Congresso Nacional por Decreto Legislativo**

X - decretar e executar a intervenção federal;

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

Atribuição delegável.

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

XIV - nomear, **após aprovação pelo Senado Federal**, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central **e outros servidores, quando determinado em lei; aprovação mediante resolução**

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional; **autorização ou referendo feito por decreto legislativo**

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em **lei complementar**, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; **Atribuição delegável somente quanto ao provimento.**

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Todas essas atribuições, ressalvadas as que ficaram consignadas, são indelegáveis. Além disso, elas não são exaustivas, apenas exemplificativas.

Todas as atribuições privativas são extensíveis, no que couber, e por força do federalismo e do princípio da simetria, aos demais Chefes dos Poderes Executivos de outros entes federados.

Reeleição

A Emenda Constitucional nº 16/97 introduziu o instituto da reeleição de cargos do Poder Executivo (CF, art. 14, § 5º), permitindo que o Presidente da República, o Governador de Estado ou o Prefeito postulem um novo mandato.

O texto constitucional não contemplou qualquer exigência quanto à necessidade de desincompatibilização, de modo que a candidatura à reeleição dá-se com o candidato no exercício efetivo do cargo.

Evidentemente que, na condição de Presidente, ele não poderá fazer campanha política (o que é totalmente ignorado pelos candidatos).

Também não há qualquer restrição quanto à possibilidade de nova eleição para períodos descontínuos. O Presidente da República reeleito poderá, após deixar o cargo, vir a postular nova investidura. Assim, somente não se admite três mandatos seguidos.

CAPÍTULO II DO PODER EXECUTIVO

Seção I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

§ 1º - A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 2º - Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3º - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º - Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 5º - Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Seção II

Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

- I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
- II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
- IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
- V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
- VI – dispor, mediante decreto, sobre:
 - a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
 - b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
- VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
- VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
- IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
- X - decretar e executar a intervenção federal;
- XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
- XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
- XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;
- XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;
- XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
- XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
- XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
- XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
- XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
- XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
- XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
- XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
- XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
- XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
- XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
- XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.



43. Crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado.

Os crimes de responsabilidade são as infrações político-administrativas cujas sanções consistem na perda da investidura dos cargos ocupados pelo agente e sua inabilitação para o exercício de funções públicas por um período de oito anos – é o chamado impeachment.

Conforme previsão constitucional do art. 85 da CF, os atos do Presidente da República que implicam na sua responsabilidade política estão ali previstos. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- I - a existência da União;**
- II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;**
- III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;**
- IV - a segurança interna do País;**
- V - a probidade na administração;**
- VI - a lei orçamentária;**
- VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.**

Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Qualquer cidadão é parte legítima para apresentar a acusação por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Com a admissão da acusação por 2/3 dos membros daquela casa, será o Presidente submetido a julgamento perante Senado.

Em caso de acusação pelas infrações penais comuns, cabe ao Procurador-Geral da República sua iniciativa, havendo juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, caso em que, sendo admitida por 2/3 dos membros, o Presidente será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

O processo de impeachment dos ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não conexos com infrações da mesma natureza do presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo STF e não pelo Senado Federal, conforme arts. 51, I, e 52, I, da Carta de 1988 e 14 da Lei 1.079/1950.

Seção III

Da Responsabilidade do Presidente da República

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- I - a existência da União;**
- II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;**
- III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;**

- IV - a segurança interna do País;
- V - a probidade na administração;
- VI - a lei orçamentária;
- VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.



44. Poder Judiciário: organização; estatuto constitucional da magistratura.

Do Poder Judiciário

O Brasil adota o sistema inglês ou sistema de unicidade de jurisdição, no qual somente o Poder Judiciário tem jurisdição, somente ele pode dizer, em caráter definitivo, o direito aplicável aos casos concretos litigiosos submetidos à sua apreciação.

Logo, não existe no Brasil a coisa julgada administrativa, tampouco a jurisdição administrativa.

São características essenciais de um Poder Judiciário independente e imparcial as diversas prerrogativas da magistratura, como a vitaliciedade, inamovibilidade etc.

O Poder Judiciário exerce, além de sua função típica, funções atípicas normativas e administrativas.

Disposições gerais

O Poder Judiciário é um dos três poderes clássicos previstos pela doutrina e consagrado como poder autônomo e independente de importância crescente no Estado de Direito, pois, como afirma Sanches Viamonte⁸¹, sua função não consiste somente em administrar a Justiça, sendo mais, pois seu mister é ser o verdadeiro guardião da Constituição, com a finalidade de preservar, basicamente, os princípios da legalidade e igualdade, sem os quais os demais tornar-se-iam vazios. Esta concepção resultou da consolidação de grandes princípios de organização política, incorporados pelas necessidades jurídicas na solução de conflitos.

Assim, dentro do sistema de separação de Poderes compete ao Poder Judiciário a função jurisdicional do Estado, ou seja, de distribuição de justiça, de resolver litígios, de aplicação da lei ao caso concreto, que lhe é posto, resultante de um conflito de interesses.

⁸¹ Temas de Direito Constitucional. São Paulo: Acadêmica, 1993. p. 36.

Contudo, o Judiciário, como os demais Poderes do Estado, possui outras funções, denominadas atípicas, de natureza administrativa e legislativa.

Desta forma, o Poder Judiciário além de suas funções típicas de preservar pela Constituição Federal e exercer a jurisdição (Jurisdição significa a aplicação da lei ao caso concreto), exerce funções atípicas como organizar suas secretárias e serviços auxiliares (art. 96, I, b, da CF).

A função jurisdicional atribui-se o papel de fazer valer o ordenamento jurídico no caso concreto, se necessário de forma coativa, ainda que em substituição à vontade das partes.

Atipicamente, por expressa delegação constitucional, os demais poderes exercem atividades jurisdicionais (a exemplo do art. 52, inc. I, da CF, que atribui ao Senado a competência para julgar algumas autoridades por crime de responsabilidade). Competência é o limite da jurisdição.

Princípios

Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário: O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tal garantia assegura o direito de ação, de invocar a tutela jurisdicional a qualquer cidadão.

Princípio da Inércia: O Poder Judiciário só se manifesta quando provocado. Trata-se de uma forma de garantir a sua imparcialidade.

Princípio do Devido Processo Legal: A prestação jurisdicional deve ser prestada com a observância de todas as formalidades legais. Decorre deste princípio uma série de outros princípios, como os do juiz natural e do promotor natural (CF, art. 5º, LIII), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da proibição das provas ilícitas (CF, art. 5º, LVI) e da publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LX).

Quinto Constitucional: um quinto do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho e dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal (Tribunais de Justiça e Tribunais da Justiça Militar) é composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e ilibada reputação, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados por lista sêxtupla da respectiva classe (arts. 94, 111-A, I e 115, I da CF).

Órgãos do Poder Judiciário

Os órgãos do Poder Judiciário são aqueles relacionados no art. 92 da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar) têm sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional.

Conforme previsão constitucional, são órgãos do Poder Judiciário:

I - o Supremo Tribunal Federal;

I-A o Conselho Nacional de Justiça;

II - o Superior Tribunal de Justiça;

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;

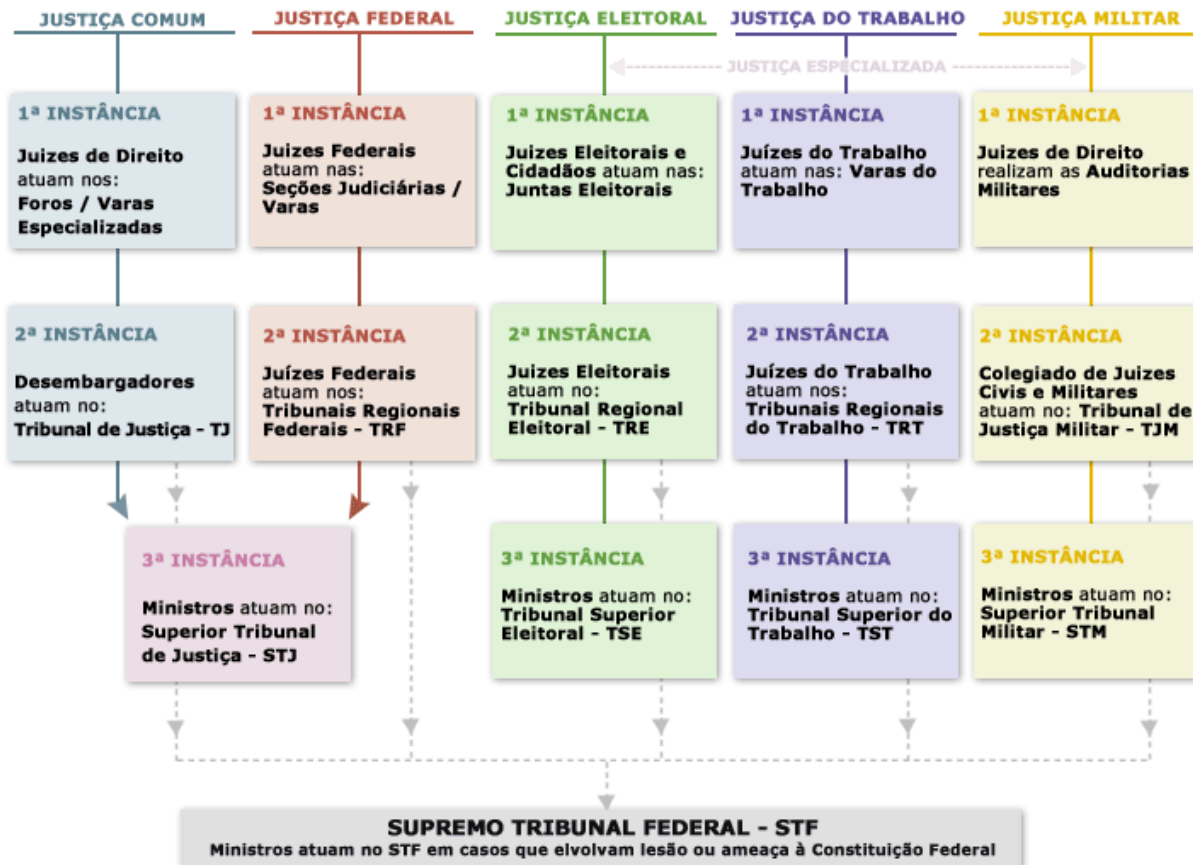
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Juízes Militares;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.

ORGANOGRAMA DO PODER JUDICIÁRIO



A Justiça Federal e a Estadual

A Justiça Comum é composta pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual Originária. À Justiça Federal e à Justiça Estadual competem as demais matérias não abrangidas pelas Justiças Especiais. Por essa razão são chamadas Justiça Comum.

Compete à Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. À Justiça Comum Estadual cabe o julgamento das demais matérias, por exclusão.

Garantias Institucionais do Judiciário

A Constituição de 1988, reportando-se ao princípio da separação dos poderes, assegura ao Judiciário a garantia de autonomia orgânico-administrativa e a garantia da independência financeira, conforme se depreende dos artigos 96 e 99⁸² da CF/88:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

- eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
- organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
- prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
- provar a criação de novas varas judiciárias;

⁸² BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1988.

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Segundo lições do professor José de Albuquerque Rocha⁸³, acerca das garantias constitucionalmente previstas para o poder Judiciário no âmbito administrativo-financeiro, a autonomia administrativa, chamada de autogoverno da magistratura, significa a capacidade conferida ao Judiciário de ministrar seus órgãos, abrangendo o pessoal e os meios financeiros, necessários ao desempenho das funções jurisdicionais.

Garantias funcionais do Judiciário

A aplicação das normas aos casos concretos e a salvaguarda dos direitos individuais e coletivos muitas vezes exigem decisões contrárias a grandes forças econômicas, políticas ou de algum dos poderes, havendo por isto a necessidade de órgãos independentes para a aplicação das leis (sistema de freios e contrapesos). Portanto, ao lado das funções de legislar e administrar, o Estado exerce a função jurisdicional típica por um poder independente, que é o Judiciário.

O exercício das funções jurisdicionais de forma independente exige algumas garantias atribuídas ao Poder Judiciário como um todo, e outras garantias aos membros desse Poder (os magistrados).

As garantias dos juízes são prerrogativas funcionais, e não privilégios pessoais, sendo, portanto, irrenunciáveis, segundo o artigo 95 da CF/88:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

⁸³ José de Albuquerque Rocha *apud* Marcus Vinícius Amorim de Oliveira.

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, §4º, 150, II, 153, III, e 153, §2º, I.

a) Vitaliciedade: Em primeiro grau, é adquirida após dois anos de exercício (em razão da emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário poderá subir para três anos, prazo já exigido para a aquisição da estabilidade daqueles servidores nomeados para cargos efetivos).

b) Inamovibilidade: Pela inamovibilidade, o juiz titular somente deixa sua sede de atividades (por remoção ou promoção) voluntariamente. Como exceção temos a remoção compulsória, por motivo de interesse público, deliberada pelo voto de 2/3 dos membros do respectivo Tribunal (ou Órgão Especial), assegurada a ampla defesa. A remoção, a disponibilidade e a aposentadoria do magistrado, por interesse público, somente são possíveis com o voto de 2/3 dos membros do respectivo Tribunal ou Órgão Especial, assegurada a ampla defesa. A inamovibilidade, portanto, não é absoluta.

c) Irredutibilidade de subsídios: Garantia estendida a todos os servidores públicos civis e militares pelo art. 37, inc. XV, da Constituição Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, trata-se de irredutibilidade meramente nominal, inexistindo direito à automática reposição do valor corroído pela inflação. Todos os magistrados estão sujeitos ao pagamento dos impostos legalmente instituídos.

Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo e dedicar-se à atividade político-partidária.

O quinto constitucional

Segundo o art. 94 da CF/88, um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Conforme previsto nos artigos 111-A e 115 da CF/88, também o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho deverão ter em seus quadros membros advindos da regra do quinto constitucional.

Cada órgão, a Ordem dos Advogados do Brasil ou o Ministério Público, formará uma lista sêxtupla para enviá-la ao Tribunal onde existe a vaga de ministro ou desembargador. Este tribunal, após votação interna para a formação de uma lista tríplice, a remete ao chefe do Poder Executivo, isto é, governadores, no caso de vagas da justiça estadual, e o presidente da república no caso de vagas da justiça federal, que nomeará um dos indicados.



45 Ativismo judicial.

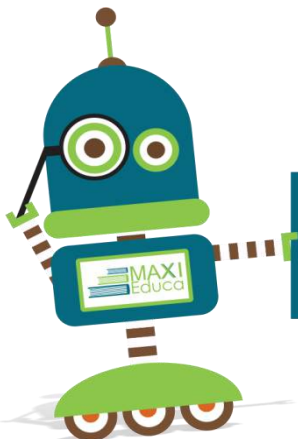
O ativismo judicial pode ser tido como *“uma postura a ser adotada pelo magistrado que o leve ao reconhecimento da sua atividade como elemento fundamental para o eficaz e efetivo exercício da atividade jurisdicional”*.

No âmbito da ciência do Direito, ele é empregado para designar que o Poder Judiciário está agindo além dos poderes que lhe são conferidos pela ordem jurídica.

O “ativismo judicial” exige que os juízes sejam atuantes no sentido não apenas de fazer cumprir a lei em seu significado exclusivamente formal, mas exige audácia na interpretação de princípios constitucionais abstratos tais como a dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, reivindicando, então, para si a competência institucional e a capacidade intelectual para fixar tais conceitos abstratos, atribuindo significado preciso aos mesmos, concretizando-os, bem como julgar os atos dos outros poderes que interpretam estes mesmos princípios.

O vocábulo ativismo, segundo investigação sobre a sua origem, foi empregado, pela primeira vez em 1916, na imprensa belga. Porém, foi consagrado nos Estados Unidos da América, em face da postura adotada pela Suprema Corte no julgamento de determinados casos, que tiveram efeitos mais abrangentes.

No Brasil encontramos vários doutrinadores que defendem a empregabilidade do ativismo judicial, desde que de forma adequada, uma vez que pode contribuir para o aprimoramento da democracia, “especialmente quando aplica toda a extensão dos efeitos dos direitos fundamentais aos excluídos dos seus efeitos”, bem como já está consagrada esta tese no STF, em vários de seus julgados.



46 Supremo Tribunal Federal: organização e competência

Supremo Tribunal Federal

Trata-se de órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, com a função principal de “guarda da Constituição”. Compete-lhe a relevante atribuição de julgar as questões constitucionais, assegurando a supremacia da Constituição Federal em todo o território nacional. Porém, O Supremo Tribunal Federal não é uma Corte exclusivamente constitucional, pois diversas outras atribuições foram-lhes conferidas pela Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
- b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
- c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
- d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
- e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
- f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
- g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
- i) o **habeas corpus**, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
- j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
- l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
- m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
- n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
- o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
- p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
- q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
- r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) o crime político;

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Súmulas vinculantes

Súmulas são enunciados aprovados pelos Tribunais, contendo a jurisprudência predominante em determinada matéria. As súmulas editadas pelos Tribunais não possuem força obrigatória, não vinculam magistrados e tribunais de instância inferior. Por outro lado, as súmulas vinculantes são aquelas editadas com o efeito de vincular os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Direta e Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Serão editadas a partir de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre uma questão constitucional que acarrete grave insegurança jurídica e multiplicidade de processos sobre questão idêntica. Somente o Supremo Tribunal Federal pode editar, rever ou cancelar súmulas vinculantes.

As súmulas vinculantes têm como requisitos formais: a) aprovação por maioria de 2/3 dos membros da Corte (oito dos onze Ministros); b) incidir sobre matéria constitucional; c) existência de reiteradas decisões da Suprema Corte sobre o tema.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm - [art102%C2%A71](#) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.



47 Superior Tribunal de Justiça: organização e competência. Justiça federal: organização e competência.

Foi criado o Superior Tribunal de Justiça pela Constituição de 1988, com a missão de assegurar a supremacia da legislação federal no Brasil, bem como uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país. É a última instância para causas infraconstitucionais submetidas à jurisdição da Justiça Comum, que não versem diretamente sobre questões constitucionais.

A Emenda Constitucional n. 45 ampliou as competências deste órgão de cúpula da Justiça comum em nosso país, ao transferir do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias. Para as sentenças estrangeiras terem eficácia executiva no Brasil é necessária a homologação judicial do STJ. Cartas rogatórias, ou seja, solicitações feitas por autoridades judiciais estrangeiras, não dependem de homologação. Exigem somente uma decisão de *exequatur* (execute-se, cumpra-se) do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os **habeas data** contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

c) os **habeas corpus**, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias;

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

A Lei nº 11.672/2008 acrescentou o art. 543-C ao Código de Processo Civil e estabeleceu um procedimento para o julgamento dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito será adotado um procedimento especial. O Presidente do Tribunal de origem deverá selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los para o Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até pronunciamento definitivo. Se mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, será feito o exame de admissibilidade do recurso especial.

Justiça federal: organização e competência.

Os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais são órgãos da justiça federal. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

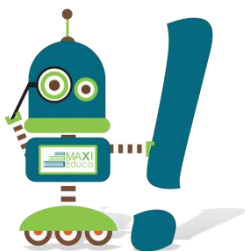
§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

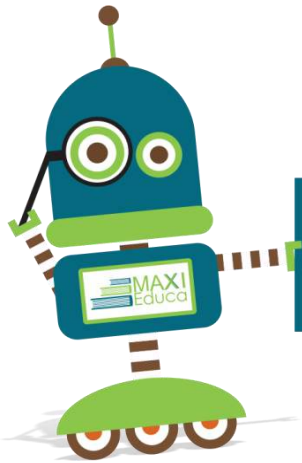
§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.



Observação: Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. Nesse caso, contudo, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

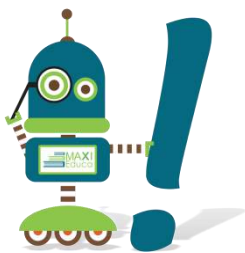


48. Justiça do Trabalho: organização e competência

A Justiça do Trabalho tem competência para julgar todas as ações envolvendo as relações de trabalho, abrangidos todos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta de todas as entidades federativas. Ações que envolvam o exercício do direito de greve; ações sobre representação sindical; ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da mesma relação, são julgadas pelas Varas do Trabalho, com a jurisdição exercida por um juiz do trabalho, com a possibilidade de recurso para as instâncias superiores.

O Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao art. 114 da Constituição Federal para excluir das competências da Justiça do trabalho “causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários, em razão de ser estranho ao conceito de relação de trabalho o vínculo jurídico de natureza estatutária existente entre servidores públicos e a administração”.

A respeito da competência da Justiça do Trabalho, o Supremo editou as Súmulas Vinculantes nº 22 e nº 23:



Súmula Vinculante nº 22: “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04”;

Súmula Vinculante nº 23: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

- I - o Tribunal Superior do Trabalho;
- II - os Tribunais Regionais do Trabalho;
- III - Juízes do Trabalho.

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;

II- os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 2º Funcionário junto ao Tribunal Superior do Trabalho:

- I- a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
- II- o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

- I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- II- as ações que envolvam exercício do direito de greve;
- III- as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
- IV- os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
- V- os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
- VI- as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
- VII- as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
- VIII- a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
- IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º- Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

- I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
- II- os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.



49. Ministério Público: princípios constitucionais

De acordo com o art. 127, *caput*, da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Não se trata de um poder do Estado, mas de uma instituição independente dos demais poderes, considerada essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado.

O Ministério público pode ser federal ou estadual. No primeiro, há os procuradores da república que atuam junto aos juízes federais (justiça federal) e pertencem ao ministério público da união. No segundo, existem os promotores de justiça que exercem suas funções perante os juízes de direito (justiça estadual) e pertencem a carreira do ministério público estadual.

Estas distinções entre o ministério público federal e estadual continuam na segunda instância, isto é, em grau de recurso. Quando a matéria for federal, quem representará a sociedade serão os Procuradores Regionais da República, sendo o processo distribuído para o Tribunal Regional Federal. Já no caso da matéria ser estadual, quem atuará serão os Procuradores de Justiça, junto aos Tribunais de Justiça Estaduais.

Segundo previsto no artigo 128 da CF, o Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

- a) o Ministério Público Federal;**
 - b) o Ministério Público do Trabalho;**
 - c) o Ministério Público Militar;**
 - d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;**
- II - os Ministérios Públicos dos Estados.**

Os Ministérios Públicos dos Estados (MPE)

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União divergem do Ministério Público dos Estados. Enquanto o MPU é regido pela Lei Complementar nº 75/1993, o MPE rege-se pela Lei nº 8.625/1993.

Ao MPU é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Sendo as carreiras dos membros dos diferentes ramos independentes entre si. Dessa forma, para ser membro do MPF, deve-se prestar concurso público para o MPF. Para ser membro do MPT, deve-se prestar concurso para o MPT, e assim por diante. Quanto à carreira técnico-administrativa, esta é única para todo o MPU. O candidato presta concurso público para o MPU e pode ser lotado em qualquer um dos ramos.

Princípios, garantias, vedações, organização e competências.

A Constituição de 1988 dotou o Ministério Público e seus membros, para garantia do efetivo exercício de seus audaciosos misteres, de uma série de prerrogativas, dentre as quais se destacam os princípios institucionais elencados no §1º de seu artigo 127.

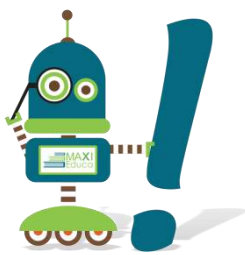
1) Princípio da unidade: os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob uma mesma direção do Procurador-Geral da República, na esfera federal, e do Procurador-Geral de Justiça, na estadual.

2) Princípio da Indivisibilidade: os integrantes do Ministério Público atuam sempre em nome de toda a instituição, podendo ser substituídos uns pelos outros, dentro dos critérios estabelecidos pela lei.

3) Princípio da independência funcional: garante a inexistência de vinculação dos órgãos da Instituição a pronunciamentos processuais anteriores de outros membros. Tal prerrogativa, juntamente com outras existentes na própria Lei Maior e no ordenamento infraconstitucional, demonstra a preocupação do legislador em garantir ao *Parquet* todos os meios para exercer seu papel fundamental de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O órgão do Ministério Público é independente no exercício de suas funções, não ficando sujeito às ordens de quem quer que seja, somente devendo prestar contas de seus atos à Constituição, às leis e à sua consciência.

No mesmo sentido, em bem acabada obra, Mazzilli doutrina:



(...) unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe; indivisibilidade significa que esses membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, porém, mas segundo a forma estabelecida na lei. Por sua vez, a independência funcional do membro ministerial brota como um seu alvedrio, garantindo um agir emancipado de quaisquer ingerências ou repressões. Instrui Luciano França Júnior:

Nessa seara, o princípio da independência afigura-se instrumento garantidor de uma atuação libertária, que visa arredar constrangimentos, pressões, imposições, censuras – interna e externa corporis – em face das importantes atribuições manuseadas.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 5º, LIII, “**que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente**”. Ao lado do tradicional princípio do juiz natural, inscreveu-se, como garantia individual, **o princípio do promotor natural**. De acordo com este as atribuições do promotor de justiça em determinado feito devem ser anteriormente fixadas. Assim, além de ser julgado por órgão independente e pré-constituído, o acusado também tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por consequência, a **designação arbitrária**, inclusive, de **promotores ad hoc** (nomeados apenas para a execução do ato) ou **por encomenda**.

Aos membros do Ministério Público foram atribuídas as mesmas garantias concedidas aos integrantes do Poder Judiciário: **vitaliciedade** (após o cumprimento do estágio probatório de dois anos, somente podem ser destituídos do cargo por sentença judicial transitada em julgado), **inamovibilidade** (não podem ser transferidos compulsoriamente de seus cargos, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado, por maioria absoluta dos votos, assegurada ampla defesa) e **irredutibilidade do subsídio** (a remuneração dos membros do Ministério Público não poderá ser reduzida, lembrando que está assegurada a irredutibilidade nominal, não se garantindo a corrosão inflacionária).

Ao mesmo tempo que são concedidas essas importantes garantias, também para assegurar a sua independência, são impostas algumas **vedações** aos membros do Ministério Público:

- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- exercer a advocacia;
- participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
- exercer atividade político-partidária;
- receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
- exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (CF, art. 128, §§ 5º, II e 6º).

Funções Institucionais

De acordo com o arts. 129 da CF/88, são funções institucionais do Ministério Público:

- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP

O art. 130-A, introduzido pela *Emenda Constitucional n. 45/2004* e regulamentado pela *Lei n. 11.372/2006*, prevê a criação do **Conselho Nacional do Ministério Público** composto por 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução.

Além da fiscalização administrativa de atos de Ministérios Públicos de todo o País, terá a importante função de formular políticas institucionais, ao elaborar um relatório anual sobre a atuação da Instituição em todo o País e propor as providências que considerar necessárias ao Congresso Nacional.

Ao CNMP compete o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

Texto Constitucional sobre o assunto

CAPÍTULO IV DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

SEÇÃO I DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

§ 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

- a) o Ministério Público Federal;
- b) o Ministério Público do Trabalho;
- c) o Ministério Público Militar;
- d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II - os Ministérios Públicos dos Estados.

§ 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

§ 2º - A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm - art128%C2%A75iie.

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

I o Procurador-Geral da República, que o preside;

II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;

III três membros do Ministério Público dos Estados;

IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:

I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

III requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.



50. Advocacia-Geral da União: representação judicial e extrajudicial da União; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização e funcionamento. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: competência constitucional.

A Advocacia-Geral da União (AGU) é o órgão mais elevado de assessoramento do Poder Executivo. É uma instituição prevista pela Constituição Federal, que a classifica como função essencial à justiça. Por isso, a AGU assume a posição de órgão de direção superior e não está vinculada a nenhum dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

A AGU assessora o presidente da República em assuntos de natureza jurídica e no controle interno da legalidade dos atos da administração, além de sugerir medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público. A instituição também deve garantir que as leis sejam aplicadas corretamente e prevenir e resolver os impasses entre os órgãos jurídicos da administração federal.

A AGU interpreta a Constituição, as leis, os tratados e outros atos normativos, devendo ser seguida uniformemente por órgãos e entidades da administração federal, de maneira que a jurisprudência administrativa no país seja unificada (a jurisprudência é a interpretação da lei com base em decisões de julgamentos anteriores sobre causas semelhantes).

Também é função da AGU orientar normativamente e exercer supervisão técnica dos órgãos jurídicos de autarquias e fundações públicas. O órgão ainda homologa os concursos públicos que selecionam profissionais para as carreiras da própria AGU.

A instituição representa a União, judicial e extrajudicialmente, nos casos em que esta figura como autora, ré ou terceira interessada. São responsáveis por essas atividades os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Procuradores Federais. A representação judicial e a consultoria jurídica das Unidades da Federação são feitas da seguinte forma:

- O Advogado-Geral da União representa a União perante o Supremo Tribunal Federal.

O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo e exerce a representação judicial da União perante o Supremo Tribunal Federal. Submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República, é nomeado dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Além disso, é responsável pela direção da Advocacia-Geral da União, Instituição de Estado classificada pela Constituição como Função Essencial à Justiça, em que assume a posição de órgão de direção superior.

Suas atribuições são as descritas no art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. Delas se destaca:

- Dirigir a Advocacia-Geral da União;
- Representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal;
- Promover a defesa de leis e atos normativos impugnados em ações diretas de inconstitucionalidade;
- Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente;
- Assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
- Assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da Administração;
- Sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público;
- Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal;
- Unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Federal;
- Editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;
- Exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos de autarquias e fundações públicas;
- Homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União.

- O Procurador-Geral da União representa a União perante o Superior Tribunal de Justiça nas questões cíveis e trabalhistas.

- O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, atua na execução da dívida ativa de natureza tributária.

A atuação da PGFN está esquematizada na Lei Complementar 73/1993, a qual define as seguintes competências:

- a) apuração da liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial;
- b) representação da União, na execução de sua dívida ativa de caráter tributário;
- c) exame prévio da legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à dívida pública externa, e promoção da respectiva rescisão por via administrativa ou judicial; e
- d) representação da União nas causas de natureza fiscal.

Na tarefa de arrecadação dos tributos e demais receitas não pagas e inscritas em dívida ativa da União, a PGFN atua perante o Poder Judiciário, mas este não participa da cobrança. Os juízes e toda a estrutura administrativa que lhes dá suporte tratam as execuções fiscais como qualquer outra ação judicial, ou seja, com imparcialidade. Cabe à PGFN fazer a cobrança e não ao Poder Judiciário.

Mas a arrecadação não se restringe ao montante advindo de cobranças judiciais, uma vez que a PGFN arrecada em programas de parcelamento e em decorrência de protestos de Certidões de Dívida Ativa, bem como evita perdas fiscais de grande monta junto ao CARF, situações que não têm qualquer relação direta com as atividades desempenhadas pelo Poder Judiciário.

Isso sem contar a arrecadação indireta que, embora incomensurável, decorre da atuação da PGFN, repercutindo de modo decisivo no pagamento espontâneo dos tributos por pessoas físicas e jurídicas, ao reconhecerem a eficácia na cobrança e defesa empreendidas pela PGFN.

- **Os Procuradores Regionais** representam a União junto aos Tribunais Regionais Federais nas cinco regiões, com sede no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco;

- **Os Procuradores-Chefes** nos Estados representam a União junto à primeira instância nas capitais (Justiça Federal e Trabalhista), e os Procuradores Seccionais e os Escritórios de Representação, junto à primeira instância no interior.

SEÇÃO II DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.



51. Representação judicial e consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal

A advocacia pública é aquela que aconselha ou patrocina interesses de pessoas jurídicas de direito público, interesses em que prevalece não a vontade do agente, mas a da coletividade consagrada no ordenamento constitucional ou legal.

A representação judicial e extrajudicial dos Estados-Membros, além das atividades de consultoria e assessoramento jurídico, é feita pela Procuradoria-Geral do Estado.

Teoricamente, e desde que não haja proibição legal (já que não houve previsão constitucional) os advogados públicos poderão advogar fora das atribuições institucionais, e desde que não violem os interesses da pessoa de direito público em relação à qual pertençam. Cabendo observa-se em cada caso, o que disciplina a lei para cada carreira.

Texto Constitucional sobre o assunto

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.



52. Limitações constitucionais do poder de tributar.

Os tributos são criados de acordo com a competência tributária que a Constituição Federal atribui à União, Estados, Distrito Federal e Município, de modo que é estabelecido parâmetros que tutelam os valores que ela considera relevantes, tais como os direitos e garantias individuais. Sabe-se, assim, que o poder de tributar do Estado não pode ser ilimitado para que não haja violação dos direitos humanos e fundamentais, por isto que a ordem constitucional impõe certos limites ao Estado para a realização de tal atividade. Limitações ao poder de tributar é o conjunto dos princípios e normas que disciplinam os balizamentos da competência tributária.

Neste prisma, limitação ao poder de tributar consiste em instrumentos que limitam a competência tributária do fisco, isto é, a delimitação do poder tributário do Estado de criar e arrecadar tributos.

Os limites ao poder de tributar, ou seja, o exercício da competência tributária desdobra-se nos princípios constitucionais tributários e nas imunidades. Diante dos princípios e das demais normas constantes do texto constitucional, pode-se afirmar que são duas as principais características do sistema tributário:

I) a rigidez, isto é, a Constituição não fornece ao legislador ordinário a liberdade para desenhar-lhe qualquer traço fundamental, uma vez que ela própria determina o campo de cada uma dessas pessoas dotadas de competência tributária;

II) exaustão e complexidade, onde a Constituição estabelece todos os contornos do sistema, pouco relegando à legislação ordinária.

Na mesma linha de pensamento Eduardo Sabbag aduz que:

A Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar, ou seja, limites à invasão patrimonial tendente à percepção estatal do tributo. Essas limitações advêm, basicamente, dos princípios e das imunidades constitucionais tributárias estão inseridas nos arts. 150, 151, e 152 da Carta Magna.

É de se salientar ainda que o Estado não pode agir na seara tributária sem respeitar o contribuinte, de modo a reduzi-lhe a dignidade, a individualidade e a privacidade. O governo não pode, portanto, sob a justificativa da arrecadação violar a Constitucional, isto é, violar os princípios constitucionais, que são os instrumentos dos Direitos Humanos.

Conforme disposto na CF/88, o assunto é tratado em seção própria:

Seção II DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.



53 Ordem econômica e ordem financeira: princípios gerais.

Ordem econômica e financeira

Segundo Uadi Lammêgo Bulos⁸⁴, **ordem econômica e financeira** é o conjunto de normas constitucionais que regulam as relações monetárias entre indivíduos e destes com o Estado.

Seu objetivo é organizar os elementos ligados à distribuição efetiva de bens, serviços, circulação de riquezas e uso da propriedade. Esse é o sentido proposto no Título VII, arts. 170 a 192, da Constituição de 1988, que instaurou entre nós aquilo que os especialistas convencionaram chamar de constituição econômica.

Constituição econômica é a parte da *constituição total*, encarregada de estatuir preceitos reguladores dos direitos e deveres dos agentes econômicos, delimitando, assim, o regime financeiro do Estado.

Dos princípios gerais da atividade econômica

O artigo 170 da Constituição Federal traz em seu corpo os princípios que regem a atividade econômica do Estado, ordem esta, influenciada pelas ideias de capitalismo humanista, já que dispõe o seguinte: *A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:*

a) Soberania nacional: garante a independência nacional para determinar sua política econômica e para adotar outro modelo econômico, evitando assim, a influência de outros países em nossa economia. Com relação aos compromissos econômicos adotados no plano internacional, não tem o condão de modificar o sistema nacional.

b) Propriedade privada: assegura o direito de propriedade (artigo 5º, XXII, CF), consagrando o capitalismo como modelo econômico.

c) Função social da propriedade: é garantido o direito de propriedade, porém ela deve atender sua função social (artigo 5º, XXIII)

d) Livre concorrência: tem como base a livre-iniciativa e a livre-concorrência, que devem ser norteadas pelos ditames da justiça social e da dignidade. A livre concorrência deve ser estimulada, para melhoria da oferta de produtos e preços ao consumidor. O próprio artigo 170, em seu parágrafo único, dispõe que *“é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”*.

⁸⁴ BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª edição. Editora Saraiva. 2014. p. 1515.

e) Defesa do consumidor: consagrado no artigo 5º, XXXII da Constituição como um direito e garantia individual e coletivo, e com suas normas reguladas na Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), é um direito fundamental que protege o consumidor, parte mais fraca da relação de consumo, atendendo ao princípio da vulnerabilidade.

f) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação: a atividade econômica deve respeitar a proteção e defesa do meio ambiente, que é considerado um direito fundamental de terceira dimensão, ligado ao valor “fraternidade”, bem como um princípio da ordem econômica, como aqui é tratado e ainda, como princípio da ordem social. Na ordem econômica deve ser respeitado para defesa de um desenvolvimento sustentável.

g) Redução das desigualdades sociais e regionais: este princípio busca o bem-estar social e também é consagrado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º, III, CF.

h) Busca do pleno emprego: consagra a valorização do trabalho para proteção dos trabalhadores brasileiros em sua estabilidade, para proteção contra despedida arbitrária, bem como verbas remuneratórias e ressarcitórias.

i) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país: de acordo com o artigo 179 da CF, “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, *tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las* pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”. Este tratamento diferenciado tem por fim atender ao princípio da igualdade associado a livre-concorrência, já que estão em posição inferior em relação as grandes empresas.

Do Estado na economia

As normas constitucionais da atividade econômica têm por fim reger a atividade financeira do Estado e estão previstas nos artigos 172 a 181 da Constituição Federal.

Existem três tipos de intervenção da atividade econômica pelo Estado previstos na Constituição:

- Intervenção direta: através da exploração de atividade econômica;
- Intervenção indireta: através da regulação da atividade econômica do estado;
- Intervenção por monopólios: caso em que o Estado reserva determinada atividade econômica à exploração estatal.

Na *atividade econômica de intervenção direta*, o Estado pode explorar atividade econômica ou prestar um serviço público. Neste último caso, o Estado tem todas as proteções necessárias decorrentes do interesse da coletividade que move sua atividade. Já no caso que envolve exploração da atividade econômica, só será permitido ao Estado essa exploração quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou quando for relevante para o interesse coletivo, hipóteses restritas já que se deve preservar a ideia gestão do Estado.

Assim, quando explora a atividade econômica em favor da igualdade de concorrência, se aproxima das regras que se aplicam ao setor privado, exceto na possibilidade de falência, que não se opera na iniciativa pública. Por esse motivo o §2º do artigo 173 da CF, dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

Na *atividade econômica de intervenção indireta*, o Estado, como regulador da atividade econômica exercerá (artigo 174 da CF):

- **Função de fiscalização;**
- **Função de incentivo;**
- **Função de planejamento.**

A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Também, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

Outrossim, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros (Lei nº 11.685/08, conhecida por “Estatuto do Garimpeiro”). As referidas cooperativas terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavrados recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, CF, na forma da lei.

O artigo 178, dispõe sobre ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Quanto a ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

Na *intervenção estatal por monopólios*, inclui-se os **recursos minerais e potenciais de energia hidráulica** e os **monopólios da União**.

Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica: As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (Art. 176, da CF).

A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Monopólios da União: de acordo com o artigo 177 da Constituição Federal, constituem monopólio da União.

- A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos (inciso I);
- A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro (inciso II);
- A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores (inciso III);
- O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem (inciso IV);
- A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do *caput* do art. 21 desta Constituição Federal (inciso V).

A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I e IV, do art. 177 (hipóteses “A” e “D”), observadas as condições estabelecidas em lei.

Prestação de serviços Públicos pelo Estado:

Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos.

Concessão de serviço público é um contrato administrativo de vínculo bilateral, oneroso, entre o poder concedente e concessionário, que deve ser precedido de licitação.

Permissão de serviço público é um ato administrativo discricionário, precário e revogável de forma unilateral.

Como visto acima, compete ao Estado prestar serviços públicos, todavia, ele pode delegar ou descentralizar esta função às pessoas da Administração Indireta, às concessionárias, e às permissionárias de serviços públicos.

Assim, é notável que em comparação com a exploração da atividade econômica, onde o Estado deve ter atuação restrita e excepcional, na prestação de serviço público, o Estado deve ter atuação principal, admitindo-se de forma excepcional a delegação ou descentralização desta função.

Da política urbana

Compete aos Municípios a política de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes fixadas em lei, com o objetivo de *ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes*. A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) fornece as diretrizes gerais.

Plano diretor

É o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo aprovado pela Câmara Municipal.

Função social da propriedade urbana

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências constantes do Plano Diretor (art. 182, § 2º, CF).

Conforme dispõe o art. 182, § 4º da CF, é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- a) Parcelamento ou edificação compulsórios;
- b) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
- c) Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Usucapião constitucional do imóvel urbano (usucapião especial urbano)

Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Independentemente do estado civil, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária

A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação e a habitação para o trabalhador rural.

Estão incluídos no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais

Trata também a CF/88 sobre a destinação de terras públicas e devolutas, prevendo que será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, sendo determinado que a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, com exceção das alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.

Da desapropriação da propriedade rural

Conforme previsto no art. 184 da CF/88, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;

II - a propriedade produtiva.

Segundo a Constituição, a **função social** é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Da usucapião

Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Segundo a Constituição, **é vedada a aquisição de imóveis públicos por usucapião.**

Segue abaixo os dispositivos Constitucionais referentes ao tema:

TÍTULO VII Da Ordem Econômica e Financeira CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Dispositivos constitucionais pertinentes ao tema:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 171. Revogado pela EC nº 06/1995.

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§3º. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

§1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

§3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§2º. É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§3º. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

§4º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.

§2º. A lei a que se refere o §1º disporá sobre:

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;

II - as condições de contratação;

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União.

§3º. A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.

§4º. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a alíquota da contribuição poderá ser:

a) diferenciada por produto ou uso;

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, “b”;

II - os recursos arrecadados serão destinados:

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;

c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

CAPÍTULO III DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

§ 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

§ 2º - O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

§ 3º - Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4º - O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5º - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;

II - a propriedade produtiva.

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:

- I - os instrumentos creditícios e fiscais;
- II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;
- III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
- IV - a assistência técnica e extensão rural;
- V - o seguro agrícola;
- VI - o cooperativismo;
- VII - a eletrificação rural e irrigação;
- VIII - a habitação para o trabalhador rural.

§ 1º - Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

§ 2º - Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária.

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1º - A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

§ 2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.



54 Princípios constitucionais da ordem econômica.

Como já estudado, o artigo 170 da Constituição Federal traz em seu corpo os princípios que regem a atividade econômica do Estado, ordem esta, influenciada pelas ideias de capitalismo humanista, já que dispõe o seguinte: *A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,*

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

a) Soberania nacional: garante a independência nacional para determinar sua política econômica e para adotar outro modelo econômico, evitando assim, a influência de outros países em nossa economia. Com relação aos compromissos econômicos adotados no plano internacional, não tem o condão de modificar o sistema nacional.

A soberania deve ordenar a busca pela efetivação dos objetivos do Estado, ou seja, pelo desenvolvimento do País, e atingindo a finalidade das atividades econômicas, bem como propiciar meios para que o Estado desenvolva políticas públicas com o objetivo de colocar o Brasil em condições iguais perante outras nações no contexto econômico global da atualidade.

b) Propriedade privada: assegura o direito de propriedade (artigo 5º, XXII, CF), consagrando o capitalismo como modelo econômico, temperado, contudo, de acordo com o inc. IV, pela necessária observância à função social, a ser igualmente aplicada à propriedade dos bens de produção.

c) Função social da propriedade: é garantido o direito de propriedade, porém ela deve atender sua função social (artigo 5º, XXIII)

d) Livre concorrência: tem como base a livre-iniciativa e a livre-concorrência, que devem ser norteadas pelos ditames da justiça social e da dignidade. A livre concorrência deve ser estimulada, para melhoria da oferta de produtos e preços ao consumidor. O próprio artigo 170, em seu parágrafo único, dispõe que *“é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”*.

e) Defesa do consumidor: consagrado no artigo 5º, XXXII da Constituição como um direito e garantia individual e coletivo, e com suas normas reguladas na Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), é um direito fundamental que protege o consumidor, parte mais fraca da relação de consumo, atendendo ao princípio da vulnerabilidade.

f) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação: a atividade econômica deve respeitar a proteção e defesa do meio ambiente, que é considerado um direito fundamental de terceira dimensão, ligado ao valor “fraternidade”, bem como um princípio da ordem econômica, como aqui é tratado e ainda, como princípio da ordem social. Na ordem econômica deve ser respeitado para defesa de um desenvolvimento sustentável.

g) Redução das desigualdades sociais e regionais: este princípio busca o bem-estar social e também é consagrado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º, III, CF.

h) Busca do pleno emprego: consagra a valorização do trabalho para proteção dos trabalhadores brasileiros em sua estabilidade, para proteção contra despedida arbitrária, bem como verbas remuneratórias e ressarcitórias.

i) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país: de acordo com o artigo 179 da CF, *“a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”*. Este tratamento diferenciado tem por fim atender ao princípio da igualdade associado a livre-concorrência, já que estão em posição inferior em relação as grandes empresas.



55 Intervenção do Estado no domínio econômico

A partir de uma análise da Constituição brasileira, podemos constatar que a intervenção do Estado no domínio econômico corresponde a todo ato ou medida legal que restrinja, condicione ou tem por fim suprimir a iniciativa privada em determinada área visando o desenvolvimento nacional e a justiça social, assegurados os direitos e garantias individuais

Dentre os motivos para o surgimento da intervenção estatal na economia, despontam o fracasso do mercado e a necessidade de recriá-lo com o Estado assumindo tarefas que sem a sua interferência, poderiam constituir perturbadoras do funcionamento adequado da atividade produtiva – a intervenção teve por fim garantir a livre competição; a eliminação da desigualdade, fruto do liberalismo econômico - o Estado passa a atuar em prol da justiça social por meio de uma distribuição justa de renda; e finalmente o Estado passa a atuar na atividade econômica como empresário com o objetivo de conseguir mais prontamente metas que demandariam maior tempo pelos particulares – Estado empresa.

Liberalismo e intervencionismo.

Liberalismo é o nome dado à doutrina que prega a defesa da liberdade política e econômica. Neste sentido, os liberais são contrários ao forte controle do estado na economia e na vida das pessoas. Em outras palavras, o liberalismo defende a ideia de que o Estado deve dar liberdade ao povo, e deve agir apenas se alguém lesar o próximo (conhecido como Princípio do Dano). No mais, em boa parte do tempo, as pessoas são livres para fazer o que quiserem, o que traz a ideia de livre mercado.

Liberalismo econômico surge com Adam Smith, que pensava que se o governo não interferisse, a economia encontraria por si mesma o ponto de equilíbrio. Do ponto de vista da pureza do pensamento econômico, o liberalismo é claro quanto a participação do Estado que deveria: intervir no mercado para evitar excesso de moeda, defender a moeda, a liberdade econômica, a concorrência, o país das ameaças externas, a propriedade privada, garantir a segurança pública e impedir que as empresas interfiram na livre concorrência, garantindo assim a livre competição.

Em economia, intervencionismo estatal refere-se à interferência do Estado na atividade econômica do país, visando a regulação do setor privado, não apenas fixando as regras do mercado, mas atuando de outras formas com vistas a alcançar objetivos que vão desde o estímulo ao crescimento da economia e à redução de desigualdades até o crescimento do nível de emprego e dos salários, ou à correção das chamadas falhas de mercado. As intervenções típicas dos governos modernos na economia ocorrem no âmbito da definição de tributos, da fixação do salário mínimo, das tarifas de serviços públicos e de subsídios.

Modalidades de intervenção

Existem diversas modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico⁸⁵.

Adotado o aspecto histórico, a intervenção pode compreender: (i) ação governamental – conforme sua manifestação no “período absolutista”, quando o Estado todo poderoso não distinguia onde atuar; (ii) “Estado liberal” - quando as empresas são pequenas e o jogo da livre concorrência é satisfatório, dispensando a intervenção; (iii) sentido “defensivo” – o Estado atua em prol das pequenas empresas contra as grandes organizações privadas, para aliviar os sintomas das crises da economia de mercado; (iv) sentido “preventivo” – o Estado atua para impedir os desajustes, cuja continuação levaria a economia ao caos; (v) intervenção “planejamento” – aperfeiçoamento dos modos de intervenção até se chegar ao planejamento.

Quanto ao critério evolutivo do avanço tecnológico, apresenta-se sob as formas de: (i) estímulo e fomento da iniciativa privada; (ii) pressão sobre a sociedade para imprimir determinado sentido às suas atividades; (iii) prestação de serviços que se ramificam em instituições jurídicas situadas fora de tratamento na área administrativa do Estado.

Ainda, levando-se em conta o avanço tecnológico considera: (i) intervencionismo – com as características de complexidade, voluntariedade e sistematização; dirigismo – com os elementos de organicidade, sistematicidade e coordenação de fins; (ii) planejamento – como a máxima forma quanto à quantidade de ingerência e de sistematização dessa ingerência.

Sob outro prisma, apresentam-se sob as formas de: (i) ofensiva – com a criação de empresas para atuarem em nome do Estado; (ii) defensiva – incluem-se expedientes como o do tabelamento dos preços; (iii) intermediária – encontramos as medidas reguladoras e controladoras.

Deve ser registrado, ainda, a intervenção por (i) “absorção” ou por “participação”, na qual a organização estatal assume ou participa parcialmente ou não do capital da unidade econômica que detém o controle patrimonial dos meios de produção; (ii) intervenção por “direção”, se o organismo estatal pressiona a economia por normas e mecanismos compulsórios; (iii) intervenção por “indução”, quando a manipulação do instrumento de intervenção se faz na conformidade das leis de mercado.

E por fim temos a intervenção em (i) direta – intervenção do Estado empresa e (ii) indireta – se realiza por meio da legislação regulamentadora, bem como a reguladora, em todos os níveis de instrumentos jurídicos (leis, decretos, circulares, portarias, avisos, etc.), sendo estas duas últimas as modalidades mais aludidas pela doutrina.

Apesar de importantes no aspecto acadêmico, a modalidade adotada pelo Estado para atuar na ordem econômica está ligada na sua essência ao modelo econômico adotado.

Intervenção no direito positivo brasileiro

A intervenção do Estado no domínio Econômica está delineada pelos artigos 173 e 174 da Constituição Federal, é de caráter excepcional mas, nem por isso, de somenos importância, sendo a ideologia adotada pelo texto constitucional definidora da forma como essa intervenção se materializa.

“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

⁸⁵ CERVO, Fernando Antonio Sacchetim. *Anotações à intervenção do Estado no domínio econômico*. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 07 nov. 2014. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.50545&seo=1>>. Acesso em: 04 maio 2015.

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Na ausência de atuação ou falta da capacidade privada caberá ao Estado sob os ditames constitucionais do art. 173, explorar a atividade econômica, instrumentalizando sua atuação via empresa pública e/ou sociedade de economia mista.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

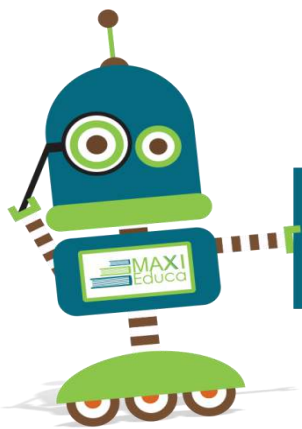
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

§ 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei."

A intervenção indireta do Estado na ordem econômica, está disposta no artigo 174 da Constituição Federal - como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.



56 Meio ambiente.

A Constituição Federal de 1988, tida como inovadora quanto a proteção do meio ambiente, utiliza pela primeira vez em um texto constitucional a expressão "meio ambiente".

O Capítulo VI, inserto no Título VIII da Ordem Social, traz no artigo 225, a noção de direito ao meio ambiente coletivo, dispondo que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Da análise do artigo, temos que:

- a) Todos: o meio ambiente pertence a todos e a cada um ao mesmo tempo, se enquadrando na categoria de direitos transindividuais. É um interesse difuso.
- b) Todos têm direito: trata-se de um direito público subjetivo de natureza difusa, oponível *erga omnes*, completado pelo direito de exercício da ação popular para a proteção ambiental prevista no art. 5º, LXXIII.
- c) Bem de uso comum do povo: significa que o meio ambiente é indisponível, já que não se trata de um bem dominical, não pertence ao domínio público. Refere-se à expressão "todos".

d) **Sadia qualidade de vida:** a sadia qualidade foi uma inovação constitucional, visto que as Constituições brasileiras sempre consagraram o direito à vida, mas sem expressar preocupação com sua qualidade.

e) **Impondo-se ao Poder Público e à coletividade:** trata-se do reconhecimento de que o Poder Público, por si só, não é capaz de cuidar e preservar o meio ambiente. A coletividade, ou seja, a sociedade civil, é **obrigada** a colaborar na proteção.

f) **Presentes e futuras gerações:** trata-se da consagração do princípio da solidariedade intergeracional, à frente delineado.

Segundo a CF/88, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, sendo certo que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

Dispõe o § 4º do artigo 225 da CF que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Como forma de proteção ao meio ambiente, o § 6º dispõe que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Deve ser lembrado que são instrumentos de proteção ao meio ambiente a ação popular e a ação civil pública, conforme dispõe o art. 5º, inc. LXXIII, da CF/88:

“Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

O binômio ilegalidade/lesividade continua sendo, em muitos casos, considerado pela doutrina e jurisprudência essencial para que a ação popular seja considerada procedente. Exceção se observa na ação popular ambiental, bastando a prova do dano ao meio ambiente e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

Em relação à Ação Civil Pública, a CF/88 em seu art. 129, inc. III, atribui como função institucional do Ministério Público *“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”*

CAPÍTULO VI DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

- I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
 - II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
 - III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
 - IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
 - V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
 - VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
 - VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
- § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
- § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
- § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
- § 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
- § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Repartição de competências federativas em matéria ambiental.

A repartição das competências nas Federações é matéria reservada à Constituição, sendo emanção direta da própria estruturação do Estado Federal, caracterizado pela divisão do poder político em diversas esferas, notadamente no Brasil onde o Município é ente federativo. Para José Afonso da Silva, *"competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades para realizar suas funções."*

O que norteia a repartição de competências é a predominância do interesse, segundo o qual caberá à União aquelas matérias de predominante interesse geral, nacional ou regional (quando ultrapassassem mais de um Estado), ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional (*rectius*: estadual), e aos Municípios os predominantes interesses locais.

Assim, diante da dúvida em responder um quesito sobre competência, deve ser verificado sempre qual ente da federação é mais condizente a defesa do meio ambiente em questão.

A Constituição de 1988 busca o equilíbrio federativo (Federalismo cooperativo) através de uma repartição de poderes que se fundamenta na técnica da enumeração de poderes da União, dos poderes remanescentes para os Estados e poderes definidos indicativamente para os Municípios.

Também verificamos áreas comuns de atuação paralela e setores concorrentes entre União e Estados, em que se outorga à primeira as normas gerais e aos últimos as normas específicas (CF, art. 24, §§ 1º e 2º), bem como, e ainda, suplementação pela legislação municipal nos casos de interesse local (CF, art. 30, I e II).

Assim, nos artigos 21 e 23 da CF (artigos ímpares) temos as competências administrativas, enquanto que nos arts. 22 e 24 (artigos pares) temos as competências legislativas

Subdividem-se, pois, as competências em:

	a) exclusiva (art. 21)	União
--	------------------------	-------

Administrativa ou Material	b) comum, cumulativa ou paralela (art. 23)	União, Estados, DF e Município
Legislativa ou formal	a) privativa (art. 22)	União
	b) concorrente (art. 24)	União, Estados e DF
	c) suplementar (art. 24, §2º e 30, I e II)	Estados e Municípios
	d) exclusiva (art. 25, §§1º e 2º)	Estados

Competência Legislativa

A CF/88 atribuiu competência legislativa concorrente sobre assuntos do meio ambiente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, conforme dispõe o art. 24, VI e VII, sendo que à União caberá legislar sobre normas gerais, enquanto os Estados e DF deverão complementar essas normas.

A concorrência enseja a possibilidade de iniciativa na área da legislação ambiental para os Estados e DF se a União se mantiver inerte. Entretanto, essa competência, chamada “plena” (chamada também de competência supletiva), não pode exorbitar da peculiaridade ou interesse do próprio Estado (limite qualitativo) e terá que se ajustar ao disposto em norma federal superveniente (limite temporal), a qual suspenderá a legislação estadual no que for incompatível. A competência concorrente poderá exercer-se não só quanto à elaboração de leis, mas de decretos, resoluções e portarias.

Aos Municípios também é atribuída competência legislativa, porém ela é suplementar supletiva, determinando o art. 30, II, competir a eles suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Em suma: À União cabe a fixação de pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, enquanto aos Estados, DF e Municípios, atendendo aos interesses regionais e locais, a de um “teto” de proteção. Assim, os Estados, DF e Municípios jamais poderão legislar de modo a oferecer menos proteção ao meio ambiente do que a união, nas normas que forem nacionais, e não nas federais.

Pode-se concluir que a competência legislativa em matéria ambiental estará sempre privilegiando a maior e mais efetiva preservação do meio ambiente, independentemente do ente político que a realize, porquanto todos receberam da Carta Constitucional aludida competência.

Competência Material

Competência material é a competência administrativa propriamente dita, que atribui a uma esfera de poder o direito de fiscalizar e impor sanções em caso de descumprimento da lei.

Em regra, o policiamento de determinada atividade é da atribuição da pessoa de Direito Público interno dotada de competência legislativa sobre a mesma. Contudo, a Constituição atribuiu, pela primeira vez, separadamente, competências administrativas, as quais eram, até então, automaticamente incluídas nas competências legislativas correspondentes.

O art. 23, VI e VII, da CF dispõe que os três níveis da federação têm competência para tomar medidas em prol da defesa do meio ambiente, da flora e fauna, contra poluição etc., ficando agora ao critério das prefeituras executar também normas federais ou estaduais, quando necessário.

A proteção do meio ambiente está adaptada à competência material comum, ou seja, é atribuída a todos os entes federados que, em pé de igualdade, exercem-na, sem, todavia, excluir a do outro, porquanto cumulativa. É prevista no art. 23 da CF/88.

Por vezes, o fato de a competência ser comum a todos os entes federados poderá tornar difícil a tarefa de discernir qual norma administrativa será a mais adequada a uma determinada situação. Os critérios que deverão ser verificados para tal análise são:

1. O critério da predominância do interesse;

2. O critério da colaboração ou cooperação entre os entes federados, conforme prevê o p. único do art. 23. Desse modo, deve-se buscar, como regra, privilegiar a norma que atenda de forma mais efetiva ao interesse comum.

A Lei complementar prevista no art. 23, p. único da CF/88, deve ter como fundamento a mútua ajuda dos entes federados. Essa lei não visa e não pode visar à diminuição da autonomia desses entes, despojando-os de prerrogativas e de iniciativas que constitucionalmente possuem, ainda que não as exerçam, por falta de meios ou de conscientização política. Essa Lei Complementar foi editada (LC nº 140/11).

Os trabalhos de proteção e cooperação relativos ao meio ambiente já vêm sendo feitos conjuntamente pelos órgãos federais e estaduais com a formulação do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente, concebido pela Lei nº 6.938/81.

O CONAMA, através da Resolução nº 237/97, procurou partilhar a competência ambiental administrativa, dispondo sobre o licenciamento ambiental a ser feito pelo IBAMA (art. 4º), estabelecendo as competências dos Estados e DF (art. 5º), determinando a área de competência dos Municípios (art. 6º) e estabelecendo que os empreendimentos e atividades serão licenciados em um nível de competência (art. 7º).

Sobre a atuação do CONAMA em matéria de licenciamento, há o preceito no art. 8º, I da Lei nº 6.938/81, que diz que compete ao CONAMA “I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA”. O inciso é claro, mostrando que instituir normas e critérios para o licenciamento não se confunde com atribuir competência aos entes federados, verificando-se explícita invasão de competência e quebra de hierarquia administrativa, acarretando vício de inconstitucionalidade e ilegalidade aos artigos da resolução supracitada.

Leis infraconstitucionais não podem repartir ou atribuir competências, a não ser que a própria Constituição da República tenha previsto essa situação, como fez expressamente no art. 23, p. único, quando previu que a competência comum estabelecendo normas de cooperação será objeto de lei complementar.

Competência Exclusiva da União

Além da competência comum vista acima, a União possui competência administrativa exclusiva em matéria ambiental, nos termos do art. 21 da CF/88:

Art. 21. Compete à União:

IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

XV – organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

XXII – executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.

XXV – estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

Os recursos minerais pertencem à União, e não ao proprietário do solo, cabendo, portanto, à administração federal, autorizar a sua exploração. O mesmo pode ser sustentado em relação à pesquisa e à lavra das jazidas de petróleo.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

§ 4º - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.

Com relação às atividades nucleares, pela importância e gravidade da matéria, pelos riscos decorrentes da má administração e pela responsabilidade do Brasil, não apenas para com os seus cidadãos, mas também com os demais Estados, a União exerce o monopólio da sua exploração.

Espaços territoriais especialmente protegidos

Foi incumbido ao poder público, no art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, o dever de definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos a fim de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ademais, a Constituição da República prevê, em seus dispositivos, os seguintes instrumentos ou obrigações impostos ao Poder Público:

a) **Preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais:** processos ecológicos essenciais são os governados, sustentados ou intensamente afetados pelos ecossistemas, sendo indispensáveis à produção de alimentos, à saúde e outros aspectos da sobrevivência humana e do desenvolvimento sustentável. Cuida-se de garantir, através de ações conjugadas de todas as esferas e modalidades do Poder Público, o que se encontra em boas condições originais, e de recuperar o que foi degradado.

b) **Manejo ecológico das espécies e ecossistemas:** manejo ecológico é a gestão e utilização dos recursos naturais pelo homem, baseada em princípios e métodos que preservam a integridade dos ecossistemas, com redução da interferência humana nos mecanismos de autorregulação dos seres vivos e do meio físico.

c) **Preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético** do País e fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético: essa proteção foi prevista na Lei nº 11.101/05 e na Convenção da Diversidade Biológica de que o Brasil é signatário. No dizer da Convenção da Biodiversidade, esta vem a ser a variedade de seres que compõe a vida na Terra, a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo, ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas. Preservar a biodiversidade, significa reconhecer, inventariar, e manter o leque dessas diferenças de organismos vivos. Hoje existe uma grande preocupação no diz respeito ao patrimônio genético.

d) **Definição, em todas as unidades da Federação, de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos**, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que **comprometa a integridade dos atributos** que justifiquem sua proteção:

trata-se da expressa previsão das **unidades de conservação** pela Constituição da República, que são espaços especialmente protegidos, seja integral ou parcialmente. Importante ressaltar que a vedação da utilização não ficou unificada para todos os tipos de unidades de conservação, variando conforme o tipo de unidade, já que a própria instituição e tipificação dependem dos atributos que se reconhecem e que se quer proteger. Veja que a própria Constituição impõe que **somente lei poderá alterar ou suprimir** tais espaços.

e) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que **se dará publicidade**: previsão expressa do EIA, acrescentando expressamente a Constituição o fato de que os estudos devem ser prévios, a fim de evitar interpretações maquiavélicas. Inclusive, o **STF** várias vezes já julgou que não podem os demais entes dispensar o EIA; o que eles podem fazer é criar controles mais rígidos.

f) Controle da produção, comercialização e emprego de técnicas que comportem risco para a vida e meio ambiente: essa disposição constitucional foi disciplinada, em parte, pela lei que regula a disposição no meio ambiente de agrotóxicos

g) Promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente: educação ambiental prevista na Lei nº 9.795/99.

h) Proteção da fauna e flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade: a proteção à fauna foi prevista na Lei nº 5.179/67, enquanto a proteção à flora, no Código Florestal, Lei nº 4.771/65.

i) Imposição da obrigação de **recuperar o meio ambiente** degradado por aquele que **explorar recursos minerais**: trata-se de uma especial obrigação imposta pela CR aos exploradores de recursos minerais, tendo em vista o histórico de degradação deixado pela exploração desse setor. A atividade da mineração possui interface direta com a realidade do meio ambiente, dado que não há como extrair um mineral sem danos.

j) Sujeição dos infratores pessoas físicas e jurídicas praticantes de condutas consideradas lesivas ao meio ambiente a sanções penais e administrativas, **independentemente da obrigação de reparar o dano**: consagração da tríplice responsabilização, penal, administrativa e civil, sendo esta última independente (isso não quer dizer que as causas absolutórias penais que fazem coisa julgada no cível não obstarão a liberação da responsabilidade civil).

k) Especial preservação, na forma da lei, da floresta amazônica, serra do mar, mata atlântica, pantanal mato-grossense e da Zona Costeira: Tão grande foi a preocupação do legislador constitucional com a manutenção desses vastos territórios, que os considerou **patrimônio nacional**, estabelecendo, em consonância com a devida proteção aos direitos de terceira geração, uma limitação ao seu uso, que só se dará na forma da lei e dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. A expressão patrimônio nacional, a que se refere o dispositivo, não tem, à evidência, o sentido de propriedade federal ou do Estado, mas de riqueza que, neste país, herdamos com a obrigação de preservar e transmitir às gerações futuras, sem perda, é claro, de seu adequado aproveitamento econômico. Deveras, qualificado como bem de uso comum do povo, não integra o patrimônio disponível do Estado. Portanto, o Estado não atua jamais como proprietário deste bem, mas, diversamente, como simples administrador de um patrimônio que pertence à coletividade.

l) Obrigatoriedade de lei federal prever a localização de usinas nucleares para que possam ser instaladas:



57 Direitos e interesses das populações indígenas.

A Constituição Federal de 1988, trouxe importantes inovações no tocante ao reconhecimento dos direitos indígenas como um todo, além do reconhecimento aos direitos territoriais sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Foi assegurado aos povos indígenas o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

Pela primeira vez reconhece-se aos índios no Brasil o direito à diferença, ou seja, de serem índios e de permanecerem como tal indefinidamente, abandonando a perspectiva assimilacionista que entendia os índios como uma categoria social transitória, fadada ao desaparecimento.

O texto constitucional traz como inovação a previsão de que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária, anteriores à formação do próprio Estado, existindo independentemente de qualquer reconhecimento oficial. Nesse sentido, é o previsto no caput do artigo 231: ***"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens."***

Destaque-se, que o texto em vigor eleva também à categoria constitucional o próprio conceito de terras indígenas, que assim se define, no parágrafo 1º do mesmo artigo: ***"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições."***

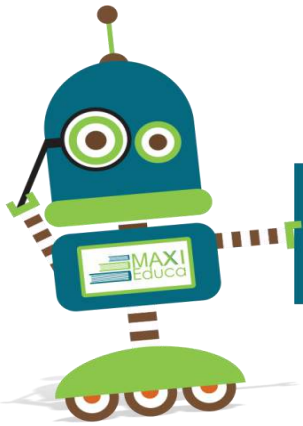
A previsão constitucional estabelece que, presentes os elementos necessários para definir uma determinada área de terra como indígena, o direito à ela por parte da sociedade indígena que a ocupa, existe e se legitima independentemente de qualquer ato constitutivo. A demarcação de uma terra indígena, fruto do reconhecimento feito pelo Estado é ato meramente declaratório, cujo objetivo é simplesmente precisar a real extensão da posse para assegurar a plena eficácia do dispositivo constitucional, que impõe ao Estado a obrigação de protegê-la.

Prevê, ainda, o texto constitucional no que diz respeito aos índios:

- o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas;
- que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos aí os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra;
- garantia da inalienabilidade e indisponibilidade das terras indígenas e a imprescritibilidade dos direitos sobre elas;
- a proibição da remoção dos índios das suas terras;
- a nulidade de todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas;
- a legitimidade dos índios, suas comunidades e organizações para ingressarem em juízo em defesa de seus direitos e interesses.

Por fim, deve ser observado que a Constituição não fala em tutela ou em órgão indigenista, mas mantém a responsabilidade da União de proteger e fazer respeitar os direitos indígenas. Apesar de não tratar de maneira expressa da capacidade civil, a Constituição reconheceu no seu Artigo 232, a capacidade processual ao dizer que ***"os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo, em defesa dos seus direitos e interesses"***. Significa que os índios podem, inclusive, entrar em juízo contra o próprio Estado, o seu suposto tutor.

O Novo Código Civil (2002) retira os índios da categoria de relativamente incapazes e dispõe que a capacidade dos índios será regulada por legislação especial, o que ainda se encontra pendente de regulamentação desde a promulgação da Constituição.



58 Interesses difusos e coletivos.

A Constituição Federal de 1988 tutela os direitos difusos e coletivos; o art. 129, III, da CF/88, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público, destaca a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

A previsão constitucional, além de reconhecer os interesses difusos e, ao mesmo tempo, destinar a sua proteção ao Ministério Público, demonstra não se tratar de norma meramente programática, mas preceptiva ou atributiva de direitos. A própria Constituição confere os meios de investigação, constantes do inquérito civil, e o instrumento de proteção judicial, a ação civil pública. Dispõe, inclusive, sobre a titularidade da ação, ao conferi-la ao Ministério Público.

Nesse sentido, o art. 5.º, LXXIII, da Carta Constitucional, que trata da ação popular, também reconhece a existência de interesses difusos e coletivos e estabelecendo que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A Magna Carta reconhece os interesses difusos e coletivos e impõe a sua proteção pelo próprio cidadão, conforme os direitos e garantias fundamentais, por meio da ação popular. A Constituição Federal não somente reconheceu a existência dos interesses difusos e coletivos, mas também estabeleceu um "sistema de garantia" desses interesses, definindo titulares do direito à proteção e instrumentos jurídicos de proteção, ao conferi-la ao Ministério Público, por intermédio do inquérito civil e da ação civil pública, e ao cidadão, por meio da ação popular.

Ao Ministério Público coube a titularidade ampla, uma vez que poderá tutelar, além dos interesses especificamente mencionados pela Constituição, como o meio ambiente e o patrimônio público e social, os demais interesses difusos e coletivos, conforme a fórmula genérica utilizada pelo mencionado art. 129 da CF/88.

Aos cidadãos coube também uma titularidade, mas restrita, uma vez que a ação popular somente pode ter por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O texto constitucional não define os interesses difusos, tarefa realizada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que, em seu art. 82, I, os reconhece como interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indetermináveis e ligadas por circunstâncias de fato.

São tratados diversos temas sobre o assunto através de dispositivos constitucionais, conforme adiante estudados.

O meio ambiente na Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988, tida como inovadora quanto a proteção do meio ambiente, utiliza pela primeira vez em um texto constitucional a expressão "meio ambiente".

O Capítulo VI, inserto no Título VIII da Ordem Social, traz no artigo 225, a noção de direito ao meio ambiente coletivo, dispondo que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Da análise do artigo, temos que:

- Todos: o meio ambiente pertence a todos e a cada um ao mesmo tempo, se enquadrando na categoria de direitos transindividuais. É um interesse difuso.

- Todos têm direito: trata-se de um direito público subjetivo de natureza difusa, oponível *erga omnes*, completado pelo direito de exercício da ação popular para a proteção ambiental prevista no art. 5º, LXXIII.
- Bem de uso comum do povo: significa que o meio ambiente é indisponível, já que não se trata de um bem dominical, não pertence ao domínio público. Refere-se à expressão “todos”.
- Sadia qualidade de vida: a sadia qualidade foi uma inovação constitucional, visto que as Constituições brasileiras sempre consagraram o direito à vida, mas sem expressar preocupação com sua qualidade.
- Impondo-se ao Poder Público e à coletividade: trata-se do reconhecimento de que o Poder Público, por si só, não é capaz de cuidar e preservar o meio ambiente. A coletividade, ou seja, a sociedade civil, é **obrigada** a colaborar na proteção.
- Presentes e futuras gerações: trata-se da consagração do princípio da solidariedade intergeracional, à frente delineado.

A Defesa do Consumidor

A Constituição Federal de 1988 trata em três artigos, fundamentalmente, da proteção ao consumidor dentro da relação de consumo, quais sejam os arts. 5.º, XXXII, 150, § 5.º, e 170, V. A defesa do consumidor é um dos direitos fundamentais do indivíduo e um dos princípios da ordem econômica do Estado, conforme a disposição da norma constitucional. Essa novidade da Constituição de 1988 demonstrou a preocupação do Poder Constituinte com a proteção do consumidor, em relação aos seus direitos básicos, uma vez que o mercado de consumo não apresenta em si mesmo mecanismos para superar a hipossuficiência econômica do consumidor.

Pode também ser afirmado que a Constituição estabeleceu em seu art. 5.º, XXXII, o "princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público" para a proteção dos interesses dos consumidores, ao fixar o dever do Estado de promover, na forma determinada na lei, a defesa do consumidor.

Da família, da criança, do adolescente e do idoso

A família: é tida pelo texto constitucional como base da sociedade, tendo especial proteção do Estado; é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, é a chamada **família monoparental**.

O casamento é civil e gratuita a sua celebração, sendo que o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Aos cônjuges, a Constituição assegura o exercício dos direitos e deveres em igualdade, sendo possível a dissolução do casamento pelo divórcio.

Como postulado da Constituição, os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável são expressos ao dispor sobre o planejamento familiar como livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Cabe também ao Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, como caso das disposições penais e legislação visando coibir a violência doméstica, contra a mulher e contra o idoso.

Tutela da criança e do adolescente: A Constituição impõe como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

- I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
- II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

A proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

- I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
- II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
- III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
- IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
- V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;
- VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
- VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

A Constituição impõe como dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, sendo que aos filhos maiores cabe o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, sendo que a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros, os quais são considerados todos aqueles residentes fora do Brasil, independentemente da nacionalidade.

Segundo o art. 228, são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial, sendo prevista a punição severa do abuso, violência e exploração sexual da criança e do adolescente através de lei.

Tutela de idosos: vários dispositivos mencionam a velhice como objeto de direitos específicos, como o previdenciário (201, I, da CF/88), assistencial (203, I, da CF/88); o art. 230 estatui que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

CAPÍTULO VII

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º A lei estabelecerá:

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.

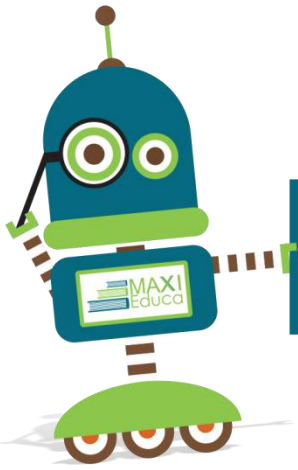
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.



Questões

*Fonte: Questões comentadas – Marcela Almendros; Guilherme Moraes Cardoso e Bruna Pinotti Garcia – 1ª Edição. Tupã – SP – Maxi Educa, 2014.

1. **(TJ/MG - Juiz - FUNDEP/2014)** Sobre o conceito de Constituição, assinale a alternativa CORRETA.
 - (A) É o estatuto que regula as relações entre Estados soberanos.
 - (B) É o conjunto de normas que regula os direitos e deveres de um povo.
 - (C) É a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação, à formação dos poderes públicos, direitos, garantias e deveres dos cidadãos.
 - (D) É a norma maior de um Estado, que regula os direitos e deveres de um povo nas suas relações.

2. **(TJ/MG - Juiz - FUNDEP/2014)** Dentre as formas de classificação das Constituições, uma delas é quanto à origem.
 Em relação às características de uma Constituição quanto à sua origem, assinale a alternativa CORRETA.
 - (A) Dogmáticas ou históricas.
 - (B) Materiais ou formais.
 - (C) Analíticas ou sintéticas.
 - (D) Promulgadas ou outorgadas.

3. **(TJ/MG - Juiz - FUNDEP/2014)** Sobre a supremacia da Constituição da República, assinale a alternativa CORRETA.
 - (A) A supremacia está no fato de o controle da constitucionalidade das leis só ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
 - (B) A supremacia está na obrigatoriedade de submissão das leis aos princípios que norteiam o Estado por ela instituído.
 - (C) A supremacia está no fato de a interpretação da constituição não depender da observância dos princípios que a norteiam.
 - (D) A supremacia está no fato de que os princípios e fundamentos da constituição se resumam na declaração de soberania.

4. **(TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014)** Em relação à natureza e classificação das normas constitucionais, é correto afirmar:
 - I. o preâmbulo não se situa no âmbito do Direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do constituinte e não apresentando, portanto, força normativa, nem criando direitos ou obrigações.
 - II. o ADCT, ou Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não tem natureza de norma constitucional, tratando-se de mera regra de transição, interpretativa e paradigmática.
 - III. a interpretação conforme a Constituição pressupõe uma Constituição rígida e, em decorrência, a supremacia hierárquica das normas constitucionais perante o ordenamento jurídico, normas essas que obedecem ao princípio da presunção de constitucionalidade.
 Está correto o que se afirma em
 - (A) III, apenas.
 - (B) I e II, apenas.

- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

5. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) As denominadas Constituições legais ou inorgânicas caracterizam-se por

- (A) inadmitir controle de constitucionalidade das leis.
- (B) dispor de forma insuficiente ou incompleta sobre a organização política do Estado, requerendo complementação legislativa de forma a tornar viável o efetivo funcionamento do sistema político por ela instituído.
- (C) circunscrever sua disciplina normativa à organização política do Estado, sem contemplar declaração de direitos e garantias fundamentais.
- (D) contemplar expressivo conjunto de normas apenas formalmente constitucionais.
- (E) ter seu conteúdo disperso em diversos textos normativos.

6. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) Considerando que a federação é cláusula pétrea, é possível a edição de emenda à constituição que afete a partilha de competências entre os entes federativos?

- (A) Sim, é possível alterar a partilha de competências, desde que se preservem as de caráter financeiro.
- (B) Não, sendo cláusula pétrea, toda e qualquer medida que, mesmo tendencialmente, venha a afetar o princípio federativo, não poderá ser objeto de deliberação parlamentar.
- (C) A federação não é cláusula pétrea
- (D) Nenhuma alternativa anterior é verdadeira.

7. (EMPLASA - Analista Jurídico - Direito - VUNESP/2014) Considerando o conteúdo das constituições, estas podem ser

- (A) meio de resolução de conflitos, pois consagram processos de decisão.
- (B) democráticas, que possuem sua origem na manifestação da vontade popular.
- (C) materiais, por suas normas tratarem de matérias especificamente constitucionais, como os direitos fundamentais.
- (D) ortodoxas, em razão de sua elaboração com base em um único e centralizado pensamento ideológico.
- (E) unitárias, quando seu conteúdo se concentra em um único documento.

8. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e da classificação das constituições, julgue os itens a seguir.

Diferentemente das constituições sintéticas, as quais se limitam às regras básicas constitucionais, as constituições semânticas extrapolam o essencial para constitucionalizar variadas matérias adicionais e estabelecer, de forma dirigente, objetivos a serem atingidos pelo legislador ordinário.

- Certo ()
- Errado ()

9. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e da classificação das constituições, julgue os itens a seguir.

Do ponto de vista jurídico, a constituição funda as bases do ordenamento jurídico, contendo, em seu corpo, disposições estruturais acerca do funcionamento do Estado, seus entes e órgãos, e dos limites à atuação estatal, quais sejam, os direitos e garantias fundamentais do cidadão.

- Certo ()
- Errado ()

10. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e da classificação das constituições, julgue os itens a seguir.

Normas materialmente constitucionais encerram disposições a respeito de matéria tipicamente constitucional, isto é, de elementos inerentes à constituição, ao passo que as normas formalmente constitucionais, embora não tratem de matéria constitucional, são constitucionais, do ponto de vista eminentemente formal, somente porque integram a constituição.

- Certo ()
- Errado ()

11. (PGE/PI - Procurador do Estado Substituto - CESPE/2014) Acerca da interpretação das normas constitucionais, assinale a opção correta.

(A) Em razão do caráter aberto e indeterminado de muitas de suas normas, a CF admite o fenômeno da construção jurídica, sem que isso configure necessariamente usurpação de poder constituinte.

(B) Lacunas constitucionais devem ser preenchidas por meio dos processos formais de mudança constitucional, não se admitindo a via interpretativa como mecanismo de solução dessas deficiências.

(C) A existência de métodos específicos de interpretação constitucional exclui a incidência dos métodos tradicionais.

(D) A normatividade constitucional não é compatível com as chamadas normas implícitas.

(E) Interpretação extensiva e analogia são procedimentos estranhos ao direito constitucional.

12. (TJ/DF - Juiz - CESPE/2014) No que se refere à aplicabilidade e à interpretação das normas constitucionais, assinale a opção correta.

(A) Conforme o método de interpretação denominado científico-espiritual, a análise da norma constitucional deve-se fixar na literalidade da norma, de modo a extrair seu sentido sem que se leve em consideração a realidade social.

(B) As denominadas normas constitucionais de eficácia plena não necessitam de providência ulterior para sua aplicação, a exemplo do disposto no art. 37, I, da CF, que prevê o acesso a cargos, empregos e funções públicas a brasileiros e estrangeiros.

(C) O dispositivo constitucional que assegura a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos não configura norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois demanda uma lei integrativa infraconstitucional para produzir efeitos.

(D) A norma constitucional de eficácia contida é aquela que, embora tenha aplicabilidade direta e imediata, pode ter sua abrangência reduzida pela norma infraconstitucional, como ocorre com o artigo da CF que confere aos estados a competência para a instituição de regiões metropolitanas.

(E) Conforme o método jurídico ou hermenêutico clássico, a Constituição deve ser considerada como uma lei e, em decorrência, todos os métodos tradicionais de hermenêutica devem ser utilizados na atividade interpretativa, mediante a utilização de vários elementos de exegese, tais como o filológico, o histórico, o lógico e o teleológico.

13. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) Pelo princípio da justeza ou da conformidade funcional da Constituição Federal,

(A) as normas constitucionais devem ser interpretadas no sentido de terem a mais ampla efetividade social, reconhecendo a maior eficácia possível aos direitos fundamentais.

(B) partindo da ideia de unidade da constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre esses bens e princípios, por inexistir hierarquia entre eles.

(C) o intérprete máximo da constituição, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer sua força normativa, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário.

(D) as normas constitucionais devem ser interpretadas em sua globalidade, afastando-se as aparentes antinomias legais.

(E) na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve-se dar primazia aos critérios que favoreçam a integração política e social, e o reforço da unidade política do estado.

14. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) É INCORRETO afirmar que, na interpretação da norma constitucional, por meio do método

(A) hermenêutico-concretizador, parte-se da norma constitucional para o problema concreto, valendo-se de pressupostos subjetivos e objetivos e do chamado círculo hermenêutico.

(B) jurídico ou hermenêutico clássico, a constituição deve ser encarada como uma lei e, assim, todos os métodos tradicionais de exegese deverão ser utilizados na tarefa interpretativa.

(C) tópico-problemático, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático visando à solução dos problemas concretizados.

(D) normativo-estruturante, esta terá de ser concretizada tão-só pela atividade do legislador, excluindo-se os demais poderes federais.

(E) científico-espiritual, a sua análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto constitucional.

15. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) No tocante à eficácia e à aplicabilidade das normas constitucionais, as

(A) definidoras dos direitos e garantias fundamentais são programáticas, dependendo sempre de regulamentação infraconstitucional.

(B) de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade indireta e imediata, não integral, produzindo efeitos restritos e limitados infraconstitucionalmente quando de sua promulgação.

(C) de eficácia limitada são de aplicabilidade mediata e diferida, mas sem vinculação com as normas infraconstitucionais subsequentes, ou seja, sem relevância jurídica interpretativa e integrativa.

(D) de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral são aquelas normas que, no momento em que a constituição entra em vigor, já estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional.

(E) declaratórias de princípios programáticos veiculam programas a serem implementados pelos cidadãos, sem interferência estatal, visando à realização de fins sociais e culturais.

16. (TJ/RJ - Juiz Substituto - VUNESP/2014) A propósito da ação direta de inconstitucionalidade, é correto afirmar que

(A) precisam demonstrar pertinência temática para a propositura da ação os seguintes legitimados: governador de Estado; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

(B) a concessão de liminar em sede de medida cautelar na ação não admite a restauração de vigência da legislação anterior, acaso existente, o que somente ocorrerá no julgamento definitivo de procedência do pedido da ação.

(C) nas ações propostas por Estado da Federação, a petição inicial deve ser firmada, exclusivamente, pelo Procurador-Geral do Estado em nome do Governador.

(D) são passíveis de ser objeto da ação: as leis e os atos normativos federais e estaduais, medidas provisórias, decreto do Chefe do Executivo que promulga tratados e convenções e emendas constitucionais.

17. (PC/TO - Delegado de Polícia - Aroeira/2014) Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, entre outros, o:

(A) Governador de Estado ou do Distrito Federal.

(B) Presidente do Senado Federal.

(C) Presidente da Câmara dos Deputados.

(D) Presidente de Assembleia Legislativa.

18. (SEFAZ/RJ - Auditor Fiscal da Receita Federal - FCC/2014) Suponha que o Advogado-Geral da União proponha ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a constitucionalidade de três artigos de lei estadual do Rio de Janeiro em face da Constituição da República. Conforme a disciplina constitucional a respeito do controle de constitucionalidade concentrado,

(A) o Advogado-Geral da União não possui legitimidade para propor ADIN.

(B) o STF deve remeter os autos do processo para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

(C) não se pode propor ADIN para questionar apenas parte de lei.

(D) o STF deve converter a ADIN em recurso extraordinário para que seja viável analisar o pedido da ação.

(E) lei estadual não pode ser objeto de ADIN.

19. (TRT/18ª REGIÃO/GO - Juiz do Trabalho - FCC/2014) Considerando a disciplina jurídica do controle de constitucionalidade e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria,

(A) súmula vinculante pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade que, se julgada procedente, produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública direta, indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

(B) ato administrativo que contrarie súmula vinculante não pode ser objeto de reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a reclamação é cabível apenas contra decisão judicial, que poderá ser cassada pelo STF, com a determinação de que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

(C) o cabimento do recurso extraordinário está sujeito à demonstração da existência de repercussão geral das questões discutidas no caso, podendo o STF recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros.

(D) a aprovação de súmula vinculante, a qual poderá ser provocada pelos legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, produzirá efeitos vinculantes apenas em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública direta, mas não em relação à Administração pública indireta e ao Poder Legislativo

20. (PC/SP - Delegado de Polícia - VUNESP/2014) Pode(m) propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal:

- (A) partido político sem representação no Congresso Nacional.
- (B) os Conselhos Federais de órgãos de classe profissional.
- (C) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional.
- (D) a Mesa da Câmara dos Deputados.
- (E) o Procurador-Geral de Justiça.

21. (TJ/SE - Titular de Serviços de Notas e de Registro - CESPE/2014) Assinale a opção correta de acordo com a disciplina constitucional, legal e jurisprudencial referente ao controle de constitucionalidade.

(A) No processamento de ação direta de inconstitucionalidade, o relator poderá, em despacho irrecurável, admitir o ingresso de assistente simples que tenha interesse no julgamento da causa.

(B) A legitimidade ativa para a propositura de representação interventiva estadual está restrita ao procurador-geral de justiça.

(C) De acordo com o STF, o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle abstrato atinge inclusive o Poder Legislativo, que ficará proibido de legislar em sentido diverso ao precedente fixado pela corte constitucional.

(D) Conforme a CF, o controle de constitucionalidade das leis é realizado somente de forma repressiva.

(E) Segundo o STF, a ação direta de inconstitucionalidade pode ser utilizada para questionar lei federal anterior à CF, desde que seja relevante o fundamento da controvérsia.

22. (TJ/MT - Juiz de Direito - FMP/2014) Assinale a alternativa correta.

Todas as leis e atos normativos são presumidos inconstitucionais, até que haja prova em contrário.

(A) A ação direta de inconstitucionalidade não admite o contraditório.

(B) É possível a concessão de medida liminar nas ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

(C) O controle de constitucionalidade difuso somente é exercido pelos tribunais superiores.

(D) O cidadão pode propor ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo federal que contrarie diretamente a Constituição da República.

23. (TRF/4ª REGIÃO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal - FCC/2014) A ação constitucional típica, na qual se discute relevante fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, denomina-se:

- (A) Ação civil pública.
- (B) Ação direta de inconstitucionalidade.
- (C) Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- (D) Ação direta declaratória de constitucionalidade.
- (E) Ação popular.

24. (TRF/4ª REGIÃO - Juiz Substituto - TRF 4ª REGIÃO/2014) Assinale a alternativa correta.

(A) O controle de constitucionalidade na modalidade concentrada foi introduzido no Brasil pela:

- (B) Constituição Federal de 1934.
- (C) Constituição Federal de 1891.
- (D) Constituição Federal de 1988.
- (E) Emenda Constitucional nº 7/77.
- (F) Emenda Constitucional nº 16/65.

25. (TRF/4ª REGIÃO - Juiz Substituto - TRF 4ª REGIÃO/2014) Assinale a alternativa correta.

A Ação Declaratória de Constitucionalidade foi introduzida no Direito Constitucional brasileiro pela:

- (A) Emenda Constitucional nº 16/65.

- (B) Constituição Federal de 1967.
- (C) Emenda Constitucional nº 7/77.
- (D) Constituição Federal de 1988.
- (E) Emenda Constitucional nº 3/93.

26. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) A propósito dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, reconhece-se que:

- (A) o pluralismo político está inserido entre seus objetivos.
- (B) a livre iniciativa é um de seus fundamentos e se contrapõe ao valor social do trabalho.
- (C) a dignidade é também do nascituro, o que desautoriza, portanto, a prática da interrupção da gravidez quando decorrente de estupro.
- (D) a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, é um de seus objetivos.
- (E) o legislativo, o executivo e o judiciário, dependentes e harmônicos entre si, são poderes da união.

27. (DPE/DF - Analista - Assistência Judiciária - FGV/2014) Sobre os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, à luz do texto constitucional de 1988, é INCORRETO afirmar que:

- (A) a República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
- (B) a República Federativa do Brasil tem como objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- (C) todo o poder emana do povo, que o exerce unicamente por meio de representantes eleitos.
- (D) entre outros, são princípios adotados pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, os seguintes: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- (E) a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a defesa da paz são princípios regedores das relações internacionais da República Federativa do Brasil.

28. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador- FCC/2014) Entre os princípios que regem, segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, encontram-se os seguintes:

- (A) defesa da paz, soberania nacional, não-intervenção e repúdio a todas as formas de tratamento desumano ou degradante.
- (B) autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e promoção do bem-estar e da justiça social.
- (C) defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, não-intervenção e repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- (D) soberania nacional, proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não intervenção e solução pacífica dos conflitos.
- (E) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, promoção do bem-estar e da justiça social.

29. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado.

A concessão de asilo político é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais.

- Certo ()
- Errado ()

30. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).

A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual.

- Certo ()
- Errado ()

- 31. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014)** Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).
O pluralismo político traduz a liberdade de convicção filosófica e política, assegurando aos indivíduos, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma apartidária.
Certo ()
Errado ()
- 32. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014)** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado
(A) democrático de Direito.
(B) burocrático.
(C) o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados.
(D) socialista progressista.
(E) humanitário social.
- 33. (PM-MG - Oficial da Polícia Militar - CRSP/PMMG/2014)** Marque a alternativa CORRETA. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, contidos no artigo 3º da Constituição Federal de 1988 é:
(A) Garantir o desenvolvimento nacional.
(B) Apoiar o pluralismo político.
(C) Promover a dignidade da pessoa humana.
(D) Desenvolver a cidadania.
- 34. (TRE/AM - Técnico Judiciário - Área Administrativa - IBFC/2014)** Assinale a alternativa que NÃO apresenta princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil:
(A) Prevalência dos direitos humanos.
(B) Repúdio ao terrorismo e ao racismo.
(C) Garantir o desenvolvimento nacional.
(D) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
- 35. (PC-RJ - Papiloscopista Policial de 3ª Classe - IBFC/2014)** Todos os enunciados abaixo correspondem a fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 1º da Constituição Federal, exceto:
(A) A Soberania.
(B) A Cidadania.
(C) A Dignidade da pessoa humana.
(D) A Prevalência dos direitos humanos.
(E) O Pluralismo político.
- 36. (PC-SE - Escrivão substituto - IBFC/2014)** Todos os enunciados abaixo correspondem a objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da Carta Política, exceto:
(A) Promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
(B) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(C) Garantir o desenvolvimento nacional.
(D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- 37. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014)** Ainda em relação aos outros remédios constitucionais analise as questões a seguir e assinale a alternativa correta.
I - O *habeas data* assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
II - Será concedido *habeas data* para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
III - Em se tratando de registro ou banco de dados de entidade governamental, o sujeito passivo na ação de *habeas data* será a pessoa jurídica componente da administração direta e indireta do Estado.
IV - O mandado de injunção serve para requerer à autoridade competente que faça uma lei para tornar viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais.
V - O pressuposto lógico do mandado de injunção é a demora legislativa que impede um direito de ser efetivado pela falta de complementação de uma lei.

- (A) Todas as afirmações estão corretas.
- (B) Apenas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas II, III e V estão corretas.
- (E) Apenas IV e V estão corretas.

38. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) O devido processo legal estabelecido como direito do cidadão na Constituição Federal configura dupla proteção ao indivíduo, pois atua no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade de condições com o Estado para defender-se.

Com base na afirmação acima, analise as questões a seguir e assinale a alternativa correta.

- I - Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
 - II - A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.
 - III - São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
 - IV - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
 - V - Não haverá prisão civil por dívida, nem mesmo a do depositário infiel.
- (A) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - (B) Apenas I, III e V estão corretas.
 - (C) Apenas III e IV estão corretas.
 - (D) Apenas IV e V estão corretas.
 - (E) Todas as questões estão corretas.

39. (PC/SP - Investigador de Polícia - VUNESP/2014) Considerando o disposto na Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida prévia autorização do delegado de polícia e não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local
- (B) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida.
- (C) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, a prática da tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
- (D) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem do juiz ou do promotor de justiça, na forma da lei.
- (E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante à noite, por determinação judicial.

40. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) A ação de habeas data, como instrumento de proteção de dimensão do direito de personalidade, destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas, bem como a garantir a correção de dados incorretos.

A partir do fragmento acima, assinale a opção correta.

- (A) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente deste até o segundo grau, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou privadas.
- (B) Além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para petição inicial, a ação de habeas data deverá vir instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou o simples decurso de dez dias sem decisão.
- (C) Do despacho de indeferimento da inicial de habeas data por falta de algum requisito legal para o ajuizamento caberá agravo de instrumento.
- (D) A ação de habeas data terá prioridade sobre todos os atos judiciais, com exceção ao habeas corpus e ao mandado de segurança.

41. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) Quanto aos princípios constitucionais de natureza penal, NÃO é correto o que se afirma em:

- (A) As penas no Brasil têm caráter preventivo e retributivo.

(B) A obrigação de reparar o dano produzido pelo crime não pode se estender aos familiares do preso, sob forma de sucessão.

(C) O princípio constitucional da responsabilidade pessoal significa que a pena não pode passar da pessoa do condenado.

(D) O princípio da proporcionalidade significa que a pena deve ser proporcional ao crime, ou seja, guardar equilíbrio entre a infração praticada e a sanção imposta.

42. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) Sobre a Lei Penal, é CORRETO afirmar que

(A) não retroage, salvo para beneficiar o réu.

(B) não retroage, salvo se o fato criminoso ainda não for conhecido.

(C) retroage, salvo disposição expressa em contrário.

(D) retroage, se ainda não houver processo penal instaurado.

43. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) Sobre as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, é CORRETO afirmar que

(A) a Lei Penal é sempre irretroativa.

(B) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível.

(C) não haverá pena de morte em nenhuma circunstância.

(D) os templos religiosos, entendidos como casas de Deus, possuem garantia de inviolabilidade domiciliar.

44. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) NÃO figura entre as garantias expressas no artigo 5º da Constituição Federal:

(A) a obtenção de certidões em repartições públicas.

(B) a defesa do consumidor, prevista em estatuto próprio.

(C) o respeito à integridade física dos presos, garantido pela lei de execução penal.

(D) a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, posto que contido na legislação ordinária trabalhista.

45. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo-se nela entrar, sem permissão do morador, EXCETO

(A) em caso de desastre.

(B) em caso de flagrante delito.

(C) para prestar socorro.

(D) por determinação judicial, a qualquer hora.

46. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) Sobre a Tutela Constitucional das Liberdades, é CORRETO afirmar:

(A) O Habeas Corpus é remédio utilizado contra ameaça ou privação ilegal do direito de locomoção.

(B) O Habeas Corpus só pode ser impetrado contra ato de Autoridade Pública, denominada de Coatora.

(C) Só o próprio lesado ou ameaçado no seu direito de ir e vir pode impetrar Habeas Corpus em seu favor.

(D) Tanto o Habeas Corpus liberatório quanto o preventivo são aplicáveis nas mesmas circunstâncias.

47. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) A teoria da reserva do possível

(A) significa a inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais.

(B) gira em torno da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do poder judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando caracterizada hipótese de omissão governamental.

(C) considera que as políticas públicas são reservadas discricionariamente à análise e intervenção do poder judiciário, que as limitará ou ampliará, de acordo com o caso concreto.

(D) é sinônima, em significado e extensão, à teoria do mínimo existencial, examinado à luz da violação dos direitos fundamentais sociais, culturais e econômicos, como o direito à saúde e à educação básica.

(E) defende a integridade e a intangibilidade dos direitos fundamentais, independentemente das possibilidades financeiras e orçamentárias do estado.

48. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador - FCC/2014) A Emenda Constitucional nº 72, promulgada em 2 de abril de 2013, tem por finalidade estabelecer a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Nos termos de suas disposições, a Emenda

(A) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal e à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos.

instituiu vedação ao legislador para conferir tratamento diferenciado aos trabalhadores domésticos, em relação aos trabalhadores urbanos e rurais.

(B) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos.

(C) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

(D) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal e ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

49. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado.

Ao tratar da nacionalidade, dispõe o Texto Constitucional que são privativos de brasileiro nato os cargos da carreira diplomática.

Certo ()

Errado ()

50. (TJ/MT - Juiz de Direito - FMP/2014) Assinale a alternativa correta.

(A) Nação é um conceito ligado a um agrupamento humano cujos membros, fixados num território, são ligados por laços culturais, históricos, econômicos e linguísticos.

(B) Cidadão é a pessoa que se vincula a outra por meio de determinada nacionalidade.

(C) Adquire-se nacionalidade primária por meio de vontade própria.

(D) A população está unida ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade.

(E) O povo é o conjunto de pessoas que se une mediante laços culturais.

51. (TRF/2ª REGIÃO - Juiz Federal - TRF 2ª Região/2014) Pablo nasceu no estrangeiro, filho de mãe brasileira e de pai mexicano, e veio a residir no Brasil pouco antes de completar 15 anos. Atingida a maioridade, optou pela nacionalidade brasileira, através de processo que tramitou na Justiça Federal. Pablo tem, agora, 30 anos de idade. Assinale a opção correta:

(A) Ele pode, em tese e imediatamente, ser nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal.

(B) Sua naturalização pode ser cancelada, também por sentença judicial, se vier a praticar atividade nociva ao interesse nacional.

(C) Em tese, Pablo poderá ser titular, dentro de alguns anos, de qualquer cargo privativo de brasileiro nato.

(D) Pablo não poderá, a qualquer tempo, ser nomeado para o cargo de Ministro de Estado da Defesa.

(E) Pablo não poderá, a qualquer tempo, ser eleito para o cargo de Vice-Presidente da República.

52. (TCE/RS - Auditor Público Externo - Engenharia Civil - Conhecimentos Básicos - FCC/2014) Sicrano, filho de mãe brasileira e pai egípcio, nascido durante período em que seus pais eram estudantes universitários na França, veio, após a maioridade, a residir no Brasil, onde pretende viver pelo resto de sua vida. Nos termos da Constituição da República, Sicrano

(A) somente seria considerado brasileiro nato se, quando de seu nascimento, sua mãe, que era brasileira, estivesse no exterior a serviço da República Federativa do Brasil.

(B) poderá vir a ser brasileiro naturalizado, se efetivamente residir no país por até quinze anos ininterruptos, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

(C) é considerado brasileiro naturalizado, desde o momento em que fixou residência no país, já que é filho de mãe brasileira, estando sujeito, contudo, a extradição, na hipótese de cometimento de crime comum a partir de então.

(D) será considerado brasileiro nato, se optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, caso em que não estará sujeito a extradição, nem mesmo na hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.

(E) somente seria considerado brasileiro nato se, quando de seu nascimento, houvesse sido registrado em repartição brasileira competente.

53. (TRE/AM - Técnico Judiciário - Área Administrativa - IBFC/2014)

Com relação aos direitos de nacionalidade, previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por decisão do Presidente da República, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
- (B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- (C) São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
- (D) É privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

54. (PC/TO - Delegado de Polícia - Aroeira/2014) No caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, o condenado terá seus direitos políticos:

- (A) mantidos.
- (B) cassados.
- (C) perdidos.
- (D) suspensos.

55. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) No que concerne às condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previstas na CRFB/88, assinale a opção correta.

- (A) José, ex-prefeito, que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de prefeito.
- (B) João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se, pela primeira vez, ao cargo de prefeito.
- (C) Marcos, brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito.
- (D) Luís, capitão do exército com 5 anos de serviço, mas que não pretende e nem irá afastar-se das atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito.

56. (TJ/MT - Juiz - FMP-RS/2014) Assinale a alternativa correta a respeito dos partidos políticos.

- (A) É vedado a eles o recebimento de recursos financeiros por parte de empresas transnacionais.
- (B) É assegurado a eles o acesso gratuito à propaganda no rádio e na televisão, exceto aqueles que não possuam representação no Congresso Nacional.
- (C) Os partidos devem, obrigatoriamente, ter caráter nacional.
- (D) Os partidos devem, após cada campanha, apresentar ao Congresso Nacional a sua prestação de contas para aprovação.
- (E) Em razão de sua importante função institucional, os partidos políticos possuem natureza jurídica de direito público.

57. (TJ/MT - Juiz de Direito - FMP/2014) Assinale a alternativa correta a respeito dos partidos políticos.

- (A) É vedado a eles o recebimento de recursos financeiros por parte de empresas transnacionais.
- (B) É assegurado a eles o acesso gratuito à propaganda no rádio e na televisão, exceto aqueles que não possuam representação no Congresso Nacional.
- (C) Os partidos devem, obrigatoriamente, ter caráter nacional.
- (D) Os partidos devem, após cada campanha, apresentar ao Congresso Nacional a sua prestação de contas para aprovação.
- (E) Em razão de sua importante função institucional, os partidos políticos possuem natureza jurídica de direito público.

58. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) A soberania popular pode ser exercida, dentre outros instrumentos previstos na Constituição Federal, pelo(a).

- (A) veto popular a projeto de lei.
- (B) plebiscito.
- (C) protesto
- (D) manifestação pública.
- (E) ato de improbidade administrativa

59. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) Julgue os itens seguintes, em relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.

O poder constituinte dos estados, dada a sua condição de ente federativo autônomo, é soberano e ilimitado.

Certo ()

Errado ()

60. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) Julgue os itens seguintes, em relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.

A despeito de serem entes federativos, os territórios federais carecem de autonomia.

Certo ()

Errado ()

61. (TRT/23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto - TRT 23ªR/2014) Sobre a administração pública, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade.

(B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

(C) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

(D) A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos se estende a emprego e funções, não abrangendo, pois, sociedades de economia mista.

(E) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se, apenas, às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

62. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) “A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado”. (MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2007, 22. ed., p. 310)

Com base no que determina a Constituição Federal a respeito da administração pública é correto afirmar, exceto:

(A) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão.

(B) A Administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

(C) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(D) A Constituição Federal não veda a acumulação remunerada de cargos públicos.

(E) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

63. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) José é cidadão do município W, onde está localizado o distrito de B. Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao município de origem.

De acordo com as normas constitucionais federais, dentre outros requisitos para legitimar a criação de um novo Município, são indispensáveis:

(A) lei estadual e referendo.

(B) lei municipal e plebiscito.

(C) lei municipal e referendo.

(D) lei estadual e plebiscito.

64. (MPE/MG - Promotor de Justiça - MPE/2014) Assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) O federalismo por agregação surge quando Estados soberanos cedem uma parcela de sua soberania para formar um ente único.

- (B) O federalismo dualista caracteriza-se pela sujeição dos Estados federados à União.
- (C) O federalismo centrípeto se caracteriza pelo fortalecimento do poder central decorrente da predominância de atribuições conferidas à União.
- (D) No federalismo atípico, constata-se a existência de três esferas de competências: União, Estados e Municípios.

65. (TRT 2ª Região/SP - Juiz do Trabalho - TRT 2R/2014) Em relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, aponte a alternativa correta:

- (A) Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, podendo, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes
- (B) Cabe aos Municípios explorarem diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
- (C) O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao quádruplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36 (trinta e seis), será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 12 (doze).
- (D) O Município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 (dois) turnos, com interstício de 15 (quinze) dias, e aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
- (E) Compete à União legislar exclusivamente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde.

66. (PC/SP - Escrivão de Polícia - VUNESP/2014) Prevê o art. 37 da Constituição Federal, de forma expressa, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e:

- (A) razoabilidade
- (B) eficiência.
- (C) proporcionalidade.
- (D) unidade.
- (E) economicidade.

67. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) Com base na jurisprudência do STF, pode-se afirmar que é inconstitucional a fixação de piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, tendo em vista o princípio federativo. Do enunciado, pode-se dizer que

- (A) a afirmação é totalmente verdadeira.
- (B) a afirmação é totalmente falsa.
- (C) a afirmação é parcialmente falsa, pois o fundamento utilizado pelo STF não é o princípio federativo, mas a restrição orçamentária imposta pela lei de responsabilidade fiscal.
- (D) nenhuma alternativa anterior é correta.

68. (Câmara Municipal de São Paulo/SP - Procurador Legislativo - FCC/2014) Segundo a Constituição Federal, os secretários municipais serão remunerados conforme dispuser lei de iniciativa

- (A) do Prefeito, exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
- (B) do Prefeito, podendo prever como parte da remuneração gratificação por tempo de serviço.
- (C) da Câmara Municipal, podendo prever como parte da remuneração gratificação por tempo de serviço.
- (D) da Câmara Municipal, exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
- (E) do Prefeito, exclusivamente por subsídio, não podendo ser superior à remuneração do Prefeito.

69. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) No que diz respeito à administração pública e aos servidores públicos, julgue os itens subsequentes.

- O salário-família para dependentes é um direito social assegurado e estendido aos servidores públicos.
- Certo ()
- Errado ()

70. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - CESPE/2014) No que diz respeito à administração pública e aos servidores públicos, julgue os itens subsequentes.

Basta a observância da legalidade estrita para que a conduta do agente público seja considerada moralmente adequada do ponto de vista da administração pública.

- Certo ()
Errado ()

71. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado.

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual.

- Certo ()
Errado ()

72. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado.

Segundo a Constituição Federal, para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 15 (quinze) vereadores, nos Municípios de mais de 15 (quinze) mil habitantes e de até 30 (trinta) mil habitantes.

- Certo ()
Errado ()

73. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado.

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria dos membros da Câmara Municipal.

- Certo ()
Errado ()

74. (SEDS/MG - Agente de Segurança Penitenciária - IBFC/2014) A incorporação entre Estados:

- (A) Não é permitida pela Constituição Federal.
(B) Depende exclusivamente da aprovação dos Deputados Estaduais dos Estados diretamente interessados.
(C) Depende da aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
(D) Depende da aprovação de todos os eleitores brasileiros, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

75. (SEDS/MG - Agente de Segurança Penitenciária - IBFC/2014) Considerando a disciplina constitucional, o prazo de validade do concurso público será:

- (A) De até um ano, prorrogável duas vezes, por igual período.
(B) De até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
(C) Aquele previsto no edital, limitado a três anos, prorrogável uma vez, por igual período.
(D) De até dois anos, sendo improrrogável.

76. (SEDS/MG - Agente de Segurança Penitenciária - IBFC/2014) Analise as seguintes afirmações, relativas à disciplina constitucional sobre o servidor público que venha a desempenhar mandato eletivo:

I. O servidor, investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

II. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção.

III. O servidor, investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Está INCORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

77. (PGE/PI - Procurador do Estado Substituto - CESPE/2014) Assinale a opção correta em relação à disciplina constitucional do poder constituinte no Brasil.

(A) Não existe direito adquirido a regime jurídico, mesmo em face do poder constituinte estadual de reforma.

(B) Emenda constitucional pode determinar que o poder constituinte de revisão se realize a cada cinco anos.

(C) O poder constituinte originário estadual sujeita-se aos mesmos condicionamentos do poder constituinte reformador federal.

(D) A CF não poderá ser emendada na constância do emprego da Força Nacional de Segurança.

(E) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposição da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

78. (PC-SE - Escrivão substituto - IBFC/2014) Segundo a Constituição Federal, no título “Da Organização do Estado”, incluem-se entre os bens dos Estados Federados:

(A) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União

(B) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo

(C) Os terrenos de marinha e seus acrescidos.

(D) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

79. (TJ-RJ - Técnico de Atividade Judiciária - FGV/2014) Com os olhos voltados à competência legislativa concorrente prevista na Constituição da República, é correto afirmar que:

(A) os Estados podem legislar sobre as respectivas matérias, desde que não afrontem as normas gerais editadas pela União;

(B) os Estados e os Municípios podem legislar sobre as respectivas matérias, observadas as normas gerais editadas pela União;

(C) os Estados podem legislar sobre as respectivas matérias, predominando a lei da menor unidade territorial no caso de conflito;

(D) todos os entes federados podem legislar sobre as matérias a que se refere, predominando o princípio da maior relevância social no caso de conflito;

(E) todos os entes federados podem legislar indistintamente sobre as matérias a que se refere.

80. (OAB - Exame de Ordem Unificado - FGV/2014) No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalares são decorrências de acidentes automobilísticos ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Uma vereadora do município, Sra. X, ciente das estatísticas expostas, apresenta projeto de lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos automotores, residentes no município, municiem seus veículos com equipamento que impeça a partida do carro no caso de o condutor ter consumido álcool. A Câmara Municipal, por voto de 2/3 dos vereadores, aprova a lei. Esta legislação deve ser considerada

(A) constitucional, por tratar de proteção de direito fundamental.

(B) inconstitucional, por tratar de matéria de competência privativa da União.

(C) inconstitucional, por vício formal relacionado ao quórum mínimo para votação.

(D) constitucional, por tratar de assunto de interesse local e ter sido aprovada por processo legislativo idôneo.

81. (SP-URBANISMO - Analista Administrativo - Jurídico - VUNESP/2014) A competência para legislar sobre direito urbanístico é

(A) privativa do Município, podendo ser delegada a outros entes federativos, como a União e os Estados.

(B) concorrente, cabendo à União legislar sobre normas gerais, o que não exclui a competência suplementar dos Municípios e do Distrito Federal.

(C) exclusiva do Município, não podendo, portanto, ser delegada a qualquer outro ente federativo.

(D) concorrente, cabendo à União legislar sobre normas gerais, o que não exclui a competência suplementar dos Estados.

(E) residual dos Estados, cabendo à União e ao Município formular normas gerais e específicas sobre as matérias, respectivamente.

82. (SP-URBANISMO - Analista Administrativo - Jurídico - VUNESP/2014) A fiscalização do Município

(A) será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

(B) é prevista na Constituição Federal como responsabilidade das Controladorias-Gerais Municipais e dos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Municípios, onde houver.

(C) será realizada pela prestação de contas anual, que ficará à disposição de qualquer contribuinte para exame, podendo ser impugnada por um terço dos eleitores do Município.

(D) será realizada exclusivamente pelo Tribunal de Contas Municipal, que julgará as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos.

(E) é de responsabilidade das Controladorias-Gerais Municipais, que deverão representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados nas contas anualmente prestadas.

83. (TRT/16ª REGIÃO/MA - Analista Judiciário - FCC/2014) Analise a seguinte situação hipotética: “Tício, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, é indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho para compor este Tribunal Superior e ocupar a vaga do Ministro Fúlvio, aposentado neste ano de 2014”. Antes de ser nomeado pelo Presidente da República o nome do Magistrado Tício deverá ser aprovado pela maioria

(A) absoluta do Senado Federal.

(B) absoluta do Congresso Nacional.

(C) simples do Senado Federal.

(D) simples do Congresso Nacional.

(E) absoluta do Supremo Tribunal Federal.

84. (DPE/DF - Analista - Assistência Judiciária - FGV/2014) Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário constataram a presença de mulheres detidas em cadeia pública masculina em uma unidade federativa brasileira. As detentas reclamavam da infraestrutura precária e confirmaram denúncias de que uma menina de 16 anos ficou detida na mesma unidade prisional estatal por 12 dias. Diante de tais circunstâncias político-administrativas, havendo a intervenção federal para assegurar a garantia dos direitos da pessoa humana, ela deverá ser decretada pelo Presidente da República:

(A) espontaneamente, sem necessidade de controle político do Congresso Nacional.

(B) após requisição do Superior Tribunal de Justiça.

(C) após prévia autorização do Congresso Nacional.

(D) após provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.

(E) após anuência do Judiciário, a se fazer por decisão de seu Órgão Especial, com chancela final do Legislativo do Estado.

85. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador - FCC/2014) Ao analisar o funcionamento do bicameralismo brasileiro no âmbito do processo legislativo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho apresenta a seguinte lição: “as Câmaras no processo legislativo brasileiro não estão em pé de igualdade” (cf. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 39. ed., 2013). Alude, assim, o autor ao caráter assimétrico, imperfeito ou desigual que informa a atuação das Casas do Congresso Nacional nos processos de

(A) apreciação dos vetos presidenciais e de elaboração das leis ordinárias e complementares.

(B) conversão de medida provisória em lei e de elaboração das leis ordinárias e complementares.

(C) revisão constitucional e de elaboração das leis ordinárias e complementares.

(D) conversão de medida provisória em lei e de elaboração das emendas constitucionais.

(E) elaboração das emendas constitucionais e de aprovação de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos com estatura equivalente às emendas constitucionais.

86. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) A Constituição brasileira não pode ser emendada

(A) a partir da implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos Estados.

(B) na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência.

(C) na vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal.

(D) quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos Municípios.

87. (Prefeitura de Cuiabá/MT - Procurador Municipal - FCC/2014) Em outubro de 2013, foi apresentada à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que tramita sob o nº 334/2013 e pretende dar nova redação ao artigo 14, §1º, da Constituição, com vistas a tornar o alistamento eleitoral e o voto facultativos. Em conformidade com o relatório de conferência de assinaturas da Casa legislativa, referida PEC foi validamente subscrita por 174 de um total de 513 Deputados Federais. Diante da disciplina constitucional da matéria, a PEC 334/2013, em princípio

(A) não afronta os limites formais, circunstanciais ou materiais impostos ao poder de reforma constitucional, estando apta a prosseguir o trâmite regular das proposições normativas da espécie.

(B) não atende à exigência constitucional relativa ao exercício de iniciativa conjunta para propositura de emendas à constituição por membros das casas legislativas.

(C) não poderá ser objeto de deliberação pelas casas do congresso nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional.

(D) somente poderá ser objeto de deliberação no que se refere à facultatividade do alistamento eleitoral, mas não do voto, que goza de tutela reforçada contra a atuação do poder de reforma constitucional.

(E) deverá ser discutida e votada em cada casa do congresso nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, a maioria absoluta dos votos dos respectivos membros.

88. (TCE/PB - Procurador - CESP/2014) De acordo com as normas constitucionais e a jurisprudência do STF acerca das CPIs, assinale a opção correta.

(A) Caso seja impetrado mandado de segurança em face de ato de CPI que tenha determinado a quebra do sigilo fiscal do impetrante, e, em seguida, sejam encerrados os trabalhos da CPI, o julgamento do writ deverá prosseguir, em virtude do temor do impetrante de eventual uso abusivo das informações.

(B) As CPIs podem ser criadas para a apuração de fato determinado, ainda que sobre esses mesmos fatos já tenham sido instaurados inquéritos policiais ou processos judiciais.

(C) A CF exige que a criação das CPIs se dê sempre em conjunto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, mediante requerimento de um terço de seus membros. No âmbito dos estados, pelo princípio da simetria, exige-se um terço dos membros da assembleia legislativa

(D) Caso o investigado já tenha prestado depoimento perante a CPI, eventual habeas corpus preventivo impetrado com o fim de garantir-lhe o exercício de seu direito ao silêncio será necessariamente considerado prejudicado, ainda que o paciente informe a existência de reconvocação para prestar novos depoimentos. Nessas situações, deverá ser impetrado novo habeas corpus.

(E) Devido ao fato de possuírem os poderes de investigação próprios das autoridades policiais, as CPIs poderão determinar a quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e de dados.

89. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os itens subsecutivos.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a comissão parlamentar de inquérito cuja criação haja sido regularmente aprovada no âmbito do Poder Legislativo, a partir de requerimento da minoria, não pode ter a sua instalação embaraçada pela falta de indicação de membros pelos líderes partidários.

Certo ()

Errado ()

90. (TJ/PR - Outorga de Delegações de Notas e de Registro - Remoção - IBFC/2014) Assinale a alternativa correta:

(A) Somente ao Poder Constituinte Derivado é assegurado o direito de alterar as chamadas “cláusulas pétreas”.

(B) O voto direto, secreto universal e periódico não é considerado “cláusula pétrea”.

(C) O Poder Constituinte Decorrente ou Complementar é aquele poder constituinte conferido aos Estados-membros da Federação instituído e regulado pelo Poder Constituinte Originário.

(D) A Constituição Federal poderá ser emendada na vigência de estado de sítio.

91. (TJ/PR - Outorga de Delegações de Notas e de Registro - Remoção - IBFC/2014) Assinale a alternativa correta:

(A) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio proporcional.

(B) A denominada imunidade formal é aquela em que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

(C) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o parlamentar que se licenciar para o exercício de outro cargo fora do Parlamento, apesar de não perder o mandato, perderá as imunidades parlamentares.

(D) As comissões parlamentares de inquérito não detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

92. (TJ-GO - Analista Judiciário - FGV/2014) A respeito das comissões parlamentares de inquérito, instituídas pelo Congresso Nacional e suas Casas Legislativas, é correto afirmar que:

(A) devem ter caráter permanente e destinar-se à apuração de fato certo e determinado;

(B) podem convocar qualquer integrante do Poder Executivo para prestar informações em matéria de sua competência;

(C) podem praticar, na apuração dos fatos que justificaram a sua instituição, quaisquer atos de competência das autoridades judiciais;

(D) podem ser intercamerais, assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares ali atuantes;

(E) é possível que venham a apreciar proposições legislativas em caráter terminativo, sempre que o regimento interno assim o autorizar.

93. (DPE/DF - Analista - Assistência Judiciária - FGV/2014) O Presidente da República dispõe, mediante decreto, acerca da criação de um novo tipo penal. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que:

(A) o Chefe do Poder Executivo Federal está impedido pela Constituição de criar um novo tipo penal mediante decreto.

(B) o Congresso Nacional pode sustar esse ato normativo por meio de um decreto legislativo.

(C) os decretos legislativos dispensam sanção presidencial.

(D) as competências privativas do Presidente da República estão dispostas no Art. 84 da Constituição da República.

(E) o Presidente da República pode criar um novo tipo penal apenas mediante a edição de medida provisória.

94. (TJ/PA – Juiz de Direito Substituto - VUNESP/2014) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá editar medida provisória, entretanto, é vedada a edição sobre matéria relativa

(A) à instituição de impostos, mesmo que produza efeitos no exercício financeiro seguinte.

(B) à majoração de impostos, mesmo se convertida em lei.

(C) à organização da administração pública.

(D) à cidadania e aos partidos políticos.

(E) a contratos administrativos e licitações.

95. (PC-SE - Escrivão substituto - IBFC/2014) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder Executivo”, compete ao Presidente da República, exceto:

(A) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos.

(B) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

(C) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal

(D) Dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

96. (PC-SE - Agente de Polícia Judiciária - IBFC/2014) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder Executivo”, o Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país, sob pena de perda do cargo, por até:

(A) 15 dias.

(B) 30 dias.

(C) 45 dias.

(D) 60 dias.

97. (PC/PI - Delegado de Polícia – UESPI/2014) Considerando o que estabelecem as normas constitucionais sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A perda do cargo é a consequência inafastável para o Prefeito que assumir outro cargo ou função na Administração Pública, seja direta ou indireta.

(B) A vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, verificada nos últimos dois anos do mandato, ensejará a realização de eleição, pelo Congresso Nacional, para ambos os cargos vagos, a ser realizada trinta dias depois da última vaga.

(C) Do Conselho da República participam, também, seis cidadãos brasileiros, com mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados pelo Presidente da República, todos com mandato de quatro anos, admitida uma única recondução.

(D) Os requisitos constitucionais para assumir o cargo de Ministro de Estado, auxiliar do Presidente da República, são os seguintes: ter mais de vinte e um anos de idade; estar no exercício dos direitos políticos; e ser brasileiro nato.

(E) Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é julgado pela Câmara dos Deputados, sob a direção do Presidente do Supremo Tribunal Federal, com a necessária autorização prévia do Senado Federal.

98. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) Imagine a hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o Presidente da República e seu Vice, após a conclusão do terceiro ano de mandato.

A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

(A) O Presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato.

(B) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que realizar-se-ão noventa dias depois de abertas as vagas.

(C) O Presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato.

(D) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que serão realizadas trinta dias após a abertura das vagas, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

99. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador - FCC/2014) A disciplina normativa sobre a sucessão no caso de vacância, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,

(A) compete privativamente ao Município, sendo inconstitucional a adoção de regime diverso do adotado pela Constituição Federal para a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, em face do princípio da simetria federativa.

(B) cabe ser definida, privativamente pelo Município, sendo lícita a adoção de regime diverso do adotado pela Constituição Federal para a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, desde que a investidura do sucessor ocorra mediante processo eletivo.

(C) compete privativamente à União, pois cuida-se de legislação sobre direito eleitoral.

(D) cabe ser definida, em caráter subsidiário, no âmbito da Constituição Estadual, de modo a suprir eventual ausência ou omissão quanto à matéria por parte da Lei Orgânica municipal.

(E) cabe ser definida, privativamente pelo Município, sendo lícita a adoção de regime diverso do adotado pela Constituição Federal para a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, ainda que a investidura do sucessor não ocorra mediante processo eletivo.

100. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da administração federal e estadual concernentes à sua área de competência.

Certo ()

Errado ()

101. (UNICAMP - Procurador - VUNESP/2014) Assinale a alternativa que contempla atribuição privativa do Presidente da República passível de delegação.

(A) Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.

(B) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

(C) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

(D) Nomear membros do Conselho da República.

(E) Conferir condecorações e distinções honoríficas.

102. (UNICAMP - Procurador - VUNESP/2014) Considerando o disposto na Constituição Federal sobre o Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

(A) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, em sessão secreta.

(B) Os servidores dos cartórios judiciais receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, limitados às decisões de caráter interlocutório.

(C) Um quinto dos lugares dos Tribunais dos Estados será composto de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes.

(D) Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

(E) O juiz goza da garantia da inamovibilidade, mas, havendo interesse público, poderá ser removido, por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

103. (TRT/23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto - TRT 23ªR/2014) Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, Estados, Distrito Federal ou Município.

(B) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção decididos, em instância única, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

(C) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em grau de recurso especial, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos.

(D) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades Judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as destes e da União.

(E) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais.

104. (TRT/23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto - TRT 23ªR/2014) Sobre o Estatuto da Magistratura, NÃO É CORRETO afirmar:

(A) A aferição do merecimento, para fins de promoção, ocorrerá conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento.

(B) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver os autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.

(C) Na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços dos membros presentes à sessão, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

(D) O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal.

(E) A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição.

105. (TRT 3ª Região/MG - Juiz do Trabalho - TRT 3R/2014) Sobre as funções institucionais do Ministério Público é incorreto afirmar:

(A) Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, inclusive através de Promotor de Justiça ad hoc.

(B) Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.

(C) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

(D) Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva.

(E) Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar.

106. (MPE/AC - CESPE/2014) Com relação ao Poder Judiciário, assinale a opção correta.

(A) De acordo com a CF, membro do MPE poderá compor o tribunal regional eleitoral, desde que nomeado pelo presidente da República, devendo atuar pelo prazo mínimo de dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos.

(B) Desde que haja previsão na constituição estadual, é possível a criação da justiça militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes auditores e, em segundo grau, pelas auditorias militares.

(C) Em casos de crimes dolosos contra a vida, o julgamento de prefeito, de competência da justiça comum estadual, será realizado perante o tribunal de justiça respectivo, dada a previsão constitucional específica, que prevalece sobre a competência geral do tribunal do júri.

(D) As decisões administrativas dos tribunais de justiça em matéria disciplinar devem ser motivadas e podem ser realizadas em sessão secreta por decisão da maioria absoluta de seus membros.

(E) Constituição estadual pode prever representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais em face de seu texto, desde que estabeleça a legitimidade exclusiva para o seu oferecimento ao procurador-geral de justiça.

107. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, na esfera federal.

(A) Em relação à tal afirmação, assinale a assertiva correta.

(B) A afirmativa está correta.

(C) A afirmativa está incorreta, pois o quórum para aprovação de súmula vinculante é de maioria absoluta.

(D) A afirmativa está incorreta, pois o efeito vinculante diz respeito apenas aos órgãos do Poder Judiciário.

(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

108. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

A criação do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu uma nova instância de recurso judicial, pode ser considerada uma aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Certo ()

Errado ()

109. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) Consoante o art. 144 da Constituição Federal, "a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Nesse sentido, todas as alternativas estão corretas, exceto a:

(A) Entre as funções da polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, está a de exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

(B) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

(C) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

(D) A segurança pública é exercida através da polícia federal, da polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(E) Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

110. (PC/SP - Delegado de Polícia - VUNESP/2014) Nos termos da Constituição Federal, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas

(A) à execução de atividades de defesa civil.

(B) ao patrulhamento ostensivo das vias públicas municipais.

(C) às funções de polícia judiciária e à apuração de infrações penais.

(D) à proteção de seus bens, serviços e instalações.

(E) ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública.

111. (PC/PI - Delegado de Polícia - UESPI/2014) Tratando-se da organização constitucional da segurança pública, é CORRETO afirmar que

(A) as funções de polícia judiciária da União são exercidas pela polícia federal, pela polícia rodoviária federal, e pela polícia ferroviária federal.

(B) às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

(C) a polícia militar, o corpo de bombeiro militar, bem como com a polícia civil do Distrito Federal estão subordinadas à União, sob a direção do Presidente da República.

(D) os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, não lhes cabendo o exercício de funções de polícia judiciária.

(E) a coordenação das atividades de segurança pública é atribuição do Conselho de Segurança Militar, órgão de assessoramento do Presidente da República.

112. (OAB - Exame de Ordem Unificado - XIV - Primeira Fase - FGV/2014) O estado de defesa e o estado de sítio são tidos como legalidades extraordinárias, verdadeiras excepcionalidades que possibilitam inclusive a suspensão de determinadas garantias constitucionais. As hipóteses de incidência e o procedimento são exaustivamente tratados pela CRFB/88.

(A) Com base na previsão constitucional dos referidos institutos, assinale a opção correta.

(B) O estado de defesa e o estado de sítio podem ser decretados pelo Presidente da República, bastando a oitiva prévia do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional e do Procurador-Geral da República.

(C) No estado de defesa, a oitiva do Congresso Nacional é posterior à sua decretação. Por sua vez, no estado de sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à decretação.

(D) Poderá o Presidente da República, à luz da CRFB/88, decretar estado de defesa em resposta a agressão armada de país vizinho.

(E) Em sendo hipótese de estado de sítio, o Congresso Nacional deverá ser fechado até o término das medidas coercitivas, para sua salvaguarda.

113. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) Nos moldes da Constituição Federal, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, incumbem:

(A) ao Ministério Público.

(B) à Polícia Federal

(C) ao Poder Judiciário.

(D) às Procuradorias Estaduais.

(E) às Polícias Cíveis.

114. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) Segundo estabelece o texto constitucional, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados subordinam-se.

(A) ao Presidente da República.

(B) aos Juízes.

(C) aos Governadores.

(D) aos Prefeitos.

(E) aos Promotores de Justiça.

115. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) Ao dispor sobre as finanças públicas, a Constituição NÃO impede que lei autorize

(A) os Estados e os Municípios a promover o depósito da remuneração de seus servidores públicos em instituição financeira privada.

(B) o Banco Central a conceder empréstimos a instituições financeiras, públicas ou privadas, sediadas no Brasil, bem como a empresas dos ramos securitário, previdenciário e de fornecimento de energia.

(C) o Tesouro Nacional e a Casa da Moeda a exercer a competência da União para emitir moeda.

(D) o Banco Central a conceder empréstimos ao Tesouro Nacional, bem como comprar e vender títulos por este emitidos.

(E) o depósito das disponibilidades de caixa da União em mais de uma instituição financeira oficial, como medida protetiva dos recursos públicos federais contra ameaças de iliquidez ou insolvência.

116. (MPE/MG - Promotor de Justiça - MPE/2014) Relativamente ao tratamento que a Constituição Federal conferiu às restrições do Estado sobre a propriedade privada, é INCORRETO afirmar:

(A) O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

(B) Estão tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

(C) O decreto que garantir tratamento especial à propriedade produtiva também fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.

(D) São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

117. (TRT 3ª Região/MG - Juiz do Trabalho - TRT 3R/2014) Sobre a ordem econômica e financeira na Constituição da República é correto afirmar:

(A) Que ela é fundada na valorização do trabalho humano, tendo como finalidade assegurar a atividade econômica e a livre concorrência.

(B) Que são alguns dos princípios da ordem econômica: a soberania; o voto popular; a propriedade privada e sua função social; a defesa do consumidor e do meio ambiente.

(C) Que é a lei que disciplina, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro e nacional, incentivando os reinvestimentos e regulando a distribuição e a remessa de lucros.

(D) Que é função da atividade econômica no Brasil a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades regionais e sociais.

(E) Que a União, os Estados, o distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

118. (TRT 2ª Região/SP - Juiz do Trabalho - TRT 2R/2014) A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Em relação a esta afirmação, aponte a alternativa correta:

(A) Uma das finalidades da ordem econômica é dar tratamento favorecido às pequenas empresas, desde que sejam constituídas de acordo com a lei nacional e tenham sua sede e administração no Brasil.

(B) A busca do pleno emprego constitui um direito fundamental coletivo e não se confunde, nem se comunica, com a ordem econômica nacional, cujo objetivo é a garantia de lucro às empresas.

(C) A atividade econômica depende sempre de autorização dos órgãos públicos para que possa ser exercida, pois é necessário o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores.

(D) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras ainda que tenham sua sede e administração em outro país.

(E) A imposição de sentenças normativas para dirimir conflitos que imponham obstáculos ao equilíbrio entre o capital e o trabalho.

119. (TJ/PA - Analista Judiciário - Fiscal de Arrecadação - VUNESP/2014) A lei orçamentária anual, de acordo com a Constituição Federal em vigor, não veda a

(A) realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

(B) realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital não autorizadas.

(C) abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

(D) transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa.

(E) abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

120. (UNICAMP - Procurador - VUNESP/2014) Conforme estabelece a Constituição Federal, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os seguintes princípios:

(A) propriedade privada e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

(B) defesa do meio ambiente e plena abertura do mercado brasileiro para os investimentos estrangeiros que possam gerar empregos no país.

(C) função social da propriedade e garantia às empresas públicas e às sociedades de economia mista de privilégios fiscais diferenciados daqueles concedidos às do setor privado.

(D) favorecimento legal ao cooperativismo e ao associativismo e redução das desigualdades nacionais.

(E) livre concorrência e proteção dos trabalhadores, urbanos e rurais, em face da automação, na forma da lei.

121. (SEFAZ/RJ - Auditor Fiscal da Receita Federal - FCC/2014) Com o objetivo de instituir o imposto sobre grandes fortunas, o governo edita medida provisória em 12/04/2013, a qual, aprovada pelo

Congresso Nacional, é convertida em lei no dia 10/06/2013. Nesta situação hipotética, o referido imposto sobre grandes fortunas

(A) pode ser cobrado a partir de 12/04/2013, pois medida provisória gera efeitos desde sua edição, os quais, posteriormente, poderão ser mantidos ou não, conforme apreciação do Congresso Nacional.

(B) pode ser cobrado apenas a partir de 01/01/2014, em decorrência do princípio da anterioridade tributária.

(C) pode ser cobrado apenas a partir de 09/09/2013, em decorrência do princípio da anterioridade tributária nonagesimal.

(D) não pode ser cobrado por ser inconstitucional, na medida em que a Constituição da República expressamente veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar.

(E) não pode ser cobrado por ser inconstitucional, na medida em que a Constituição da República proíbe a criação do imposto sobre grandes fortunas em respeito ao princípio da igualdade tributária.

122. (SEFAZ/RJ - Auditor Fiscal da Receita Federal - FCC/2014) A competência para fixar as alíquotas máximas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, de quaisquer bens ou direitos, cabe

(A) à Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

(B) ao Senado Federal.

(C) ao Presidente da República.

(D) ao Congresso Nacional.

(E) ao Governador do respectivo Estado ou do Distrito Federal.

123. (EMPLASA - Analista Jurídico - Direito - VUNESP/2014) Os princípios constitucionais orçamentários orientam como devem ser elaborados, aprovados e executados os orçamentos públicos. Assim, prevê a Constituição Federal que a lei orçamentária anual deverá compreender o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da seguridade social. Esta previsão, constante do art. 165, § 5º da Constituição, é denominada princípio constitucional.

(A) do equilíbrio orçamentário

(B) da pureza orçamentária.

(C) da legalidade orçamentária

(D) da não afetação de receita.

(E) da universalidade orçamentária.

124. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) A leitura do lema “Educação: direito de todos e dever do Estado!” À luz do Direito Constitucional favorece o entendimento de que:

(A) o direito fundamental à educação exclui o direito à creche, dado tratar-se de dever da família.

(B) a educação é dever exclusivo do estado, sendo, portanto, alheio à família e à sociedade.

(C) o dever do estado com a educação dos deficientes é de atendimento educacional especializado, obrigatoriamente, fora da rede regular de ensino.

(D) a gratuidade do ensino público veda a percepção de quaisquer valores pelos estabelecimentos oficiais ainda que de cunho voluntário.

(E) a omissão no oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público importa em responsabilidade da autoridade competente.

125. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) A Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito fundamental a ser assegurado ao cidadão. A propósito desse direito,

(A) assegura-se o fornecimento de medicamentos de alto custo exclusivamente aos necessitados, devido à infinitude das demandas e à finitude dos recursos.

(B) é exclusiva do ministério público a legitimidade para ajuizamento de ação de mandado de segurança com vistas a promover o fornecimento de medicamentos.

(C) é vedada à iniciativa privada a exploração econômica da assistência à saúde dado o direito fundamental à saúde ser consectário do direito à vida.

(D) regula-se o sistema único de saúde (SUS) exclusivamente por meio da legislação infraconstitucional, visto que está fora das matérias constitucionais.

(E) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas de saúde com fins lucrativos.

126. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) A Constituição Federal de 1988 prevê a família como célula *mater* da sociedade, ao que goza, assim, de especial proteção do Estado. Por isso,

- (A) concebe-se como família aquela união feita por pessoas de diferentes sexos, desde que formalizada perante as autoridades notariais de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
- (B) entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
- (C) são exercidos diferentemente pelo homem e pela mulher, tendo em vista a própria diferença de gênero e os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal.
- (D) considera-se o casamento religioso inapto para gerar efeito civil, visto que a República Federativa do Brasil constitui um Estado laico.
- (E) é de livre decisão do casal o planejamento familiar, admitindo-se, porém, intervenção coercitiva do Estado para controle da natalidade.

127. (SEAP/DF - Analista Direito - IADES/2014) Quanto à ordem social preconizada pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) Constituem patrimônio cultural brasileiro apenas os bens de natureza imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência a identidade, a ação, e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
- (B) O Poder Público, isoladamente, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
- (C) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
- (D) A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração anual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do Poder Público.
- (E) A União organizará o sistema de cultura de cada estado, município e Distrito Federal.

128. (TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - FCC/2011) No que tange à Emenda Constitucional, é correto afirmar:

- (A) A Constituição Federal, em situação excepcional, poderá ser emendada na vigência de intervenção federal.
- (B) Pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado.
- (C) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um quarto, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- (D) A matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- (E) A proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

129. (TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - FCC/2011) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, sendo que:

- (A) se a medida provisória não for apreciada em até trinta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
- (B) a deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias não dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
- (C) é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
- (D) prorrogar-se-á por duas vezes por iguais períodos a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
- (E) caberá à comissão exclusiva de Deputados examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

130. (TCM-RJ - Técnico de Controle Externo - 2ª Etapa - FJG - RIO/2011) O Processo Legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis

delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. As normas constitucionais estabelecem que:

- (A) a discussão dos projetos de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal tem início no Senado Federal
- (B) a Constituição pode ser emendada mediante proposta de no mínimo 1% do eleitorado do país
- (C) a lei que disponha sobre criação de cargos na administração autárquica é de iniciativa privativa do Congresso Nacional
- (D) as leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, que deve solicitar a delegação ao Congresso Nacional, tendo esta delegação a forma de resolução
- (E) o veto realizado pelo Presidente da República pode ser rejeitado pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros do Congresso



Respostas

1. Resposta: “C”. Constituição é muito mais do que um documento escrito que fica no ápice do ordenamento jurídico nacional estabelecendo normas de limitação e organização do Estado, mas tem um significado intrínseco sociológico, político, cultural e econômico. Independente do conceito, percebe-se que o foco é a organização do Estado e a limitação de seu poder.

2. Resposta: “D”. Quanto à origem, a Constituição pode ser outorgada, quando imposta unilateralmente pelo agente revolucionário, ou promulgada, quando é votada, sendo também conhecida como democrática ou popular.

3. Resposta: “B”. A Constituição Federal e os demais atos normativos que compõem o denominado bloco de constitucionalidade, notadamente, emendas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum especial após a Emenda Constitucional nº 45/2004, estão no topo do ordenamento jurídico. Sendo assim, todos os atos abaixo deles devem guardar uma estrita compatibilidade, sob pena de serem inconstitucionais. Por isso, estes atos que estão abaixo na pirâmide, se sujeitam a controle de constitucionalidade.

4. Resposta: “E”. I está correta porque predomina no entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que o preâmbulo não tem força normativa e apenas reflete a ideologia política majoritária da Assembleia Constituinte. O ato das disposições constitucionais transitórias, por mais que seja composto de normas que aos poucos deixarão de ser exigíveis conforme a nova situação constitucional se consolida, faz parte do bloco de constitucionalidade, motivo pelo qual II está incorreta. III está correta porque reforça a possibilidade de controle de constitucionalidade de normas que se encontrem em hierarquia inferior à do bloco de constitucionalidade. Sendo assim, I e III estão corretas.

5. Resposta: “E”. Constituição inorgânica ou assistêmica (sem sistematização) são aquelas que não estão reunidas, codificadas, sob uma única forma. As normas estão espalhadas pelo ordenamento. Tradicionalmente, é o que ocorre nas Constituições costumeiras.

6. Resposta: “B”. Quando a Constituição Federal fala nas cláusulas pétreas, não exige que eventual emenda constitucional exclua tais regras, mas que meramente tendam a abolir. No conceito de tendente a abolir a federação, encontra-se a exclusão de competências dos entes federativos.

7. Resposta: “C”. Pelo conceito material de Constituição, o que define se uma norma será ou não constitucional é o seu conteúdo e não a sua mera presença no texto da Carta Magna. Em outras palavras, determinadas normas, por sua natureza, possuem caráter constitucional, como é o caso das normas relativas a direitos fundamentais.

8. Resposta: “Errado”. A constituição semântica não tem seu conteúdo limitado e é mero reflexo do contexto político da sociedade, sendo simples instrumento da dominação do poder. Eventuais objetivos

a serem atingidos pelo legislador ordinário são mais ilusões do que efetivas normativas a serem cumpridas. A classificação ontológica de Constituição não se liga à sua forma – sintética/analítica.

9. Resposta: “Certo”. Em termos pragmáticos, a Constituição é o documento que fica no ápice do ordenamento jurídico nacional estabelecendo normas de limitação e organização do Estado.

10. Resposta: “Certo”. Normas materialmente constitucionais são as que abordam matéria constitucional, independentemente de estarem ou não no texto constitucional, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa, que aborda aspectos sobre a inelegibilidade, trata de matéria constitucional mas formalmente é inconstitucional. Por seu turno, normas formalmente constitucionais são as que se encontram previstas no texto constitucional mas que não necessariamente abordam matéria constitucional (ex.: norma que aborda o Colégio Pedro II é formalmente constitucional, mas não materialmente constitucional).

11. Resposta: “A”. Desde a metade do século XX, o discurso do Positivismo não mais se adéqua às exigências jurídicas; no entanto, o pós-positivismo não promoveu um simples retorno ao jusnaturalismo, mas uma inclusão no ordenamento jurídico das ideias de justiça e legitimidade, bem como dos princípios como o da dignidade humana, da razoabilidade, da solidariedade e da reserva de justiça. No Brasil, desde o ano de 2001, 13 anos depois da Constituição Federal de 1988, parece estar se formando um novo direito constitucional. Neste novo Direito constitucional se percebe uma onda de ativismo na qual o intérprete assume o papel de efetivador da norma, não mais se contentando com a interpretação literal. Quando se vai além no processo de interpretação, num fenômeno de construção jurídica, se está legitimado pela própria ordem constitucional, salvo se houver evidente abuso da prerrogativa.

12. Resposta: “E”. O método científico-espiritual vai além da literalidade da norma, envolvendo a compreensão da Constituição como uma ordem de valores e como elemento do processo de integração. O artigo 37, I, CF não traz norma de aplicabilidade plena. Conforme doutrina constitucionalista o art. 230, §2º, CF trata-se de norma de eficácia plena, produzindo ampla e irrestritamente seus efeitos. A regulamentação sobre a competência de instituição de regiões metropolitanas é norma de eficácia plena, não contida.

Com efeito, somente resta a alternativa “E”, considerando que o método jurídico ou hermenêutico-clássico parte da premissa de que a Constituição é uma lei, devendo ser interpretada como tal, dispondo o intérprete dos seguintes elementos tradicionais ou clássicos da hermenêutica jurídica, que remontam à Escola Histórica do Direito de Savigny, de 1840: gramatical (ou literal); histórico; sistemático (ou lógico); teleológico (ou racional); e genético.

13. Resposta: “C”. O princípio da conformidade funcional ou da justeza é um dos princípios interpretativos das normas constitucionais e prescreve que ao intérprete da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, é defeso, proibido, modificar a repartição de funções fixadas pela própria Constituição Federal.

14. Resposta: “D”. Este método parte da premissa de que existe uma relação necessária entre o texto e a realidade. O teor literal da norma (elemento literal da doutrina clássica), que será considerado pelo intérprete, deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social. A norma terá de ser concretizada não só pela atividade do legislador, mas, também, pela atividade do Judiciário, da administração, do governo etc. Logo, está errada a afirmação de que neste método somente atua o legislador, restando “D” incorreta.

15. Resposta: “D”. As normas que definem direitos e garantias fundamentais são de eficácia imediata, motivo pelo qual “A” está incorreta. As de eficácia contida também, mas podem ter a eficácia restringida por lei, estando “B” incorreta. As normas de eficácia limitada possuem relevância jurídica interpretativa e integrativa, motivo pelo qual “C” está errada. E as normas programáticas trazem metas a serem atingidas e efetivadas pelo Estado, então “E” está incorreta. “D”, por seu turno, traz adequada conceituação das normas de eficácia plena e aplicabilidade direta.

16. Resposta: “D”. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade é uma lei ou ato normativo federal ou estadual que contrarie a Constituição Federal (art. 102, I, “a”, CF). Não é somente a lei que aceita o controle de constitucionalidade, embora lei seja o tipo mais clássico de ato normativo. É possível o controle de qualquer ato normativo federal ou estadual, por exemplo, uma medida provisória ou um Decreto autônomo. Qualquer ato normativo caracteriza-se por possuir abstração e generalidade,

bastando isto para ser considerado como tal. Contudo, para ser passível de controle de constitucionalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, precisa também ser autônomo.

17. Resposta: “A”. O rol de legitimados para proposição da ação é taxativo e está previsto no artigo 103 da CF: “Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o **Governador de Estado ou do Distrito Federal**; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional” (grifo nosso).

18. Resposta: “A”. O rol de legitimados para proposição da ação é taxativo e está previsto no artigo 103 da CF: “Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”. O artigo 2º da Lei nº 9.868/1999 repete o teor do artigo 103, CF. O Advogado-Geral da União representa o Presidente da República neste tipo de ação, mas não tem autonomia para a proposição.

19. Resposta: “C”. A repercussão geral é um dos mecanismos criado pelo Legislativo para restringir o número de recursos no STF. Prevista no art. 102, §3º, CF, desde a Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a ser requisito de admissibilidade do RE, exigindo que a matéria tenha relevante valor social, político, econômico ou jurídico, transcendendo o interesse individual das partes. Dos 11 ministros, ao menos 8 (2/3) devem dizer que não há repercussão geral. Logo, a falta de repercussão geral deve ser bem evidente.

20. Resposta: “D”. O artigo 103, CF traz rol taxativo de legitimados que “podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - **a Mesa da Câmara dos Deputados**; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”. Das alternativas, somente a “D” traz uma hipótese do dispositivo.

21. Resposta: “B”. “A” está incorreta porque as modalidades comuns de intervenção de terceiros não são permitidas na ação direta de inconstitucionalidade, mas apenas a do “amicus curiae”; “B” está correta porque é necessário que o controle de constitucionalidade previsto no âmbito estadual guarde uma necessária compatibilidade com este controle no âmbito federal (se o Procurador-Geral da República faz a representação na esfera federal, cabe ao Procurador-Geral de Justiça fazê-la no estadual); “C” está incorreta porque o Poder Legislativo não fica totalmente de mãos atadas em seu poder de legislar devido à decisão do Supremo, o que contrariaria a separação dos Poderes; “D” está incorreta porque o controle de constitucionalidade pode ser tanto repressivo quanto preventivo; “E” está incorreta porque com relação às leis anteriores à Constituição Federal o que se mede é a recepção ou ausência dela, somente cabendo controle de constitucionalidade com relação às normas posteriores, estando as anteriores incompatíveis automaticamente derogadas.

22. Resposta: “C”. “A” está incorreta porque a presunção feita é de constitucionalidade, ou seja, todas as leis e atos normativos são presumíveis constitucionais; “B” está incorreta porque há contraditório na ação direta de inconstitucionalidade, papel este desempenhado pelo Advogado-Geral da União no âmbito federal; “C” está correta porque cabe medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, regulada dos artigos 10 a 12 da Lei nº 9.868/1999; “D” está incorreta porque o controle de constitucionalidade

difuso pode ser exercido em qualquer esfera do Poder Judiciário; “E” está incorreta porque o cidadão não é legitimado, mas tão somente os expressamente enumerados no artigo 103, CF.

23. Resposta: “C”. Em seu artigo 102, §1º, a Constituição prevê que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental deverá ser disciplinada em lei específica, papel cumprido pela Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Conforme artigo 1º desta lei, a arguição “[...] será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.

24. Resposta: “E”. A Constituição imperial de 1824 nada versava sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade, tendo sido introduzido expressamente na Constituição de 1891. O controle de constitucionalidade só viria a sofrer inovação radical com a Emenda Constitucional nº 16 de 1965, mas já sob o regime militar, tendo sido instituída a ação genérica de inconstitucionalidade, oferecendo competência ao Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato federal, mediante representação que lhe fosse encaminhada pelo Procurador-Geral da República.

25. Resposta: “E”. A Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1992 alterou os artigos 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da Constituição Federal. Neste sentido, o artigo 102, I, “a”, CF passou a vigorar com a seguinte redação: “a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. Ainda, o artigo 103, §4º, CF, passou a vigorar com a seguinte redação: “a ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República”.

26. Resposta: “D”. O artigo 1º, CF traz os princípios fundamentais (fundamentos) da República Federativa do Brasil: “I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político”. O princípio de “A” se encontra no inciso V; o de “B” no inciso IV; o de “C” no inciso III, pois viola a dignidade humana da mãe forçá-la a dar luz a um filho que resulte de estupro; o de “E” decorre dos incisos I e II e é previsão do artigo 2º, que dispõe que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Somente resta a alternativa “D”, que apesar de realmente trazer um objetivo da República Federativa brasileira – previsto no artigo 3º, IV, não tem a ver com os princípios fundamentais, mas sim com os objetivos.

27. Resposta: “C”. A democracia brasileira adota a modalidade semidireta, porque possibilita a participação popular direta no poder por intermédio de processos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Como são hipóteses restritas, pode-se afirmar que a democracia indireta é predominantemente adotada no Brasil, por meio do sufrágio universal e do voto direto e secreto com igual valor para todos. Contudo, não é a única maneira de se exercer o poder (artigo 14, CF e artigo 1º, parágrafo único, CF).

28. Resposta: “C”. O último artigo do título I trabalha com os princípios que regem as relações internacionais da República brasileira: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - **não-intervenção**; V - igualdade entre os Estados; VI - **defesa da paz**; VII - **solução pacífica dos conflitos**; VIII - **repúdio ao terrorismo e ao racismo**; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. Os grifos apontam que a alternativa “C” descreveu corretamente 4 dos princípios que regem as relações internacionais da República brasileira.

29. Resposta: “Certo”. O último artigo do título I trabalha com os princípios que regem as relações internacionais da República brasileira: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] X - concessão de asilo político”.

30. Resposta: “Errado”. A dignidade da pessoa humana coloca a pessoa humana em si, como indivíduo, na qualidade de valor-fonte da sociedade. Nem sempre a noção de interesse coletivo implicará na quebra do direito individual, pois a dignidade da pessoa humana possui forte cunho individual.

31. Resposta: “Certo”. A expressão pluralismo remete ao reconhecimento da multiplicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas e sociais no âmbito de uma nação. Quando se fala em pluralismo político, afirma-se que mais do que incorporar esta multiplicidade de ideologias cabe ao Estado nacional fornecer espaço para a manifestação política delas. Pluralismo político vai além do pluripartidarismo ou multipartidarismo, que é apenas uma de suas consequências e garante que mesmo os partidos menores e com poucos representantes sejam ouvidos na tomada de decisões políticas, porque abrange uma verdadeira concepção de multiculturalidade no âmbito interno.

32. Resposta: “A”. Consta no *caput* do artigo 1º, CF: “a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito [...]”.

33. Resposta: “A”. Neste sentido, é a disciplina constitucional: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; **II - garantir o desenvolvimento nacional**; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

34. Resposta: “C”. Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (artigo 3º, II, CF), mas não princípio regente das relações internacionais, previstos no artigo 4º, CF.

35. Resposta: “D”. Neste sentido, disciplina: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a **soberania**; II - a **cidadania**; III - a **dignidade da pessoa humana**; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o **pluralismo político**. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. A prevalência dos direitos humanos, por seu turno, é princípio que rege as relações internacionais brasileiras (artigo 4º, II, CF).

36. Resposta: “A”. O constituinte trabalha no artigo 3º da Constituição Federal com os objetivos da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é princípio que rege as relações internacionais brasileiras (artigo 4º, IX, CF).

37. Resposta: “A”. No que tange ao tema, destaque para os seguintes incisos do artigo 5º da CF: “LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; LXXII - conceder-se-á *habeas data*: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Os itens “I” e “II” repetem o teor do artigo 5º, LXXII, CF. Já o item “III” decorre logicamente da previsão dos direitos fundamentais como limitadores da atuação do Estado, logo, as informações requeridas serão contra uma entidade governamental da administração direta ou indireta. Por sua vez, o item “IV” reflete o artigo 5º, LXXI, CF, do qual decorre logicamente o item “V”, posto que a demora do legislador em regulamentar uma norma constitucional de aplicabilidade mediata, que necessita do preenchimento de seu conteúdo, evidencia-se em risco aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal.

38. Resposta: “A”. Nos termos do artigo 5º, LIII, CF, “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”, restando o item “I” correto; pelo artigo 5º, LX, CF, “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o

exigirem”, motivo pelo qual o item “II” está correto; e prevê o artigo 5º, LXVI, CF que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, confirmando o item “IV”. Por sua vez, o item “III” está incorreto porque “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (artigo 5º, LVI, CF); e o item “V” está incorreto porque a jurisprudência atual ainda aceita a prisão civil do devedor de alimentos, sendo que o texto constitucional autoriza tanto esta quanto a do depositário infiel (artigo 5º, LXVII, CF).

39. Resposta: “C”. “A” está incorreta porque a autorização é dispensada (artigo 5º, XVI, CF); “B” porque o júri não julga crimes culposos contra a vida, só dolosos (artigo 5º, XXXVIII, CF); “D” porque a ordem deve ser judicial e não pode partir do Ministério Público (artigo 5º, XII, CF); “E” porque o ingresso por determinação judicial se dá durante o dia (artigo 5º, XI, CF). Somente resta “C”, que traz a previsão do artigo 5º, XLIII, CF: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

40. Resposta: “D”. “A” está errada porque o objeto, necessariamente, tem que se referir a informações pessoais; “B” está errada porque contraria os termos do artigo 8º, parágrafo único da Lei nº 9.507/1997; “C” está errada porque o recurso cabível é apelação (artigo 15, Lei nº 9.507/1997). Somente resta a alternativa “D”, consoante ao artigo 19, *caput*, Lei nº 9.507/1997: “Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas-corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator”.

41. Resposta: “B”. Trata-se do direito individual assegurado no artigo 5º, XLV, CF: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. Logo, a obrigação se transfere nos limites da herança, sendo que em eventual sucessão se apurará no patrimônio do falecido o suficiente para pagamento da reparação do dano e, eventual saldo remanescente, será transmitido aos herdeiros.

42. Resposta: “A”. Preconiza o artigo 5º, XL, CF: “XL - a lei penal **não retroagirá**, salvo para **beneficiar** o réu”. Assim, se vier uma lei posterior ao fato que o exclua do rol de crimes ou que confira tratamento mais benéfico (diminuindo a pena ou alterando o regime de cumprimento, notadamente), ela será aplicada.

43. Resposta: “B”. Neste sentido, prevê o artigo 5º, XLII, CF: “XLII - a prática do **racismo** constitui crime **inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”, restando “B” correta. “A” é incorreta porque a lei penal retroage para beneficiar o réu; “C” é incorreta porque é aceita a pena de morte para os crimes militares praticados em tempo de guerra; “D” é incorreta porque igrejas não possuem inviolabilidade domiciliar.

44. Resposta: “D”. Embora o direito previsto na alternativa “D” seja um direito fundamental, não é um direito individual, logo, não está previsto no artigo 5º, e sim no artigo 7º, CF, em seu inciso IX (“remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”).

45. Resposta: “D”. A propósito, o artigo 5º, XI, CF dispõe: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, **durante o dia**, por determinação judicial”. Sendo assim, não cabe o ingresso por determinação judicial a qualquer hora, mas somente durante o dia.

46. Resposta: “A”. Prevê a Constituição em seu artigo 5º, LXVIII: “LXVIII - conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, trata-se de ação que tem por fim proteger a liberdade de locomoção.

47. Resposta: “B”. A teoria da reserva do possível busca impedir que se argumente por uma obrigação infinita do Estado de atender direitos econômicos, sociais e culturais. No entanto, não pode ser invocada como muleta para impedir que estes direitos adquiram efetividade. Se a invocação da reserva

do possível não demonstrar cabalmente que o Estado não tem condições de arcar com as despesas, o Poder Judiciário irá intervir e sanar a omissão.

48. Resposta: “C”. A Emenda Constitucional nº 72/2013, que ficou conhecida no curso de seu processo de votação como PEC das domésticas, deu redação ao parágrafo único do artigo 7º, o qual estende alguns dos direitos enumerados nos incisos do caput para a categoria dos trabalhadores domésticos, quais sejam: “IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social”. Os direitos descritos na alternativa “C” estão previstos nos incisos XXVII e XX do artigo 7º da Constituição, não estendidos aos empregados domésticos pela emenda.

49. Resposta: “Certo”. Estabelece a Constituição: “Artigo 12, § 3º, CF. São **privativos de brasileiro nato** os cargos: [...] V - da carreira diplomática”.

50. Resposta: “A”. Nação é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e tem os mesmos costumes, formando assim, um povo. Uma nação se mantém unida pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. O conceito de Nação, por vezes, pode ser mais amplo que o conceito de País ou mesmo de território. Sendo assim, “A” está correta. Por sua vez, “B” está incorreta porque nacionalidade não é um vínculo entre duas pessoas, mas com o próprio Estado; “C” está incorreta porque a nacionalidade primária é automática; “D” está incorreta porque população é um conceito que abrange não só os nacionais, mas também os estrangeiros residentes no país; “E” está incorreta porque traz o conceito de Nação, de certo modo, não de povo.

51. Resposta: “C”. A Constituição reconhece o brasileiro nato também pelo critério do *ius sanguinis*. Se qualquer dos pais estiver a serviço do Brasil, é considerado brasileiro nato, mesmo que nasça em outro país. Se qualquer dos pais não estiverem a serviço do Brasil e a pessoa nascer no exterior é exigido que o nascido do exterior venha ao território brasileiro e aqui resida ou que tenha sido registrado em repartição competente, caso em que poderá, aos 18 anos, manifestar-se sobre desejar permanecer com a nacionalidade brasileira ou não. Em ambos casos, a pessoa é considerada brasileira nata. Pablo, por seu turno, é brasileiro nato e não se sujeita a nenhuma das restrições constitucionais aplicadas aos brasileiros naturalizados.

52. Resposta: “D”. Se qualquer dos pais não estiverem a serviço do Brasil e a pessoa nascer no exterior é exigido que o nascido do exterior venha ao território brasileiro e aqui resida ou que tenha sido registrado em repartição competente, caso em que poderá, a partir dos 18 anos, manifestar-se sobre desejar permanecer com a nacionalidade brasileira ou não (artigo 12, I, “c”, CF). No caso, Sicrano poderá ser considerado brasileiro nato e não existe na Constituição hipótese que autorize a extradição de brasileiro nato.

53. Resposta: “B”. Neste sentido, “Art. 12, CF. São brasileiros: I - natos: [...] c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”. “A” está incorreta porque o cancelamento de naturalização se dá por decisão judicial; “C” está incorreta porque define brasileiros naturalizados; “D” está incorreta porque o que é privativo é o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

54. Resposta: “D”. Os direitos políticos nunca podem ser cassados ou perdidos, mas no máximo suspensos. A condenação criminal transitada em julgado justifica a suspensão dos direitos políticos, o que é disposto no artigo 15, III, CF: “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: [...] III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”.

55. Resposta: “B”. Prevê o artigo 14, § 3º, CF: São condições de elegibilidade, na forma da lei: [...] VI - a idade mínima de: c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz”, de modo que João preenche o requisito etário para a candidatura. “A” está errada porque a renúncia é exigida para cargo diverso (artigo 14, §6º, CF); “C” está errada porque

o analfabeto não pode se eleger (artigo 14, §4º, CF); “D” está errada porque o afastamento neste caso é exigido (artigo 14, §8º, I, CF).

56. Resposta: “C”. O artigo 17 da Constituição Federal regulamenta os partidos políticos e coloca o caráter nacional como preceito que deva necessariamente se observado: “É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: I - **caráter nacional**; II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar”.

57. Resposta: “C”. “A” está incorreta porque o que é vedado é o recebimento de recursos de entidade ou governo estrangeiros, mas não de transnacionais (artigo 17, II, CF); “B” está incorreta porque o acesso gratuito à propaganda no rádio e na televisão dispensa representatividade no Congresso Nacional (artigo 17, §3º, CF); “C” está correta porque o partido político deve ter caráter nacional (artigo 17, I, CF); “D” está incorreta porque a prestação de contas é feita ao Tribunal Superior Eleitoral; “E” está incorreta porque partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado.

58. Resposta: “B”. Neste sentido, o artigo 14, CF: “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular”.

59. Resposta: “Errado”. A soberania é elemento intrínseco ao Estado nacional, ou seja, à União. O Brasil, enquanto Estado Nacional, é soberano. Suas unidades federativas, por seu turno, não possuem o atributo da soberania, tanto que não podem dele se desvincularem (atitudes neste sentido podem gerar intervenção federal por atentarem contra o regime federativo). Logo, os Estados-membros possuem autonomia relativa, limitada ao previsto pela Constituição, e não possuem soberania.

60. Resposta: “Errado”. Os Territórios, atualmente não existentes no país, se vierem a existir, possuem vinculação com a União e não a autonomia enquanto entes federativos. Somente são entes federativos a União, os Estados, O distrito Federal e os Municípios.

61. Resposta: “D”. O artigo 37, caput da Constituição Federal colaciona os cinco princípios descritos na alternativa “A” como de necessária observância na Administração Pública em todas suas esferas e em todos os seus Poderes. Já a alternativa “B” repete previsão expressa do artigo 37, VI, CF; assim como a alternativa “C” traz a previsão do artigo 37, XVIII, CF; e a alternativa “E” repete o previsto no artigo 37, V, CF.

Somente resta a alternativa “D”, que contraria o teor do artigo 37, XVII, CF: “A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público”. Com efeito, as sociedades de economia mista não estão excluídas da proibição de acumulação remunerada de cargos, razão pela qual a alternativa é incorreta.

62. Resposta: “D”. A alternativa “A” colaciona a exigência do artigo 37, II, CF; a alternativa “B” traz os clássicos princípios da Administração Pública previstos no *caput* do artigo 37; em “C” percebe-se o prazo de validade de um concurso público e sua possibilidade de prorrogação nos moldes exatos do artigo 37, III, CF; e “E” repete o teor do artigo 37, §5º, CF. Por sua vez, a vedação de acumulações ao servidor público está prevista no artigo 37, XVI, CF: “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

63. Resposta: “D”. Disciplina o artigo 18, §4º, CF: “§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o **desmembramento** de Municípios, far-se-ão por **lei estadual**, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”.

64. Resposta: “B”. O federalismo dualista é caracterizado por uma rígida separação de competências entre o ente central (união) e os entes regionais (estados-membros). Sendo assim, não há uma relação mais intensa de submissão e sim de autonomia.

65. Resposta: “A”. Desde logo, percebe-se o teor do artigo 25, *caput* e §3º, CF: “Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição [...] Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.

66. Resposta: “B”. Trata-se do teor do artigo 37, *caput*, CF: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e **eficiência**”.

67. Resposta: “B”. Trata-se de julgamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de nº 4167, ajuizada em 2008, pelos governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará em face à Lei nº 11.738/2008, no que se refere à criação do nacional dos professores atuantes na rede pública de ensino. A Lei nº 11.738/2008 (norma impugnada) veio a regulamentar o art. 60 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), em seu inciso III, alínea “e”, instituindo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da EC (Emenda Constitucional), de nº 53/06, que alterou a redação do art. 206, CF, VIII. A manifestação da AGU (Advocacia Geral da União) foi pela improcedência da ação e neste mesmo sentido foi a manifestação do PGR (Procurador Geral da República) que, em relação à ofensa ao art. 169, CF, defendeu o julgamento da ação sem análise do mérito e, ao restante, a improcedência da ação. Foi esse o entendimento firmado pelo STF em sua decisão, na qual reconheceu a constitucionalidade da norma.

68. Resposta: “D”. É o teor do artigo 39, §4º, CF: “O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”.

69. Resposta: “Certo”. Salário-família é o benefício pago na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de qualquer condição até a idade de quatorze anos ou inválido de qualquer idade, previsto na Constituição Federal e sendo devido aos servidores públicos, consoante à regulamentação da Lei nº 8.112/1990 em seus artigos 197 a 201.

70. Resposta: “Errado”. O princípio da moralidade administrativa, assegurado no artigo 37 da Constituição ao lado do princípio da legalidade, demonstra que não basta ao administrador respeitar a lei: deve ir além, agir conforme a melhor conduta moral, ser um espelho de conduta ao exterior. Logo, a legalidade estrita é necessária, mas insuficiente, ao comportamento do bom agente público.

71. Resposta: “Certo”. Nestes termos, prevê o artigo 24 da Constituição em seu inciso XI: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre: [...] XI - **procedimentos** em matéria processual”. Vale destacar que a competência para legislar sobre direito processual propriamente dito é privativa da União (artigo 22, I, CF).

72. Resposta: “Errado”. Neste sentido, a disciplina do artigo 29, CF em seu inciso IV, alínea “b”: “para a composição das **Câmaras Municipais**, será observado o limite máximo de: [...] b) **11 (onze) Vereadores**, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes”. Portanto, no máximo, um Município com este número de habitantes pode ter 11 vereadores, não 15 vereadores.

73. Resposta: “Errado”. A primeira parte da assertiva está correta, trazendo o *caput* do artigo 31, CF: “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”. Da mesma forma, a segunda parte da assertiva está correta, trazendo o §1º do mesmo dispositivo: “o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver”. O único erro se encontra na parte final da assertiva, notadamente quanto ao quórum para que deixe de prevalecer o parecer prévio, que não é de maioria absoluta, mas sim de dois terços, o que se extrai do §2º do dispositivo: “o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de **dois terços** dos membros da Câmara Municipal”.

74. Resposta: “C”. É o que prevê a Constituição Federal: “Artigo 18, §3º, CF. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do Congresso Nacional, por **lei complementar**”.

75. Resposta: “B”. Nos termos constitucionais, “o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período**” (artigo 37, III, CF).

76. Resposta: “B”. O item I está correto porque, nos termos do artigo 38, II, CF, o servidor “investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração”; o item II está incorreto porque, nos termos do artigo 38, IV, CF, o servidor “em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento**”; o item III está correto porque, nos termos do artigo 38, III, CF, o servidor “investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior”. Logo, apenas II está incorreta.

77. Resposta: “A”. O Supremo Tribunal Federal consagrou jurisprudência, de natureza quase principiológica, segundo a qual “não há direito adquirido a regime jurídico” (RE 227755 AgR/CE, dentre muitos). Evidentemente que esse reconhecimento se revela importante elemento de ajuste das relações administrativas às possibilidades governamentais, sobretudo à luz da reserva do possível, e de evolução legislativa e jurídica.

78. Resposta: “A”. A respeito, prevê o artigo 26, I, CF: “Incluem-se entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”.

79. Resposta: “A”. Prevê o artigo 24, § 2º, CF que “a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a **competência suplementar dos Estados**”. Os Estados não ficam impedidos de criar leis regulamentadoras destas matérias enquanto a União não o faça, mas sobrevivendo norma geral reguladora, perdem a eficácia os dispositivos de lei estadual com ela incompatível.

80. (OAB - Exame de Ordem Unificado - FGV/2014)

Resposta: “B”. Disciplina o artigo 22, XI, CF que “compete privativamente à União legislar sobre: [...] XI - trânsito e transporte”. Logo, a matéria não poderia ter sido legislada por lei municipal.

81. Resposta: “D”. A competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito financeiro e urbanístico. “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”.

82. Resposta: “A”. Disciplina o artigo 31, *caput*, CF: “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”.

83. Resposta: “C”. Nos termos do artigo 52, III, “a”, CF: “Compete privativamente ao Senado Federal: [...] III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição”; sendo que a respeito prevê o artigo 111-A, CF: “o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela **maioria absoluta do Senado Federal**” (grifo nosso).

84. Resposta: “D”. Prevê o artigo 36, CF: “A decretação da intervenção dependerá: [...] III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal”. Por seu turno, prevê o referido artigo 34, VII, CF: “VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) **direitos da pessoa humana**; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta”. No caso relatado no enunciado, há evidente desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

85. Resposta: “B”. Na apreciação e elaboração de leis e emendas constitucionais, no geral, ambas Casas do Congresso Nacional possuem a mesma força, seja quando deliberam de forma conjunta, seja quando deliberam de forma autônoma. Na deliberação conjunta, como no caso do veto (art. 66, §4º, CF) e da revisão constitucional (art. 3º, ADCT), a força dos membros é equivalente. Da mesma forma, em matéria de emenda constitucional e equivalentes, a deliberação tem a mesma força (art. 60, CF). Nos casos de leis ordinárias, conversão de medidas provisórias em leis e de leis complementares, quase sempre a deliberação principal se fará na Câmara dos Deputados, o que a coloca numa posição de destaque no sistema jurídico-constitucional.

86. Resposta: “C”. Nos termos do artigo 60, §1º, CF, “a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio”. Presentes estas circunstâncias que indicam instabilidade no cenário nacional, não é possível emendar a constituição.

87. Resposta: “A”. Um deputado federal precisa do apoio de ao menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, logo, 172 deputados federais. Então, o requisito formal subjetivo de iniciativa foi preenchido com a assinatura de 174. Não houve votação durante estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, logo, ausentes limites circunstanciais. Em termos materiais, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, mas tão somente “o voto direto, secreto, universal e periódico” (artigo 60, §4º, II, CF). Sendo assim, a proposta poderá ser objeto de deliberação.

88. Resposta: “B”. O artigo 58 da Constituição regulamenta as Comissões Parlamentares de Inquérito em seu §3º: “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”. A existência de investigação criminal ou civil em curso não importam para fins de possibilitar a instauração de CPI, bastando o preenchimento dos requisitos do dispositivo retro.

89. Resposta: “Certo”. Coloca-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas – notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar – devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. A norma inscrita no art. 58, § 3º, da CR destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional. A maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, § 3º, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado. Precedentes: MS 24.847/DF, Rel.

Min. Celso de Mello. A ofensa ao direito das minorias parlamentares constitui, em essência, um desrespeito ao direito do próprio povo, que também é representado pelos grupos minoritários que atuam nas Casas do Congresso Nacional. (...) O requisito constitucional concernente à observância de 1/3 (um terço), no mínimo, para criação de determinada CPI (CF, art. 58, § 3º), refere-se à subscrição do requerimento de instauração da investigação parlamentar, que traduz exigência a ser aferida no momento em que protocolado o pedido junto à Mesa da Casa legislativa, tanto que, 'depois de sua apresentação à Mesa', consoante prescreve o próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 102, § 4º), não mais se revelará possível a retirada de qualquer assinatura. Preenchidos os requisitos constitucionais (CF, art. 58, § 3º), impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências (CF, art. 58, § 3º), cumpre, ao presidente da Casa legislativa, adotar os procedimentos subseqüentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não se revestindo de legitimação constitucional o ato que busca submeter, ao Plenário da Casa legislativa, quer por intermédio de formulação de questão de ordem, quer mediante interposição de recurso ou utilização de qualquer outro meio regimental, a criação de qualquer CPI. A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos), não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional, que não dispõe de qualquer parcela de poder para deslocar, para o Plenário das Casas legislativas, a decisão final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena de frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que o integram), do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles que se estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo. A rejeição de ato de criação de CPI, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso interposto por líder de partido político que compõe a maioria congressual, não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria CR outorga às minorias que atuam nas Casas do Congresso Nacional." (MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-4-2007, Plenário, DJE de 18-12-2009).

90. Resposta: "C". Poder constituinte decorrente consiste no poder dos Estados-membros elaborarem sua própria Constituição por suas Assembleias Legislativas (artigo 25, CF), restando "C" correta. "A" está incorreta porque o Poder Constituinte Originário é o único que pode definir cláusulas pétreas; "B" está incorreta porque o voto nestes moldes é cláusula pétrea (artigo 60, §4º, II, CF); "D" está incorreta porque a Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio (artigo 60, §1º, CF).

91. Resposta: "C". O parlamentar que se licencia (que se afasta das suas funções parlamentares) para ocupar outro cargo na Administração Pública não conta com a inviolabilidade penal (ou mesmo imunidades) (Informativo STF nº 135), logo, "C" está correta. "A" está incorreta porque no Senado Federal não vige o princípio proporcional; "B" está incorreta porque a imunidade formal abrange apenas a prisão e o processo de parlamentares; "D" está incorreta porque as comissões parlamentares de inquérito possuem poder de investigação.

92. Resposta: "D". Em termos gerais, as Comissões Parlamentares, que podem ser permanentes ou temporárias e internas ou intercamerais, são criadas com o intuito de auxiliar a atuação do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Dentre estas comissões, está a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem suas características principais descritas no art. 58, § 3º da Constituição Federal. A proporcionalidade da representação partidária nas comissões em geral está assegurada no artigo 58, §4º, CF.

93. Resposta: "E". A Constituição Federal fixa diversos limites para a edição de medidas provisórias, dentre elas versar sobre direito penal, nos termos do artigo 62, §1º, I, "b", CF: "É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: I - relativa a: [...] b) direito penal, processual penal e processual civil".

94. Resposta: "D". Disciplina o artigo 62, § 1º, CF: "É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: I – relativa a: a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; b) direito penal, processual penal e processual civil; c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; III – reservada

a lei complementar; IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República”.

95. Resposta: “C”. A incumbência descrita na assertiva “C” é privativa do Senado Federal: “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [...] X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.

96. Resposta: “A”. Prevê o artigo 83, CF: “O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a **quinze dias**, sob pena de perda do cargo”.

97. Resposta: “B”. Disciplina, neste sentido, o artigo 81, §1º, CF: “Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. § 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei”.

98. Resposta: “D”. Quem assume no lugar do Vice-Presidente, segundo a ordem prevista no artigo 80, CF, é sucessivamente, “o **Presidente da Câmara dos Deputados**, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”. Como vagaram os dois cargos, Presidência e Vice-Presidência, “[...] far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga (artigo 81, *caput*, CF), mas “ocorrendo a vacância nos **últimos dois anos** do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita **trinta dias** depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei” (artigo 81, §1º, CF).

99. Resposta: “B”. A questão da necessária compatibilidade com a Constituição Federal deve ser vista com reservas. Neste sentido, inegável que certos preceitos constitucionais devem ser respeitados, como o princípio democrático, de onde se depreende a necessidade de eleições para o caso de vacância do titular do Poder Executivo e de seu vice. Entretanto, não é necessário repetir a regulamentação da Constituição Federal quanto ao Executivo Federal na legislação municipal.

100. Resposta: “Errado”. No termos do artigo 87, parágrafo único, CF: “Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: I - **exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência** e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República; II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério; IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República”. O erro da afirmativa está na extensão da capacidade de orientação, coordenação e supervisão ao âmbito estadual, o que violaria o pacto federativo.

101. Resposta: “A”. Neste sentido, é a disciplina constitucional: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; [...]. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e **XXV**, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações”.

102. Resposta: “E”. “A” está incorreta porque a decisão, mesmo sobre infrações disciplinares, é tomada em sessão pública; “B” está incorreta porque o único legitimado para decidir é o juiz e não seu servidor, ainda que por delegação; “C” está incorreta porque a lista é sêxtupla; “D” está incorreta porque o prazo em que se proíbe o exercício é de três anos. Somente resta a alternativa “D”, aplicando-se o artigo 95, CF: Os juízes gozam das seguintes garantias: [...] II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII”. Logo, o motivo de interesse público pode gerar a quebra da garantia da inamovibilidade.

103. Resposta: “D”. As competências de processamento e julgamento estão previstas nos artigos 102, CF – em relação ao Supremo Tribunal Federal – e 105, CF – quanto ao Superior Tribunal de Justiça. As regras de competências previstas nas alternativas “A”, “B”, “C” e “E” estão incorretas, pelos seguintes motivos:

Quanto à alternativa “A”, o art. 102, I, “e”, CF prevê que o Supremo Tribunal Federal processa e julga originariamente “o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território”, excluindo os Municípios.

Em relação à alternativa “B”, o artigo 102, II, “a”, CF, prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o ‘habeas corpus’, o mandado de segurança, o ‘habeas data’ e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”, logo, o recurso é ordinário, não extraordinário.

No que tange à alternativa “C”, o artigo 105, I, “d”, CF prevê que o Superior Tribunal de Justiça processará e julgará originariamente “os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”, de modo que o julgamento é originário, não em sede de recurso especial.

Sobre a alternativa “E”, “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal” são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 102, I, “o”, CF, mas não em sede de recurso ordinário, e sim originariamente.

Resta a alternativa “D”, que vai de encontro com o artigo 105, I, “g”, CF, competindo originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar “os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União”.

104. Resposta: “C”. O Estatuto da Magistratura tem suas regulamentações gerais descritas no artigo 93 da CF, sendo que todas as alternativas, exceto a “C” estão em compatibilidade com este dispositivo. Neste sentido, o artigo 93, II, “d”, CF prevê que “na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de **dois terços de seus membros**, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação”. Sendo assim, não consideram-se apenas os membros presentes, mas todos os membros do Tribunal.

105. Resposta: “A”. O artigo 129, CF, estabelece as funções institucionais do Ministério Público, nos seguintes termos: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - **promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei**; II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - **promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos**; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI - **expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva**; VII - **exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar** mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. Com efeito, embora o Ministério Público possa promover a defesa dos direitos e dos interesses das populações indígenas, não o faz por promotor *ad hoc*, figura não mais aceita, nos termos do artigo 129, §2º, CF, que prevê: “As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição”.

106. Resposta: “C”. Conforme artigo 29, X, CF, estabelece-se o “julgamento do **Prefeito** perante o **Tribunal de Justiça**”, abrangendo inclusive crimes dolosos contra a vida.

107. Resposta: “A”. Neste viés, observa-se o caput do artigo 103-A, CF, que regulamenta a denominada súmula vinculante: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.

108. Resposta: “Errado”. O Conselho Nacional de Justiça não é uma nova instância de recurso judicial, mas sim um órgão administrativo que faz o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (artigo 103-B, CF).

109. Resposta: “C”. Vale colacionar o inteiro teor do artigo 144, CF: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. § 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. § 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares**. § 5º às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei”. Conforme grifo, as infrações penais militares não se incluem na competência da polícia civil, restando a alternativa “C” incorreta.

110. Resposta: “D”. Nos termos do artigo 144, §8º, CF, a criação de guardas municipais destina-se à “proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.

111. Resposta: “D”. “A” está incorreta porque a polícia federal exerce com exclusividade o papel de polícia judiciária da União (artigo 144, §1º, IV, CF); “B” está incorreta porque excetuam-se as militares (artigo 144, § 4º, CF); “C” está incorreta porque o vínculo não se estabelece com a União (artigo 144, § 6º, CF); “D” está correta porque traz o teor do artigo 144, § 8º, CF – “os Municípios poderão constituir **guardas municipais** destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”; “E” está incorreta porque o constituinte não prevê o Sistema de Segurança Militar.

112. Resposta: “B”. Nos termos do artigo 136, § 4º, CF, “decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de **vinte e quatro horas**, submeterá o ato com a respectiva **justificação ao Congresso Nacional**, que decidirá por maioria absoluta”. “A” está incorreta porque não basta a oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional; “C” está incorreta porque é caso de estado de sítio; “D” está incorreta porque o Congresso Nacional nunca será fechado.

113. Resposta: “E”. Disciplina o artigo 144, § 4º, CF: “Às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais**, exceto as militares”.

114. Resposta: “C”. Prevê o artigo 144, § 6º, CF: “As **polícias militares e corpos de bombeiros militares**, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

115. Resposta: “A”. Conforme o artigo 164, §3º, CF, “as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei”. Logo, lei pode prever que o depósito será feito em instituição privada.

116. Resposta: “C”. A alternativa “A” está de acordo com o previsto no artigo 216, §1º, CF; a alternativa “B” está de acordo com o artigo 216, §5º, CF; a alternativa “D” está conforme o artigo 184, §5º, CF. Somente não guarda compatibilidade com a Constituição a alternativa “C”, porque, nos termos do artigo 185, parágrafo único, “a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social”.

117. Resposta: “E”. “A” está incorreta porque a finalidade é “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (artigo 170, *caput*, CF); “B” está incorreta porque os princípios da ordem econômica são soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País – nada se falando a respeito do voto popular; “C” está incorreta porque o que a Constituição prevê no artigo 172 é que “a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital **estrangeiro**, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros”, não incluindo o capital nacional; “D” descreve princípios da ordem econômica e não funções da atividade econômica. Somente resta “E”, em consonância com o texto constitucional: “Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico”.

118. Resposta: “A”. Nos termos do artigo 170, CF, “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”.

119. Resposta: “E”. Conforme dispõe o §3º do artigo 167, CF, “a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62”, restando correta a alternativa “E”.

120. Resposta: “A”. Estabelece o artigo 170, CF, os seguintes princípios que regem a ordem econômica: I - soberania nacional; II - **propriedade privada**; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - **tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País**”. Nos grifos, denotam-se os princípios colacionados na alternativa “A”. “B” está incorreta porque a abertura do mercado brasileiro ao estrangeiro não é plena; “C” está incorreta porque as empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem privilégios fiscais diferenciados; “D” está incorreta porque não consta como princípio o favorecimento legal ao cooperativismo e ao associativismo; “E” também não traz um princípio, mas um direito social.

121. Resposta: “D”. A vedação de medida provisória que verse sobre matéria que seria tratada por lei complementar se encontra no artigo 62, III, CF. Por seu turno, “compete à União instituir impostos sobre: [...] grandes fortunas, nos termos de lei complementar” (artigo 163, VII, CF).

122. Resposta: “B”. Embora o artigo 155 preveja que “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão *causa mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos”, o § 1º do

dispositivo prevê que o imposto previsto no inciso “terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal”.

123. Resposta: “E”. A lei orçamentária anual visa efetivar a lei de diretrizes orçamentárias e por isso é a mais concreta de todas as leis que compõem a tríade orçamentária, visto que terá previsão de receitas e despesas, para um período de um ano. Sendo assim, tem abrangência universal de todos os aspectos do orçamento.

124. Resposta: “E”. Em que pese o direito à educação ser um direito de segunda dimensão, classicamente relacionado à ideia de norma programática do texto constitucional, as promessas feitas pelo constituinte não podem ser tomadas de forma vã. A omissão do Estado em garantir a gratuidade do ensino público, assegurada no artigo 206, IV, CF, gera responsabilidade da autoridade que deveria ter tomado providências para tanto. No mais, trata-se de dever compartilhado e não exclusivo do Estado, que abrange todas as esferas educacionais, inclusive o ensino em creche, além do ensino não formal. Os deficientes devem ser integrados neste sistema, não excluídos dele. Eventualmente, os estabelecimentos oficiais podem perceber valores, notadamente provenientes de doações.

125. Resposta: “E”. Os medicamentos de alto custo devem ser fornecidos a todos aqueles que o necessitarem, não somente aos hipossuficientes, até mesmo porque é possível que uma pessoa com boa renda não tenha condições de arcar com estes.

O mandado de segurança buscando o fornecimento de medicamentos pode ser interposto pelo Ministério Público, mas não somente por ele, também pela Defensoria Pública e pelo próprio interessado.

O sistema de saúde está previsto na Lei nº 8.080/1990, mas encontra substrato constitucional, especialmente em seu artigo 6º. Referida lei especial assegura a possibilidade de participação de entidades privadas no sistema, desde que não possuam fim lucrativo, ou seja, atendam pelo preço do SUS.

126. Resposta: “B”. A alternativa “A” está incorreta porque o que se equiparou à família foi a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a qual independe de formalização escrita.

A alternativa “C” está incorreta porque o artigo 226, §5º, CF prevê a igualdade entre homem e mulher no casamento: “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. O casamento religioso, por sua vez, pode gerar efeitos civis, conforme artigo 226, §2º, restando “D” incorreta.

O Estado não pode intervir coativamente no planejamento familiar, decisão totalmente livre do casal (artigo 226, §7º, CF), restando “E” incorreta. Resta a alternativa “B”, que corretamente traz o teor do artigo 226, §4º, CF: “entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”.

127. Resposta: “C”. A alternativa “A” está incorreta porque o patrimônio cultural também pode ter natureza material (artigo 216, *caput*, CF). “B” está incorreta porque o Poder Público promoverá e protegerá o patrimônio cultural não isoladamente e sim com a colaboração da comunidade (artigo 216, §1º, CF). A alternativa “C” está correta e traz o teor do artigo 210, *caput*, CF: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. O Plano Nacional de Cultura é de duração plurianual (artigo 215, §3º, CF). O previsto na alternativa “E” vai contra a descentralização do Sistema Nacional de Cultura (artigo 216-A, *caput*, CF).

128. Resposta: E. Art. 60 § 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

129. Resposta: C. Art. 62 § 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

130. Resposta: D. Art. 68 § 2º - A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício

Referências Bibliográficas

AGRA, Walber de Moura. Tratado de Direito Constitucional, v. 1 / coordenadores Ives Gandra da Silva Martins, Gilmar Ferreira Mendes, Carlos Valder do Nascimento. – São Paulo: Saraiva, 2010.

ALMENDROS, Marcela; CARDOSO, Guilherme Moraes; GARCIA, Bruna Pinotti. Questões comentadas – 1ª Edição. Tupã – SP – Maxi Educa, 2014.

BALTAZAR, Antonio Henrique Lindemberg. Da Aplicabilidade das normas constitucionais. Disponível em: https://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/AntonioLindemberg/_lindemberg_toq11.pdf

BACHOF, Otto. Estado de Direito e Poder Político. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. LVI. Coimbra, Coimbra Editora, 1996.

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2002.

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011.

_____. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência / Luís Roberto Barroso - 3. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2008.

BERTRAMELLO, Rafael Grandulpho. Os Direitos Sociais: conceito, finalidade e teorias. 2013; disponível em: <http://rafaelbertramello.jusbrasil.com.br/artigos/121943093/os-direitos-sociais-conceito-finalidade-e-teorias>.

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora UnB, 6.ª ed., 1995.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Atual. – São Paulo: Malheiros Editores, 2012.

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª edição. Editora Saraiva. 2014.

CAMARGO, Marcelo Novelino. O Conteúdo Jurídico da Dignidade da Pessoa Humana. In: CAMARGO, Marcelo Novelino (Org.). Leituras Complementares de Direito Constitucional: direitos fundamentais. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2007.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional*. 4. ed. Coimbra: Almedina, 1987.

_____. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7 ed. Almedina. 2003. pag. 51.

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 16. Ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. 2ª ed. Reform. – São Paulo: Moderna, 2004.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. (2011), Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Editora Atlas.

DIDIER JR, Fredie – Org. Ações Constitucionais. 6ª ed. Rev., ampl. E atual. – Salvador: Editora Juspodivm, 2012.

DIMOULIS, Dimitri. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais/Dimitri Dimoulis, Soraya Lunardi. --São Paulo: Atlas, 2011.

DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Apontamentos Gerais dos Direitos Fundamentais. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 19 jun. 2012. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.37586&seo=1> .

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª ed. Rev. E aum. – São Paulo: Saraiva, 2009.

_____. Curso de Direito Constitucional. 38ª ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012.

FERREIRA, Thiago Augusto de O. M. TCU: papel na avaliação de políticas públicas. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3136, 1 fev. 2012. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/20989>>. Acesso em: 26 maio 2015.

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2012.

HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983.

LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. – São Paulo: Cia das Letras, 2009 (7ª reimpressão).

LIMA, José Juarez Tavares. Evolução constitucional do Brasil. Revista Don Domênico - Periódico de Divulgação Científica da Faculdade Don Domênico. 6ª Edição – setembro de 2012. [www.faculdadedondomenico.edu.br/revista].

Manual básico – Remuneração dos Agentes Políticos Municipais – TCE/SP – disponível em: http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/2007_remuneracao_ag_politicos_municipais.pdf.

MENDES, Gilmar. Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na Ordem constitucional. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, nº. 10, janeiro, 2002. Disponível na Internet: <http://www.direitopublico.com.br/>, acesso em 05/2015.

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996.

MENDES, G. F.; COELHO, I. M.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editores, 2000.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005.

MORAES, Alexandre de. Legitimidade da Justiça Constitucional. Disponível em: <http://www.sedep.com.br/?idcanal=24171>.

NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. A moderna interpretação constitucional. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 7, n. 60, 1 nov. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/3497>.

OLIVEIRA, Márcio Batista de. O direito ao lazer na formação do homem social. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 76, maio 2010. Disponível em: < http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7406 > .

PRADO, Ney in CRETTELA JÚNIOR, José; MARTINS, Ives Gandra da Silva; RESEK, José Francisco et al. A *Constituição brasileira de 1988: interpretações*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988.

PAULO, Vicente. Resumo de direito constitucional descomplicado/Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 6ª ed. – São Paulo: Método, 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed. Rev. Atual. E ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

_____. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 7ª ed. Rev. E atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

SILVA, Anabelle Macedo. Concretizando a Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Malheiros Editores, 2009.

_____. Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros Editores, 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed. Rev. Atual. E ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, 287.

SOARES, José de Ribamar Barreiros. Comissões parlamentares de inquérito no direito brasileiro. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados Centro de Documentação e Informação Coordenação de Biblioteca <http://bd.camara.gov.br>

SOUZA JÚNIOR, Luiz Lopes. A Constituição e seus sentidos: sociológico, político e jurídico? Qual o sentido que melhor reflete o conceito de Constituição? Disponível em [http:// www.lfg.com.br](http://www.lfg.com.br). 09 de julho de 2009.

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica (em) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, pág. 244.

STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. A nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da legitimidade da jurisdição constitucional.

SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. Interpretação conforme a Constituição. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 39, 1 fev. 2000. Disponível em: [http:// jus.com.br/artigos/133](http://jus.com.br/artigos/133) .

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. revista e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.

TORRES, Michell Laureano. A divisão da competência legislativa entre os entes federados. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 06 jun. 2014. Disponível em: [http:// www. conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48447&seo=1](http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48447&seo=1).

VIAMONTE, Sanches. Temas de Direito Constitucional. São Paulo: Acadêmica, 1993.